مختارات فقهية من نصوص تراثية

الجزء الرابع

إعداد

قسم الفقه المقارن بكليتي الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف

وكلية الشريعة والقانون بالقاهرة

مقدمة مختصرة عن كتاب بداية ا لمجتهد

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام خاتم الانبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

فهذه ترجمة موجزة لعلم من أعلام السادة المالكية، وأحد الفلاسفة المسلمين بالمغرب العربي، وأحد من تولى القضاء بها، ألا وهو الإمام القاضي أبي الوليد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد، مع تعريف بكتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد وذكر منهجه في كتابه، وقد قسمت الحديث عن ذلك إلى مبحثين:

المبحث الأول: ترجمة الإمام أبي الوليد بن رشد الحفيد رحمة الله عليه.

المبحث الثاني: منهج الإمام ابن رشد الحفيد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد.

المبحث الأول

ترجمة الإمام أبي الوليد بن رشد الحفيد (رحمة الله عليه)

أولاً: اسمه ونسبه وكنيته، ومولده ووفاته:

هو العلامة الفيلسوف، أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي.

ولد سنة عشرين وخمسمائة قبل وفاة جده القاضي أبي الوليد بن رشد بشهر وتوفي سنة خمسٍ وتسعين وخمسمائة [(١)].

ثانياً: البيئة العلمية التي نشأ بها، وشيوخه وتلاميذه:

لقد نشأ الإمام ابن رشد الحفيد في بيئة علمية محبة للعلم ومعظمة له، يقومون بطلب العلم وتعليمه للناس ابتغاء وجه الله تعالى، فكان جده ووالده- رحمهما الله تعالى- من كبار فقهاء السادة المالكية بالمغرب، فلا عجب أن يكون الحفيد امتداداً لهذه الأسرة المباركة المفعمة بحب العلم والإيمان والحكمة، قال تعالى: "والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا"[(٢)]، فجده-رحمة الله عليه- من أهل العلم والجلالة والعدالة [(٣)]، قال أبو الفضل التيفاشي: جرت مناظرة بين يدي ملك المغرب المنصور يعقوب بين الفقيه أبي الوليد بن رشد، وأبي بكر بن زهر فقال ابن رشد لابن زهر في تفضيل قرطبة: ما أدري ما تقول، غير أنّه إذا مات عالمٌ بإشبيلية فأريد بيع كتبه حملت إلى قرطبة حتى تباع فيها، وإن مات مطربٌ بقرطبة فأريد بيع آلاته حملت إلى إشبيلية، قال:

---

(١) الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، لإبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون برهان الدين اليعمري، ٢/ ٢٥٨، تحقيق وتعليق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، ط: دار التراث للطبع والنشر، القاهرة، سير أعلام النبلاء-للإمام الذهبي، ٣٠٧/٢١، ط الرسالة.

(٢) الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، ١٩٨/١.

(٣) سورة الأعراف، جزء من الآية رقم ٥٨.

وقرطبة أكثر بلاد الله كتبًا [١].

كان ابن رشد الجد زعيم فقهاء وقته بأقطار الأندلس والمغرب ومقدمهم، المعترف له بصحة النظر، وجودة التأليف، ودقة الفقه، وكان إليه المفزع في المشكلات، فقد كان الناس يلجأون إليه، ويعولون في مهماتهم عليه [٢].

كما كان والده-رحمه الله- أيضًا من أهل العلم الكبار الذين يشار إليهم بالبنان لسعة علمهم وفقههم، فقد عرض ابن رشد الحفيد موطأ الإمام مالك على أبيه، كما أخذ الفقه عن أبي القاسم بن بشكوال، وأبي مروان بن مسرة، وأبي بكر بن سمحون، وأبي جعفر بن عبد العزيز، وأبي عبد الله المازري، وأخذ علم الطب عن أبي مروان بن جزيول البلنسي، كما درس الأصول[٣].

وحدث وسمع من ابن رشد الحفيد: أبو بكر بن جهور، وأبو محمد بن حوط الله، وأبو الحسن سهل بن مالك وغيرهم [٤].

يقال: إن ابن رشد الحفيد: ما ترك الاشتغال مذ عقل سوى ليلتين: ليلة موت أبيه وليلة عرسه وإنه سود في ما ألف وقيد نحواً من عشرة آلاف ورقة، ومال إلى علوم الحكماء فكانت له فيها الإمامة، وكان يُفزع إلى فتياه في الطب، كما يُفزع إلى فتياه في الفقه مع وفور العربية، وقيل: كان يحفظ ديوان أبي تمام، والمتنبي [٥].

---

(١) نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب، تحقيق: إحسان عباس، ١/ ١٥٥، لشهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني، تحقيق: إحسان عباس، ط: دار صادر- بيروت- لبنان.

(٢) اصطلاح المذهب عند المالكية، د/ محمد إبراهيم علي، ص ٣١١، ط: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث الإمارات العربية المتحدة – دبي، الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠م.

(٣) الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، لابن فرحون، ٢/ ٢٥٧، سير أعلام النبلاء-للإمام الذهبي، ٢١/ ٣٠٧-٣٠٨.

(٤) الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، ٢/ ٢٥٨.

(٥) التكملة لكتاب الصلة، لابن الأبار، محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلنسي، ٢/ ٧٤، تحقيق: عبد السلام الهراس، ط: دار الفكر للطباعة – لبنان، سنة النشر: ١٤١٥هـ- ١٩٩٥م.

وقد تولي ابن رشد الحفيد قضاء قرطبة، وحمدت سيرته في القضاء بها، وكانت له عند الملوك وجاهة عظيمة، ولم يصرفها في رفعة حاله، ولا في جمعه للمال، إنما قصرها على مصالح أهل بلده خاصة، ومنافع أهل الأندلس عامه [١].

قال الأبار: ولم ينشأ بالأندلس مثله كمالًا وعلمًا وفضلًا، وكان على شرفه أشد الناس تواضعًا، وأخفضهم جناحًا [٢].

قال ابن أبي أصيبعة في تاريخ الحكماء: كان أوحد في الفقه والخلاف، وبرع في الطب، وقيل: كان رث الثياب، قوي النفس، لازم في الطب أبا جعفر بن هارون مدة [٣].

ثالثاً: تصانيفه ومؤلفاته:

لقد نالت مؤلفات ابن رشد الحفيد وآراؤه وترجيحاته شهرة واسعة، واعتمادًا كبيرًا ممن جاء بعده من علماء المالكية، فابن رشد تتميز مؤلفاته بسلاسة الأسلوب، وحسن العرض وعمق الاستنباط، والتفريع، مع العلم الواسع بخبايا الآراء المالكية من مختلف مدارسها، وقدرة على الجمع بين أطراف الموضوع، ولم يكن ابن رشد عالمًا فقط، بل كان عالمًا جمع إلى العلم ملكة أصيلة، وموهبة قديرة في التدريس، وطريقة مشوقة في عرض الفقه المالكي، عرضًا يجذب قلوب الطلاب قبل أفهامهم، فلا غرو أن كانت مؤلفاته قرة عين من جاء بعده، وآراؤه مركز اعتبار المالكية[٤].

ومن هذه المصنفات والمؤلفات ما يلي:

١-بداية المجتهد ونهاية المقتصد في الفقه (وهو الكتاب الذي بين أيدينا):

---

(١) الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، ٢/٢٥٨.

(٢) التكملة لكتاب الصلة، للأبار، ٢/٧٤.

(٣) سير أعلام النبلاء، للإمام الذهبي، ٢١/٣٠٨.

(٤) اصطلاح المذهب عند المالكية، د/ محمد إبراهيم علي، ص ٣١١، ط: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث الإمارات العربية المتحدة – دبي، الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠م.

ولقد ذكر في هذا الكتاب أسباب الخلاف، وعلل ووجه فأفاد وأمتع به، ولا يُعلم في وقته أنفع منه ولا أحسن سياقًا.

٢- الكليات في الطب.

٣- مختصر المستصفى في الأصول.

٤- الضروري في العربية[١].

٥- شرح أرجوزة ابن سينا في الطب.

٦-المقدمات.

٧- جوامع كتب أرسطوطاليس.

٨- شرح كتاب النفس.

٩- تلخيص الإلاهيات لنيقولاوس. [٢] وغيرها كثير.

وكان يُفزع إلى فتياه في الطب، كما يُفزع إلى فتياه في الفقه مع الحظ الوافر من الإعراب والآداب والحكمة[٣].

رابعًا: سبب تأليفه بداية المجتهد:

لقد ذكر ابن رشد الحفيد سبب تأليفه لهذا الكتاب في المقدمة حيث قال رحمه الله تعالى:

«فإن غرضي في هذا الكتاب أن أثبت فيه لنفسي على جهة التذكرة من مسائل الأحكام المتفق عليها والمختلف فيها بأدلتها، والتنبيه على نكت الخلاف فيها، ما يجري مجرى الأصول والقواعد لما عسى أن يرد على المجتهد من المسائل المسكوت عنها في الشرع، وهذه المسائل في الأكثر هي المسائل المنطوق بها في الشرع، أو تتعلق بالمنطوق به تعلقًا قريبًا، وهي المسائل التي وقع الاتفاق عليها، أو اشتهر الخلاف فيها بين الفقهاء الإسلاميين من لدن

---

(١) الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، ٢٥٨/٢.

(٢) سير أعلام النبلاء، ٣٠٩/٢١.

(٣) الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، ٢٥٨/٢.

الصحابة - رضي الله عنهم - إلى أن فشا التقليد» [١].

فهذا الكتاب(بداية المجتهد) لمن أراد أن يعلم أسباب الاختلاف بين الفقهاء، ويبرر أوجه تعدد الأقوال، ويربط الأحكام الفقهية بأصولها إجمالًا، ويبتعد عن نقل أقوال الفقهاء مجردة، فيعتدل في حكمه عليها[٢].

(١) بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد، ١/ ٩، ط: دار الحديث – القاهرة: ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م.

(٢) اصطلاح المذهب عند المالكية، ص ٣٣٧.

المبحث الثاني

منهجه في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد

أولًا: التعريف بالمصطلحات التي ذكرها في كتابه[١]:

لقد استخدم ابن رشد- رحمه الله تعالى- مصطلحات خاصة به في كتابه ومصطلحات عامة مشهورة يعرفها الأعم الأغلب من الناس، فمن ذلك ما يلي:

إذا قال الحديث ثابت: فيقصد به ما أخرجه البخاري في صحيحه، أو مسلم في صحيحه، أو ما اتفقا عليه[٢].

إذا قال "هذا الأثر أخرجه الشيخان": فيريد بذلك ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما[٣].

"كتاب البخاري": المراد به الجامع الصحيح للإمام البخاري[٤].

مصطلح "الآثار": ويقصد به ما ورد من الأحاديث الصحيحة عن النبي ﷺ، وليس المقصود بذلك عنده ما ورد عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين[٥].

مصطلح "الجمهور": يقصد به أكثر الفقهاء، ويدخل فيهم الأئمة الفقهاء الثلاثة: أبو حنيفة، مالك، والشافعي، رحمة الله عليهم أجمعين[٦].

"فقهاء الحجاز": يقصد بهم: الأئمة: مالك والليث والشافعي [٧].

"فقهاء الكوفة": يريد بهم: أبو حنيفة وأصحابه والثوري[٨].

---

(١) إجماعات ابن رشد الحفيد، ابن فائزة الزبير، ص ٧٤-٧٧.

(٢) بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ٥٣/١.

(٣) بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ٢٦/١.

(٤) بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ٥٢/٢.

(٥) بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ٢٥/١.

(٦) بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ٧٦/١.

(٧) بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ١١/٢.

(٨) بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ٢١/٢.

"الفقهاء السبعة": [١]: والمقصود بهم: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وخارجة بن زيد بن ثابت، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وسليمان بن يسار. واختلف في السابع فقيل: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل: سالم بن عبد الله، وقيل: أبو بكر بن عبد الرحمن»[٢]

إذا قال: "قال أبو عمر" فالمراد به: أبو عمر بن عبد البر، صاحب التمهيد والاستذكار على موطأ الإمام مالك»[٣].

مصطلح "المذهب" يقصد به مذهب الإمام مالك- رضي الله عنه-[٤]

إذا قال "وقال القاضي": فإنما يقصد بذلك نفسه(ابن رشد الحفيد) [٥] وأحيانًا يقيده بالقاضي اسماعيل بن إسحاق[٦]، أو القاضي أبو بكر الباقلاني[٧]، أو القاضي عبد الوهاب [٨]، وأحيانًا يطلق على القاضي عبد الوهاب: القاضي أبو محمد[٩].

---

(١) بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ١٩٣/٣.

(٢) الذب عن مذهب الإمام مالك، لأبي محمد عبد الله بن (أبي زيد) عبد الرحمن النفزي القيرواني، المالكي (ت ٣٨٦ هـ)، (٣٧٦/١)، تحقيق: د. محمد العلمي، ط: المملكة المغربية - الرابطة المحمدية للعلماء - مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث - سلسلة نوادر التراث الطبعة: الأولى، ١٤٣٢هـ - ٢٠١١م، مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز» ص ١٥٢،١٥٣.

(٣) بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ١٨/٣،١٦٤.

(٤) بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ٣٧/١.

(٥) بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ١٢/١، ٩٥/١، ١٤٨/١.

(٦) بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ١٧١/٢.

(٧) بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ٣/ ١٥٠.

(٨) بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ٣/ ١٩٥.

(٩) بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ٣/ ٢٢٠.

إذا قال "عندنا": فأحيانًا يقصد بذلك المكان وهو قرطبة[١] وأحياناً يقصد بقوله عندنا أي في مذهبنا أي المالكي[٢].

"الكلام الفقهي": يقصد به علم أصول الفقه[٣].

ثانيًا: المصادر التي اعتمد عليها ابن رشد في كتابه[٤]:

لقد اعتمد ابن رشد على مصادر كثيرة في كتابه بداية المجتهد: فمنها في الحديث، ومنها في الفقه وأصوله ومنها ما اعتمد عليه في نقل المذاهب الفقهية، فمثلا في الحديث اعتمد على مصادر كثيرة منها: صحيحي البخاري ومسلم، وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وموطأ الإمام مالك، ومصنف ابن أبي شيبة، ومسند الإمام أحمد[٥].

كما اعتمد في نقل المذاهب ونسبتها إلى أصحابها على كتاب الاستذكار لابن عبد البر[٦].

وأما في الفقه وأصوله: فقد اعتمد على مصادر كثيرة منها:

١-المدونة لسحنون بن سعيد التنوخي[٧].

٢- الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام[٨].

٣-العتبية لأبي عبد الله محمد بن أحمد العتبي[٩].

---

(١) بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ١/ ١٤١.

(٢) بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ١/ ٩٩.

(٣) بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ١/ ٧٧.

(٤) إجماعات ابن رشد الحفيد، بن فائزة الزبير، ص ٨٨.

(٥) بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ١/١٠٤، ١/١٠٩، ١/١١٥، ١/١١٧، ٢/٩٥، ٣/١٦، ١/١٦٥، ١/٢١٩.

(٦) بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ١/٩٥.

(٧) بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ١/٨٦.

(٨) بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ٢/٦.

(٩) بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ٣/١٥.

٤- الواضحة، لابن حبيب [١].

٥- البرهان في أصول الفقه" لأبي المعالي الجويني[٢].

ثالثًا: منهج ابن رشد في كيفية عرض المسائل الفقهية ومناقشتها [٣]:

بعد الخوض في غمار البحث في كتاب ابن رشد يتضح منهجه في كتابه من خلال ما يلي:

أولًا: يقوم بتقسيم الكتاب الذي يريد الكلام عنه الى أبواب على جهة الإجمال، فيقول مثلاً: "كتاب الوضوء: إن القول المحيط بأصول هذه العبادة ينحصر في خمسة أبواب"

ثانيًا: يقوم بتفصيل الكلام في كل باب من هذه الأبواب، وذلك بذكر الحكم الشرعي مع ذكر الأدلة عليه من الكتاب والسنة-مع بيانه لدرجة الحديث من حيث الصحة أو الضعف- والإجماع والقياس.

ثالثًا: يقدم ذكر المسائل التي اتفق عليها الفقهاء.

رابعًا: يذكر المسائل المختلف في حكمها بين فقهاء الأمصار، فيقوم بتحرير محل النزاع في المسألة محل البحث، وذلك بذكر مواطن الاتفاق ومواطن الاختلاف بين الفقهاء في المسألة، والاستدلال على ذلك.

خامسًا: لا يتطرق إلى التفريع في المسائل، وإنما يقتصر على ذكر أمهات المسائل التي اشتهر الخلاف فيها بين الفقهاء.

سادسًا: يذكر أقوال الفقهاء في المسألة محل البحث حتى لو كانوا غير مشهورين ويعتمد في نقل أقوالهم على كتاب الاستذكار لابن عبد البر-رحمه الله

---

(١) بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ٤/٧٣.

(٢) بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ٣/١٣٨.

(٣) ابن رشد الحفيد، حياته-علمه فقهه، لحمادي العبيدي، ١١٨-١٢٣، ط: الدار العربية للكتاب ١٩٨٤م.

تعالى- كما ذكر هو بنفسه في كتابه بداية المجتهد.

سابعًا: يذكر سبب الاختلاف بين الفقهاء في حكم المسألة محل البحث؛ حتى يربط الخلاف بين الفقهاء بأسبابه، وعدته في ذلك الاعتماد على ذكر أسباب الاختلاف بين الفقهاء من الناحية اللغوية (كاختلاف الإعراب مثلاً)، أو الحديثية(كصحة الحديث أو ضعفه)، أو الأصولية (كتردد اللفظ بين أن يكون عاماً يراد به الخاص أو خاصاً يراد به العام).

ثامنًا: يذكر أدلة كل فريق، ولكن مع الاقتصار على أقوى الأدلة وأشهرها عند كل فريق.

تاسعًا: في بعض الأحيان لا يرجح ابن رشد قولاً في المسألة، كمسألة مقدار الممسوح من الرأس في الوضوء، وإذا تساوت أدلة الفريقين في المسألة اكتفى بعرض أقوالهم وأدلتهم دون ترجيح، كما في مسألة غسل اليدين إلى المرفقين، وأحياناً يجمع بين القولين المتعارضين في المسألة، وأحياناً يرجح في المسألة، وقد يخالف مذهبه المالكي إن رأى قوة الدليل في غيره من المذاهب.

ونضرب لذلك مثالين، المثال الأول: لمسألة جمع فيها بين القولين المتعارضين في المسألة، والمثال الثاني: لمسألة قام فيها بالترجيح مخالفاً لمذهبه المالكي.

المثال الأول: حكم اشتراط النية في الوضوء:

قال رحمه الله تعالى: "المسألة الأولى من الشروط اختلف علماء الأمصار هل النية شرط في صحة الوضوء أم لا؟ .....وسبب اختلافهم: تردد الوضوء بين أن يكون عبادة محضة أعني: غير معقولة المعنى، وإنما يقصد بها القربة فقط كالصلاة وغيرها، وبين أن يكون عبادة معقولة المعنى كغسل النجاسة، فإنهم لا يختلفون أن العبادة المحضة مفتقرة إلى النية والعبادة المفهومة المعنى غير مفتقرة إلى النية والوضوء فيه شبه من العبادتين ولذلك وقع الخلاف فيه، وذلك أنه

يجمع عبادة ونظافة، والفقه أن ينظر بأيهما هو أقوى شبها فيُلحق به" [١].

ففي هذه المسألة جمع ابن رشد بين القولين المتعارضين في المسألة بذكر رأي وسط، ومعنى ذلك أن المتوضئ إذا قصد العبادة تعينت عليه النية، وإن قصد النظافة والطهارة سقطت عنه النية[٢].

المثال الثاني: حكم أكل لحوم الخيل:

قال رحمه الله تعالى: وأما سبب اختلافهم في الخيل فمعارضة دليل الخطاب في هذه الآية [٣] لحديث جابر [٤] ومعارضة قياس الفرس على البغل والحمار له، لكن إباحة لحم الخيل نص في حديث جابر فلا ينبغي أن يعارض بقياس ولا بدليل خطاب[٥] فهنا ذهب إلى القول بجواز أكل لحم الخيل مخالفًا بذلك لمذهبه المالكي القائل بعدم الجواز، حيث ترجح لديه هذا القول.

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

---

(١) بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ١/١٥.

(٢) ابن رشد الحفيد، لحمادي العبيدي، ص١٢٠.

(٣) وهي قوله تعالى: {والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة} [النحل: ٨].

(٤) عن جابر بن عبد الله، «أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل» رواه مسلم في صحيحه، برقم: (١٩٤١).

(٥) بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (٣/ ٢٢،٢٣).

دليل الخطاب: هو مفهوم المخالفة. يراجع: إيضاح المحصول من برهان الأصول، لأبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري، (١٣٧)، تحقيق: د. عمار الطالبي، ط: دار الغرب الإسلامي، تونس، الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م، قواعد الأصول ومعاقد الفصول مختصر تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل، لصفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي (١٢٨)، ومعه حاشية نفيسة: لمحمد جمال الدين بن محمد سعيد القاسمي، تحقيق: د/ أنس بن عادل اليتامى، د/ عبد العزيز بن عدنان العيدان، ط: دار ركائز للنشر والتوزيع – الكويت الطبعة: الأولى، ١٤٣٩هـ - ٢٠١٨م.

أحكام الأقضية والشهادات

دكتور
أحمد محمد لطفي
أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بكلية
الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف دقهلية

كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ [١]

(١) بدأ المصنف في هذا الباب بأحكام القضاء، وكعادته في كتابه لم يتعرض لتعريفه، حيث اتبع هذا الصنيع، لذا أورد تعريفه فيما يلي:

القضاء في اللغة:

في اللغة: يطلق القضاء في لغة العرب ويراد به معانٍ عدة، أهمها:

- الآداء: يقال: قضى فلان دينه، أي: أداه.
- التبليغ: ومنه قوله تعالى: ﴿وَقَضَيْنَآ إِلَيْهِ ذَٰلِكَ ٱلْأَمْرَ﴾ [١] أي: بلغناه إياه.
- الخلق: ومنه قوله تعالى: ﴿فَقَضَىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَٰوَاتٍ﴾ [٢] أي: خلقهن.
- القدر: يقال: قضى فلان الأمر، أي: قدره تقديرًا، وعلى هذا فالقضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدر، والآخر بمنزلة البناء وهو القضاء.
- العمل: ومنه قوله تعالى: ﴿فَٱقْضِ مَآ أَنتَ قَاضٍ﴾ [٣] أي: اعمل ما أنت عامل.

القضاء في الاصطلاح:

الحنفية: عَرَّفَ الحنفية القضاء بتعريفات متعددة، منها:

قيل: هو الحكم بين الناس بالحق، والحكم بما أنزل الله عز وجل [٤].

قيل: القضاء هو قول ملزم يصدر عن ولاية عامة [٥].

المالكية: تعددت تعريفات المالكية للقضاء، وأقتصر منها على ما يلي:

القضاء هو: صفة حكمية توجب لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي ولو بتعديل أو تجريح لا في عموم مصالح المسلمين [٦].

وقال ابن رشد وابن فرحون: القضاء هو الإخبار عن حكمٍ شرعيٍ على سبيل الإلزام [٧].

الشافعية: اختلفت عبارات فقهاء الشافعية عند تعريفهم للقضاء:

قال إمام الحرمين: القضاء هو إظهار حكم الشرع في الواقعة من مطاع [٨].

=

وقال الخطيب الشربيني: القضاء فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالى [٩].

الحنابلة: القضاء عند الحنابلة هو: الإلزام بالحكم الشرعي وفصل الخصومات [١٠].

وقيل: هو تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات [١١].

حكم القضاء وأدلته:

اتفق الفقهاء على مشروعية القضاء، واستدلوا على ذلك بأدلةٍ كثيرةٍ من الكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول:

أولًا: من الكتاب:

استدلوا بأدلةٍ كثيرة منها:

١- قوله تعالى: ﴿يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلۡنَٰكَ خَلِيفَةٗ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱحۡكُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ﴾[١٢].

وجه الدلالة:

أمر الله عز وجل نبيه داود عليه السلام أن يحكم بالناس بالحق، وهذا دليل على مشروعية القضاء:

وللعلماء في الحكم الذي أخذ منه قولان:

الأول: مأخوذ من الحكمة التي تُوجِبُ وضع الشيء في موضعه.

الثاني: مأخوذ من إحكام الشيء، ومنه: حكمة اللجام، لما فيه من الإلزام [١٣].

٢- قوله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ﴾ [١٤] حيث دلت الآية على وجوب التحاكم ونصب القضاة.

٣- قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ﴾ [١٥] وقوله تعالى ﴿وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ﴾ [١٦] وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحۡكُمَ بَيۡنَهُمۡ إِذَا فَرِيقٞ مِّنۡهُم مُّعۡرِضُونَ﴾ [١٧] وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوۡلَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحۡكُمَ بَيۡنَهُمۡ أَن يَقُولُواْ سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَا﴾ [١٨].

=

وجه الدلالة:

الآية الأولى تعد من أمهات الآيات التي اشتملت على كثير من أحكام الشرع، وهذا إجماع على أن من كان حاكمًا وجب عليه الحكم بالعدل، والمقصود جميع الأمانات، فالآية خطاب لولاة المسلمين تأمرهم بتحري العدل في أحكامهم، والعدل هو فصل الخصومات على ما في كتاب الله، والذي يحكم بالعدل هو العالم، أما الحاكم الذي لا يدري بحكم الله ورسوله فهو لا يدري ما العدل؛ لأنه لا يعقل الحجة [١٩].

وفى الآية الثانية ألزم الله عز وجل رسوله ﷺ بالحكم بين الناس بما أنزل الله، وإلا لما كان للحكم أثر.

فقد ورد في سبب نزولها عن ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ بَعْضُ الْيَهُودِ لِبَعْضٍ مِنْهُمْ ابْنُ صُورِيَّا وَشَاسُ بْنُ قَيْسٍ وَكَعْبُ بْنُ أُسَيْدٍ: اذْهَبُوا بِنَا إِلَى مُحَمَّدٍ لَعَلَّنَا نَفْتِنُهُ عَنْ دِينِهِ، فَأَتَوْهُ فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ قَدْ عَرَفْتَ أَنَّا أَحْبَارُ يَهُودَ وَأَشْرَافُهُمْ، وَإِنِ اتَّبَعْنَاكَ اتَّبَعَكَ كُلُّ الْيَهُودِ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِ خُصُومَةٌ فَنُحَاكِمُهُمْ إِلَيْكَ فَتَقْضِي لَنَا عَلَيْهِمْ وَنُؤْمِنُ بِكَ، فَأَبَى ذَلِكَ الرَّسُولُ صَلَّى الله عليه وسلم فنزلت [٢٠].

وفى الآية الثالثة بين الله ضلال الكافرين والمنافقين في عدم تحاكمهم إلى رسول الله ﷺ وهو الإعراض، والجملة الشرطية شرح للتولي والمبالغة، حيث أفادت مفاجأتهم والإعراض عن الحكم عقب دعوتهم إليه، وقيل: هذا الإعراض إنما يكون إذا اشتبه الأمر عليهم، وهذا الإعراض إنما يكون إذا كان الحق عليهم، أما إذا كان الحق لهم فإنهم يذعنون لعلمهم القاطع أن رسول الله ﷺ لا يحكم إلا بالحق [٢١].

ثانيًا: من السنة:

يستدل على مشروعية القضاء بأحاديث كثيرة، أقتصر منها على ما يلي:

١- ما روي أن النبي ﷺ حكم بين الناس [٢٢] وبعث عليًا إلى اليمن ليحكم

=

بين الناس [٢٣].

فقد أرسى النبي ﷺ في هذا الحديث قاعدة هامة وأساسية من القواعد التي يقوم عليها عماد الدولة الإسلامية، وهي قاعدة فرضية القضاء، وأكد ذلك فعله ﷺ، وإرساله لعلي بن أبي طالب وغيره من الصحابة لكي يحكموا بين الناس في بقاع الدولة المختلفة.

٢- ما روي أن النبي ﷺ قال: لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا [٢٤].

وجه الدلالة:

مدح البني ﷺ القاضي الذي يقضي بالحق، وجعل هذه الصفة من الصفات التي يحسد عليها العبد.

وقد وردت أحاديث تدل على ذم القضاء، وأحاديث أخرى تدل على مدحه:

فالتي تدل على ذمه كثيرة، منها:

أ – ما روي أن النبي ﷺ قال: مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ، فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ [٢٥].

ففي الحديث ترهيب شديد من تولي القضاء لما فيه من الخطر العظيم، وقد ذكر العلماء أن في تشبيه القضاء بالذبح بغير سكين وجهان:

الأول:

إن السكين يؤثر في الظاهر والباطن جميعًا، والذبح بغير سكين يؤثر في الباطن بإزهاق الروح، ولا يؤثر في الظاهر، ووبال القضاء لا يؤثر في الظاهر؛ إذ الظاهر أنه عظمة، إلا أن باطنه هلاك.

قال ابن الصلاح: "معناه ذَبْحٌ من حيث المعنى؛ لأن بين عذاب الدنيا إن رشد وبين عذاب الآخرة إن فسد" [٢٦].

=

الثاني:

إن الذبح بالسكين يريح، وبغيرها كالخنق وغيره يكون الألم فيه أكثر، فذكر ليكون أبلغ في التحذير، ومن الناس من فتن بمحبة القضاء، فأخرجه عما يتبادر إليه الفهم من سياقه، فقال: إنما قال ذبح بغير سكين ليشير إلى الرفق به، ولو ذبح بالسكين لكان أشق عليه، ولا يخفى فساد هذا [٢٧].

ب – ما روي أن النبي ﷺ قال لأبى ذر: يا أبا ذر: إني أراك ضعيفًا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تَوَلَّيَنَّ مال يتيم، ولا تأمَّرَنَّ على اثنين [٢٨].

فقد رَهَّبَ النبي ﷺ من الدخول في القضاء لِعِظَمِ خطره وأمانته، وما ذلك الترهيب إلا ليكون من يقدم على القضاء على علم بمخاطره، وعلى استعدادٍ لما فيه من أمانة ومسئولية.

وأما الأخبار التي تدل على مدحه في كثيرة، منها:

أ – ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ، فَاجْتَهَدَ، فَأَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ، فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ، فَلَهُ أَجْرٌ [٢٩].

ب – ما روي أن النبي ﷺ قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالًا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها [٣٠].

وللجمع بين الأحاديث التي تدل على الذم، والأحاديث التي تدل على المدح يمكن القول: إن الأخبار التي تدل على ذم القضاء محمولة على من علم من نفسه أنه لا يقوم بالقضاء إما لجهله، أو لقلة أمانته، والأخبار التي تدل على المدح محمولة على من علم من نفسه القيام بالقضاء لعلمه وأمانته.

والدليل على صحة ذلك: ما روي أن النبي ﷺ قال: الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: قَاضِيَانِ فِي النَّارِ: قَاضٍ يَقْضِي فِي النَّاسِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، وَيُوَكِّلُ بَعْضَهُمْ مَالَ بَعْضٍ، وَقَاضٍ يَتْرُكُ عَمَلَهُ وَيَقْضِي بِغَيْرِ الْحَقِّ، فَهَذَانِ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ يَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ [٣١].

=

ثالثًا: الإجماع:

حيث أجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاة والحكم بين الناس.

رابعًا: المعقول:

إن الظلم من شِيَمِ النفوس وطبع العالم، يقول الشاعر:

الظلم من شيم النفوس فإن تجد * ذا عفة فلعله لا يظلم [٣٢]

وبالتالي كان لا بد من وجود حاكم ينصف المظلوم من الظالم، ولا يكون ذلك إلا بِنَصْبِ القضاة.

حكم طلب القضاء:

ذكر العلماء أن طلب القضاء تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة، بعد أن ذكروا أن أصله الجواز، وتفصيل ذلك على النحو التالي:

أولًا: الوجوب:

يكون القضاء واجبًا على الشخص إذا كان من أهل العلم والعدالة، أي يكون مستحقًا للقضاء، ولا يوجد في البلد قاض، أو يوجد، ولكن ولايته غير صحيحة، أو كان القضاء بيد شخصٍ لا يجوز أن يبقى فيه، ولا سبيل إلى عزله إلا بتصدي هذا إلى الولاية، ففي هذه الأحوال وأمثالها يجب عليه أن يتصدى للقضاء ويسعى له، لأن ذلك يؤدي إلى حفظ الحقوق، وجريان الأحكام على وِفْقِ مقتضى الشرع.

ثانيًا: المباح:

يكون طلب القضاء مباحًا إذا كان الرجل من أهل الاجتهاد، وكان فقيرًا وله عيال، فيجوز له طلبه لسد حاجته، أيضًا يباح له طلبه إن كان رفضه يؤدي إلى إلحاق الضرر به.

ثالثًا: المستحب:

يستحب للرجل أن يطلب القضاء إذا كان من أهل الاجتهاد والعلم إلا أنه خامل

=

الذكر لا يعرفه الناس، ولا يأخذون من علمه، ويريد الإمام أن يشهره بولاية القضاء ليعلم الناس، أو كان لا يعرفه الإمام، فأراد السعي في القضاء ليعرف علمه، فعندئذ يستحب له السعي فيه وتحصيله بهذه النية.

رابعًا: الكراهة:

يكره للشخص الدخول في القضاء وطلبه إذا كان الغرض من ذلك طلب الجاه والاستعلاء على الناس.

وذكر ابن فرحون المالكي أن القول بالتحريم في هذه الصور يكون أوجه لقوله تعالى: ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلا فَسادًا﴾ (٣٣).

ويكره أيضًا طلب القضاء إذا كان الشخص غنيًّا وليس في حاجةٍ لأخذ الرزق على القضاء، أو كان مشهورًا ولا يحتاج أن يشهر نفسه وعلمه بالقضاء.

خامسًا: الحرام:

يحرم على الشخص أن يسعى في طلب القضاء وهو جاهل لا تتوافر فيه أهلية القضاء، أو كان من أهل العلم إلا أنه متلبس بما يوجب فسقه، أو كان قصده بالولاية الانتقام من أعدائه، أو قبول الرشوة من الخصوم، وما أشبه ذلك من المقاصد، فهذا يحرم عليه السعي في القضاء (٣٤).

أركان القضاء:

للنظام القضائي في أي دولة أركان يقوم بها، وبدون هذه الأركان أو تخلف أحدها لا يكتمل بنيان هذا النظام، وهذه الأركان هي:

الأول: القاضي: وهو الذى يعين من قبل ولي الأمر – الدولة – للفصل في الدعاوى والخصومات، لأن السلطان أو رئيس الدولة لا يستطيع أن يقوم بكل شيء.

الثاني: الحكم: وهو ما يصدر عن القاضي لحسم النزاع وقطع الخصومة، =

وهو يكون – أي الحكم – إما بإلزام المحكوم عليه بكلام نطق به القاضي، كأن يقول له القاضي: حكمت عليك بكذا، وهذا يسمى قضاء إلزام أو استحقاق بالفعل، مثل ما يقع من الحكام بالقسمة الجبرية، وإما أن يكون هذا الحكم بمنع الحاكم المنازعة بقوله للمدعى: ليس لك حق قبل خصمك بعد عجزك عن الإثبات وحلف المدعى عليه، وهذا يسمى قضاء الترك.

الثالث: المحكوم به: وهو في قضاء الإلزام والاستحقاق ما ألزم به القاضي المحكوم عليه من إيفاء المدعى حقه، وهو في قضاء الترك عبارة عن ترك المدعى المنازعة.

الرابع: المحكوم عليه: هو الشخص الذي يصدر ضده الحكم وهو في حقوق الشرع من يستوفى فيه الحق سواء أكان مدعى عليه أم لا، وقد يكون المحكوم عليه واحدا كما قد يكون متعددا.

الخامس : المحكوم له: وهو المدعى بحق له خالصا، أو يغلب فيه حقه طبقا لنظرية الأحناف القائلين بأن الحق الذى يتعلق بالعباد إما أن يكون حقا خالصا لهم، وإما أن يكون حقا يشترك فيه حق العبد وحق الله تعالى[٣٥].

السادس: كيفية القضاء.

الهوامش

(١) سورة الحجر: من الآية ٦٦.

(٢) سورة فصلت: من الآية ١٢.

(٣) سورة طه: من الآية ٧٢.

(٤) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني، ٢/٧، طبعة دار الكتب العلمية – بيروت.

(٥) الاختيار، لابن مودود الحنفي، طبعة مطبعة الحلبي – مصر، الطبعة الثانية ١٩٧٣م، ٨٢/٢.

(٦) مواهب الجليل شرح مختصر خليل، للحطاب، ٨٦/٦، طبعة دار الفكر- بيروت، الطبعة الثالثة ١٤١٣هـ - ١٩٩٢م، منح الجليل شرح مختصر خليل، للشيخ عليش، ٢٥٥/٨، طبعة دار الفكر.

(٧) تبصرة الحكام في أصول الأقضية والأحكام، لابن فرحون، ٩/١، طبعة دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٦هـ - ١٩٩٦م، منح الجليل، ٢٥٥/٨.

(٨) أسنى المطالب شرح روض الطالب، للشيخ زكريا الأنصاري، ٢٧٧/٤، طبعة دار الكتاب الإسلامي.

(٩) مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، للخطيب الشربيني، ٢٧٥/٦، طبعة دار الكتب العلمية – بيروت.

(١٠) كشاف القناع على متن الإقناع، للبهوتي، ٢٨٥/٦، طبعة المكتب الإسلامي.

(١١) شرح منتهى الإرادات، للبهوتي، ٤٨٥/٣، طبعة دار الفكر.

(١٢) سورة ص: من الآية رقم ٢٦.

(١٣) الحاوي الكبير، للماوردي، ٣/١٦، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ - ١٩٩٩م.

(١٤) سورة النساء: من الآية رقم ٦٥.

(١٥) سورة النساء: من الآية رقم ٥٨.

(١٦) سورة المائدة: من الآية رقم ٤٩.

(١٧) سورة النور: من الآية رقم ٤٨.

(١٨) سورة النور: من الآية رقم ٥١.

(١٩) فتح القدير، للشوكاني، ٦٠٧/١، التفسير الكبير، ١١٣/١٠، تفسير الخازن، ٥٤٩/١.

(٢٠) تفسير النهر الماد من البحر المحيط، لابن حيان، ٥٩٠/١، طبعة مؤسسة الكتب الثقافية، دار الجنان.

(٢١) فتح القدير، للشوكاني، ٥٥/٤، روح المعاني، للألوسي، ٢٩٥/١٨، طبعة دار إحياء التراث العربي.

(٢٢) حكم النبي ﷺ بين الناس حديث صحيح مأخوذ من جملة أحاديث، يأتي عرضها في ثنايا البحث.

(٢٣) أخرجه الترمذي، كتاب الأحكام، باب ما جاء في القاضي لا يقضى بين الخصمين حتى يسمع كلًا منهما، برقم (١٣٣١) ٦١٠/٣، وأبو داود، كتاب الأقضية، باب كيف القضاء، برقم (٣٥٨٢) ٤٣٤/٥.

(٢٤) أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب الحث على طلب العلم، برقم (٧٣) ٣٩/١، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها برقم (٨١٦) ٢٠١/٢.

(٢٥) أخرجه الترمذي، كتاب الأحكام، باب ما جاء عن رسول الله في القاضي، برقم (١٣٢٥) ٦٠٦/٣، وأبو داود، كتاب الأقضية، باب في طلب القضاء، برقم (٣٥٧١) ٤٢٥/٥، وابن ماجة، كتاب الأحكام، باب ذكر القضاة، برقم (٢٣٠٨) ٧٧٤/٢.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وأعله ابن الجوزي كما ذكر صاحب تلخيص الحبير، وقال: لا يصح، وهو خطأ.

(٢٦) نيل الأوطار، للشوكاني، ٣٠٠/٨.

(٢٧) شرح فتح القدير، للإمام كمال الدين بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام، ٢٦٢/٧، طبعة دار الكتب العلمية – بيروت، التلخيص الحبير، لابن حجر، ١٨٤/٤.

(٢٨) أخرجه مسلم، كتاب الوصايا، باب كراهة الإمارة، برقم (١٨٢٦) ٧/٦.

(٢٩) أخرجه البخاري، كتاب الاعتصام، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطا، برقم (٦٩١٩) ٢٦٧٦/٦، ومسلم، كتاب الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، برقم (١٧١٦) ١٣١/٥.

(٣٠) سبق تخريجه.

(٣١) أخرجه الترمذي، كتاب أبواب الأحكام، باب ما جاء عن رسول الله في القاضي، برقم (١٣٢٢) ٦٠٥/٣.

(٣٢) البيت للمتنبي ذكره في قصيدة عنوانها "لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى"، يراجع: ديوان المتنبي، ص ٥٧٠، طبعة دار الجيل – بيروت.

(٣٣) سورة القصص: من الآية رقم ٨٣.

(٣٤) يراجع: معين الحكام، للطرابلسي، ص ١٠، طبعة دار الفكر، تبصرة الحكام، لابن فرحون، ١٤/١، ١٥، مواهب الجليل، للحطاب، ٨٧،٨٨/٦ معني المحتاج، ٢٥٩/٦، البحر الزخار، ١٠٣/٦، نهاية المحتاج، ٢٣٦/٨.

(٣٥) د. محمد سلام مدكور: القضاء في الإسلام. ص ١٦ وما بعدها، طبعة المطبعة العالمية – القاهرة، نشر دار النهضة العربية – القاهرة، ١٣٨٤هـ – ١٩٦٤م.

الْبَابُ الْأَوّلُ

فِي مَعْرِفَةِ مَنْ يَجُوزُ قَضَاؤُهُ

النّظَرُ فِي هَذَا الْبَابِ فِيمَنْ يَجُوزُ قَضَاؤُهُ، وَفِيمَا يَكُونُ بِهِ أَفْضَلَ [١].

---

[١] **التمييز بين الفتيا والقضاء:**

الفتوى في اللغة: هي الجواب عما يشكل من المسائل الشرعية، يقال: أفتاه في الأمر، أبانه له، والفتيا والفتوى ما أفتى به الفقيه.

وجاء في مختار الصحاح: "استفتاه في مسألة فأفتاه، والاسم الفتيا والفتوى، وتفاتوا إليه: ارتفعوا إليه في الفتيا " [١].

وفي اللسان: أفتاه في الأمر: أبانه له، وأفتى الرجل في المسألة واستفتيه فأفتاني إفتاءً، وفتى وفتوى اسمان يوضعان موضع الإفتاء، وأفتيته في مسألته إذا أجبته عنها، والاسم الفتوى [٢].

وفي الاصطلاح: الفتوى هي تبيين الحكم الشرعي للسائل عنه والإخبار بلا إلزام [٣].

وقيل: هي الإخبار عن حكم الله تعالى بمقتضى الأدلة الشرعية على جهة العموم والشمول.

وأعرض أولًا لأوجه الاتفاق، ثم أتبع ذلك ببيان أوجه الاختلاف:

أولًا: أوجه الاتفاق بين الفتوى والقضاء:

١- يتفق القضاء مع الفتوى في الغرض من كلٍّ منهما، إذ الغرض هو تبيين الحكم الشرعي، ففي القضاء يتم تبيين الحكم الشرعي في المنازعة، وإجبار المتخاصمين على العمل به والامتثال له، وكذلك الفتوى فالمستفتي يطلب الفتوى لمعرفة الحكم الشرعي لاتباعه والسير على نهجه.

٢- أهمية كل من منصبي الفتوى والقضاء، حيث أنزل العلماء الفتوى =

والقضاء منزلةً رفيعة، واهتموا بها اهتماماً بالغًا، فالمفتي هو مناط الأحكام وملاذ الخلائق في تفاصيل الحلال والحرام، واعتبر العلماء المفتي وارثًا للنبوة، بل يرى الشاطبي في الموافقات أن قائم مقام النبي ﷺ وجعلوا القضاء كذلك في مرتبة عالية، إذ أنه كذلك من وظائف الأنبياء [٤].

٣- يتفق القضاء والإفتاء في أن كلًّا منهما فرض كفاية، مع التشديد على التروي والتثبت، فقد كان الخلفاء الراشدون رضوان الله تعالى عليهم يتثبتون في إصدار الأحكام مخافة الوقوع في مخالفة حكم الله تعالى، ومن هنا نشأ مبدأ المشاورة فيما بينهم فيما يجد لهم من قضايا، وكان عمر بن الخطاب يستشير علي بن أبي طالب ويقول: "لولا علي لهلك عمر" وكذلك الأمر بالنسبة للمفتي.

٤-يحرم على المفتي أن يتساهل في فتواه، وكذلك يحرم على القاضي أن يتساهل في حكمه.

ثانيًا: أوجه الاختلاف بين الفتوى والقضاء:

يختلف القضاء عن الفتوى في عدة أمور، منها:

١- صفة الإلزام: فحكم القاضي ملزم للمتخاصمين ويملك القاضي إجبار الخصوم على تنفيذه، وهو ما لا يتوافر في الفتوى، إذ لا يلزم بها المستفتي، ولذلك فإن القضاء منشئ للإلزام، أما الفتوى فهي إخبار عن حكم الله تعالى في المسألة.

٢- نطاق الإفتاء أوسع من نطاق القضاء، فالفتوى شريعة عامة تتعلق بالمستفتي وغيره، أما القضاء فهو خاص بالخصوم فقط لا يتعداهما إلى غيرهما [٥].

وأرى أن هذا القول محل نظر؛ فالقول بأن القضاء لا يتعدى الخصوم قول منتقد؛ لأن الحكم الصادر في منازعةٍ مَّا لا مانع من تطبيقه على نفس المنازعة إذا وقعت بين خصمين آخرين، وهو من باب السابقة القضائية المعترف بها.

=

فَأَمّا الصِّفَاتُ الْمُشْتَرَطَةُ فِي الْجوَازِ [١] فَأَنْ يَكُونَ حُرًّا [٢] مُسلِمًا [٣].....
بَالِغًا [٤] ذَكَرًا .....

٣- يعتمد القاضي في حكمه على وسائل الإثبات الشرعية من بينةٍ وإقرارٍ وما إلى ذلك، أما المفتي فلا اعتماد له على الحجج؛ وإنما يعتمد على الأدلة وحدها.

٤- لا تجوز الهدية للقاضي، لاحتمال المحاباة والميل في الحكم بخلاف المفتي، فالهدية له جائزة؛ لأنه لن يفتيه بما يريد، وعلى فرض التسليم بذلك فقد قَدَّمْنَا أن الفتوى غير ملزمة.

[١] أراد المصنف بهذه الصفات: الشروط التي ينبغي توافرها في القاضي، والتي لا تصح ولايته، ولا ينفذ قضاؤه إلا بها.

[٢] اشتراط الحرية في القاضي من الشروط التي اتفق عليها الفقهاء، ونظرًا لاختفاء الرق وعدم وجوده فأرى أنه لا وجه لتفصيل الكلام فيه.

[٣] **اشتراط الإسلام في القاضي:**

اتفق الفقهاء على أنه يشترط في القاضي أن يكون مسلمًا.

(٤) **اشتراط التكليف في القاضي:**

يعد هذا الشرط من الشروط المتفق عليها بين الفقهاء [١٣] ومؤداه: أن يكون القاضي بالغًا عاقلًا، ويدل على اشتراط التكليف في القاضي ما يلي:

١- ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يعقل، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق" [١٤].

قوله ﷺ: " تعوذوا من رأس السبعين وإمارة الصبيان " [١٥].

٢- إن الصبي والمجنون وَمَنْ في حكمهما قولهما غير معتدٍ به لنفسيهما، فلا يعقل أن يَنْفَذَ قولهما على غيرهما، كما أنهما غير مكلفين بما تقتضيه =

عَاقِلًا [١] عَدْلًا [٢] .....

الشريعة، فكيف يصلح لتكليف العباد مَنْ لَمْ يصلح لتكليف نفسه! أضف إلى ذلك: أنهما لا يملكان ولاية على نفسيهما، فكيف يملكانها على غيرهما! [١٦].

٣- إن تولية رئيس الدولة منصبًا لشخصٍ إنما تكون مقيدة بالمصلحة، ولا تتحقق المصلحة في تولية الصبي والمجنون منصب القضاء، فلا يصح تولية أي منهما [١٧].

ولا يشترط أن يبلغ القاضي سنًا معينة، بل الشرط هو البلوغ، فإذا كان الشخص بالغًا وتوفرت فيه بقية الشروط الأخرى فهو صالح لتولي هذا المنصب حتى ولو كان حديث السن، لكن لو رأى رئيس الدولة أو من له حق تولية القضاء اشتراط بلوغ سن معينة للصلاحية لهذا المنصب، فهذا لا شيء فيه، لأنه يدخل في باب المصلحة [١٨].

(١) العقل من الشروط المجمع عليها بين الفقهاء، فغير العاقل لا يجوز أن يكون قاضيا، حيث لا يستطيع التمييز بين الأشياء، ولا ولاية له على نفسه فمن باب أولى لا تنعقد له ولاية على غيره.

(٢) **تعريف العدالة:**

العدالة في اللغة هي الاستقامة، وقال الجرجاني: العدالة: عبارة عن الاستقامة على طريق الحق بالاجتناب عما هو محظور دينًا [١٩].

والعدالة: هي محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة ليس معها بدعة، وتتحقق باجتناب الكبائر، وترك الإصرار على الصغائر وبعض المباح، ولابد أن تتوافر العدالة عند منافسة الأغراض.

يقول السبكي عن بعض العلماء: لابد عندي في العدالة من وصفٍ آخر، وهو الاعتدال عند انبعاث الأغراض، حتى يملك نفسه عن اتباع هواه ".

وارتضى السيوطي تعريفًا للعدالة اعتبره أحسن التعريفات، ومفاده أن العدالة

=

هي: مَلَكَةٌ في النفس تمنع من اقتراف صغيرةٍ أو كبيرةٍ دالة على الخسة، أو مباحٍ يخل بالمروءة [٢٠].

وقال القرطبي: العدالة هي الاعتدال في الأحوال الدينية، وذلك يتم بأن يكون مجتنبًا للكبائر، محافظًا على مروءته وعلى ترك الصغائر، ظاهر الأمانة غير مغفل [٢١].

حكم تولية الفاسق منصب القضاء:

اختلف الفقهاء في حكم تولية الفاسق منصب القضاء على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

ذهب جمهور المالكية، والشافعية، والحنابلة إلى عدم جواز تولية الفاسق منصب القضاء [٢٢].

واستدلوا بما يلى:

١- قول الله تعالى ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمَۢا بِجَهَٰلَةٖ﴾ [٢٣] حيث قالوا: إن الله أمر بالتبيين عند قوله، وبالتالي فهو غير موثوق في قوله، ولا يجوز توليته القضاء.

٢- استدلوا بما روي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَسْأَلُهَا عَنْ شَيْءٍ، فَقَالَتْ: أُخْبِرُكَ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي بَيْتِي هَذَا: اللهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا، فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا، فَرَفَقَ بِهِمْ، فَارْفُقْ بِهِ [٢٤].

٣- ما روي عن أبي هريرة أن الرسول ﷺ قال: أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ [٢٥].

وجه الدلالة:

قالوا: إن غير القادر على تحمل الأمانة لا يحملها، والفاسق ليس أهلًا لذلك، لعدم توفر أهلية القضاء فيه

=

وَقَدْ قِيلَ فِي الْمَذْهَب [١] إنّ الْفِسْقَ يُوجِبُ الْعَزْلَ، وَيُمْضِي مَا حَكَمَ بِهِ.
وَاخْتَلَفُوا فِي كَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ، فَقَالَ الشّافِعِيُّ :يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ، وَمِثْلُهُ حَكَى عَبْدُ الْوَهّابِ عَنِ الْمَذْهَب، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ :يَجُوزُ حُكْمُ الْعَامّيّ، قَالَ الْقَاضِي: [٢] وَهُوَ ظَاهِرُ مَا حَكَاهُ جَدّي – رَحْمَةُ اللّهِ عَلَيْهِ – فِي

القول الثاني:

ذهب الحنفية إلى جواز تولية الفاسق للقضاء، معتبرين العدالة شرط كمال وأفضلية، إلا أن هذا المذهب ليس على إطلاقه، وإنما اعتبر فقهاء الحنفية الضرورة في هذه المسألة، فتولية الفاسق عندهم مقيدة بالضرورة، وذلك كما إذا لم يتوفر العادل، فهنا إذا تولى القضاء فاسق، صحت ولايته، لتعذر وجود العدل، واستدل أصحاب هذا المذهب بقياس القضاء على الشهادة [٢٦].

القول الثالث:

يرى الإمام أحمد أن شروط القضاء تعتبر حسب الإمكان، ويجب تولية الأمثل فالأمثل، وبناءً على هذا يُوَلَّى للعدم أنفع الفاسقين وأقلهم شرًا [٢٧].

واستدل أصحاب هذا المذهب بما يلي:

١- قول الله تعالى ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوۡمَۢا بِجَهَٰلَةٖ﴾ [٢٨] قالوا: إن الله أمر بالتبيين عند قول الفاسق، ولا يجوز أن يكون الحاكم ممن لا يقبل قوله، ويجب التبيين عند حكمه.

٢- إن الفاسق غير أهل للشهادة عنده، وبالتالي فلئلا يكون قاضيًا أولى.

(١) لفظ المذهب عند المالكية أطلقه متأخروا المالكية على ما عليه الفتوى في المذهب، ويطلق في مقابلة المذاهب الأخرى.

انظر: حاشية العدوي على الرسالة، ٤٣٨/١.

(٢) لفظ القاضي إذا أطلق عند المالكية فالمراد به: القاضي عبد الوهاب =

الْمُقَدِّمَاتِ عَنِ الْمَذْهَبِ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ كَوْنَ الِاجْتِهَادِ [١] فِيهِ مِنَ الصِّفَاتِ الْمُسْتَحَبَّةِ [٢].

البغدادي صاحب التآليف المشهورة، وعند الشافعية إذا أطلق القاضي في كتب الخرسانيين فالمراد به: أبو علي حسين المروذي، وإذا أطلق في كتب متوسطي العراقيين فالمراد به: القاضي أبو حامد المروذي، وعند متقدمي الحنابلة فيراد به القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء، أما المتأخرون كصاحب الإقناع والمنتهى ومن بعدهما فيطلقون لفظ القاضي ويريدون به: القاضي علاء الدين المرداوي.

(١) الاجتهاد في اللغة: افتعال من الجهد - بفتح الجيم وضمها - وهو استنفاد الجهد في طلب الشيء المرغوب إدراكه، وهو بذل الوسع والمجهود.

وفي الاصطلاح: قال الغزالي: هو بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة.

وقال غيره من الأصوليين: الاجتهاد بذل الطاقة واستفراغ الوسع في تحقيق أمرٍ من الأمور بحيث يحس العجز عن المزيد ولا يكون ذلك إلا فيما استلزم الجهد والمشقة.

لسان العرب، ٣٩٧/٢، المستصفى، ٢٧/٢، المحصول، ٧٥/١، الإحكام ، للآمدي،٢ /١٣، كشف الأسرار، ٢ /٣٠٠ .

(٢) **اشتراط الاجتهاد في القاضي:**

اختلف الفقهاء في مدى اشتراط الاجتهاد فيمن يتولي منصب القضاء وكان خلافهم على مذهبين:

القول الأول:

ذهب جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية والحنابلة، ومحمد من الحنفية إلى اشتراط الاجتهاد في القاضي، بمعنى لا يُوَلَّى القضاء إلا مجتهد.

=

ومع اشتراط أصحاب هذا القول الاجتهاد في القاضي إلا أنهم لم يجعلوا هذا الشرط على إطلاقه؛ بل أجازوا في حالة الضرورة تولية المقلد، أو مجتهد المذهب إذا لم يوجد غيره [٢٩].

القول الثاني:

ذهب جمهور الحنفية، وبعض المالكية، والزيدية إلى أن الاجتهاد ليس شرطًا في تولية القاضي، بل يجوز تولية غير المجتهد

وبالتالي يجوز عندهم تولية الجاهل والمقلد، والمقصود بالجاهل عندهم: من لا يَقْدِرُ على أخذ المسائل من كتب الفقه وضبط أقوال الفقهاء [٣٠].

أدلة القول الأول:

استدل الجمهور على مذهبهم باشتراط الاجتهاد في القاضي بالكتاب، والسنة، والمعقول:

أولًا: من الكتاب: استدلوا بما يلي:

١- قوله تعالى: ﴿يَدَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ﴾ [٣١] وقوله تعالى: ﴿وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ﴾ [٣٢] وقوله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [٣٣].

وجه الدلالة:

أمر الله في الآيات السابقة الحاكم أن يحكم بالعدل وبالحق وبما أنزل الله، والمقلد والجاهل لا يقدران على تَعَقُّلِ حجج الله، ولا يستطيعان كذلك النظر في الكتاب والسنة لاستنباط الأحكام، وإنما المجتهد هو القادر على ذلك [٣٤].

أضف إلى ذلك: أن الحوادث ممدودة، والنصوص محدودة، فلا يجد القاضي في كل حادثة نصاً يقضى به في الخصومة، وبالتالي يحتاج إلى استنباط المعنى من المنصوص عليه، ولا يمكنه ذلك إلا إذا كان عالمًا مجتهدًا [٣٥].

٢- قوله سبحانه وتعالى ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ

=

أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَٰبِ﴾ (٣٦).

وجه الدلالة:

يستدل بهذه الآية على اشتراط الاجتهاد من وجهين:

الأول: إنه مَنَعَ من المساواة، فيجب حملها على العموم، فتطبق على القضاء وغيره.

الثاني: إنه قالها زجرًا، فصار أمرًا، أي في معنى الأمر بالعلم، والنهي عن الجهل (٣٧)

ثانيًا: من السنة:

استدلوا بقول النبي ﷺ: الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: قَاضِيَانِ فِي النَّارِ: قَاضٍ يَقْضِي فِي النَّاسِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، وَيُوَكِّلُ بَعْضَهُمْ مَالَ بَعْضٍ، وَقَاضٍ يَتْرُكُ عَمَلَهُ وَيَقْضِي بِغَيْرِ الْحَقِّ، فَهَذَانِ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ يَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ (٣٨).

حيث أوضح النبي ﷺ أن القاضي الذي يقضي بكتاب الله مصيره الجنة، ولا يتمكن القاضي من ذلك إلا ذا كان مجتهدًا، فكان الاجتهاد مشترط في القاضي.

٤- استدلوا بالقياس على الفتوى، فقالوا: إن الحكم آكد من الفتيا، لأنه فتيا وإلزام، كما أن المفتي لا يجوز أن يكون عاميًا مقلدًا فالحكم أولى، وبالتالي فمن لم يَجُزْ أن يكون مفتيًا لم يَجُزْ أن يكون قاضيًا من باب أولى (٣٩).

المناقشة:

يناقش الاستدلال بالقياس على المفتي والعامي بأن العامي مضطر، والحاكم غير مضطر، كما أن العامي يلتزمه في حق نفسه، والحاكم يوجبه على غيره (٤٠).

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني على مذهبهم بعدم اشتراط الاجتهاد في

=

القاضي بالسنة والمعقول:

١ – من السنة:

استدلوا بما روى عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ، قَالَ: قُلْتُ: تَبْعَثُنِي إِلَى قَوْمٍ يَكُونُ بَيْنَهُمْ أَحْدَاثٌ، وَلا عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ؟ قَالَ: إِنَّ اللهَ سَيَهْدِي لِسَانَكَ، وَيُثَبِّتُ قَلْبَكَ، قَالَ: فَمَا شَكَكْتُ فِي قَضَاءٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ بَعْدُ [٤١].

وجه الدلالة:

دل هذا الحديث على أن الاجتهاد ليس بشرط؛ حيث إن الرسول ﷺ بعث عليًّا إلى اليمن للقضاء، ولم يكن عليًّا آنذاك مجتهدًا بشهادته على نفسه، حيث قال: ولا علم لي بالقضاء.

وقد ناقش ابن الهمام الاستدلال بحديث بَعْثِ النبي ﷺ عليًّا إلى اليمن قائلًا: " الاستدلال على تقليد المقلد بتقليد النبي ﷺ عليًّا اليمن، ولم يكن مجتهدًا فليس بشئ، فإنه ﷺ دعا له بأن يهدي الله قلبه، ويثبت لسانه، فإنه بهذا الدعاء رزق أهلية الاجتهاد فلا إشكال، وإلا فقد حصل له المقصود من الاجتهاد وهو العلم والسداد، وهذا غير ثابت في غيره [٤٢].

٢- من المعقول:

استدلوا بقولهم: إن الغرض من نَصْبِ القاضي أن يفصل في الخصومات، وأن يقوم بإيصال الحقوق إلى مستحقيها، فإذا أمكنه ذلك بعلم غيره، بأن يرجع إلى فتوى غيره من العلماء جاز قضاؤه، كما يحكم بقول المقومين في الأمور التي تحتاج إلى تقويم الخبراء [٤٣].

أضف إلى ذلك: أنه من المسلم به أن القاضي يستعين في القضايا التي تحتاج إلى رأي الخبراء والمختصين برأي هؤلاء، ويحكم بناءً على ما أبدوه من

=

رأي، ومثل هذا حكمه في القضايا مستيقنًا بعلم غيره من العلماء المجتهدين، فكما جاز له الرجوع إلى رأي الخبراء جاز له أن يحكم بعد الرجوع إلى علم غيره من المجتهدين [٤٤].

المناقشة:

نوقش هذا الدليل: بأن الغرض من نَصْبِ القاضي ليس هو القضاء على أي وجهٍ كان، وإنما القضاء على وجه الكمال، وهذا لا يتحقق إلا إذا توافرت في القاضي صفة الاجتهاد [٤٥].

متطلبات الاجتهاد المشترط في القاضي:

إذا أريد للقاضي أن يكون عالما بالأحكام الشرعية، فينبغي أن يتوافر فيه ما يلي:

١- أن يكون عارفا من القرآن والسنة ما يتعلق بالأحكام، ولا يشترط أن يكون حافظا للآيات الكريمة، أو الأحاديث الشريفة عن ظهر قلب؛ بل يكفي أن يكون عارفا بمواضع أحكام القرآن والسنة، لكى يرجع إليها عند الاحتياج إليها، إلا أنه مع ذلك يجب أن يعرف خاص القرآن وخاص السنة وعامها، ويعرف المطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والناسخ والمنسوخ، والنص والظاهر، وغير ذلك من مباحث علوم القرآن وعلوم السنة، أضف إلى ذلك أنه يجب أن يميز في السنة بين المتواتر والآحاد، حتى يتمكن من الترجيح في حال التعارض.

٢- أن يكون عارفا بلسان العرب، لغة ونحوا وصرفا وبلاغة، لأنه لا بد منها في فهم الكتاب والسنة.

٣- أن يعرف أقوال العلماء من الصحابة ومن بعدهم، إجماعًا واختلافًا، فلا يخالفهم في اجتهادهم إذا أجمعوا على حكم من الأحكام، ولا يجب أن يعرف أقوالهم في كل مسألة، بل يكفيه معرفة أقوالهم في المسألة المعروضة عليه، ويكفى أن يعرف أن المسألة التي يفتي فيها لا يصادم قوله الإجماع.

=

٤- أن يكون عارفا بالقياس وشرائطه، وأنواعه، فيعرف القياس الجلي، وهو ما يقطع بنفي الفارق بين المقيس والمقيس عليه، أو بعبارةٍ أخرى: هو ما كانت علة الفرع أقوى منها في الأصل، وذلك كقياس الضرب على التأفيف الوارد في قوله تعالى: "إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريما" [٢] كذلك ينبغي أن يعرف القياس المساوي، وهو ما كانت العلة التي بني عليها الحكم في الأصل موجودة بقدر ما هي متحققة في الأصل، ويعرف القياس الأدنى، وهو ما كانت العلة في الفرع أضعف وأقل وضوحا مما في الأصل مع تساوي الاثنين في تحقيق أصل المعنى الذي صار به الوصف علة [٤٦].

ويبين القاضي عياض طريقة العمل بالأدلة الشرعية فيقول: "إن ترتيب الاجتهاد على ما يوجبه العقل، ويشهد له الشرع تقديم كتاب الله عز وجل على ترتيب أدلته في الوضوح من تقديم نصوصه، ثم ظواهره ثم مفهوماته، ثم كذلك السنة على ترتيب متواترها، ومشهورها، وآحادها، ثم ترتيب نصوصها وظواهرها ومفهوماتها، ثم الإجماع عند عدم الكتاب ومتواتر السنة، وعند عدم هذه الأصول كلها القياس عليها والاستنباط منها، إذ كتاب الله مقطوع به، فوجب تقديم ذلك كله، ثم الظواهر، ثم المفهوم لدخول الاحتمال في معناها ثم أخبار الآحاد عند عدم الكتاب والمتواتر منها، وهى مقدمة على القياس لإجماع الصحابة وتركهم نظر أنفسهم متى بلغهم خبر الثقة، وامتثالهم مقتضاه دون خلاف منهم في ذلك، ثم القياس أحرى عند عدم الأصول على ما مضى عليه عمل الصحابة ومن بعدهم من السلف المرضيين رضى الله عنهم" [٤٧].

ولا يشترط أن يكون مجتهدا في كل علم يتعلق به الاجتهاد، لأنه لو كان ذلك كذلك لـم يوجد مجتهد بعد الصحابة إلا نادراً [٤٨].

ويقرر ابن قدامة أنه ليس من شرط الاجتهاد أن يكون مجتهدا في كل =

وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي اشْتِرَاطِ الذُّكُورَةِ، فَقَالَ الْجُمْهُورُ: هِيَ شَرْطٌ فِي صِحّةِ الْحُكْمِ [١]، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ :يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ قَاضِيًا فِي الْأَمْوَالِ [٢].

قَالَ الطَّبَرِيُّ: [٣] يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ حَاكِمًا .....

المسائل، بل من عرف أدلة مسألة وما يتعلق بها تثبت له صفة الاجتهاد وإن كان جاهلا بغيرها، كما إذا كان يعرف الفرائض وأصولها، فليس من شرط اجتهاده فيها أن يكون عارفا بالبيوع أو الحدود أو غيرهما من أبواب الفقه، وقد ثبت أنه ما من إمام من المجتهدين إلا وتوقف في بعض المسائل، وقال بعض العلماء: من يجيب في كل مسألة فهو مجنون، وإذا ترك العالم كلمة لا أدري فقد أصيبت مقاتله.

وحكي أن الإمام مالكا ﷺ سئل عن أربعين مسألة فقال في ست وثلاثين منها: لا أدري ، ولم يمنع ذلك من كونه أحد الأئمة المجتهدين الكبار.

والمعتبر أصول هذه الأمور، وهو مجموع مدون في فروع الفقه وأصوله، فمن عرف ذلك ورزق فهمه كان مجتهدا له الفتيا وولاية القضاء [٤٩].

القول الراجح:

بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتها في هذه المسألة يتضح أن القول باشتراط الاجتهاد المطلق في القاضي يعد أمرًا ليس باليسير، إذ إن الاجتهاد المطلق يصعب تحققه في هذا الزمان، وبالتالي ينبغي في هذا المقام الاقتصار على اشتراط كون من يريد منصب القضاء عالمًا بالأحكام الشرعية من فقهٍ وحديثٍ وتفسيرٍ وأصول الفقه وما إلى ذلك.

(١) هذا هو القول الأول الذي يرى عدم جواز تولي المرأة القضاء مطلقا.

(٢) يشير إلى القول الثاني الذي تزعمه الحنفية.

(٣) هو الإمام أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري، مفسر، مؤرخ، =

عَلَى الْإِطْلَاقِ فِي كُلِّ شَيْءٍ [١].

أصولي، فقيه، ولد سنة ٢٢٤هـ وتوفي سنة ٣١٠ هـ ، كان مجتهدا لا يقلد، سمع من إسحاق بن إسرائيل، ومحمد بن حميد الرازي، وغيرهما، وأخذ عنه الطبراني، ومن أشهر مصنفاته: تهذيب الآثار.

انظر في ترجمته: تاريخ بغداد، ١٦٢/٢، شذرات الذهب، ٢٦٠/٢، طبقات الشيرازي، ص ٣٤٢.

(١) هذا هو القول الثالث، وهو قول ابن جرير الطبري.

الهوامش

(١) المعجم الوسيط، ٦٨٠/٢، القاموس المحيط، ٣٧٣/٤، مختار الصحاح، ص ٤٩١.

(٢) لسان العرب، ٥/٢٠.

(٣) شرح منتهى الإرادات، ٤٥٦/٣.

(٤) المجموع، للنووي،٧٢/١، الموافقات، للشاطبي، ٢٤٤/٤، طبعة المكتبة التجارية الكبرى.

(٥) إعلام الموقعين، ٢٢٠/٤، مطالب أولى النهى، ٤٤٠/٦.

(٦) مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر، ٤٥٣/٢، المبسوط، للسرخسي، ١٠٨/١٦، شرح فتح القدير، ٧/ ٥٥٢، شرح النيل، ١١٤/١٣، أدب القاضي، للماوردي، ٢٢٩/١ ٠

(٧) تحفة المحتاج إلى شرح المنهاج، لابن حجر الهيثمي، ١٠٦/١٠.

(٨) مغني المحتاج، ٢٦٢/٦، الأحكام السلطانية، ص ٦١، المغني، ١٤/١٤، المحلى، لابن حزم، ٣٦٣/٩، البحر الزخار، ١٩/٦، مواهب الجليل، ٩٠/٦، شرح الخرشي، ١٣٨/٧ بلغة السالك، ٣٠٥/٢، ٣٠٦، المنتقى، ١٨٣/٥.

(٩) سورة النساء: من الآية ١٤١.

(١٠) أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه، برقم (١٢٨٩) ٤٥٤/١.

(١١) د/ محمد رأفت عثمان: النظام القضائي في الفقه الإسلامي، ص ٧٨.

(١٢) د/ عبد العال عطوة: محاضرات في علم القضاء، ص ٤٤، د/ محمد رأفت عثمان: النظام القضائي في الفقه الإسلامي، ص ٨٠ وما بعدها.

(١٣) المبسوط، ١٠٨/١٦، شرح فتح القدير، ٢٥٣/٧، بلغة السالك، ٣٠٦/٢، مواهب الجليل، ٨٧/٦، المهذب، ٣٧٧/٣، الإقناع، ٨٤/٥، المغنى، ١٢/١٤، المحلى، ٣٦٣/٩، البحر الزخار، ١١٩/٦.

(١٤) السنن الكبرى، للبيهقي، كتاب، باب من تجب عليه الصلاة، ٨٣/٣.

(١٥) مصنف ابن أبي شيبة، ٤٦١/٧، ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد، كتاب الفتن، باب التعوذ من الفتن، ٢٢٠/٧.

(١٦) المبدع، ١٩/١٠، السيل الجرار، للشوكاني، ٢٧٤/٤.

(١٧) د/ محمد رأفت عثمان: النظام القضائي في الفقه الإسلامي، ص ٨٢.

(١٨) د/ عبد العال عطوة: محاضرات في علم القضاء، ص ٣٨ وما بعدها.

(١٩) التعريفات، للجرجاني، ص ١٥٢.

(٢٠) شرح مختصر ابن الحاجب، ٦٩٦/١، الأشباه والنظائر، للسيوطي، ص ٣٨٤.

(٢١) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ٣٩٦/٣.

(٢٢) بداية المجتهد، ٣٨٤/٢، شرح الزرقاني على خليل، ١٢٣/٧، حاشية الدسوقي، ١٢٩/٤ التاج والإكليل، ٢٢١/٢، بلغة السالك لأقرب السالك المعروف بحاشية الصاوي، طبعة المكتبة التجارية الكبرى، ٣٠٥/٢، شرح الخرشي، ١٣٨/٧، المنتقى شرح موطأ مالك، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧م، ١٨٤/٥، كشاف القناع، ٢٩٥/٦، المغني، لابن قدامة، ١٤/١٤.

(٢٣) سورة الحجرات: الآية رقم ٦.

(٢٤) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الإمام العادل وعقوبة الجائر، برقم (١٨٢٨) ١٤٥٨/٣.

(٢٥) أخرجه أبو داود، كتاب البيوع، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، برقم (٣٥٣٤) ٥،٣٩٤، والترمذي، كتاب أبواب البيوع، برقم (١٢٦٤) ٥٥٦/٣، وقال: هذا حديث حسن غريب.

(٢٦) الهداية، للمرغيناني، طبعة دار الكتب العلمية - بيروت، ١٠١/٣٠، مجمع الأنهر، شرح ملتقى الأبحر، لشيخ زادة، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، ١٥١/٤.

(٢٧) الإقناع، للمقدسي، ٣٩٦/٤، الإنصاف، ١٨١/١٢.

(٢٨) سورة الحجرات: الآية ٦.

(٢٩) مواهب الجليل، ٨٨/٦، أدب القاضي، للماوردى،٦٣٦/١، نهاية المحتاج، للرملي ٢٢٦/٨، المغني، لابن قدامة، ٣٨٢/١١، روضة القضاة، للسمناني، ٥٩/١، الإنصاف، للمرداوي، ١٧٨/١١.

(٣٠) معين الحكام، للطرابلسي، ص ١٤، البحر الرائق، ٢٨٨/٦، بداية المجتهد، ٤٩٩/٢، شرح الأزهار، ٣١١/٤.

(٣١) سورة ص: من الآية رقم ٢٦.

(٣٢) سورة المائدة: من الآية رقم ٤٩.

(٣٣) سورة النحل: من الآية ٤٤.

(٣٤) المغني، لابن قدامة، ٣٨٢/١١.

(٣٥) المنتقى شرح الموطأ، ١٨٣/٥.

(٣٦) سورة الزمر: الآية رقم ٩.

(٣٧) أدب القاضي، للماوردي، ٦٣٨/١.

(٣٨) الحديث سبق تخريجه.

(٣٩) المغني، ٣٨٢/١١، أدب القاضي، للماوردي، ٦٣٩/١.

(٤٠) الحاوي الكبير، للماوردي، ٢٢٥/٨.

(٤١) أخرجه أبو داود، كتاب الأقضية، باب كيف القضاء، برقم (٣٥٨٢) ٣٠١/٣.

(٤٢) شرح فتح القدير، لابن الهمام، ٣٦٠/٦.

(٤٣) بدائع الصنائع، ٣/٧.

(٤٤) د/ محمد رأفت عثمان: النظام القضائي في الفقه الإسلامي، ص ١٩٣ وما بعدها.

(٤٥) شرح فتح القدير، ٢٤٤/٧.

(٤٦) د/ محمد رأفت عثمان: السابق، ص ١٨٣ وما بعدها.

(٤٧) شرح فتح القدير، ٢٤٤/٧.

(٤٨) الموافقات، للشاطبي، ٩٠/٤.

(٤٩) المغنى، ٤٢/٩، الإقناع في فقه الشافعية، ٨١/٥.

(٥٠) د/ محمد رأفت عثمان: النظام القضائي في الفقه الإسلامي، ص ١٢٠ وما بعدها، د/ إبراهيم عبد الحميد: نظام القضاء في الإسلام، ص ٢٣، ٢٤.

(٥١) قال الماوردي: "وشذ ابن جرير فجوز قضاؤها في جميع الأحكام، ولا اعتبار بقول يرده الإجماع ".

وقال ابن رشد: "قال الطبري: يجوز أن تكون المرأة حاكمًا على الإطلاق في كل شيء".

وقال ابن قدامة: "وحكى عن ابن جرير أنه لا تشترط الذكورية؛ لأن المرأة يجوز أن تكون مفتيةً، فيجوز أن تكون قاضية".

الأحكام السلطانية، للماوردي، ص ٦٥، بداية المجتهد، ٥٣١/٢، المغني، لابن قدامة، ٣٥٢/١٠.

(٥٢) سورة النساء: الآية ٣٤.

والمقصود بالقوامة هنا القوامة الأسرية، أي قوامة رب الأسرة، وهي من القيام على الشيء والاستبداد بالنظر فيه وحفظه بالاجتهاد، فقيام الرجل على المرأة يكون مقتضاه أن يقوم فيه ببرها وتأديبها وإمساكها في بيتها ومنعها من البروز.

تفسير القرطبي، ١٧٣٨/٣ - ١٧٣٩، المحلى، لابن حزم، ٤٢٩/٩، أحكام القرآن لابن العربي، ٤١٥/١.

(٥٣) الأحكام السلطانية، للماوردي، ص ٦٥.

(٥٤) سورة طه: من الآية رقم ١١٤.
(٥٥) صدر الآية رقم ٣٤ من سورة النساء.
(٥٦) أحكام القرآن، لابن العربي، ٤١٥/١، تفسير القرطبى، ١١٥/٣.
(٥٧) سورة النساء: الآية ٣٥.
(٥٨) تفسير الطبري، ٤٩/٥، د/ إبراهيم عبد العزيز بدوي، تعيين القاضي وأعوانه في الإسلام، ١٩٤/١.
(٥٩) أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب كتاب النبي ﷺ إلى كسرى، برقم (٤١٦٣) ١٦١٠/٤.
(٦٠) شرح النيل، ٢٥/١٣.
(٦١) نيل الأوطار، للشوكاني، ٢٦٨/٩.
(٦٢) النظام القضائي في الفقه الإسلامي، للدكتور/ محمد رأفت عثمان، ص ١٢٧.
(٦٣) المحلى، ٤٢٩/٩، القضاء في الإسلام، للشيخ/ إبراهيم عبد الحميد، ص ٣١ – ٣٣.
(٦٤) المغنى، لابن قدامة، ١٣/١٤.
(٦٥) المنتقى شرح الموطأ، للباجي، ١٨٢/٥.
(٦٦) المرجع السابق، ١٨٢/٥.
(٦٧) د / إبراهيم بدوي، تعيين القاضي وأعوانه في الإسلام، ٢٠١/١ – ٢٠٢.
(٦٨) تبيين الحقائق، ١٨٧/٤.
(٦٩) المحلى، لابن حزم، ٤٢٩/٩، ٤٣٠، محاضرات في علم القضاء، د/ عبد العال عطوة، ص ٦٦.
(٧٠) د/ محمد رأفت عثمان، النظام القضائي في الفقه الإسلامي، ص ١٤٢، ١٤٣.
(٧١) الأشباه والنظائر، للسيوطي، ١٧١ - ١٧٢، الأشباه والنظائر، لابن نجيم، ١٦٠.
(٧٢) سورة النساء: الآية ٥٨.
(٧٣) المحلى، لابن حزم، ٤٣٠/٩، د/ إبراهيم بدوي، السابق، ٢٠٣/١.
(٧٤) أخرجه البخاري، كتاب الاستقراض، باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه، برقم (٢٤١٦) ٩٠١/٢.
(٧٥) المحلى، لابن حزم، ٤٢٩/٩.
(٧٦) نظام القضاء في الإسلام، للشيخ، إبراهيم عبد الحميد، ص ٣٤.
(٧٧) تاريخ الخلفاء، للسيوطي، ص ٣٨١.
(٧٨) محاضرات في علم القضاء، ص ٤٨، النظام القضائي في الفقه الإسلامي، ص ١٤٣.
(٧٩) المحلى، لابن حزم، ٤٢٩/٩.

(٨٠) مواهب الجليل، ١٨١/٦.

وَلَا خِلَافَ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ أَنّ السّمْعَ وَالْبَصَرَ [١] وَالْكَلَامَ مُشْتَرَطَةٌ فِي اسْتِمْرَارِ

---

(١) **اختلف الفقهاء في تولية الأعمى منصب القضاء:**

فالصحيح في مذهب الشافعية أنه لا يجوز تقليد الأعمى منصب القضاء، وحكى الجرجاني قولًا قديمًا بعيدًا أنه يصح توليته، حتى قيل: إن ابن أبى عصرون قاضى قضاة الشام عَمِيَ في آخر عمره، واستمر قاضيًا، وألف كتابا في جواز قضاء الأعمى باسم " رسالة في نفي قضاء الأعمى وجوازه ".

واستدلوا بما روي أن النبي ﷺ استخلف ابن أم مكتوم على الصلاة وغيرها من أمور المدينة.

وقال ابن أبي الدم بعد حكايته لهذا القول: هو غريب، لم أَرَ أحدًا حكاه غيره، ومثله لا يُعَدُّ من المذهب [١].

الجواب:

بالنسبة لاستخلاف ابن أم مكتوم فقد أجاب المانعون لولاية الأعمى باحتمال أنه استخلفه في الأمور العامة من الحراسة وما يتعلق بها، لا في خصوص الحكم [٢].

ويرى المالكية: أنه لا يجوز تولية الأعمى والأصم والأبكم، وإن حكم واحد منهم نَفَذَ حكمه، لأن هذه الخصال ليست مشترطة في صحة ولاية القضاء، إلا أن عدمها يوجب فسخ الولاية، فإن وَلِيَ القضاء مَنْ لَمْ تجتمع فيه هذه الخصال، وَجَبَ عزله، ونقض كل ما مضى من أحكامه [٣].

ونسب بعض الفقهاء القول بجواز تولية الأعمى إلى الإمام مالك، إلا أن ابن فرحون في تبصرة الحكام أنهى هذه المسألة بردٍ قاطعٍ نفي فيه نسبة هذا القول إلى الإمام مالك، بل إنه حكى إجماعًا في ذلك ، فقال ما نصه: " وأما سلامة السمع والبصر فإن القاضي عياض حكى فيه الإجماع عن العلماء مالك وغيره، وهو المعروف إلا ماحكاه الماوردي عن مالك أنه يجوز قضاء الأعمى، وذلك

=

وِلَايَتِهِ، وَلَيْسَ شَرْطًا فِي جَوَازِ وِلَايَتِهِ، وَذَلِكَ أَنّ مِنْ صِفَاتِ الْقَاضِي فِي الْمَذْهَبِ مَا هِيَ شَرْطٌ فِي الْجَوَازِ، فَهَذَا إِذَا وُلِّيَ عُزِلَ وَفُسِخَ جَمِيعُ مَا حَكَمَ بِهِ، وَمِنْهَا مَا هِيَ شَرْطٌ فِي الِاسْتِمْرَارِ وَلَيْسَتْ شَرْطًا فِي الْجَوَازِ، فَهَذَا إِذَا وَلِيَ الْقَضَاءَ عُزِلَ وَنَفَذَ مَا حَكَمَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَوْرًا [1]**، وَمِنْ هَذَا الْجِنْسِ عِنْدَهُمْ هَذِهِ الثَّلَاثُ صِفَاتٍ.**

غير معروف ولا يصح عند مالك، ولأنه لا يتأتى قضاء ولا ضبط، ولا تمييز لحقٍ من باطل، ولا تعيين طالبٍ من مطلوب، ولا شاهد من مشهود عليه من الأعمى، وفي وثائق ابن القاسم الجزم بأن السمع والبصر شرط في الصحة كما قال القاضي عياض" أ.هـ.

أدب القضاء، لابن أبي الدم، ص ٧٤، تبصرة الحكام، ١/٢٢، ٢٣.

ويرى الشافعية أيضًا أن فَقْدَ هذه الخصال لا يوجب التولية ولا يجيزها، أما إذا أصاب هذه الحواس ضعف، صحت التولية؛ لأن الأصم لا يفرق بين الإقرار والإنكار، والأعمى لا يَعْرِفُ الطالب من المطلوب، وخرج بالأعمى الأعور، فإنه يصح توليته، وكذا من يبصر بالنهار فقط دون الليل.

غاية ما في هذا الشرط أن يكون ذا يقظةٍ تامة، وقوّة على تنفيذ الحق بحيث لا يؤتى من غفلة، أي: لا يصاب في الحكم، بأن يحكم بخلاف الحق من أجل غفلته، ولا يخدع من غرّة، أي: لا يخدع عن الحق بسبب غرور شخص له.

(١) **حكم بذل القاضي الرشوة وقبولها:**

أولا: دفع الرشوة لتولي منصب القضاء:

من المتفق عليه بين العقلاء أن الرشوة هي الداء العضال الذي إذا أصيب به المجتمع المتقدم الراقي صار مجتمعًا يحتل مكانةً هابطة، بل صار من أرذل المجتمعات على الإطلاق، فالرشوة دليل على فساد الذمم وخرابها، ودليل على انعدام أو غياب الوازع الديني لدى الأفراد.

والقضاء من أخطر المناصب؛ لأن عليه مدار العدل، فإذا كان القاضي غير

=

عادل في نفسه، فكيف يعدل مع غيره.

حكم القضاء مع وجود الرشوة:

بتتبع ما ورد الفقهاء في هذه المسألة يتضح أن القاضي الذي يتم تعيينه عن طريق الرشوة تُعَدُّ توليته باطلة، ولا يصلح أن يكون قاضيًا.

ويرى الماوردي الشافعي أن من دفع رشوة ليعين في منصب القضاء، فإن حاله لا يخلو من ثلاثة أقسام [٤]:

القسم الأول:

أن يكون القضاء واجبًا عليه، كما إذا لم يكن هناك من يصلح للقضاء غيره، أو يكون مستحبًا ليخلص الناس من ظُلْمِ قاضٍ آخر، فإنَّ دَفْعَ الرشوة في هذه الحالة يجوز له، ويحرم على مَنْ أخذها.

القسم الثاني:

أن يكون طلبه محظورًا أو مكروهًا، فدفعه الرشوة في هذه الحالة ليتولى القضاء ممنوع ومكروه بحسب حال الطلب.

القسم الثالث:

أن يكون طلبه للقضاء مباحًا، فإذا كان دفع الرشوة بعد التعيين فالحرمة على الذي دُفِعَتْ له الرشوة لقول النبي ﷺ: هَدَايَا الْأُمَرَاءِ غُلُولٌ، وإن كان دَفْعُ الرشوة قبل التعيين فالحرمة على الاثنين الدافع والآخذ، فقد ثبت أن النبي ﷺ: لَعَنَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِي [٥].

ويرى الحنفية أن القاضي إذا عُيِّنَ بطريق الرشوة فإن ولايته لا تنعقد وتعتبر باطلة، ولو قضى فإن أحكامه تعتبر غير نافذة [٦].

ويرى المالكية أن القاضي الذي يعين بطريق الرشوة لا تنعقد ولايته، وإن وَلِيَ وحكم فإن أحكامه ترد ولا يجوز قبولها، حتى ولو جاءت موافقة للحق [٧].

=

قبول الرشوة من الخصوم:

الرشوة: هي المال المبذول للغير من مُحِقٍّ ليحصل على حقه، أو مبطل ليحصل على حق غيره مع شرط ذلك [٨].

وبذل الرشوة وكذلك أخذها أمر حرمته الشريعة الإسلامية، ورتبت على هذا التحريم أمور نذكرها في حينها إن شاء الله تعالى.

أدلة تحريم الرشوة:

يستدل على تحريم الرشوة بأدلةٍ كثيرة منها:

١- قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ﴾ [٩] حيث ورد النهي في الآية عن أكل أموال الناس بالباطل، وليس هناك من باطل أشد من أكل الأموال عن طريق الرشوة، ولهذه الرشوة صور:

- أن يأخذها الحاكم ليحكم بغير الحق، وهذا هو منتهى الفساد والضلال؛ لأنه بذلك يخالف مقتضيات وظيفته، والتكاليف الشرعية المنوطة به، فإذا أخذ المال ليحكم بغير الحق فقد خان الأمانة، لأنه مؤتمن على إيصال الحقوق إلى مستحقيها، وخالف الحكم بالعدل المأمور به.

- أن يأخذها الحاكم ليماطل في الحكم، أو ليمتنع عنه، وفى هذا أيضاً من الفساد ما فيه؛ لأنها إعانة للظالم على توطيد دعائم ظلمه، وتعطيل لفريضة محكمة وسنة متبعة جاء الأمر بها في القرآن.

- أن يأخذ الحاكم الرشوة لإيصال الحق إلى مستحقه، ودفع الظلم والضرر عنه، وهذا أيضًا من باب أكل أموال الناس بالباطل، إذ إنه يتعين عليه إيصال الحقوق إلى مستحقيها، ودفع الظلم عن المظلومين، والأخذ على أيدي المعتدين والظالمين، وهذه أمانة فأخذه المال من المظلوم لدفع الظلم عنه خيانةً لهذه الأمانة، ويكون من قبيل الأكل بالباطل المنهي عنه في الآية، والنهي فيها يقتضي

=

التحريم [١٠].

٢- ما ثبت أن النبي ﷺ: لَعَنَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِي [١١] وغير ذلك من الآيات والأحاديث التي نهت عن الظلم وأمرت بالعدل.

ولكن إذا بذل القاضي رشوةً لتولي القضاء، فما هو مصير الأحكام التي حكم بها؟

اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يرى أن القاضي إذا قبض رشوة أو تَوَلَّى القضاء عن طريق الرشوة فأحكامه صحيحة نافذة، ولا يجوز إبطالها، وهو قول ضعيف في مذهب الحنفية قال به البزدوي، والكمال بن الهمام [١٢].

وحجة هؤلاء:

أن القاضي إذا أخذ الرشوة فإنه يصير فاسقًا، ومن مذهبهم أن الفسق لا يوجب عزل القاضي، وبالتالي فولايته قائمة وقضاؤه ينفذ؛ لأنه قضاء بحق [١٣].

القول الثاني:

يرى أن أحكام القاضي التي ارتشى فيها باطلة، حتى ولو حكم بالحق، وهو قول السرخسي وابن نجيم [١٤].

واستدلوا: بأن القاضي إذا ارتشى فهو عامل لنفسه، بمعنى أنه حكم لنفسه من حيث المضمون، وحكم الحاكم لنفسه باطل، فظهر من ذلك أن خصوص هذا الفسق مؤثر في عدم نفاذ الحكم وسبب لبطلانه [١٥].

القول الثالث:

إن أحكام القاضي المرتشي غير نافذة كلها، سواءً هي التي ارتشى بسببها أم لا، وهو قول الإمام أبى حنيفة، حيث نقل عنه قوله: "لو قضى القاضي زمانًا بين الناس، ثم علم أنه مرتش ينبغي للقاضي الذي يختصمون إليه أن يبطل كل

=

وَمِنْ شَرْطِ الْقَضَاءِ عِنْدَ مَالِكٍ أَنْ يَكُونَ وَاحِدًا، وَالشّافِعِيُّ يُجِيزُ أَنْ يَكُونَ فِي الْمِصْرِ قَاضِيَانِ اثْنَانِ إِذَا رُسِمَ لِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا يَحْكُمُ فِيهِ، وَإِنْ شُرِطَ اتّفَاقُهُمَا فِي كُلّ حُكْمٍ لَمْ يَجُزْ [١] وَإِنْ شُرِطَ الِاسْتِقْلَالُ لِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَوَجْهَانِ: الْجَوَازُ وَالْمَنْع [٢].

قضاياه" [١٦].

(١) السبب أنه قد يقع بينهما من خلافٍ في الاجتهاد يؤدي إلى عدم الفصل في المنازعات.

وصرح ابن فرحون بعدم صحة عقد الولاية للحاكمين معًا على أن يجتمعا ويتفقا على الحكم في كل قضيةٍ إذا كان ذلك قد شرط في عقد ولايتهما، وعند الحنابلة وجهان:

الأول: لا يجوز، لأن ذلك يؤدي إلى إيقاف الحكم والفصل في الخصومات، لأنهما قد يختلفان في الاجتهاد.

والثاني: الجواز، إذا كان القاضيان لا يشتركان في قضيةٍ واحدة.

حاشية الدسوقي، ١٣٤/٤ –١٣٥، مغني المحتاج، ٢٦٩/٦، كشاف القناع، ٢٩٢/٦، تبصرة الحكام، ٢٢/١ وما بعدها.

(٢) **تعدد القضاة:**

- ذهب إلى المالكية إلى أنه لا يجوز أن يولَّى القضاء قاضيا فأكثر على وجه الاشتراك، وبالتالي لا يكون لأحدهما الانفراد بالنظر في قضية ولا قبول بينه، ولا انفراد بإنفاذ الحكم، أما إذا تعدد القضاة على أن ينفرد كل واحد منهم بالنظر فيما يرفع إليه فجائز.

ودليلهم:

إجماع الأمة، إذ لم يختلف في ذلك أحد من زمن رسول الله ﷺ إلى يومنا هذا، ولا نعلم أنه أشرك بين قاضيين في زمن من الأزمان [١٧].

=

قَالَ[١]: وَإِذَا تَنَازَعَ الْخَصْمَانِ فِي اخْتِيَارِ أَحَدِهِمَا وَجَبَ أَنْ يَقْتَرِعَا عِنْدَهُ.

وَأَمَّا فَضَائِلُ الْقَضَاءِ فَكَثِيرَةٌ، وَقَدْ ذَكَرَهَا النَّاسُ فِي كُتُبِهِمْ .

وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي الْأُمِّيِّ [٢] هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَاضِيًا؟ وَالْأَبْيَنُ جَوَازُهُ؛ لِكَوْنِهِ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – أُمِّيًّا، وَقَالَ قَوْمٌ: لَا يَجُوزُ، وَعَنِ الشَّافِعِيِّ الْقَوْلَانِ جَمِيعًا؛ لِأَنَّهُ

– ويرى الشافعية أنه يجوز أن يجعل قضاء بلدٍ إلى اثنين أو أكثر على أن يحكم كل واحدٍ منهما في موضعٍ، أو على أن يحكم أحدهما في حق والآخر في غيره، أو على أن يحكم كل واحدٍ منهما في زمان، والآخر في زمان؛ لأنهما يملكان الحكم بإذنه، فكان على حسب ما أُذِنَ فيه لهما.

وفي هذه الحالة لا يكون حكم أحدهما متوقفًا على حكم الآخر، أما إذا اشترط الإمام اجتماعهما على الحكم، فلا يجوز، لِمَا قد يقع بينهما من خلاف في الاجتهاد يؤدي إلى عدم الفصل في المنازعات.

وَصَرَّحَ ابن فرحون بعدم صحة عقد الولاية للحاكمين معًا على أن يجتمعا ويتفقا على الحكم في كُلِّ قضيةٍ إذا كان ذلك قد شُرِطَ في عقد ولايتهما، وعند الحنابلة وجهان:

الأول:

لا يجوز؛ لأن ذلك يؤدي إلى إيقاف الحكم والفصل في الخصومات؛ لأنهما قد يختلفان في الاجتهاد.

والثاني:

الجواز، إذا كانا لا يشتركان في قضية واحدة [١٨].

(١) القائل هو المؤلف، الإمام ابن رشد.

(٢) الأمي هو الشخص الذي لا علم له بالقراءة والكتابة.

يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ خَاصًّا بِهِ لِمَوْضِعِ الْعَجْزِ [١].

وَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِ حُكْمِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ، وَتَوْلِيَتُهُ لِلْقَاضِي شَرْطٌ فِي صِحّةِ قَضَائِهِ، لَا خِلَافَ أَعْرِفُ فِيهِ.

وَاخْتَلَفُوا مِنْ هَذَا الْبَابِ فِي نُفُوذِ حُكْمِ مَنْ رَضِيَهُ الْمُتَدَاعِيَانِ [٢] مِمّنْ لَيْسَ بوَالٍ عَلَى

---

(١) دليل الشافعية على عدم جواز كون الأمي أو العامي قاضيا: قوله تعالى ﴿وأن أحكم بينهم بما أنزل الله﴾ ولما روي أن النبي ﷺ قال: القضاة ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار، فأما الذي في الجنة، فرجل عرف الحق فحكم بـه، فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فجار في حكمه فهو في النار، ورجل قضى بين الناس على جهلٍ فهو في النار، والمقلد يقضي بجهل، ولأن الحكـم أكـبر مـن الفتيا، لأن المفتي لا يلـزم المستفتي ما يفتيه، فإذا لم يجز يكون المفتي عاميا، فلأن لا يجوز أن يكون القاضي عاميًا أولى.

(٢) إذا كان التحكيم يدخل في نطاق الجواز، فإن الفقهاء قد وضعوا شروطا للمحكم، لا يصح تحكيمه إلا بها، وهذه الشروط هي:

يشترط في المحكم أن يكون ممن توافرت فيه شروط القاضي، أما إذا كان غير أهلٍ لولاية القضاء، فلا تصح ولايته للتحكيم، ولا ينفذ حكمه، وهو ما ذهب إليه الشافعية، إلا أنهم استثنوا من ذلك التحكيم في النكاح فلا يشترط توافر أهلية القضاء.

ويرى الحنفية أنه لا يشترط في المحكم سوى أن يكون ما حكم فيه من الأمور تقبل فيها شهادته، ولذلك صح عندهم تحكيم المرأة بخلاف الأعمى والمحدود في قذف إذ إنهم لا يصلحون، ولأن الحكم في حق المحكمين بمنزلة القاضي، وكل من صلح شاهدًا صلح قاضيًا.

فالمعتبر عند الحنفية في أهلية الشهادة بالنسبة للحكم في حالتين: حالة التحكيم، ووقت الحكم، حتى إذا لم يكن من أهل الشهادة وقت التحكيم، ثم =

الْأَحْكَامِ، فَقَالَ مَالِكٌ: يَجُوزُ، وَقَالَ الشّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ: لَا يَجُوزُ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ إِذَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ قَاضِي الْبَلَدِ (١).

صار من أهلها وقت الحكم لا يصير حكمًا، ولا ينفذ حكمه، وكما لو كان شاهدًا وقت التحكيم، ثم زالت عنه أهلية الشهادة وقت الحكم لأي سببٍ من أسباب الزوال (١٩).

ويرى المالكية أن الشخص إذا كان من أهل القضاء جاز تحكيمه وكان أهلًا له، ويعد حكمه نافذًا إن جاء موافقًا لشرع الله، ولا يجوز نقض حكمه ما دام الطرفان قد رضيا به (٢٠).

(١) أشار المصنف في هذا النص إلى خلاف الفقهاء في مسألة التحكيم.

التحكيم في اللغة: التفويض، يقال: حاكمه إلى حاكم، أي: دعاه، وحكمت الرجل: فَوَّضْتُ إليه، ومن اختاره الطرفان للتحاكم إليه يسمى حَكَمًا، أو محكما، كما يسمى حاكمًا، ويسمى كلًّا من أطراف النزاع المحكم فيه محتكما.

وفي الاصطلاح: هو أن يحتكم طرفان إلى ثالث يختاراه برضاهما ليكون حاكمًا بينهما في دعواهما بدلًا من القاضي.

وقيل: التحكيم هو تولية الخصمين حاكمًا يحكم بينهما (٢١)

وأرى أن التعريف الأخير للتحكيم محل نظر؛ لأنه عَبَّرَ بقوله حاكمًا، والمحكم شرط فيه ألا يكون معينًا من قِبَلِ الإمام، وعلى فرض كونه حاكمًا، فإنه لا يُوَلَّى مِنْ قِبَلِ الخصمين؛ بل من قِبَلِ الإمام.

والتحكيم جائز، وقيل: لا يجوز، وقيل: جوازه مقيد بعدم وجود قاضٍ في البلد (٢٢).

ويفرق بين القضاء والتحكيم بأن القضاء من الولايات العامة، والتحكيم تولية خاصة من الخصمين فهو من القضاء إلا أنه أقل منه في الدرجة.

الْبَابُ الثّانِي

فِي مَعْرِفَةِ مَا يَقْضِي بِهِ

وَأَمّا فِيمَا يُحْكَمُ فَاتّفَقُوا أَنّ الْقَاضِيَ يَحْكُمُ فِي كُلّ شَيْءٍ مِنَ الْحُقُوقِ كَانَ حَقًّا لِلّهِ أَوْ حَقًّا لِلْآدَمِيّينَ [1] وَأَنّهُ نَائِبٌ عَنِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ فِي هَذَا الْمَعْنَى، وَأَنّهُ يَعْقِدُ الْأَنْكِحَةَ وَيُقَدّمُ الْأَوْصِيَاءَ.

وَهَلْ يُقَدّمُ الْأَئِمّةَ فِي الْمَسَاجِدِ الْجَامِعَةِ [2]؟ فِيهِ خِلَافٌ، وَكَذَلِكَ هَلْ يَسْتَخْلِفُ؟ فِيهِ

---

(١) أشار المصنف في هذا النص إلى نطاق حكم المحكم، وما يجوز له أن يحكم فيه:

وقد اتفق فقهاء الحنيفة والمالكية والشافعية على أنه لا يجوز التحكيم في الحدود التي وجبت حقا لله، ويرى بعض فقهاء الحنابلة جواز التحكيم في الحدود وغيرها.

أما التحكيم في القصاص: فيرى بعض الحنفية جواز التحكيم فيه ومنعه المالكية والبعض الآخر من الحنيفة، وللشافعية قولان أقواهما: عدم الجواز.

وعرض الماوردي الشافعي لهذه المسألة، وذكر أن الأحكام في التحكيم ثلاثة أقسام:

(١) قسم يجوز فيه التحكيم، وهو حقوق الأموال، وعقود المعاوضات وما يصح فيه العفو والإبراء.

(٢) قسم لا يجوز فيه التحكيم، وهو ما اختص القضاة بالإخبار عنه من حقوق الله تعالى والولايات على الأيتام، وارتفاع الحجر على مستحقيه.

(٣) قسم مختلف فيه، وهي الأنواع الأربعة التي ذكرها.

(٢) **القضاء في المسجد:**

اختلف الفقهاء في حكم القضاء في المسجد، وجاء خلافهم على قولين:

=

القول الأول:

يرى الحنفية، والمالكية، والحنابلة، والزيدية جواز القضاء في المسجد [٢٣].

القول الثاني:

يرى الشافعية، والإمامية أن جلوس القاضي للحكم في المسجد مكروه.

ويرى الماوردي أن القضاء في المسجد لا يكره في حالتين:

الأولى:

في تغليظ الأيمان إذا لزم تغليظها بالمكان والزمان، فإن رسول الله غلظ لعان العجلاني في مسجده.

الثانية:

أن يحضر القاضي للصلاة، فيتفق حضوره حضور خصمين إليه فلا يكره له تعجيل النظر بينهما فيه، فقد قضى رسول الله في المسجد على هذا الوجه، وكذلك قضى الأئمة من بعده، لأن حضورهم في المسجد لم يكن مقصورًا على القضاء فيه [٢٤].

أدلة القول الأول:

استدل جمهور الفقهاء على قولهم بجواز القضاء في المسجد بالأدلة الآتية:

أولًا: من الكتاب:

استدلوا بقوله تعالى: ﴿ وَهَلْ أَتَىٰكَ نَبَؤُا۟ ٱلْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا۟ ٱلْمِحْرَابَ ﴾ [٢٥].

وجه الدلالة:

دلت هذه الآية صراحةً على جواز القضاء في المسجد؛ حيث إن داود عليه السلام كان في محرابه، وهو أشرف مكان في داره، وكان قد أمر ألا يدخل عليه أحد في ذلك اليوم، فلم يشعر إلا بخصمين قد تسوروا المحراب ليسألانه عن شأنهما، وقصا عليه قصتهما، وطلبا منه الحكم بينهما ففعل.

وقيل: إن داود جَزَّأَ الدهر إلى أربعة أيام: يوم لنسائه، ويوم لقضائه، ويوم =

يخلوا فيه لعبادة ربه، ويوم لبنى إسرائيل يسألونه [٢٦].

ثانيا: من السنة:

أ - استدلوا بما روي أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ وَنَادَى: يَا كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ: يَا كَعْبُ قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ، قَالَ كَعْبٌ: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: قُمْ فَاقْضِهِ [٢٧].

وجه الدلالة:

إن النبي ﷺ قضى بينهما في المسجد، وليس أدل على جواز القضاء في المسجد من هذا الحديث.

ب – ما روي أن النبي ﷺ قضى بالرجم على رجل اعترف أمامه ثلاث مرات بالزنا، وكان ذلك في المسجد [٢٨]، فهذا دليل واضح على جواز القضاء في المسجد.

ثالثاً: الإجماع:

استدلوا بالإجماع فقالوا: إن القضاء في المسجد وقع من الصحابة رضي الله عنهم، فقد كان الخلفاء الأربعة يقضون في المسجد، ولم يخالفهم أحد من الصحابة، وكذلك كان شريح، والحسن البصري، والشعبي يقضون في المسجد.

قال الإمام مالك: "القضاء في المسجد من أمر الناس القديم، وهو الحق الصواب؛ لأنه يرضى فيه بالدون من المجلس، وهو أقرب على الناس في شهودهم، ويصل إليه الضعيف والمرأة" [٢٩].

رابعًا:

استدلوا بفعل الصحابة فيما ورد عنهم من وقائع، ومنها:

=

أ – ما روي عن الحسن البصري قال: دخلت المسجد فرأيت عثمان بن عفان، وقد ألقى رداءه على كومةٍ من الحصى ونام عليه، فأتاه سقاء بقربته ومعه خصم، فجلس عثمان وقضى بينهما [٣٠].

ب – ما روي أن علي بن أبى طالب كان يقضي في المسجد [٣١].

المناقشة:

نوقش قضاء النبي ﷺ في المسجد وكذلك قضاء أصحابه بأن ذلك كان عَرَضًا على سبيل الصدفة، ولم يكن قصدًا.

قال الماوردي: "وأما ما روي عن الصحابة من النظر فيه، فإنما كان نادرًا على الوجه الذي قدمناه" [٣٢].

وقال القاضي أبو الطيب الطبري: "إن ذلك كان يتفق في حكومة، ومثل ذك لا نكرهه، وإنما نكره أن يقصد المسجد ولم ينقل ذلك عنهم" [٣٣].

ويجاب عن ذلك بأن ما وقع من النبي ﷺ وأصحابه من القضاء في المسجد لم يكن من باب الصدفة؛ إذ لو كان صدفة لَبَيَّنَ النبي ﷺ أن هذا أمر عارض، والأصل خلافه.

خامسًا:

استدلوا بالقياس: حيث قاسوا القضاء في المسجد على قراءة القرآن على اعتبار أن القضاء قربةً إذا كان بالحق، فأشبه قراءة القرآن والمسجد من أفضل الأماكن التي تؤدى فيها القربات.

أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بكراهة القضاء في المسجد بالأدلة الآتية:

أ – استدلوا بما روي عن معاذ أن النَّبِيّ ﷺ قَالَ: جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ، وَخُصُومَاتِكُمْ، وَحُدُودَكُمْ، وَشِرَاءَكُمْ وَبَيْعَكُمْ، وَجَمِّرُوهَا يَوْمَ جَمْعِكُمْ، وَاجْعَلُوا عَلَى أَبْوَابِهَا مَطَاهِرَكُمْ [٣٤].

=

حيث نهى النبي ﷺ عن فصل الخصومات في المساجد، فكان القضاء في المسجد ممنوع شرعًا.

المناقشة:

يناقش هذا القول بأن غاية ما فيه أنه يزجر من رفع صوت الخصوم في المسجد، فإن القاضي إذا فعل ذلك تجنب الخصوم ما يشوش على المصلين من أصوات وغيرها، وقد أَنْزَلَ النبي ﷺ وفد ثقيف في المسجد وهم باقون على شركهم، وأَذِنَ للحبشة أن يلعبوا فيه بحرابهم، وكانوا يتناشدون فيه الأشعار، ومعلوم أن في هذه الأمور من التشويش على المصلين زيادةً على ما يحصل من قعود خصمين أو أكثر بين يدي الحاكم في المسجد مع ما هو معلوم من أن القضاء بالحق، هو من العمل بالشريعة وتبليغها إلى العباد، ونشر أحكامها بينهم، وفى ذلك من المصالح ما لا يخفى [٣٥].

ب - استدلوا بما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: لَا وَجَدْتَ، إِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا [٣٦].

حيث نهى الرسول ﷺ عن نشد الضالة في المسجد، لما يحدثه من تشويش، ولا شك أن القضاء في المسجد فيه تشويش يزيد على ما في نشد الضالة، فكان ممنوعًا.

ج - إنه قد يكون في الخصوم من لا يمكنه اللبث في المسجد، كالجنب والحائض، كما أن الخصوم يجرى بينهم التكاذب والشتائم فنزه المسجد عن ذلك [٣٧].

القول الراجح:

بعد عرض أقوال الفقهاء في مسألة القضاء في المسجد، وما اعتمد عليه كل قولٍ أرى أن القول بجواز القضاء في المسجد هو الأولى بالقبول؛ لأن المسجد في عهد رسول الله ﷺ كان يفصل فيه في أغلب المنازعات، ولكن هذا الجواز

=

خِلَافٌ فِي الْمَرَضِ وَالسَّفَرِ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ، وَلَيْسَ يَنْظُرُ فِي الْحَيَاةِ، وَلَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْوُلَاةِ، وَيَنْظُرُ فِي التَّحْجِيرِ عَلَى السُّفَهَاءِ عِنْدَ مَنْ يَرَى التَّحْجِيرَ عَلَيْهِمْ.

مشروط بعدم تعريض المسجد للمهانة والابتذال، وألا يؤدي هذا القضاء إلى أن يدخل المسجد من لا يجوز له دخوله، كالحائض والجنب والكافر.

وأرى أنه في عصرنا الحاضر لا داعي للقضاء في المساجد بعد ما خصصت أماكن للقضاء، وهي ساحات المحاكم، وبالتالي يمكن القول: إنه لا يجوز القضاء في المسجد في حال تخصيص مكان معين للقضاء، أما إذا لم يُخَصَّصْ مكان للقضاء فهنا يجوز القضاء في المسجد.

وَمِنْ فُرُوعِ هَذَا الْبَابِ: هَلْ مَا يَحْكُمُ فِيهِ الْحَاكِمُ يُحِلُّهُ لِلْمَحْكُومِ لَهُ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي نَفْسِهِ حَلَالًا؟ وَذَلِكَ أَنّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنّ حُكْمَ الْحَاكِمِ الظّاهِرِ الّذِي يَعْتَرِيهِ لَا يُحِلُّ حَرَامًا وَلَا يُحَرّمُ حَلَالًا، وَذَلِكَ فِي الْأَمْوَالِ خَاصّةً؛ لِقَوْلِهِ – عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسّلَامُ: إنّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إلَيّ، فَلَعَلّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا، فَإِنّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النّارِ [١].

(١) الحديث أخرجه البخاري، كتاب الشهادات، باب من أقام البينة بعد اليمين، برقم (٢٥٣٤)، ومسلم، كتاب الأقضية، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة، برقم (١٧٣).

الهوامش

(١) مغني المحتاج، ٢٦٢/٦، نهاية المحتاج، ٨/ ٢٣٨، أدب القضاء، لابن أبي الدم، ص ٧٤.

(٢) إعانة الطالبين، ٢٥٣/٤.

(٣) مواهب الجليل، ٩٩/٦، شرح الخرشي، ١٣٩/٧، حاشية الدسوقي، ١٣٠/٤، التاج والإكليل،٢٢١/٢، المنتقى، ١٨٣/٥.

(٤) الحاوي الكبير، للماوردي، ٦٣/٢٠.

(٥) أخرجه أبو داود، كتاب الأقضية، باب في كراهية الرشوة، برقم (٣٥٨٠) ٤٣٣/٥، والترمذي، كتاب أبواب الأحكام، باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم، برقم (١٣٣٦) ٦١٤/٣، وقال: حديث حسن.

(٦) البحر الرائق، ٢٨٤/٦.

(٧) الشرح الكبير، ١٩١/٤.

(٨) نيل الأوطار، للشوكاني، ٢٢٣/٨.

(٩) سورة النساء: من الآية رقم ٢٩.

(١٠) د/ إبراهيم صالح إبراهيم: نظام القضاء في الفقه الإسلامي، ص ١٩٧ وما بعدها.

(١١) سبق تخريجه.

(١٢) شرح فتح القدير، ٣٥٨/٦.

(١٣) البحر الرائق، ٣٨٥/٦.

(١٤) شرح فتح القدير، ٣٥٨/٦.

(١٥) روضة القضاة، ٨٨/١، البحر الرائق، لابن نجيم، ٢٨٤/٦، درر الحكام، ٤٠٤/٢.

(١٦) شرح فتح القدير، ٣٥٨/٦.

(١٧) المنتقى، ١٨٢/٥-١٨٣، التاج والإكليل، ٢٢٢/٢.

(١٨) حاشية الدسوقي، ١٣٤/٤ –١٣٥، معنى المحتاج، ٢٦٩/٦، كشاف القناع، ٢٩٢/٦ تبصرة الحكام، ٢٢/١ وما بعدها.

(١٩) المبسوط، ١١١/١٦، حاشية ابن عابدين، ٤٢٨/٥.

(٢٠) حاشية الدسوقي، ١٣٦/٤.

(٢١) المدخل الفقهي العام، د/ مصطفى الزرقا: طبعة دار الفكر، الطبعة التاسعة ١٩٦٨٠١٩٦٧ ١/٥٥٥، د / محمد سلام مدكور: القضاء في الإسلام، طبعة دار النهضة العربية، القاهرة. ص ١٣١، حاشية ابن عابدين، ١٢٥/٨.

(٢٢) حاشية ابن عابدين، ١٢٥/٨، الكافي في فقه الإمام مالك، ص ٥٠١، ٥٠٢، التاج والإكليل، ٢٢٣/٢، شرح الزرقاني على خليل، ١٢٩/٧، الإقناع، ٨٩/٥، حاشية الجمل على المنهج، ٣٣٩/٥، شرح منتهى الإرادات، ٤٥٦/٣، مغنى المحتاج، ٢٦٧/٦-٢٦٨.

(٢٣) البحر الرائق، ٣٠٣/٦، بدائع الصنائع، ١٣/٧، التاج والإكليل، ١٠٣/٨، ١٠٤ حاشية الدسوقي، ١٣٧/٤، المغني، ٩٦/١٠، السيل الجرار، ٢٨٩/٤.

(٢٤) حاشية قليوبي، ٣٠٣/٤، أسنى المطالب، ٢٩٧/٤، شرائع الإسلام، ٧٤/٤، الحاوي، ٣٠/١٦، ٣١.

(٢٥) سورة ص: الآية ٢١.

(٢٦) أحكام القرآن، للجصاص، ٥٦٠/٣.

(٢٧) أخرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب رفع الصوت في المساجد، برقم (٤٧١) ١٠١/١، ومسلم، كتاب المساقاة، باب استحباب الوضع من الدين، برقم (١٥٥٨) ١١٩٢/٣.

(٢٨) فتح الباري، ١٣٥/١٣.

(٢٩) شرح مختصر خليل، ١٤٨/٧، التاج والإكليل، ١٠٤/٨.

(٣٠) السنن الكبرى، للبيهقي، ٤٤٧/٢.

(٣١) السنن الكبرى ٢٦٠/١٠.

(٣٢) أدب القاضي، للماوردي، ٢٠٩/١.

(٣٣) المرجع السابق.

(٣٤) الحديث أخرجه ابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات، باب ما يكره في المساجد، برقم (٧٥٠) ٢٤٧/١، والبيهقي، كتاب المساجد، باب كراهة نشد الضالة في المسجد ١٠٣/١٠.

(٣٥) زاد المعاد، ٢٦/٣، السيل الجرار، ٢٨٩/٤وما بعدها.

(٣٦) الحديث أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهى عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد، برقم (٥٦٨) ٥٩/٣.

(٣٧) البيان، للعمراني، ٤٠٢/١٢.

الْبَابُ الثّالِثُ
فِيمَا يَكُونُ بِهِ الْقَضَاءُ
الْفَصْلُ الْأَوّلُ
فِي الشّهَادَةِ [١]

---

(١) **تعريف الشهادة:**

الشهادة في اللغة: تطلق الشهادة في اللغة على معانٍ متعددة منها [١]:

- العلم والبيان :كقول المؤذن "أشهد أن لا إله إلا الله" أي: أعلم أن لا إله إلا الله، وأبين أن لا إله إلا الله، وقوله "أشهد أن محمداً رسول الله" أي : أعلم وأبين أن محمدًا رسول الله، ومنه قوله تعالى ﴿شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ﴾ [٢] فمعنى شهد الله أي: قضى الله، وشهد فلان عند الحاكم، أي: بين ما يعلمه وأظهره .
- الحضور: قال: شهده شهود، أي: حضروه، فهو شاهد، وقوم شهود أي حضور، وهو في الأصل مصدر، قال تعالى ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [٢] أي: من حضر منكم شهر رمضان وهو مقيم غير مسافر فليصم ما حضر وأقام فيه [٣].
- الحلف: ومنه قولك: أشهد بكذا، أي : أحلف بكذا، وقولهم شهد بكذا أي حلف، ومنه قوله تعالى ﴿وَيَدْرَؤُاْ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ﴾ [٤].
- الإخبار: يقال: شهد بكذا، أي: أخبر به، وأدى ما علمه بالمعاينة أو السماع، ولذا تعدى بالباء، لأنه متضمن معنى أخبر فصار من معانى الشهادة الإخبار بما قد شوهد.

=

الشهادة في الاصطلاح الفقهي:

اختلف الفقهاء في تعريف الشهادة، وأعرض تعريف الشهادة في كل مذهبٍ على حدة على النحو التالى:

أولًا: المذهب الحنفي:

عرف فقهاء الأحناف الشهادة بتعريفاتٍ متعددة، أقتصر منها على ما يلى:

قيل: الشهادة هي إخبار صدقٍ لإثبات حقٍ بلفظ الشهادة في مجلس القضاء ولو بلا دعوى(٥).

ثانيًا: المذهب المالكي:

لدى المالكية في تعريف الشهادة تعريفات ثلاث:

التعريف الأول:

قال ابن عرفة: الشهادة قول هو بحيث يوجب على الحاكم سماعه الحكم بمقتضاه إن عدل قائله مع تعدده أو حلف طالبه (٦).

التعريف الثاني:

الشهادة: هي إخبار حاكمٍ عن علمٍ ليقضى بمقتضاه (٧).

عرف الشافعية الشهادة بتعريفات كثيرة أقتصر منها على تعريفين فقط:

الأول: الشهادة هي: إخبار عن شيء بلفظ أشهد (٨).

الثاني: الشهادة : هي إخبار عن شيء بلفظ خاص (٩).

رابعًا: المذهب الحنبلي:

الشهادة عند الحنابلة هي: الإخبار بما علمه بلفظ خاص" (١٠).

حكم الشهادة:

يختلف حكم الشهادة باختلاف ما إذا كان المقصود من الحكم هو الأثر المترتب عليها، أو كان المقصود حكمها من حيث التحمل والأداء:

=

فمن ناحية الأثر المترتب عليها:

فبمجرد ثبوت الشهادة وآدائها من الشاهد الذى توافرت فيه شروطها، وجب على القاضي الحكم بموجبها، ولا يجوز له التأخير، وإذا كان القياس يأبى جواز الحكم بالشهادة، لاحتمال الكذب، إلا أن هذا القياس لا ينبغي النظر إليه؛ لأن الفقهاء باشتراطهم العدالة في الشاهد ترجح عندهم جانب الصدق على جانب الكذب، وبالتالي وجب على القاضي الحكم بها على الفور، فلو امتنع القاضي من الحكم بعد ذلك أثم لتركه الفرض، واستحق العزل لأنه ارتكب ما يفسق به، ويعزر لأنه ارتكب ما لا يجوز له ارتكابه شرعا.

ومع ذلك فإنه يجوز للقاضي تأخير الحكم لأحد الأسباب الآتية:

١- أن تكون الدعوى بين الأقرباء، فيأمل القاضي حصول الصلح بينهما، وكذلك إذا رجى الصلح بين الخصوم من غير الأقارب.

٢- أن يدعي المدعى عليه أن لديه دفعا للدعوى، ويطلب الإمهال لإحضار بينته على الدفع، أو يطلب المدعي الإمهال لإحضار بينته على الدعوى.

٣- أن يكون لدى القاضي ريب وشبهة في الشهود.

٤- أن يكون القاضي بحاجةٍ للبحث عن الحكم في الكتب أو سؤال العلماء عنه[١١] .

أما من ناحية التحمل والأداء:

فقد اتفق جمهور الفقهاء على أن تحمل الشهادة وأدائها فرض من فروض الكفايات، إذا قام بها من يتحقق به الغرض، سقط الفرض عن الباقين، وإن امتنع الجميع أثموا جميعا، حيث إن الشهادة في هذه الحالة تصبح متعينة في حقهم، كما أن أداء الشهادة يعتبر من قبيل الأمانة للمشهود له في ذمة الشاهد والأمانة تقتضى الآداء [١٢] ويلزم الشاهد آداء الشهادة لله سبحانه وتعالى فيما عدا أسباب الحدود ، لقوله تعالى "وأقيموا الشهادة لله"، أما في آداء الشهادة المتعلقة بحقوق

=

العباد، فلا بد لوجوب الأداء أن يطلب المشهود له الشهادة، فإذا طلبها وجب على الشاهد أن يقوم بآدائها.

أما في حقوق الله تعالى وفيما عدا الحدود فيلزمه أن يؤديها حسبةً لله من غير طلب من أحد، وفي مسائل الحدود فهو مخير بين أن يشهد حسبة، وبين أن يستر، لأن كل واحدٍ منهما أمر مندوب إليه لقوله تعالى "وأقيموا الشهادة لله" وقوله ﷺ : "من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة" وقد ندب الشرع إلى كلا الأمرين، فإن شاء أداها حسبة، وإن شاء ستر على أخيه المسلم [١٣].

والستر في هذه الحالة أحب بدلالة قوله ﷺ للذي شهد عنده على ماعز: هلا سترته بثوبك، حيث إن المخاطب بالقول في هذا الحديث هو هزال، إذ إن ماعزًا أقر بالزنا ولم يشهد عليه أحد، والذي أشار عليه بالإقرار هو هزال، فلما قال النبي ﷺ ذلك لهزال قال: يا رسول الله: لم أدر أن في الأمر سعة ، ولا يعارض أفضلية الستر قوله تعالى " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " لأن الحدود لا مدعى فيها [١٤] .

ويجب التنبيه إلى أن الممتنع عن آداء الشهادة لا يلحقه الإثم إلا إذا كانت شهادته مفيدة ونافعة للمشهود له، ويصيبه ضرر في حالة عدم آدائها، أما إذا أصاب الشاهد ضرر من جراء شهادته فإنها تعتبر غير لازمة له.

الأدلة على تحمل الشهادة وآدائها :

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا۟﴾ [١٥].

وجه الدلالة:

في هذه الآية نهى الله تبارك وتعالى الشهود عن الامتناع عن أدء الشهادة، وقد تباينت أقوال المفسرين في هذه الآية على النحو التالي:

=

أولا:

يرى ابن عباس وقتادة والربيع بن أنس أن معنى الآية أن الشهداء لا يجوز لهم الامتناع عن تحمل الشهادة وأدائها وإثباتها في الكتاب، فإذا دعوا للتحمل وجبت عليهم الإجابة، ويكون الامتناع عن التحمل أو الإباء – على حد تعبير القرآن – مكروه من باب الكراهة التنزيهية؛ لأن التحمل فيه إعانة على حفظ حقوق المسلمين [١٦] .

ثانيا:

يرى مجاهد وسعيد بن جبير والسدي أن معنى الآية: لا يأب الشهداء عن آداء الشهادة إذا كانت قد حصلت عندهم بالتحمل ودعوا لآدائها، فيكون المراد نهي مسمى الشهداء عن الإباء أو الامتناع، والشهداء هم الذين اتصفوا بالشهادة، ولا اتصاف بالشهادة قبل الدعاء إليها إلا بالتحمل، فيلزم أن يكون النهي عن إباء الأداء مستعملًا في حقيقته [١٧].

وهذا القول غير مسلم؛ لأن الله سماهما شاهدين وأمر باستشهادهما قبل أن يستشهدا، حيث قال تعالى ﴿وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ﴾ [١٨] إذ أنه لا خلاف في أن حالة الابتداء مرادةً بهذا اللفظ كما في قوله تعالى "فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره" [١٩] فسماه الله عز وجل زوجاً قبل حصول الزواج، وإنما يلزم الشاهد في إثبات الشهادة ابتداءا، ويلزمه إقامتها على طريق الإيجاب إذا لم يوجد من يشهد غيره، وعلى هذا فإن النهي لا يقتصر على نهي الشهود عن الامتناع؛ بل يشمل معها حالة التحمل [٢٠] .

ثالثا:

يرى الحسن البصري وابن عباس في القول الآخر أن معنى الآية: لا يأب الشهداء عن تحمل الشهادة إذا حملوها، ولا يأبوا عن إقامتها إذا تحملوها [٢١].

قال القرطبي بعد ذكره أقوال العلماء في معنى هذه الآية: "وقد يستلوح من

=

هذه الآية دليل على أنه يجوز للإمام أن يقيم للناس شهودًا، ويجعل لهم من بيت المال كفايتهم، فلا يكون لهم شغل إلا تحمل حقوق الناس حفظًا لها، وإن لم يكن ذلك ضاعت الحقوق وبطلت، فيكون المعنى: ولا يأب الشهداء إذا أخذوا حقوقهم أن يجيبوا، فإن قيل: هذه شهادة بالأجر، قلنا: إنما هي شهادةً خالصةً من قومٍ استوفوا حقوقهم من بيت المال، وذلك كأرزاق القضاة والولاة، وجميع المصالح التي تعن للمسلمين، وهذه من جملتها" (٢٢).

وقال في موضع آخر: "قال ابن عطية: والآية كما قال الحسن جمعت بين أمرين على جهة الندب، فالمسلمون مندوبون إلى معونة إخوانهم، فإذا كانت الفسحة لكثرة الشهود، والأمن من تعطيل الحق، فالمدعو مندوب، وله أن يتخلف لأدنى عذر، وإن تخلف لغير عذر فلا إثم عليه ولا ثواب له، وإن كانت الضرورة وخيف تعطل الحق أدنى خوف قوى الندب وقرب من الوجوب، وإذا علم أن يذهب ويتلف بتأخر الشاهد عن الشهادة فواجب عليه القيام بها، لاسيما إن كانت محصلة وكان الدعاء إلى آدائها، فإن هذا الظرف آكد، لأنها قلادة في العنق تقتضى الآداء" (٢٣).

الدليل الثاني:

استدلوا بما روي عن زيد بن خالد الجهني أن النبي ﷺ قال: "ألا أخبركم بخير الشهداء، الذى يأتي بشهادته قبل أن يسألها" (٢٤).

وجه الدلالة:

ذكر النووي أن المراد بهذا الحديث تأويلان:

الأول:

وهو أصحها وأشهرها، وهو ما ذهب إليه مالك وأصحاب الشافعي، أنه محمول على من عنده شهادة لإنسان بحق ولا يعلم ذلك الإنسان أنه شاهد، فيأتي إليه فيخبره بأنه شاهد له.

=

وَالنَّظَرُ فِي الشُّهُودِ فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: فِي الصِّفَةِ، وَالْجِنْسِ، وَالْعَدَدِ.

فَأَمَّا عَدَدُ الصِّفَاتِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي قَبُولِ الشَّاهِدِ بِالْجُمْلَةِ فَهِيَ خَمْسَةٌ:

الْعَدَالَةُ وَالْبُلُوغُ (١) وَالْإِسْلَامُ وَالْحُرِّيَّةُ وَنَفْيُ التُّهْمَةِ، وَهَذِهِ مِنْهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا،

الثاني:

أنه محمول على شهادة الحسبة، وذلك في غير حقوق الآدميين المختصة بهم [٢٥].

(١) يعرف البلوغ بأحد الأشياء الآتية:

أولا: الاحتلام:

وهو ما يعبر عنه بخروج المني، فمتى خرج المني من ذكر الصبى، أو من قبل الصبية عُد كل منهما بالغا، يستوى في ذلك أن يكون نزول المني في النوم أو في اليقظة، وهذا الأمر محل اتفاق بين العلماء، من غير مخالفة من أي منهم، وحجتهم في ذلك قول الله تعالى: ﴿وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَٰلُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَـْٔذِنُوا۟﴾ [٢٦] وقول النبي ﷺ: رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبى حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل [٢٧].

ثانيا: الإنبات:

أي إنبات شعر العانة حول ذكر الرجل، وقبل المرأة، لما روى عن عطية القرظي قال: كنت من سبى بنى قريظة، فكانوا ينظرون فمن أنبت الشعر قتل، ومن لم ينبت لم يقتل فكنت فيمن لم ينبت.

ثالثا: السن:

وهو أمر مختلف فيه: فقال الشافعي، والصاحبان من الحنفية، وأحمد بن حنبل أن سن البلوغ للجارية والغلام إذا لم يحدث احتلام هو خمس عشرة سنة.

واستدلوا بما روى عن ابن عمر أن النبي ﷺ عرضه يوم أحد وهو ابن أربع

=

وَمِنْهَا مُخْتَلَفٌ فِيهَا.

أَمَّا الْعَدَالَةُ فَإِنّ الْمُسْلِمِينَ اتّفَقُوا عَلَى اشْتِرَاطِهَا فِي قَبُولِ شَهَادَةِ الشّاهِدِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ﴾ (البقرة: ٢٨٢) وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى

عشرة سنة، فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه [٢٨].

وقال ابن عبد البر: سن البلوغ هو خمس عشرة سنة لمن عرف موعد ولادته، أما من جهل وقت ولادته فهو إنما يحكم ببلوغه بإنبات شعر عانته، لما روى أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد: ألا تضربوا الجزية إلا على من جرت عليه المواسي [٢٩].

وقال الإمام مالك: لا حد للبلوغ من السن، واستدل بحديث النبي ﷺ الذى جاء فيه: .... وعن الصبى حتى يحتلم [٣٠].

ويرى أبو حنيفة أن الغلام يبلغ بتسع عشرة سنة، والجارية تبلغ لسبع عشرة سنة.

وقيل: إن أدنى المدة في حق الغلام اثنتا عشرة سنة، وفى حق الجارية تسع سنين، بحيث لو ادعى أحدهما البلوغ في هذه المدة قبل منه ذلك، ولا يقبل منه ما دون ذلك، لأن الظاهر يكذبه [٣١].

إضافة إلى ذلك فإن هناك أمران يختص بهما النساء في البلوغ وهذان الأمران هما:

- **الحيض**، فإذا حاضت الفتاة عدت بالغة، وتجرى عليها التكاليف الشرعية لما روى أن النبي ﷺ قال: لا يقبل الله صلاة حائضٍ إلا بخمار" [٣٢].
- **الحمل**، حيث عده الفقهاء دليلاً على بلوغ الجارية، إذ أن الولد يخلق من ماء الرجل وماء المرأة.

﴿وَأَشْهِدُواْ ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ (الطلاق: ٢)

وَاخْتَلَفُوا فِيمَا هِيَ الْعَدَالَةُ، فَقَالَ الْجُمْهُورُ :هِيَ صِفَةٌ زَائِدَةٌ عَلَى الْإِسْلَامِ [١]، هُوَ أَنْ يَكُونَ مُلْتَزِمًا لِوَاجِبَاتِ الشَّرْعِ وَمُسْتَحِبّاتِهِ، مُجْتَنِبًا لِلْمُحَرّمَاتِ وَالْمَكْرُوهَاتِ .وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ :يَكْفِي فِي الْعَدَالَةِ ظَاهِرُ الْإِسْلَامِ، وَأَنْ لَا تُعْلَمَ مِنْهُ جَرْحَةٌ [٢] .

---

(١) للعلماء في المعيار الذي تُقَاسُ به العدالة أقوال كثيرة، أقتصر منها على ما يلي:

- قال بعض الأحناف: إن العدل هو الذى لم يُطْعَنْ في بطنٍ ولا فرج.
- وقيل: إن العدل هو الذي لم تُعْرَفْ عليه جريمةٌ في دينه.
- وقيل: هو من اجتنب الكبائر، وَأَدَّى الفرائض، وغلبت حسناته سيئاته [٣٣].

وجاء في روضة القضاة: " إذا كانت أكثر أمور الإنسان حسنة، فهو عدل إذا لم يرتكب كبيرة، وإن كان قد ارتكب كبيرة وتاب وأصلح وقبلت شهادته في قول أبى يوسف، وقال غيره: إذا كان الرجل ملازمًا للجماعة، مؤديًا للفرائض، معروفًا بصدق المعاملة، مؤديًا للأمانة، صدوق اللسان فهو عدل " [٣٤].

(٢) اختلف الفقهاء في حد العدالة المشترطة في الشاهد، هل هي العدالة الباطنة، أم يكتفى بالعدالة الظاهرة، وانتهى خلافهم إلى قولين:

القول الأول:

يرى الحنفية أن المعول عليه في عدالة الشهود هو العدالة الظاهرة فقط، وهذه العدالة يكتفى فيها بكون الشاهد مسلمًا، أما العدالة الحقيقية التي تحتاج إلى تزكيةٍ فغير مشترطة، ولا يجوز للقاضي أن يسأل عن الشهود إلا في جرائم الحدود والقصاص، بشرط أن يطعن الخصم فيه [٣٥] .

=

القول الثاني:

يرى المالكية والشافعية والحنابلة أن القاضي ملزم بالسؤال عن الشاهد وتزكيته، سواء طعن فيه الخصم أو لم يطعن [٣٦].

أدلة القول الأول:

استدل أبو حنيفة على قوله بالاكتفاء بالعدالة الظاهرة في الشاهد التي هي الإسلام بالأدلة الآتية:

١- من الكتاب:

استدلوا بقوله تعالى: ﴿وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ﴾ [٣٧]، وقوله تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ﴾[٣٨].

وجه الدلالة :

في هاتين الآيتين دليل على الاكتفاء بالعدالة الظاهرة فقط، إذ في الآية الأولى لم يشترط المولى عز وجل أكثر من كون الشاهدين من رجالنا أي مسلمين، ولو كانت هناك شروط زائدة على ذلك لبينها .

وفى الآية الثانية وصف الله سبحانه وتعالى مؤمني هذه الأمة بالوساطة، وهي العدالة، وقال سيدنا عمر ﷺ عدول بعضهم على بعض، فصارت العدالة أصلا في المؤمنين، وزوالها بعارض، ولأن العدالة الحقيقية مما لا يمكن الوصول إليها فتعلق الحكم بالظاهر، وقد ظهرت عدالتهم قبل السؤال عن حالهم فيجب الاكتفاء به إلا أن يطعن الخصم؛ لأنه إذا طعن الخصم وهو صادق في الطعن فيقع التعارض بين الظاهرين، فلا بد من الترجيح بالسؤال، والسؤال في الحدود والقصاص طريق لدرئها، والحدود يحتال فيها للدرء [٣٩].

٢- استدلوا من السنة بما روى أن أعرابيًا جاء إلى رسول الله ﷺ فقال: إني رأيت الهلال، فقال رسول الله ﷺ: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم، قال: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم ، قال: يا بلال أذن في الناس فليصوموا.

=

وجه الدلالة :

إن النبي ﷺ قبل شهادة الأعرابي من غير أن يسأل عن عدالته، بل كل ما سأل عنه النبي ﷺ هو إسلام الأعرابي فقط، فلما علم إسلامه اكتفى بذلك، ولو لم يكن ذلك كافيًا ما فعله رسول الله ﷺ .

المناقشة:

ناقش ابن حزم الاستدلال بهذا الحديث بأن الحديث فيه سماك بن حرب، ورواية سماك لا نحتج بها ولا نقبلها منهم، وهم قد احتجوا بها في أخذ الدنانير من الدراهم، فيلزمهم أن يأخذوها هاهنا، وإلا فهم متلاعبون في الدين، فإن تعلق من فرق بين هلال رمضان وهلال شوال بهذين الخبرين، وقال: لم يرد إلا في هلال رمضان؟ قلنا: ولا جاء نص قط بالمنع من ذلك في هلال رمضان، وأنتم أصحاب قياس، فهلا قستم هلال شوال على هلال رمضان؟

فإن قالوا: إن الشاهد في هلال رمضان لا يجر إلى نفسه، والشاهد في هلال شوال يجر إلى نفسه؟ قلنا: فردوا بهذا الظن بعينه شهادة الشاهدين في شوال أيضا؛ لأنهما يجران إلى أنفسهما كما تفعلون في سائر الحقوق.

وأيضا: فإن من يكذب في مثل هذا لا يبالي قبل أو رد؟ ونقول لهم: إذا صمتم بشهادة واحد؛ فغم الهلال بعد الثلاثين، أتصومون أحدا وثلاثين؟ فهذه طامة، وشريعة ليست من دين الله تعالى أم تفطرون عند تمام الثلاثين، وإن لم تروا الهلال؟ فقد أفطرتم بشهادة واحد وتناقضتم [٤٠].

٤- استدل أبو حنيفة على مذهبه من المعقول فقال: إن العدالة الحقيقية لا يمكن الوصول إليها، لأنها أمر خفى سببه الخوف من الله تعالى، ودليل ذلك الإسلام، فإذا وجد يكتفى به، لأن القطع بالعدالة لا يحصل ولو مع الاستقصاء، ولذلك كان السلف الصالح يكتفون بظاهر العدالة، وأول من سأل عن عدالة الشهود هو ابن شبرمة.

=

فقد روى عنه أنه قال: أول من سأل في السر أنا ، كان الرجل يأتي القوم إذا قيل له: هات من يزكيك فيقول: قومي يزكونني، فيستحي القوم فيزكونه، فلما رأيت ذلك سألت في السر، فإذا صحت شهادته قلت: هات من يزكيك في العلانية [٤١] فدل اتفاق السلف على أن المعتبر هو العدالة الظاهرة فقط.

أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بضرورة سؤال القاضي عن الشهود بالأدلة الآتية:

١- استدلوا من الكتاب بقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا۟ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ [٤٢] وقوله تعالى: ﴿مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ﴾ [٤٣].

وجه الدلالة :

دلت الآية الأولى على أن غير العدل لا يجوز أن يكون شاهدا، إذ أن قوله "منكم" يفيد من المسلمين لا من غيرهم.

وفى الآية الثانية دليل على عدم الاكتفاء بالعدالة الظاهرة، حيث إن فيها تقييد من الله للحكام عن الاسترسال عن كل شاهد، وقصر القبول للشهادة على الرضى الذى له شمائل ينفرد بها، وفضائل يتحلى بها، تجعل له مزيةً على غيره توجب له رتبة الاختصاص بقبول قوله على غيره، ولا يعلم أن الشاهد مرضى قبل السؤال، ورضاء الحاكم بالشهود فرع عن معرفتهم.

٢- استدلوا بما روي عن عمر بن الخطاب ﷺ أنه شهد عنده رجل، فقال له عمر: لست أعرفك ولا يضرك ألا أعرفك، ائت بمن يعرفك، فقال رجل من القوم: أنا أعرفه، قال: بأي شيء تعرفه؟ قال: بالعدالة والفضل، فقال: هو جارك الأدنى الذي تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه؟ قال: لا، قال: فعاملك بالدينار والدرهم اللذين يستدل بهما على الورع؟ قال: لا، قال: فرفيقك في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال: لا، قال: لست تعرفه، ثم قال للرجل: ائت بمن يعرفه [٤٤].

=

وَسَبَبُ الْخِلَافِ كَمَا قُلْنَا تَرَدُّدُهُمْ فِي مَفْهُومِ اسْمِ الْعَدَالَةِ الْمُقَابِلَةِ لِلْفِسْقِ، وَذَلِكَ أَنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنّ شَهَادَةَ الْفَاسِقِ لَا تُقْبَلُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى} :يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا (الحجرات: ٦).

وَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنّ الْفَاسِقَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ إِذَا عُرِفَتْ تَوْبَتُهُ، إِلَّا إِنْ كَانَ فِسْقُهُ مِنْ قِبَلِ الْقَذْفِ، فَإِنّ أَبَا حَنِيفَةَ يَقُولُ :لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَإِنْ تَاب، وَالْجُمْهُورُ

وجه الدلالة:

إن عمر بن الخطاب لم يكتف بالعدالة الظاهرة في الشاهد؛ بل طلب المزيد لكي يتضح حال الشاهد، وبالتالي وجب عدم اعتبار العدالة الظاهرة والاكتفاء بها.

وكان ذلك بمحضر من الصحابة من غير إنكارٍ من أي منهم فكان إجماعًا على عدم الاكتفاء بالعدالة الظاهرة، ولو كان للعدالة الظاهرة أثر لسأل عمر الرجل عن إسلامه.

٤- استدلوا من المعقول فقالوا : إن القضاء يبنى على الحجة ، وهى شهادة العدول ، والعدالة قبل السؤال ثابتة بالظاهر وهو لا يصلح حجة للاستحقاق، فوجب التعرف عليها بسؤال القاضي عنها صيانة لقضائه عن البطلان ، ولإسناد الحكم إلى البرهان، لأن العدل مأخوذ من الاعتدال في الأقوال، والأفعال والاعتقاد، فهو وصف زائد على الإسلام وغير معلوم بمجرد الإسلام [٤٥].

الرأي الراجح:

هو القول بعدم الاكتفاء بالعدالة الظاهرة، فلا بد من السؤال والاستفسار عن الشاهد، لأن شهادته هذه يترتب عليها إثبات الحقوق وإسقاطها، وبالتالي وجب الاحتياط في ذلك.

يَقُولُونَ :تُقْبَلُ [١].

---

(١) **شهادة المحدود في قذف:**

اتفق الفقهاء على عدم قبول شهادة القاذف بعد الحد ولم يتب ولكنهم اختلفوا فيما إذا تاب القاذف بعد إقامة الحد عليه ، هل تقبل شهادته أم لا؟ وكان خلافهم على مذهبين:

المذهب الأول:

يرى جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة والإمامية والإباضية إلى قبول شهادة المحدود في القذف إذا تاب [٤٦].

المذهب الثاني:

يرى الحنفية والظاهرية أن المحدود في قذفٍ لا تقبل شهادته حتى ولو تاب [٤٧].

أدلة المذهب الأول:

استدل الجمهور على مذهبهم بقبول شهادة المحدود في قذف بعد التوبة بالأدلة الآتية:

١- استدلوا بقوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ وَأَصۡلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ﴾ [٤٨].

وجه الدلالة:

إن الآية صريحة في قبول التوبة منه، وبما أن عدم قبول شهادته كان عقاباً على جريمته، فالتوبة تسقط العقوبة وترفعها، وبالتالي جاز قبول شهادته بعدها.

٢- استدلوا من السنة بقول الرسول ﷺ: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له" [٤٩] .

=

وجه الدلالة:

إن الحديث أقر اعتبار التوبة مسقطةً للذنوب، وإذا سقط الذنب وجب أن يسقط ما ترتب عليه من عقوبة.

٣- القياس على من حد في غير القذف، فكما تقبل شهادته فكذلك المحدود في القذف، فقد روى أن شريحا أجاز شهادة أقطع من بني أسد، فقال: أتجيز شهادتي؟ قال: نعم، وأراك لذلك أهلا، وكان قد قطع في سرقة [٥٠].

المناقشة:

إن هذا القياس قياس مع الفارق، إذ المحدود في القذف يخالف المحدود في غيره، لأن التوقف في شهادة المحدود في غير القذف كان لفسقه، وقد زال ذلك بالتوبة، أما المحدود في القذف فإن رد الشهادة هنا من تمام الحد، ولا يجوز القياس هنا، إذ القياس لا مدخل له في مقادير الحدود، والزيادة على النص بالقياس لا تجوز [٥١].

أدلة المذهب الثاني:

استدل الحنفية على مذهبهم بما يأتي:

١- استدلوا بقوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ وَأَصۡلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ﴾ [٥٢] .

وجه الدلالة:

إن الله نهى عن قبول شهادة القاذف على التأبيد بقوله "ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً " فصار التخصيص دليلا على أنه يتناول زمان ما بعد التوبة، لأن المحدود في القذف لا يخرج بالتوبة من أن يكون محدوداً فيه، وعلى هذا فإن من قال بأن رد شهادته مؤقت إلى وجود التوبة يكون راداً لما اقتضاه النص، فيكون قوله مردودا، لأن قيد التأبيد لا فائدة له إلا بتأبيد رد الشهادة، وإلا لقال " ولا تقبلوا

=

لهم شهادة "وأولئك هم الفاسقون جملة مستأنفة لبيان تعليل عدم القبول، ثم استثنى الذين تابوا، وهذا لأن رد الشهادة على ذلك التقدير ليس إلا للفسق ويرفع التوبة، فلا معنى للتأبيد على تقدير قبول الشهادة بالتوبة، وبهذا يتبين أن المحدود في قذف مخصوص من عمومات الشهادة عملا بالنصوص كلها صيانة لها عن التناقض [٥٣].

المناقشة:

يناقش الاستدلال بهذه الآية بأنه غير مسلم؛ لأن معنى أبدا: ما دام قاذفا، كما يقال: لا تقبل شهادة الكافر أبدا، فإن معناه: ما دام كافرا، كما أن الله تعالى لم يذكر في كتابه ألا تقبل شهادة القاذف أبدا بعد الحد في رميه، بل نهى عن قبول شهادته في الحال التي وجبت عليه الحد فيها ، وسماه فيها فاسقا، وبالتالي فإن إقامة الحد عليه لا يحدث خللا في شهادته، بل الأحرى قبولها بعد توبته وإقامة الحد عليه [٥٤].

٢- استدلوا بقول النبي ﷺ في حديث عائشة: " لا تجوز شهادة خائنٍ ولا خائنة، ولا مجلود حدا، ولا ذي غمرٍ على أخيه، ولا مجربٍ بشهادة زور، ولا القانع أهل البيت، ولا ظنينٍ في ولاء ، ولا قرابة " [٥٥].

٣- استدلوا من المعقول بقولهم: إن القذف متضمن للجناية على حق الله تعالى وحق الآدمي، وهو من أوفى الجرائم، فناسب تغليظ الزجر ورد الشهادة أبدا من أقوى أسباب الزجر، لأنه مؤلم لقلب القاذف كما يؤلم الجلد بدنه، ففيه معنى الزجر، وعزل لولاية لسانه الذى تطاول به على عرض أخيه المسلم [٥٦].

المناقشة:

يناقش هذا الدليل بما يلى:

أولا:

تغليظ الزجر لا ضابط له، وقد حصلت مصلحة الزجر بالحد، وكذلك سائر

=

الجرائم جعل الشارع مصلحة الزجر عليها بالحد، وإلا فلا تطلق نساؤه، ولا يؤخذ ماله ولا يعزل عن منصبه، ولا تسقط روايته، لأنه أغلظ في الزجر، وقد أجمع المسلمون على قبول رواية أبي بكرة ﷺ.

ثانيا:

إن تغليظ الزجر من الأوصاف المنتشرة التي لا تنضبط، وقد حصل إيلام القلب والبدن والنكاية في النفس بالضرب الذي أخذ من ظهره.

ثالثا:

إن رد الشهادة لا ينزجر به أكثر القاذفين، وإنما يتأثر بذلك وينزجر أعيان الناس، وقل أن يوجد القذف من أحدهم، وإنما يوجد غالبا من الرعاع والسقط ومن لا يبالي برد شهادته وقبولها؛ وأيضا فكم من قاذفٍ انقضى عمره وما أدى شهادةً عند حاكم، ومصلحة الزجر إنما تكون بمنع النفوس ما هي محتاجة إليه، وهو كثير الوقوع منها، ثم هذه المناسبة التي ذكرتموها يعارضها ما هو أقوى منها؛ فإن رد الشهادة أبدا تلزم منه مفسدة فوات الحقوق على الغير وتعطيل الشهادة في محل الحاجة إليها، ولا يلزم مثل ذلك في القبول فإنه لا مفسدة فيه في حق الغير من عدلٍ تائب قد أصلح ما بينه وبين الله، ولا ريب أن اعتبار مصلحةٍ يلزم منها مفسدةٍ أولى من اعتبار مصلحةٍ يلزم منها عدة مفاسد في حق الشاهد وحق المشهود له وعليه، والشارع له تطلع إلى حفظ الحقوق على مستحقيها بكل طريقٍ وعدم إضاعتها، فكيف يبطل حقاً قد شهد به عدل مرضي مقبول الشهادة على رسول ﷺ وعلى دينه روايةً وفتوى [٥٧].

الرأي الراجح:

يترجح عندي في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من قبول شهادة المحدود في قذف بعد توبته، لأن رفع إثبات العقوبة إنما جاء بنص، وكذلك رفع =

وَسَبَبُ الْخِلَافِ هَلْ يَعُودُ الِاسْتِثْنَاءُ فِي قَوْله تَعَالَى} :وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ] (النور: ٤) [إلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ] (النور: ٥) [إِلَى أَقْرَبِ مَذْكُورٍ إِلَيْهِ، أَوْ عَلَى الْجُمْلَةِ إِلَّا مَا خَصّصَهُ الْإِجْمَاعُ، وَهُوَ أَنّ التّوْبَةَ لَا تُسْقِطُ عَنْهُ الْحَدّ، وَقَدْ تَقَدّمَ هَذَا.

وَأَمّا الْبُلُوغُ فَإِنّهُمْ اتّفَقُوا عَلَى أَنّهُ يُشْتَرَطُ حَيْثُ تُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ. وَاخْتَلَفُوا فِي شَهَادَةِ الصّبْيَانِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْجِرَاحِ وَفِي الْقَتْلِ، فَرَدّهَا جُمْهُورُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ؛ لِمَا قُلْنَاهُ مِنْ وُقُوعِ الْإِجْمَاعِ عَلَى أَنّ مِنْ شَرْطِ الشّهَادَةِ الْعَدَالَةَ.

العقوبة جاء هو الآخر بنص، كم أن الأخذ بهذا القول هو الذي يتفق وروح الشريعة التي مبناها على التسامح.

الهوامش

(١) لسان العرب، ٢٢٣/٧ وما بعدها، القاموس المحيط،٣١٧/١، تاج العروس،٣٩١/٢، المصباح المنير،٣٤٨/١، الصحاح في اللغة، ٦٩٠/١.

(٢) سورة آل عمران: من الآية ١٨ .

(٣) المصباح المنير،٣٤٨/١، الصحاح في اللغة، ٦٩٠/١.

(٤) سورة النور: الآية ٨.

(٥) حاشية ابن عابدين، ٤٦٢/٥ .

(٦) مواهب الجليل، للحطاب، ١٥١/٦، شرح الخرشي على مختصر خليل، ١٧٥/٧.

(٧) حاشية الدسوقي، ١٦٤/٤.

(٨) تحفة المحتاج، ٢١١/١٠.

(٩) نهاية المحتاج ، ٢٩٢/٨.

(١٠) كشاف القناع ، ٤٠٤/٦ .

(١١) رد المحتار، ٤٦٣/٥ .

(١٢) المغنى ، لابن قدامة، ١٥٤/١٠ وما بعدها، كشاف القناع، ٤٠٤/٦، تبيين الحقائق ، ٢٠٧/٤، نهاية المحتاج ، ٢٩٢/٨، قليوبي ، ٣٣٠/٤، تبصرة الحكام، لابن فرحون، ١/ ١٧٥.

(١٣) بدائع الصنائع ، ٢٨٢/٦ .

(١٤) البحر الرائق، ٥٩/٧ .

(١٥) سورة البقرة: من الآية ٢٨٢.

(١٦) أحكام القرآن، لابن العربي، ٢٥٦/١، تفسير ابن كثير، ٣٣٥/١ .

(١٧) أحكام القرآن، لابن العربي، ٢٥٦/١، المبسوط، ١٧٧/١٦ .

(١٨) سورة البقرة: من الآية ٢٨٢.

(١٩) سورة البقرة: من الآية ٢٣٠.

(٢٠) أحكام القرآن، للجصاص، ٥٢٠/١ .

(٢١) المحلى ، لابن حزم،٦٣٠/١٠ وما بعدها، تفسير ابن كثير، ٣٣٦/١ .

(٢٢) تفسير القرطبى،٦٣٢/٢ .

(٢٣) تفسير القرطبى، ٦٣٢/٢ .

(٢٤) أخرجه مسلم، كتاب الأقضية، باب خير الشهود، ١٣٤٤/٣ .

(٢٥) شرح النووي على صحيح مسلم ، ١٧/١٢ .

(٢٦) سورة النور: من الآية ٥٩.

(٢٧) الحديث أخرجه الترمذي، كتاب الحدود، ٣٢/٤ .

(٢٨) الحديث أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الخندق، ١٥٠٤/٤.

(٢٩) الحديث سبق تخريجه.

(٣٠) الحديث سبق تخريجه.

(٣١) يراجع في تفصيل ذلك: المغنى، لابن قدامة، ١٨٢/١٠.

(٣٢) السنن الكبرى، للبيهقي ، ٢٣٣/٣.

(٣٣) بدائع الصنائع، ٢٦٨/٦.

(٣٤) روضة القضاة، للسمناني، ٢٣٤/٤.

(٣٥) البحر الرائق، ٦/٥، العناية، ٢٦٦/٧.

(٣٦) منح الجليل، ٤٠٧/٨ ، المغنى، ٢٧٧/١٠، كشاف القناع، ٤٤١/٥، أسنى المطالب، ٣١٥/٤، تحفة المحتاج، ١٧٧/٥ .

(٣٧) سورة البقرة: من الآية ٢٨٢.

(٣٨) سورة البقرة: من لآية ١٤٣.

(٣٩) بدائع الصنائع، ٢٧٠/٦ .

(٤٠) المحلى، ٣٧٦/٤ .

(٤١) أحكام القرآن، للجصاص، ٦٩١/١، بدائع الصنائع، ٢٧١/٦ .

(٤٢) سورة الطلاق: من الآية.

(٤٣) سورة البقرة: من الآية ٢٨٢.

(٤٤) سبل السلام، ١٢٩/٤ .

(٤٥) المبسوط، ١١٣/١٦ .

(٤٦) منح الجليل، ٤٣٩/٨، الأم ، ٢٢٥/٦، الإنصاف، ٥٩/١٢، شرائع الإسلام، ١١٦/٤ ، شرح النيل، ١٢٨/١٣.

(٤٧) أحكام القرآن، للجصاص، ٤١٠/٣، تبيين الحقائق، ٢١٩/٤ .

(٤٨) سورة النور: الآيتان ٤، ٥.

(٤٩) فتح الباري، ٧٣٤/١٣، السنن الكبرى، للبيهقي، ١٥٤/١٠.

(٥٠) المبسوط، ١٢٢/١٦.

(٥١) المبسوط، ١٢٢/١٦.

(٥٢) سورة النور: الآيتان ٤، ٥.

(٥٣) شرح العناية، ٤٠٠/٧، المبسوط، ١٢٢/١٦.

(٥٤) تفسير الطبري، ٨٠/١٨ .

(٥٥) الحديث سبق تخريجه.

(٥٦) إعلام الموقعين، ٩٨/١.

(٥٧) إعلام الموقعين، ٩٨/١.

وَأَمّا الْإِسْلَامُ فَاتّفَقُوا عَلَى أَنّهُ شَرْطٌ فِي الْقَبُولِ، وَأَنّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْكَافِرِ، إلّا مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْ جَوَازِ ذَلِكَ فِي الْوَصِيّةِ فِي السّفَرِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَٰدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ (المائدة: ١٠٦).

فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ :يَجُوزُ ذَلِكَ عَلَى الشُّرُوطِ الّتِي ذَكَرَهَا اللّهُ تَعَالَى، وَقَالَ مَالِكٌ وَالشّافِعِيُّ :لَا يَجُوزُ ذَلِكَ، وَرَأَوْا أَنّ الْآيَةَ مَنْسُوخَة.

وَأَمّا الْحُرّيّةُ فَإِنّ جُمْهُورَ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ عَلَى اشْتِرَاطِهَا فِي قَبُولِ الشّهَادَةِ، وَقَالَ أَهْلُ الظّاهِرِ: [1] تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ؛ لِأَنّ الْأَصْلَ إنّمَا هُوَ اشْتِرَاطُ الْعَدَالَةِ، وَالْعُبُودِيّةُ لَيْسَ لَهَا تَأْثِيرٌ فِي الرّدِّ، إلّا أَنْ يَثْبُتَ ذَلِكَ مِنْ كِتَابِ اللّهِ أَوْ سُنّةٍ أَوْ إجْمَاعٍ. وَكَأَنّ الْجُمْهُورَ رَأَوْا أَنّ الْعُبُودِيّةَ أَثَرٌ مِنْ أَثَرِ الْكُفْرِ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ لَهَا تَأْثِيرٌ فِي رَدِّ الشّهَادَة

وَأَمّا التُّهْمَةُ الّتِي سَبَبُهَا الْمَحَبّةُ فَإِنّ الْعُلَمَاءَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنّهَا مُؤَثّرَةٌ فِي إسْقَاطِ الشّهَادَةِ.

---

(١) فقهاء من أهل السُّنَّة يأخذون بظاهر النصوص، وينفون القياس، وينتسبون إلى داوود الظاهري، ومن أبرزهم ابن حزم الظاهري.

الهوامش

(١) المغني، ١٠/١٨٠، الإنصاف، ١٢/٣٩، إعلام الموقعين، ١/٧١.

(٢) تبيين الحقائق، ٤/٢٢٤، المدونة، ٤/٣٥٦، حاشية الدسوقي، ٤/١٧٢، أسنى المطالب، ٤/٣٨١، المغنى، ١٠/١٨٠.

(٣) سورة المائدة: الآية ١٠٦.

(٤) الطرق الحكمية، ص ١٨٨.

(٥) المحلى، ١٠/٥٩٣.

(٦) الطرق الحكمية، لابن القيم، ص ١٨٨.

(٧) تفسير ابن كثير، ٢/١٢١.

(٨) الحديث أخرجه الترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب من سورة المائدة، ٥/٢٥٩.

(٩) فتح الباري، ٥/٤١٢.

(١٠) فتح الباري، ٥/٤١٢.

(١١) تفسير الفخر الرازي، ١٢/١١٦.

(١٢) سورة البقرة: الآية ٢٨٢.

(١٣) تفسير القرطبي، ٣/٣٤٠، أحكام القرآن، للجصاص، ٢/٢٠٥.

(١٤) تفسير الفخر الرازي، ٢/٨٦، ٨٧.

(١٥) سورة الطلاق: من الآية ٢.

(١٦) يراجع بتصرف: فتح القدير، للشوكاني، ٢/٨٦، تفسير ابن كثير، ٢/١٢٠، الطرق الحكمية، لابن القيم، ص ١٨٦،المحلى لابن حزم، ١٠/٥٨٩.

(١٧) سورة المائدة: الآية ١٠٦.

(١٨) الطرق الحكمية، لابن القيم، ص ١٨٦.

(١٩) سورة المائدة: الآية ١٠٧.

(٢٠) سورة البقرة: من الآية ٢٨٣.

(٢١) يراجع في بيان هذه الاعتراضات وغيرها، المغني،١٠/١٨١ وما بعدها، الطرق الحكمية، ص١٨٧.

(٢٢) الحديث أخرجه البخاري، كتاب الشهادات، باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة، ٢/٩٥٣.

(٢٣) المرجع السابق.

(٢٤) مغني المحتاج، ٤٢٧/٤، المغني، لابن قدامة، ١٨٢/١٠.

(٢٥) المغني، لابن قدامة، ١٨٩/١٠، الإنصاف، ١٦٠/٣.

(٢٦) الطرق الحكمية، ص ١٣٩.

(٢٧) بدائع الصنائع، ٢٦٧/٦، المدونة، ٥٤١/٤، تحفة المحتاج، ٢٤٠/١٠، المغني، ١٨٩/١٠.

(٢٨) الطرق الحكمية، ص ١٤٠.

(٢٩) سورة النساء: من الآية ١٣٥.

(٣٠) سورة البقرة: من الآية ٢٨٢.

(٣١) سورة الطلاق: من الآية ٢.

(٣٢) تفسير القرطبي،٥٣١/٢.

(٣٣) سورة البينة: الآيتان رقم ٧، ٨.

(٣٤) الطرق الحكمية، ص ١٤٠.

(٣٥) الطرق الحكمية، ص ١٦٧، المحلى، ٦٠٠/١٠.

(٣٦) أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب الرحلة في المسألة النازلة، ٤٥/١.

(٣٧) فتح الباري، ٢٣١/١.

(٣٨) المسند، ٧/٤، ويراجع المناقشة والرد عليها في فتح الباري، ٢٣١/١.

(٣٩) يراجع في هذه الآثار: الطرق الحكمية، ص ١٤٢.

(٤٠) إعلام الموقعين، ٦١/٢، المغني، ١٨٩/١٠.

(٤١) الطرق الحكمية، ص ١٤١.

(٤٢) الطرق الحكمية، لابن القيم، ص ١٦٧.

(٤٣) سورة النحل: الآية ٧٥.

(٤٤) المحلى، ٦٠٢/١٠.

(٤٥) أحكام القرآن، للجصاص، ٤٩٥/١وما بعدها.

(٤٦) تفسير القرطبي، ٥٣١/٢.

(٤٧) سورة البقرة: الآية ٢٨٢.

(٤٨) أحكام القرآن، للجصاص، ٦٧٤/١ وما بعدها.

(٤٩) الطرق الحكمية، ص ١٤٣.

(٥٠) أحكام القرآن، للجصاص، ٦٤٧/١.

(٥١) شرح فتح القدير، ٣٩٩/٧.

(٥٢) الطرق الحكمية، ص ١٤٣.

وَاخْتَلَفُوا فِي رَدِّ شَهَادَةِ الْعَدْلِ بِالتُّهْمَةِ لِمَوْضِعِ الْمَحَبَّةِ أَوِ الْبِغْضَةِ الَّتِي سَبَبُهَا الْعَدَاوَةُ الدُّنْيَوِيَّةُ، فَقَالَ بِرَدِّهَا فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ، إِلَّا أَنَّهُمُ اتَّفَقُوا فِي مَوَاضِعَ عَلَى إِعْمَالِ التُّهْمَةِ، وَفِي مَوَاضِعَ عَلَى إِسْقَاطِهَا، وَفِي مَوَاضِعَ اخْتَلَفُوا فِيهَا فَأَعْمَلَهَا بَعْضُهُمْ وَأَسْقَطَهَا بَعْضُهُمْ.

فَمِمَّا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ رَدُّ شَهَادَةِ الْأَبِ لِابْنِهِ وَالِابْنِ لِأَبِيهِ [1]، وَكَذَلِكَ الْأُمُّ لِابْنِهَا، وَابْنُهَا

---

(١) **شهادة الوالد لولده:**

اختلف الفقهاء في حكم قبول شهادة الوالد لولده والعكس على مذهبين:

المذهب الأول:

يرى جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة إلى عدم قبول شهادة الوالد لولده والعكس [1].

المذهب الثاني:

يرى ابن حزم الظاهري، وابن القيم، والرواية الثانية عند الحنابلة جواز شهادة الوالد لولده والعكس [2].

أدلة المذهب الأول:

استدلوا من السنة بأحاديث كثيرة منها:

أ – ما روي عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: لا تقبل شهادة خائنٍ ولا خائنة، ولا ذي غمرةٍ على أخيه المسلم، ولا شهادة الولد لوالده، ولا شهادة الولد لوالده" [3].

ب - روي أن الحسن شهد لعلي رضي الله عنهما مع قنبر عند شريح رحمه الله بدرعٍ له قال شريح رحمه الله: ائت بشاهدٍ آخر فقال علي ﷺ مكان الحسن، أو مكان قنبر قال لا، بل مكان الحسن ﷺ، قال علي ﷺ أما سمعت رسول الله ﷺ يقول للحسن والحسين: هما سيدا شباب أهل الجنة، فقال قد سمعت، ولكن

=

ائت بشاهدٍ آخر، فعزله عن القضاء، ثم أعاده عليه وزاد في رزقه [٤].

وجه الدلالة:

دل هذان الحديثان على أنه كان ظاهراً فيما بينهم أن شهادة الولد لوالده لا تقبل إلا أنه وقع لعليٍ ﷺ في الابتداء أن للحسن ﷺ خصوصيةً في ذلك لما خصه به رسول الله ﷺ من السيادة، ووقع عند شريح رحمه الله أن السبب المانع وهو الولادة قائم في حقه، ولا طريق لمعرفة الصدق والكذب حقيقةً في حق من هو غير معصوم عن الكذب، فيبني الحكم على السبب الظاهر، وهو كما وقع عند شريح رحمه الله، وإليه رجع علي ﷺ، والمعنى فيه تمكن تهمة الكذب، فإن العدالة تدل على رجحان جانب الصدق عند استواء الخصمين في حقه ولا تدل على ذلك عند عدم الاستواء [٥].

المناقشة:

نوقش الحديث الأول بأن فيه مقال؛ لأنه مروي عن يزيد وهو مجهول، فإن كان المراد هو يزيد بن سنان فهو كذاب، وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي، ويزيد يضعف في الحديث، ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه [٦].

الجواب:

يجاب عن ذلك بأنه قد جاء نص صريح عن رسول الله ﷺ بعدم قبول شهادة الوالد لولده، وهو حديث عائشة أن النبي ﷺ قال: لا تقبل شهادة الولد لوالده، ولا شهادة الوالد لولده، ولا المرأة لزوجها، ولا الزوج لامرأته، ولا العبد لسيده، ولا المولى لعبده، ولا الأجير لمن استأجره [٧].

ج – ما رواه مسلم بسنده عن عبد الله بن عبيد الله بن أبى مليكة أن المسور بن مخرمة حدثه أنه سمع رسول الله ﷺ على المنبر وهو يقول: إن بنى هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علىَ بن أبى طالب، فلا آذن لهم، ثم لا آذن

=

لهم ، إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما فاطمة بضعة منى، يريبني ما رابها، ويؤذيني ما آذاها [٨].

وجه الدلالة:

إن النبي ﷺ أخبر أن فاطمة بضعة منه، ومعنى ذلك أنها جزء منه، فكانت بمنزلة نفسه، وما دامت لا تقبل شهادة الرجل لنفسه، فكذلك لا تجوز شهادة الوالد لولده، على اعتبار أنه منه.

المناقشة:

ناقش ابن القيم هذا الاستلال قائلا: وأما حجتكم على المنع فمدارها على البعضية التي بين الأب وابنه، وأنها توجب أن تكون شهادة أحدهما للآخر شهادة لنفسه، وهذه حجة ضعيفة؛ فإن هذه البعضية لا توجب أن تكون كبعضه في الأحكام، لا في أحكام الدنيا ولا في أحكام الثواب والعقاب؛ فلا يلزم من وجوب شيءٍ على أحدهما أو تحريمه وجوبه على الآخر وتحريمه من جهة كونه بعضه، ولا من وجوب الحد على أحدهما وجوبه على الآخر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجني والد على ولده، فلا يجنى عليه، ولا يعاقب بذنبه، ولا يثاب بحسناته، ولا تجب عليه الزكاة ولا الحج بغنى الآخر، ثم قد أجمع الناس على صحة بيعه منه وإجارته ومضاربته ومشاركته، فلو امتنعت شهادته له لكونه جزئه فيكون شاهدا لنفسه، لامتنعت هذه العقود، إذ يكون عاقداً لها مع نفسه [٩].

د – استدلوا بقول النبي ﷺ: أنت ومالك لأبيك [١٠].

وجه الدلالة:

إن النبي ﷺ جعل الابن وما في ملكه ملك لأبيه، وبالتالي لا تجوز شهادته له.

=

المناقشة:

ناقش ابن حزم الاستدلال بهذا الحديث بقوله: ليس فيه منع من قبول شهادة الابن لأبويه، ولا من قبول الأبوين له، وإن كان هو وماله لهما فكان ماذا؟ ونحن كلنا لله تعالى وأموالنا، وقد أمرنا بأن نشهد له عز وجل، فقال عز وجل: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وكل ذي حقٍ فهو مأمور بأخذ حقه ممن هو له عنده متى قدر على ذلك أجنبيا كان أو غير أجنبي، ومن لم يفعل ذلك فقد عصى الله عز وجل وأعان على الإثم والعدوان وقدر على تغيير منكر فلم يفعل بل أقر المنكر والباطل والحرام، ولم يغير شيئا من ذلك [١١].

أدلة المذهب الثاني:

استدل القائلون بعدم جواز قبول شهادة الوالد لولده والعكس بما يلي:

أ – استدلوا بقوله تعالى: ﴿أَنِ ٱشْكُرْ لِى وَلِوَٰلِدَيْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ﴾ [١٢] وقوله تعالى: ﴿وَٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًٔا ۖ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنۢبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾ [١٣] .

وجه الدلالة:

في الآية الأولى أمر الله عز وجل بشكر الوالدين، ومن أعظم الشكر لهما الشهادة لهما بالحق [١٤].

وفى الآية الثانية سوى الله عز وجل بين جميع من ذكرهم في الآية في وجوب الإحسان إليهم، فيلزم من ذلك إذا قلنا بعدم قبول شهادة الوالد لولده أن لا تجوز شهادة أحد من هؤلاء، وما دامت شهادة هؤلاء مقبولة، فكذلك شهادة الوالدين لفرعهما والأولاد لأصلهما.

ب – استدلوا بقول الله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ﴾ [١٥] .

=

وجه الدلالة:

إن الله أمر بالشهادة عليهم، ولو لم تكن مقبولة لما أمر بها، ولأنها إنما ردت للتهمة في إيصال النفع، ولا تهمة في شهادته عليه، فوجب أن تقبل، كشهادة الأجنبي، بل أولى، فإن شهادته لنفسه لما ردت للتهمة في إيصال النفع إلى نفسه، كان إقراره عليه مقبولا [١٦].

ج – استدلوا من الأثر بما يلي:

- قال عمر بن الخطاب ﷺ: تجوز شهادة الوالد لولده، والولد لوالده، والأخ لأخيه .

- وقال ابن وهب: حدثنا يونس عن الزهري قال: لم يكن يتهم سلف المسلمين الصالح في شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده، ولا الأخ لأخيه، ولا الزوج لامرأته، ثم دخل الناس بعد ذلك فظهرت منهم أمور حملت الولاة على اتهامهم فتركت شهادة من يتهم إذا كانت من قرابة، وصار ذلك من الولد والوالد والأخ والزوج والمرأة، لم يتهم إلا هؤلاء في آخر الزمان.

- وقال أبو عبيد: حدثني الحسن بن عازب عن جده شبيب بن غرقدة قال: كنت جالسا عند شريح، فأتاه علي بن كاهل وامرأة وخصم، فشهد لها علي بن كاهل وهو زوجها، وشهد لها أبوها، فأجاز شريح شهادتهما، فقال الخصم: هذا أبوها وهذا زوجها، فقال له شريح: أتعلم شيئا تجرح به شهادتهما؟ كل مسلم شهادته جائزة.

- وقال عبد الرزاق: حدثنا سفيان بن عيينة عن شبيب بن غرقدة قال: سمعت شريحا أجاز لامرأة شهادة أبيها وزوجها، فقال له الرجل: إنه أبوها وزوجها، وقال شريح: فمن يشهد للمرأة إلا أبوها وزوجها ؟.

- وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن سليمان قال: شهدت لأمي عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، فقضى بشهادتي.

=

لَهَا. وَمِمّا اخْتَلَفُوا فِي تَأْثِيرِ التُّهْمَةِ فِي شَهَادَتِهِمْ شَهَادَةُ الزّوْجَيْنِ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ، فَإِنّ مَالِكًا رَدّهَا وَأَبَا حَنِيفَةَ، وَأَجَازَهَا الشّافِعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ، وَالْحَسَنُ .وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى :تُقْبَلُ شَهَادَةُ الزّوْجِ لِزَوْجِهِ، وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهَا لَهُ، وَبِهِ قَالَ النّخَعِيُّ.

وَمِمّا اتّفَقُوا عَلَى إِسْقَاطِ التُّهْمَةِ فِيهِ شَهَادَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ مَا لَمْ يَدْفَعْ بِذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ عَارًا عَلَى مَا قَالَ مَالِكٌ، وَمَا لَمْ يَكُنْ مُنْقَطِعًا إِلَى أَخِيهِ يَنَالُهُ بِرُّهُ وَصِلَتُهُ، مَا عَدَا الْأَوْزَاعِيّ فَإِنّهُ قَالَ :لَا تَجُوزُ. وَمِنْ هَذَا الْبَابِ اخْتِلَافُهُمْ فِي قَبُولِ شَهَادَةِ الْعَدُوّ عَلَى عَدُوّهِ، فَقَالَ مَالِكٌ وَالشّافِعِيُّ :لَا تُقْبَلُ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ :تُقْبَلُ.

فَعُمْدَةُ الْجُمْهُورِ فِي رَدِّ الشّهَادَةِ بِالتُّهْمَةِ مَا رُوِيَ عَنْهُ – عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسّلَامُ - أَنّهُ

– وقال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري قال: أجاز عمر بن عبد العزيز شهادة الابن لأبيه إذا كان عدل [١٧].

فهذه الآثار تدل على جواز شهادة الوالد لولده وقبولها.

المناقشة:

يمكن أن يناقش قضاء شريح بأن فيه تناقض، إذ قد روى أن شريح رد شهادة الحسن بن على حين شهد مع قنبر لعلى بن أبى طالب، وقال: أما سمعت رسول الله ﷺ قال للحسن والحسين: هما سيدا شباب أهل الجنة ..... إلخ [١٨].

الرأي الراجح:

بعد عرض الآراء وما اعتمد عليه كل فريق فإنه يترجح عندي القول بعدم قبول شهادة الوالد لولده والعكس، نظرا لما تؤدى إليه من تهمة، قد تؤثر على الحكم المقضي به، وحرصا على إقامة العدل بين المتقاضيين.

قَالَ : لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ (١) ، وَمَا خَرّجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ قَوْلِهِ – عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسّلَامُ :لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى حَضَرِيٍّ (٢) ؛ لِقِلّةِ شُهُودِ الْبَدَوِيّ مَا يَقَعُ فِي الْمِصْرِ. فَهَذِهِ هِيَ عُمْدَتُهُمْ مِنْ طَرِيقِ السّمَاعِ.

وَأَمّا مِنْ طَرِيقِ الْمَعْنَى فَلِمَوْضِعِ التُّهْمَةِ، وَقَدْ أَجْمَعَ الْجُمْهُورُ عَلَى أَنّ تَأْثِيرَهَا فِي الْأَحْكَامِ الشّرْعِيّةِ مِثْلُ اجْتِمَاعِهِمْ عَلَى أَنّهُ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ الْمَقْتُولَ، وَعَلَى تَوْرِيثِ الْمَبْتُوتَةِ فِي الْمَرَضِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ خِلَافٌ.

وَأَمّا الطّائِفَةُ الثّانِيَةُ، وَهُمْ شُرَيْحٌ وَأَبُو ثَوْرٍ، وَدَاوُدُ – فَإِنّهُمْ قَالُوا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَبِ لِابْنِهِ فَضْلًا عَمّنْ سِوَاهُ إذَا كَانَ الْأَبُ عَدْلًا .وَعُمْدَتُهُمْ قَوْله تَعَالَى} : ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَۚ﴾ (النساء: ١٣٥) وَالْأَمْرُ بِالشّيْءِ يَقْتَضِي إجْزَاءَ الْمَأْمُورِ بِهِ إلّا مَا خَصّصَهُ الْإِجْمَاعُ مِنْ شَهَادَةِ الْمَرْءِ لِنَفْسِهِ.

---

(١) مصنف عبد الرزاق، كتاب الشهادات، باب لا يقبل متهم ولا جار إلى نفسه ولا ظنين، برقم (١٥٣٦٥) والترمذي، كتاب أبواب الشهادات عن رسول الله، باب ما جاء فيمن لا تجوز شهادته، برقم (٢٢٩٨) والبيهقي، كتاب الشهادات، باب لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ وَلَا ظَنِينٍ وَلَا خَصْمٍ، برقم (٢٠٨٦٠) والزيلعي في نصب الراية، وقال: حديث غريب.

(٢) أخرجه ابن ماجة، كتاب الأحكام، باب من لا تجوز شهادته، برقم (٢٣٦٧) وأبو داود، كتاب الأقضية، باب شهادة البدوي على أهل الأمصار، برقم (٣٦٠٢) والحاكم في المستدرك برقم (٧٠٤٨) وقال: لم يصححه المؤلف وهو حديث منكر على نظافة سنده.

الهوامش

(١) المبسوط، ١٢١/١٦، تبيين الحقائق، ٢١٩/٤، تبصرة الحكام، ٣٢٣/١ حاشية الدسوقي، ١٦٨/٤، الأم، ٥٠/٧، أسنى المطالب، ٣٥١/٤، المغني، ١٨٦/١٠، الإنصاف، ٦٦/١٢.

(٢) المحلى، ٥٠٥/٨، إعلام الموقعين، ٨٧/١، المغني، لابن قدامة، ١٨٦/١٠.

(٣) نصب الراية، للزيلعي، ٨٢/٤.

(٤) سبق تخريجه.

(٥) المبسوط، ١٢٢/١٦.

(٦) سنن الترمذي، ٥٤٦/٤.

(٧) العناية شرح الهداية ، ٤٠٣/٧.

(٨) شرح النووي، ٢٠٩/١٧.

(٩) إعلام الموقعين، ٨٩/١، ٩٠.

(١٠) السنن الكبرى، للبيهقي، ٤٨٠/٧.

(١١) المحلى، ٥٠٨/٨.

(١٢) سورة لقمان: من الآية ١٤.

(١٣) سورة النساء: من الآية ٣٦.

(١٤) المحلى، ٥٠٨/٨.

(١٥) سورة المائدة: من الآية ٨.

(١٦) المغنى، ١٨٧/١٠.

(١٧) يراجع في بيان هذه الآثار : إعلام الموقعين، ٨٨/١، ٨٩.

الْفَصْلُ الثّانِي

فِي الْأَيْمَانِ

وَأَمّا الْأَيْمَانُ فَإِنّهُمُ اتّفَقُوا عَلَى أَنّهَا تَبْطُلُ بِهَا الدّعْوَى عَنِ الْمُدّعَى عَلَيْهِ إِذَا لَـمْ تَكُـنْ لِلْمُدّعِي بَيّنَةٌ. ..... وَأَمّا الْقَضَاءُ بِالْيَمِينِ مَعَ الشّاهِدِ فَإِنّهُمُ اخْتَلَفُوا فِيهِ [١]؛ فَقَالَ

---

(١) **حكم القضاء بالشاهد واليمين:**

اختلف الفقهاء في مسألة حكم القضاء بالشاهد واليمين ، وانتهى خلافهم إلى قولين:

القول الأول:

يرى أنصار هذا المذهب جواز القضاء بيمين صاحب الحق مع الشاهد، وإن وقع بينهم الخلاف في الدعاوى محل القضاء بالشاهد واليمين:

فالمالكية: قالوا كل ما جازت فيه شهادة النساء، جاز فيه الشاهد واليمين.

والشافعية قالوا: يقضي باليمين مع الشاهد في الدعاوى المالية، والدعاوى المتعلقة بالعقود المالية، ولا يقضي به في الحدود، والجناية على النفس وما دونها.

أما الحنابلة: فقد ذهبوا إلى صحة القضاء باليمين مع الشاهد في الدعاوى المالية، وفي كل ما يقصد به المال، ولا يقضي به في الحدود، و النكاح، و الطلاق، و العتاق، و القصاص، و الولاء.

وذهب الظاهرية إلى أنه يقضي باليمين مع الشاهد في الدماء والقصاص، والنكاح والطلاق، والرجعة، ولا يقضي بهما في الحدود [١].

القول الثاني:

يرى أنصار هذا الرأي أنه: لا يجوز القضاء باليمين مع الشاهد في أي نوعٍ من أنواع الدعاوى [٢].

=

أولا: أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول القائل بجواز القضاء بالشاهد واليمين بما يلي:

١- ما روي عن ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قضى باليمين مع الشاهد [٣].

٢- ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قضي رسول الله ﷺ بشاهدٍ ويمينٍ في الحقوق [٤].

وجه الدلالة:

دل الحديثان السابقان على أن رسول الله ﷺ قضي باليمين مع الشاهد، وما ذاك إلا دليل على الجواز.

٣- استدلوا من الأثر بما يلي:

أ- روي عن علي بن أبي طالب أن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يقضون بشهادة الشاهد الأول ويمين المدعي.

ب - روي أن عليا ﷺ قضي باليمين مع الشاهد، وقضي بذلك أبي بن كعب على عهد عمر رضي الله عنهما [٥].

ج - استدلوا بقول الشافعي رحمه: "اليمين مع الشاهد لا يخالف من ظاهر القرآن شيئا، لأنا نحكم بشاهدين وشاهدٍ وامرأتين ولا يمين، فإذا كان شاهدا، حكمنا بشاهد ويمين، وليس هذا بخلاف ظاهر القرآن، لأنه لم يحرم أن يجوز أقل مما نص عليه في كتابه، ورسول الله ﷺ أعلم بمعنى ما أراد الله، وقد أمرنا الله أن نأخذ ما أتانا وننتهى عما نهانا [٦].

ثانيا: أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني القائل بعدم جواز القضاء بالشاهد واليمين بما يلي:

١- **من الكتاب:**

=

٢- استدلوا بقوله تعالى: ﴿وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ﴾ (٧).

وجه الدلالة:

إن هذه الآية جاءت في مقام بيان كيفية الشهادة، واقتصرت على ذكر صورتين فقط للشهادة، فالحاصل أن الله تبارك وتعالى اقتصر في مقام البيان على شهادة الرجلين، والرجل والمرأتين، والاقتصار في مقام البيان يفيد الحصر، فكأن الله قال: لا تشهدوا بغيرهم، فإذا قيل بصحة القضاء بالشاهد واليمين فإن هذا يكون منافيا للحصر، ويكون زيادة على القرآن بحديث مروي بطريق الآحاد، والزيادة على القرآن نسخ له، ولا يصح نسخ القرآن بالسنة الأحادية، لأن القرآن متواتر فهو قطعي الثبوت وخبر الآحاد ظني الثبوت، فلا ينسخ المتواتر الذي هو قطعي الثبوت، ولا تقبل الزيادة من الأحاديث إلا إذا كان الخبر بها متواترا، أو مشهورا على الأقل (٨).

وجاء في أحكام القرآن لابن العربي "أن الله تعالى قسم أنواع الشهادات، ولم يرد في الآية ذكر الشاهد واليمين، فلا يجوز القضاء به، إذ إنه يكون حينئذ قسما ثالثا لم يرد فيما أوضحه الله، فالقول بجوازه بناء على ذلك يكون زيادةً على ما في كتاب الله" (٩).

٢ – من السنــة :

أ – استدلوا بقوله ﷺ في حديث ابن عباس: البينة على المدعي واليمين على من أنكر (١٠).

ب – قولـه ﷺ لو يعطي الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعي عليه " (١١).

وجه الدلالة:

أفاد الحديثان أن رسول الله ﷺ حصر اليمين في جانب المدعي عليه، فلو

=

كان للمدعي يمين لما كان الحصر صحيحا.

مناقشة أدلة الرأي الأول:

نوقش الحديث الأول بما يلي:

أ – نوقش هذا الحديث بأن حديث ربيعة عن سهيل لا يحتج به؛ لآن ربيعه لم يروه عن سهيل بن أبي صالح، وقد أنكره سهيل، فلا يصلح للاحتجاج به بعد إنكار راويه له.

وأجاب ابن حجر في الفتح بأن رجال الحديث ثقات، ولا يضره أن سهيلا نسبه بعد أن حدث به ربيعه، لأنه كان بعد ذلك يرويه عن ربيعه عن نفسه عن أبيه [١٢].

ب – جاء في البدائع ما نصه: "طعن يحيى بن معين في الحديث، وقال: لم يصح عن رسول الله ﷺ القضاء بشاهد ويمين" [١٣].

الجـــواب:

أجاب ابن حجر عن هذا الاعتراض فقال: قال الشافعي في حديث ابن عباس: هذا الحديث ثابت، لا يرده أحد من أهل العلم لو لم يكن فيه غيره، مع أن معه غيره مما يشهد له.

جـ – نوقش الحديث أيضاً بأن المراد بشاهدٍ ويمين، هو القضاء بيمين المنكر مع شاهد الطالب، والمراد أن الشاهد الواحد لا يكفي في ثبوت الحق، فتجب اليمين على المدعي عليه [١٤].

الجـــواب:

أجاب ابن العربي عن هذه المناقشة بقوله: إن هذا جهل باللغة، فإن المعية تقتضي أن تكون من شيئين في جهة واحدة لا في المتضادين [١٥].

مناقشة أدلة الرأي الثاني :

نوقشت أدلة الرأي الثاني بما يلي:

=

مَالِـكٌ وَالشّـافِعِيُ، وَأَحْمَـدُ، وَدَاوُدُ، وَأَبُـو ثَـوْرٍ وَالْفُقَهَـاءُ السّـبْعَةُ الْمَـدَنِيُّونَ

أ – بالنسبة للآية: يمكن أن يناقش الاستدلال بها، بأن هذا ليس من قسم الشهادة، وإنما الحكم هنالك باليمين، وحظ الشاهد ترجيح جنبة المدعي.

ب – اعترض البعض على حديث البينة على المدعي، بأنه ضعيف، وإن سلم صحته، فإنه لا يفيد الحصر، بدليل أن اليمين تشرع في حق المودع، إذا ادعى رد الوديعة وتلفها، وفي حق الأمناء لظهور خيانتهم، وفي حق الملاعـن، وفي القسامة، وتشرع في حق البائع والمشتري إذا اختلفا في الثمن، والسلعة قائمـة [١٦].

الرأي الراجـح:

بعد عرض آراء العلماء وأدلتهم في هذه المسألة ومناقشة ما أمكن من الأدلة، يتبين رجحان الرأي القائل بصحة القضاء بالشاهد ويمين المدعي في الأموال، لثبوت الحديث الذي يفيد هذا، ولضعف استدلال المخالف، ولأن القول بهذا الرأي يتفق مع روح التشريع الإسلامي، إذ أنه في بعض الأحايين يكون للمدعي شاهدان، فيموت أحدهما، أو يكون غائبا لا يتوصل إلى شهادته بسهوله أو يكون قد طرأ له ما يمنعه من أداء الشهادة كالجنون، فإذا لم يقضي القاضي له بالحق المدعي بالشاهد الواحد الباقي مع يمينه، فإن هذا يؤدي إلى ضياع الكثير من حقوق الناس، مع وجود الظن بثبوت هذه الحقوق، والشريعة تعتبر الظنون في كثير من الأحايين، وشهادة الشاهد الواحد تفيد ظنا ما بثبوت الحق، لأن الشاهد متصف بالعدالة، والعدالة مانعة له من الكذب، فإذا تأكدت شهادته بيمين المدعي، حصل الظن الغالب بثبوت الحق وهذا الرأي رجحه بعض المحدثين [١].

وَجَمَاعَةٌ :يُقْضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشّاهِدِ فِي الْأَمْوَالِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالثّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ وَجُمْهُورُ أَهْلِ الْعِرَاقِ :لَا يُقْضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشّاهِدِ فِي شَيْءٍ، وَبِهِ قَالَ اللّيْثُ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ.

وَسَبَبُ الْخِلَافِ فِي هَذَا الْبَابِ تَعَارُضُ السّمَاعِ، أَمّا الْقَائِلُونَ بِهِ فَإِنّهُمْ تَعَلّقُوا فِي ذَلِكَ بِآثَارٍ كَثِيرَةٍ.

الهوامش

(١) بداية المجتهد، ٤٦٧/٢، المهذب، ٣٩٦/٣، ٣٩٧، المغني، ٧٥/١٤، المحلى، ٤٠٣/٩، ٤٠٤.

(٢) أحكام القرآن لابن العربي، ١ / ٢٥٣، بدائع الصنائع، ٧ / ١٨، تبصرة الحكام،١ / ٢٦٨، سبل السلام، ٢ / ١٤٨، المحلى، ٩ /٤٠٤، بداية المجتهد، ٢ / ٤٦٧.

(٣) موطأ مالك، ٧٢١/٢، مسند أحمد، ١٢٠/٥، سنن الترمذي، ٦٢٨/٣.

(٤) الحديث أخرجه الدار قطني، كتاب الأقضية والأحكام، حديث رقم (٣٣)، ٤/ ٢١٣.

(٥) البيهقي، كتاب الشهادات: باب القضاء باليمين مع الشاهد ١٠ /١٧٣

(٦) السنن الكبرى للبيهقي: ١٠ / ١٧٥.

(٧) سورة البقرة: من الآية ٢٨٨.

(٨) د/ محمد رأفت عثمان: النظام القضائي في الفقه الإسلامي، ص ٤٠٦، ٤٠٧.

(٩) أحكام القرآن، لابن العربي ١/ ٢٥٣.

(١٠) أخرجه البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، برقم (٤٥٥٢) ٣٥/٦، ومسلم، كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه، برقم (١٧١١) ١٢٨/٥.

(١١) الحديث سبق تخريجه.

(١٢) تكملة فتح القدير، ٦ / ١٥٥، فتح الباري، ٥ / ١٧٨، ١٧٩.

(١٣) بدائع الصنائع، ٧ / ٢٥ ٠

(١٤) المرجع السابق .

(١٥) نيل الأوطار، ٩ / ١٩٤، ١٩٥.

(١٦) أحكام القرآن، لابن العربي، ٢٥٣/١.

الْفَصْلُ الثّالِثُ

النُكُولُ [١]

---

(١) **تعريف النكول:**

النكول في اللغة: هو الجبن والتأخر، يقال: نكل عن اليمين ينكل بالضم، أي جبن، ونكله عن الشيء، أي صرفه عنه.

قال ابن الأثير: الكل بالتحريك من التنكيل، وهو المنع والتنحية عما يريد، ومنه النكول في اليمين، وهو الامتناع منها وترك الإقدام عليها [١].

والنكول في الاصطلاح هو الرجوع في اليمين بعد إيجابها.

وهذا الامتناع من حيث ثبوته نوعان:

أ _ بالقول: كأن يقول المدعى عليه: لا أحلف.

ب – السكوت إذا كان ناطقا، ، فهذا السكوت يكون دلالة على النكول.

ونكول المدعى عليه قد يكون اعترافا منه، لأنه سكت وامتنع عما يدفع به الضرر عن نفسه، وهو اليمين، وقد يكون النكول بذلا منه.

وإذا نكل المدعى عليه فإن حكم القاضي بعد النكول مباشرة، جاز ذلك عند الأحناف؛ لأن النكول إقرار، فيكون الحكم هنا حكما بعد إقرار المدعى عليه، لكن هذا الإقرار فيه شبهة، إذ ربما لجأ المدعى عليه إلى البذل ، والأولى عند الأحناف أن يخبر القاضي المدعى عليه أن مذهبه القضاء بالنكول، إذ ربما جهل مذهب القاضي، ويعرض عليه اليمين ثلاث مرات، إذ ربما يرجع عن نكوله، وإذا رجع عن النكول قبل الحكم جاز تحليفه وقبول بينته، وإن ظل ممتنعا إلى الحكم، حكم القاضي، ولا يقبل بعد ذلك رجوعه عن النكول [٢].

ويرى الأحناف كذلك أن اليمين لا ترد على المدعى بعد نكول المدعى عليه؛ لأن الرسول ﷺ قال: اليمين على المدعى عليه، والمدعي هنا مذكور

=

بالألف واللام، وذلك ينفي ردها على المدعي، أيضا فإن الرسول قسم البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وهذه تنفي اشتراكهما في اليمين، فلا يرد اليمين على المدعي [٣].

ويرى الشافعية أنه لا يحكم بمجرد النكول، بل إذا نكل المدعى عليه ردت اليمين على المدعي، ولا يحكم بمجرد النكول إلا في صورٍ منها:

١- إذا طلب الساعي على الزكاة من المال، فادعى أنه بادر في أثناء الحول، واتهمه الساعي، يحلفه ندبا، وقيل: يحلفه وجوبا، فعلى هذا إذا نكل والمستحق غير محصور أخذت منه الزكاة ، ولا يحلف الساعي والإمام.

٢- إذا مات من لا وارث له، فادعى الحاكم أو منصوبه على إنسان بدين للميت وجد في تذكرته فأنكر، فقيل: يقضى بالنكول، وصحح الرافعي أنه يحبس حتى يقر أو يحلف.

٣- إذا ادعى قيم المسجد أو الوقف دعوى، ونكل المدعى عليه، فهل يرد اليمين على المباشر أو حبسه؟ أرجحها عند الرافعي التفرقة بين أن يكون باشرها بنفسه فترد، أو لا، فلو ادعى إتلاف مال الوقف ونكل فلا ترد، ثم قيل: يقضى بنكول، وقيل: يحبس حتى يقر أو يحلف [٤].

أنواع اليمين :

تنقسم اليمين المعتبرة وسيلة من وسائل الإثبات إلى قسمين:

١- يمين المدعي: وظيفة اليمين في هذه الحالة هي إتمام البينة، وتستعمل في حالة ما إذا كانت بينة المدعي غير كافية، أو ناقصة، وتكون في الأمور التي يجوز فيها القضاء بالشاهد واليمين، ويسميها الفقهاء اليمين المتممة، ولا يجوز ردها على الخصم.

٢- يمين المدعى عليه وتستعمل هذه اليمين لدفع الدعوى الموجهة إليه من المدعي، وهذه اليمين تسمى اليمين الحاسمة، ويجوز ردها على الخصم الآخر،

=

وَأَمَّا ثُبُوتُ الْحَقِّ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِنُكُولِهِ فَإِنّ الْفُقَهَاءَ أَيْضًا اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ، فَقَالَ مَالِكٌ، وَالشّافِعِيُّ وَفُقَهَاءُ أَهْلِ الْحِجَازِ وَطَائِفَةٌ مِنَ الْعِرَاقِيّينَ :إِذَا نَكَلَ الْمُدّعَى عَلَيْهِ لَمْ يَجِبْ لِلْمُدّعِي شَيْءٌ بِنَفْسِ النُكُولِ، إِلّا أَنْ يَحْلِفَ الْمُدّعِي أَوْ يَكُونَ لَهُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَجُمْهُورُ الْكُوفِيّينَ :يَقْضِي لِلْمُدّعِي عَلَى الْمُدّعَى عَلَيْهِ بِنَفْسِ النُكُولِ، وَذَلِكَ فِي الْمَالِ بَعْدَ أَنْ يُكَرّرَ عَلَيْهِ الْيَمِينَ ثَلَاثًا.

وَقَلْبُ الْيَمِينِ عِنْدَ مَالِكٍ يَكُونُ فِي الْمَوْضِعِ الّذِي يُقْبَلُ فِيهِ شَاهِدٌ وَامْرَأَتَانِ، وَشَاهِدٌ وَيَمِينٌ. وَقَلْبُ الْيَمِينِ عِنْدَ الشّافِعِيّ يَكُونُ فِي كُلّ مَوْضِعٍ يَجِبُ فِيهِ الْيَمِينُ .وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: [1] أَرُدُّهَا فِي غَيْرِ التُّهْمَةِ، وَلَا أَرُدُّهَا فِي التُّهْمَةِ. وَعِنْدَ مَالِكٍ فِي يَمِينِ

لقول النبي ﷺ: البينة على المدعي واليمين على من أنكر [5].

شروط وجوب اليمين على المدعى عليه:

١- إنكار المدعى عليه للحق المدعى به، فلو أقر به لا يحلف، لانتهاء الخصومة بالإقرار بالحق المدعى به.

٢- أن يطلب المدعي توجيه اليمين إلى المدعى عليه، ويقوم القاضي بتوجيهها للمدعى عليه.

٣- أن تكون اليمين شخصية، وتكون كذلك إذا اتصلت بشخص الحالف مباشرة.

٤- ألا يكون الحق المدعى به حقا خالصاً لله تعالى، إذ الحقوق الخالصة لله لا توجه فيها اليمين باتفاق.

٥- أن يكون الحق المدعى به مما يحتمل الإقرار به شرعا [6].

(١) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، الأنصاري، الكوفي، فقيه من =

التُّهْمَةِ هَلْ تَنْقَلِبُ؟ أَمْ لَا؟ قَوْلَانِ.

فَعُمْدَةُ مَنْ رَأَى أَنْ تَنْقَلِبَ الْيَمِينُ مَا رَوَاهُ مَالِكٌ مِنْ »أَنّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – رَدّ فِي الْقَسَامَةِ [1] الْيَمِينَ عَلَى الْيَهُودِ بَعْدَ أَنْ بَدَأَ بِالْأَنْصَارِ . «وَمِنْ حُجّةِ

أصحاب الرأي، تولى القضاء في عهد بني أمية، وفي عهد العباسيين، وأفتى بالرأي والقياس، توفي بالكوفة سنة ١٤٨ هـ، ومن أشهر مصنفاته: كتاب الفرائض.

وفيات الأعيان، ٣ / ٣١٩، البداية والنهاية، ١٠ / ١٠٥.

(١) القسامة في اللغة: هي كما قال ابن منظور الذين يحلفون على حقهم ويأخذون، يقال: قسامة الرجل، وقتل فلان فلاناً بالقسامة، أي باليمين، وهي اسم من الإقسام وضع موضع الصدر، وحقيقتها في اللغة: أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفراً على استحقاقهم دم صاحبهم إذا وجدوه قتيلاً بين قوم ولم يعرف قاتله .

لسان العرب ، ١١/١٦٤ ، ١٦٥ .

وفي الاصطلاح : اختلفت فيها عبارات الفقهاء :

فعرفها الأحناف بأنها: تستعمل في اليمين بالله تعالى بسببٍ مخصوص، وعددٍ مخصوص على شخصٍ مخصوص، وهو المدعى عليه، على وجهٍ مخصوص، وهو أن يقول خمسون من أهل المحلة إذا وجد فيها قتيل: بالله ما قتلناه ولا علمنا قاتله، فإذا حلفوا يغرمون الدية.

وقيل: هي أيمان يقسم بها أهل محلةٍ أو دارٍ وجد فيها قتيل به أثر، يقول كل واحد منهم: بالله ما قتلته ولا علمت له قاتلاً.

وقال المالكية هي: خمسون يمينًا على قتل حرٍ مسلم محقق الحياة.

والشافعية يطلقونها على مطلق الأيمان، وقيل: هي اسم للأيمان، ولعل الشافعية اكتفوا بذلك لوضوح المعنى اللغوي ودلالته على المعنى الشرعي، كذلك فإن المذاهب الأخرى تعرضت بتعريفها، الأمر الذي فيه الكفاية.

وصورة القسامة لدى الشافعية: أن يوجد قتيل بموضعٍ لا يعرف من قتله ولا بينة، =

مَالِكٍ أَنّ الْحُقُوقَ عِنْدَهُ إنّمَا تَثْبُتُ بِشَيْئَيْنِ :إمّا بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ، وَإمّا بِنُكُولٍ وَشَاهِدٍ، وَإمّا بِنُكُولٍ وَيَمِينٍ. أَصْلُ ذَلِكَ عِنْدَهُ اشْتِرَاطُ الِاثْنَيْنِيّةِ فِي الشّهَادَةِ، وَلَيْسَ يَقْضِي عِنْدَ الشّافِعِيّ بِشَاهِدٍ وَنُكُولٍ.

وَمِمّا اتّفَقُوا عَلَيْهِ فِي هَذَا الْبَابِ أَنّهُ يَقْضِي الْقَاضِي بِوُصُولِ كِتَابِ قَاضٍ آخَرَ إلَيْهِ، لَكِنّ هَذَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ مَعَ اقْتِرَانِ الشّهَادَةِ بِهِ، أَعْنِي :إذَا أَشْهَدَ الْقَاضِي الّذِي يَثْبُتُ عِنْدَهُ الْحُكْمُ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ أَنّ الْحُكْمَ ثَابِتٌ عِنْدَهُ، أَعْنِي :الْمَكْتُوبَ فِي الْكِتَابِ الّذِي أَرْسَلَهُ إلَى الْقَاضِي الثّانِي. فَشَهِدَا عِنْدَ الْقَاضِي الثّانِي أَنّهُ كِتَابُهُ، وَأَنّهُ أَشْهَدَهُمْ بِثُبُوتِهِ .وَقَدْ قِيلَ :إنّهُ يُكْتَفَى فِيهِ بِخَطِّ الْقَاضِي، وَأَنّهُ كَانَ بِهِ الْعَمَلُ الْأَوّلُ. وَاخْتَلَفَ مَالِكٌ، وَالشّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ إنْ أَشْهَدَهُمْ عَلَى الْكِتَابَةِ وَلَمْ يَقْرَأْهُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ مَالِكٌ :يَجُوزُ، وَقَالَ الشّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ :لَا يَجُوزُ، وَلَا تَصِحُّ الشّهَادَةُ [1].

ويدعي وليه على شخصٍ أو جماعةٍ أنهم قتلوه، وتوجد قرينةً تشعر بصدق المدعي، ويقال له: اللوث، فيحلف على ما يدعيه ويحكم له.

أما الحنابلة فقالوا: القسامة هي الأيمان المكررة في دعوى القتل.

وقيل: هي الأيمان إذا كثرت على وجه المبالغة، فالقاضي وأهل اللغة يذهبون إلى أنها القوم الذين يحلفون.

انظر: بدائع الصنائع، ٤٢٢/٧، الهداية، ٣٨٣/٣، بلغة السالك، ٤٢٩/٣، البهجة، ٣٦٥/٢، مغني المحتاج، ٣٧٨/٥، حاشية قليوبي، ١٦٣/٤، الشرح الكبير، ٧٨/٩ ، المغني، ١٨٨/١٢ .

(١) **القضاء بكتاب القاضي إلى القاضي:**

من المتفق عليه أن صحة حكم القاضي مشروط بوقوعه في دائرة الاختصاص المعينة له من قِبَلِ الإمام، إلا أن ذلك قد يكون عسيرًا في بعض

=

الأحوال، كما في المنازعات التي تحدث في دائرةٍ أخرى، لذلك بحث الفقهاء مسألة كتاب القاضي إلى قاض آخر ليحكم بما ثبت عنده.

وقد أجمع الفقهاء على جواز قبول الكتابة من قاض إلى آخر، وأجاز الحنابلة الكتابة إلى غير المعين، كأن يكتب ويقول: إلى كل من يصله كتابي من قضاة المسلمين [٧].

وذهب الحنفية إلى جواز قبول كتاب القاضي إلى القاضي في الحقوق، بخلاف الحدود، والقصاص، فلا تجوز الكتابة فيها، وذلك لأن كتاب القاضي إلى القاضي بمنزلة الشهادة على الشهادة، والشهادة على الشهادة لا تجوز في الحدود والقصاص، فكذلك كتاب القاضي إلى القاضي؛ لأن فيه شبهة البدلية، والحدود والقصاص كل منهما يسقط بالشبهة.

وقيل: إنه يقبل في العقار، ولا يقبل في الأعيان المنقولة.

وعن أبي يوسف: أنه يقبل في العبد دون الأمة.

وعن محمد: أنه يقبل في كل ما ينقل ويتحول.

والدليل على جواز كتاب القاضي إلى القاضي قول الله تعالى: ﴿قَالَتْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَؤُا۟ إِنِّىٓ أُلْقِىَ إِلَىَّ كِتَٰبٌ كَرِيمٌ﴾ [٨].

وما روي عن الضحاك بن قيس، وقيل الضحاك بن سفيان قال: ولاني رسول الله ﷺ بعض الأعراب، ثم كتب إلى أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فورثتها، وكان عمر ﷺ لا يورث المرأة من دية زوجها حتى قال له الضحاك: أن النبي ﷺ كتب إليه، فورثها عمر من دية زوجها [٩].

وروي أن النبي ﷺ جهز جيشًا، فأمر عليه عبد الله بن رواحه، ودفع إليه كتابا مختوما، وقال: لا تفكه إلا بعد ثلاث فإذا مضت ثلاث فقصه، واعمل بما فيه [١٠].

وروي عن عبد الله بن عكيم قال: أتانا كتاب رسول الله ﷺ قبل موته بشهر،

=

ألا تنتفعوا من الميتة بإهابٍ ولا عسب [١١].

وروي أن النبي ﷺ كتب إلى قيصر: بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد رسول الله إلى عظيم الروم: ﴿قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِۦ شَيْـًٔا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَقُولُوا۟ ٱشْهَدُوا۟ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ [١٢] فلما وصل إليه الكتاب قبله ووضعه على رأسه، ووضعه في المسك، فبلغ ذلك النبي ﷺ قال: ثبت ملكه [١٣]، وكتب إلى كسرى بن هرمز: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى بن هرمز، أما بعد: أسلموا تسلموا، فلما بلغه الكتاب مزقه، فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: تمزق ملكه [١٤] فملك الروم باقٍ إلى اليوم، وملك المجوس تمزق وذهب.

المدة بين القاضي الكاتب والقاضي المكتوب إليه:

قَيَّدَ الحنفية الكتاب بمسافة القصر، فقالوا: لابد من وجود مسافة قصر بين بلد القاضي الكاتب، وبلد المكتوب إليه [١٥].

أما المالكية: فلا اعتبار للمسافة عندهم، فيجوز الكتابة بين القضاة بَعُدت المسافة أم قربت [١٦]

وذهب الحنابلة إلى أنه لا تشترط المسافة البعيدة، حيث قالوا: يقبل الكتاب وإن كان القاضيان في بلدٍ واحد، وإلا إذا بعث إليه ليحكم بما ثبت عنده، فهنا لابد من وجود مسافة القصر [١٧].

ونظر الشافعية إلى الغرض من الكتاب، وأسسوا رأيهم على ذلك فقالوا: إذا كان الغرض من الكتاب نقل شهادة، أو ثبوت حق، فلا خلاف بينهم في اشتراط مسافة القصر في نقل الشهادة، وفي الكتاب المتضمن ثبوت الحق وجهان: أصحهما: أنه لابد من مسافة القصر [١٨].

الشهادة على كتاب القاضي:

اتفق فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة – عدا أبي ثور من الشافعية – على

=

أن القاضي لا يقبل كتاب قاضٍ آخر إلا إذا شهد شاهدان عدلان أنه قرئ عليهما، أو بحضرتهما.

وقال محمد وأبو حنيفة: لابد أن يشهد الشهود بختم القاضي.

وذهب المالكية إلى أن كتاب القاضي إذا جاء مجردًا عن الشهادة، فلا قيمة له، ولا يترتب عليه أثر، إلا أنهم لم يقيدوا ذلك بقراءة الكتاب على الشهود.

وهذا الكلام فيما إذا سار بالكتاب غير الخصم، أما إذا سار به الخصم، فلابد من أن يأتي بشاهدين يشهدان أن هذا هو كتاب القاضي.

وقرر الفقهاء أنه لا يقبل في تحمل كتب القضاة وآدائها شهادة النساء، حتى ولو كانت الحقوق التي تضمنها هذا الكتاب مما تقبل فيه شهادة المرأة [١٩].

شروط تحمل الشهود للشهادة على الكتاب:

اشترط الفقهاء شروطا لتحمل الشهود الشهادة على الكتاب وآدائها وهي:

١ – أن يعلما ما فيه، وعلمهما بما فيه يكون بأحد ثلاثة أوجه: إما أن يقرأه القاضي عليهما، وإما أن يأمر من يقرأه بحضرته عليهما، وإما أن يقرأه الشاهدان عليه، فإن لم يعلما ما فيه، ودفعه القاضي إليهما مختومًا ليشهدوا به، لم يجز.

٢ – أن يقول القاضي لهما: هذا كتابي إلى القاضي فلان، فاشهدا على بما فيه، فإن لم يقل لهما: هذا كتابي إلى فلان، واقتصر بهما على عنوانه، لم يجز، وإن قال لهما: هذا كتابي إلى فلان، ولم يسترعهما الشهادة ولا قال: اشهدا عليَّ بما فيه، ففي صحة التحمل والأداء بهذا القول وحده وجهان بناءً على الخلاف في جواز الشهادة على المقر بالسماع من غير استدعاء المقر للشهود.

٣ – ألا يغيب الكتاب عنهما بعد تحمل ما فيه إلا أن يكونا قد كتبا فيه شهادتهما ليتذكرا به صحة الكتاب ومعرفته، فإن غاب الكتاب عنهما قبل إثبات خطهما فيه، أو ارتابا بعد الخط، لم يصح التحمل، إلا أن يعيد القاضي قراءته عليهما، ويقول لهما: هذا هو كتابي الذي أشهدتكما على بما فيه إلى القاضي

=

وَمِمّا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْ هَذَا الْبَابِ قَضَاءُ الْقَاضِي بِعِلْمِهِ، وَذَلِكَ أَنّ الْعُلَمَاءَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنّ الْقَاضِيَ يَقْضِي بِعِلْمِهِ فِي التّعْدِيلِ وَالتّجْرِيحِ، وَأَنّهُ إذَا شَهِدَ الشُّهُودُ بِضِدّ عِلْمِهِ لَمْ يَقْضِ بِهِ، وَأَنّهُ يَقْضِي بِعِلْمِهِ فِي إقْرَارِ الْخَصْمِ وَإِنْكَارِهِ، إلّا مَالِكًا فَإِنّهُ رَأَى أَنْ يُحْضِرَ الْقَاضِي شَاهِدَيْنِ لِإِقْرَارِ الْخَصْمِ وَإِنْكَارِهِ.

وَكَذَلِكَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنّهُ يَقْضِي بِعِلْمِهِ فِي تَغْلِيبِ حُجّةِ أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ عَلَى حُجّةِ الْآخَرِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ خِلَافٌ.

وَاخْتَلَفُوا إذَا كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ، فَقَالَ قَوْمٌ :لَا يُرَدُّ حُكْمُهُ إذَا لَمْ يَخْرِقِ الْإِجْمَاعَ، وَقَالَ قَوْمٌ :إذَا كَانَ شَاذًّا، وَقَالَ قَوْمٌ :يُرَدُّ إذَا كَانَ حُكْمًا بِقِيَاسٍ. وَهُنَالِكَ سَمَاعٌ مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنّةٍ تُخَالِفُ الْقِيَاسَ، وَهُوَ الْأَعْدَلُ، إلّا أَنْ يَكُونَ الْقِيَاسُ تَشْهَدُ لَهُ الْأُصُولُ وَالْكِتَابُ مُحْتَمِلٌ وَالسُّنّةُ غَيْرُ مُتَوَاتِرَةٍ.

وَأَمّا مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى فَلِلتُّهْمَةِ اللّاحِقَةِ فِي ذَلِكَ لِلْقَاضِي. وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنّ لِلتُّهْمَةِ

فلان، لأنه قد يحتمل أن يبدل في الغيبة بغيره [٢٠].

بيانات كتاب القاضي:

بادئ ذي بدءٍ أقول: إن مذهب الشافعي أن العنوان ليس شرطا في قبول الكتاب، ولا فرق عند الشافعي بين عنوانه من داخله وخارجه، ويجوز أن يقبله حتى ولو لم يكن معنونًا؛ لأن الحكم به متعلق بما يؤديه الشهود من مضمونة، فلم يكن لعنوانه ولا لفقده تأثير في الحكم بما شهد شهوده.

ويرى الماوردي من الشافعية أن عنوان الكتاب الذي يكون في داخله هو عرف قديم، والعنوان الموضوع على ظاهرة عرف مستحدث، والعرف المعمول به أولى من العرف المتروك [٢١].

تَأْثِيرًا فِي الشّرْعِ، مِنْهَا أَنْ لَا يَرِثَ الْقَاتِلُ عَمْدًا عِنْدَ الْجُمْهُورِ مَنْ قَتَلَهُ. وَمِنْهَا رَدُّهُمْ شَهَادَةَ الْأَبِ لِابْنِهِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمّا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ.

وَأَمّا عُمْدَةُ مَنْ أَجَازَ ذَلِكَ، أَمّا مِنْ طَرِيقِ السّمَاعِ فَحَدِيثُ عَائِشَةَ فِي قِصّةِ هِنْدِ بِنْتِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ مَعَ زَوْجِهَا أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ حِينَ قَالَ لَهَا – عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسّلَامُ - وَقَدْ شَكَتْ أَبَا سُفْيَانَ : خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ دُونَ أَنْ يَسْمَعَ قَوْلَ خَصْمِهَا [(١)].

---

(١) مسألة قضاء القاضي بعلمه مطلقا من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء اختلافا كبيرا، وانتهى خلافهم إلى ثلاثة أقوال:

لا خلاف بين العلماء في أن القاضي يجوز أن يقضي بعلمه في التعديل والتجريح، وأجمع العلماء كذلك على أن القاضي لا يقضي بضد علمه إذا شهد الشهود بضده، وأنه يقضي بعلمه في إقرار الخصم وإنكاره [(٢٢)].

إلا أن الخلاف وقع بينهم في: هل يعتبر علم القاضي وسيلةً من وسائل الإثبات، أي هل يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه من غير بينةٍ ولا إقرار؟ وكان الخلاف بينهم على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يرى أنصار هذا المذهب أنه لا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه في أي شيء، لا في حدٍ ولا في مال، ولا في غيرهما، سواءً عَلِمَهُ قبل ولايته أم بعدها، وهو ما ذهب إليه المالكية، وقول عند الشافعية، وظاهر مذهب الحنابلة، والإباضية، وهو قول الشعبي، وشريح [(٢٣)].

القول الثاني:

فَرَّقَ أنصار هذا الرأي بين حقوق الله وحقوق العباد:

فقالوا: لا يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في حقوق الله عز وجل، شريطه أن

=

يكون عَلِمَهُ في ولايته، أما ما عَلِمَهُ قبل ولايته، فلا يجوز له القضاء فيه، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي في الأصح، ورواية عن أحمد، والزيدية [٢٤].

القول الثالث:

يرى أصحابه أنه يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه في كل شيء؛ لأن علمه أقوى من العلم الذي يحصل له بشهادة الشهود، وإذا جاز له أن يقضي بشهادة الشهود، فلأن يقضي بعلم نفسه أولى.

وهو قول أبي يوسف ومحمد من الحنفية، والراجح لدى الشافعية، ورواية عن أحمد، والظاهرية [٢٥].

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول على قولهم بعدم جواز قضاء القاضي بعلمه بالكتاب، والسنة، والمعقول:

أولًا: من الكتاب:

استدلوا بقوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ﴾ [٢٦].

وجه الدلالة:

جعل الله سبحانه وتعالى إقامة حد القذف مشروطًا بوجود الشهود الأربعة، ولو جاز للقاضي أن يقضي بعلمه لما قرنه بالشهادة [٢٧].

ثانيًا: من السنة:

استدلوا بما روي عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا بِقَوْلِهِ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ، فَلَا يَأْخُذْهَا [٢٨].

وجه الدلالة:

أفاد الحديث أن الرسول ﷺ يقضي بما يسمع لا بما يعلم، وهو دليل على أن

=

القاضي لا يجوز له أن يقضي بعلمه.

المناقشة:

نوقش هذا الاستدلال بأن النص على السماع لا ينفي كون غيره طريقًا للحكم، بل يمكن القول: إن هذا الحديث حجةً ظاهرةً واضحةً للقائلين بجواز قضاء القاضي بعلمه، إذ العلم أقوى من السماع؛ لأنه يمكن بطلان ما سمعه الإنسان، ولا يمكن بطلان ما علمه [٢٩].

ثالثًا: من المعقول:

استدلوا بقولهم: لا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه؛ لأن تجويز القضاء بعلمه يؤدي إلى التهمة، وقد يحكم بما يشتهي، ويحيل ما اشتهاه على علمه، فوجب أن يمنع من ذلك [٣٠].

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني القائل بالتفريق على مذهبهم بما يلي:

١- ما روي عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِذَا وَجَدْتُمْ لِلْمُسْلِمِ مَخْرَجًا، فَادْرَءُوا عَنْهُ؛ فَإِنَّهُ أَنْ يُخْطِئَ حَاكِمٌ مَنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ [٣١].

وجه الدلالة:

أمر النبي ﷺ بدرء الحدود عن المسلمين قدر الإمكان، وما ذاك إلا لحرص الإسلام على الستر، وللطابع الخاص الذي يميزها عن غيرها، لذلك لا يجوز الحكم فيها بعلم القاضي.

٢- ذكر الحنفية تعليلًا أورده صاحب الاختيار، حيث قال: " أما جواز قضائه بما علمه من حقوق الآدميين في زمن ولايته ومحلها، فلأن علمه كشهادة الشاهدين، بل هو أولى، لأن اليقين حاصلٌ بما عَلِمه بالمعاينة والسماع، والحاصل بالشهادة ليس إلا غلبة الظن، وأما عدم جوَاز قضائه بما علمه قبل

=

ولايته، أو في غير محل ولايته، فلأنه قبل ولايته، وفي غير محل ولايته شاهد لا حاكم، وشهادة الفرد لا تقبل، وصار كما لو كان قد علم ذلك بالبينة العادلة ثم ولي القضاء، فإنه لا يعمل بها، وأما حقوق الله عز وجل فلا يقضي فيها بعلمه؛ لأنه خصم فيها، فالحاكم نائبٌ عن الله عز وجل في تنفيذ حقوقه تعالى [٣٢].

أدلة القول الثالث:

استدل أصحاب القول الثالث القائل بجواز قضاء القاضي بعلمه مطلقًا بما يلي:

١- قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ [٣٣].

وجه الدلالة:

يوضح ابن حزم الظاهري المراد من الآية فيقول: "وليس من القسط أن يُتْرَكَ الظالم على ظلمه لا يغيره، وأن يعلن الفاسق الكفر بحضره الحاكم، والإقرار بالظلم والطلاق، ثم يقره مع المرأة، ويحكم له بالزوجية والميراث، فيظلم أهل الميراث حقهم"[٣٤].

٢- ما روي عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، فَلَا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ [٣٥].

وجه الدلالة:

إن النبي ﷺ حكم لهند بالتصرف في مال زوجها، بأن تأخذ من ماله بالمعروف، والنبي ﷺ هنا إنما حَكَمَ بعلمه، فدل على أن حكم الحاكم بعلمه جائز.

المناقشة:

نوقش هذا الدليل بأن الحديث لا يدل على جواز القضاء بعلم القاضي؛ لأنه

=

فتوى وليس حكم، بدليل أن الرسول ﷺ قال ذلك في حق أبي سفيان وهو غائب، ولو كان حُكْمًا لاستدعاه، ولم يحكم عليه في غيابه [٣٦].

٢- ما روي عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ يَسْتَعْدِي عَلَى أَبِي سُفْيَانَ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ ظَلَمَنِي حَدِّي فِي مَهْبِطِ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ ﷺ: إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّاسِ بِذَلِكَ الْمَوْضِعِ وَلَرُبَّمَا لَعِبْتُ أَنَا وَأَنْتَ وَنَحْنُ غِلْمَانٌ، فَإِذَا قَدِمْتَ مَكَّةَ، فَأْتِنِي بِأَبِي سُفْيَانَ فَلَمَّا قَدِمَ أَتَاهُ الْمَخْزُومِيُّ بِأَبِي سُفْيَانَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ ﷺ: يَا أَبَا سُفْيَانَ خُذْ هَذَا الْحَجَرَ مِنْ هَا هُنَا فَضَعْهُ هَاهُنَا، فَقَالَ: وَاللهِ لَا أَفْعَلُ فَقَالَ: وَاللهِ لَتَفْعَلَنَّ، فَقَالَ: لَا أَفْعَلُ فَعَلَاهُ عُمَرُ بِالدِّرَّةِ وَقَالَ: خُذْهُ لَا أُمَّ لَكَ مِنْ هَا هُنَا فَضَعْهُ هَا هُنَا، فَأَخَذَهُ فَوَضَعَهُ فَكَأَنَّ عُمَرَ ﷺ دَخَلَهُ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ثُمَّ قَالَ: اللهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ إِذْ لَمْ تُمِتْنِي حَتَّى غَلَبْتُ أَبَا سُفْيَانَ عَلَى رَأْيِهِ، وَذَلَّلْتَهُ لِي بِالْإِسْلَامِ، قَالَ: فَاسْتَقْبَلَ أَبُو سُفْيَانَ ﷺ الْقِبْلَةَ فَقَالَ: اللهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ الَّذِي لَمْ تُمِتْنِي حَتَّى أَدْخَلْتَ قَلْبِي مِنَ الْإِسْلَامِ مَا ذَلَّلْتَنِي بِهِ لِعُمَرَ ﷺ [٢٧].

ففي هذه الرواية حَكَمَ عمر ﷺ بعلمه، وهذا دليل على جواز حكم الحاكم بعلمه [٣٧].

الاعتراضات الواردة على هذه القصة:

يعترض على الاستدلال بهذه الواقعة من وجوه:

الأول:

إن ما صنعه عمر مع أبي سفيان بناءً على ادعاه المخزومي لم يكن حكمًا، بل كان إنكارًا لمنكرٍ رآه، بدليل أنه لم توجد منهم دعوى بشروطها، ولم يوجد إنكار، ولا إثبات بشرطهما من المدعي عليه، فكانت إنكارًا لمنكر وقع قديما.

الثاني:

إن الاستدلال بهذا الأثر على أنه حُكْمٌ بالعلم، وهو يعارض مع ما روي عن

=

عمر أنه لا يقضي بعلمه، وإنما إذا كان ولابد حكمًا فليكن شاهدًا لا قاضيًا إذا رغب المتخاصمان.

الثالث:

إن قضاء القاضي بشهادة الشهود لا يؤدي إلى التهمة، بخلاف حكمه بعلمه، فإنه يؤدي إلى التهمة، أما تجريح الشهود وتعديلهم، فيجوز للقاضي أن يعتمد فيه على علمه وفراسته بغير خلاف؛ لأنه إذا لم يستطع الوصول إلى عدالتهم وتجريحهم عن طريق علمه تسلسل لدية المزكون إلى ما لا نهاية، فيحتاج الشهود إلى مزكيين، ويحتاج المزكون إلى مزكين، فيتسلسل، وهذا خلاف القضاء بالعلم، فلا يجوز [٣٨].

٣- استدلوا بالقياس فقالوا: إن القاضي يحكم بالشاهدين لأن شهادتهما تعطيانه ظنًّا غالبًا بصحة ما شهدا به، فيكون ما علمه القاضي، وتحقق منه أولى [٣٩].

المناقشة:

يناقش هذا الدليل، بأن القضاء بالشاهدين لا يؤدي إلى تهمةٍ على خلاف الحكم بالعلم، فإنه يؤدي إلى تهمة، إذ إن القاضي لا يؤمن أن تتطرق إليه التهمة حتى ولو كان تقيًّا، فيحكم على من يشاء من غير حجة [٤٠].

القول الراجح:

بعد عرض أقوال الفقهاء في مسألة قضاء القاضي بعلمه، وذكر الأدلة ومناقشة ما أمكن منها، يظهر رجحان الرأي الثاني الذي يفرق بين حقوق الله وحقوق العباد؛ لأنه الموافق للمعقول، والأولى بالقبول، لأن شهادة الشاهدين لا تبلغ مرتبة العلم.

وهذا القول هو الذي رجحه الإمام الشوكاني في نيل الأوطار، وكذلك رجحه الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين [٤١].

=

ويرى البعض من المعاصرين [٤٢] بعد موافقته لرأي الشوكاني أنه من الاحتياط في هذه المسألة، إذ لابد أن يكون القاضي عدلًا، حتى يصح له أن يحكم بعلمه، أما لو فقدت العدالة فيمن يصلح لتولي القضاء، فولى أفضل من توفرت فيه بقية الشروط، فلا يصح لهذا أن يحكم بعلمه، لأنه غير مأمونٍ أن يدعي علمًا بحدوث جرائم من أشخاصٍ يريد أن يؤذيهم، فيدعى مثلًا على رجلٍ أنه شاهده يطلق زوجته طلاقًا ثلاثًا ونحو ذلك [٤٣].

ومع ذلك فقد استثنى الفقهاء القائلين بعدم الجواز صورًا يجوز فيها القضاء بالعلم وهي:

١- الإساءة إلى القاضي في مجلسه.

٢- الإساءة من الخصم إلى الخصم أمامه.

٣ – الإساءة إلى الشهود.

٤ – الإساءة إلى هيئة مجلسه، كمستشاريه ومفتيه وأعوانه.

فإذا وقع أحد هذه الأمور الأربعة في مجلس القاضي، كان له تأديب المسيء استنادًا إلى علمه؛ لأن الحال لا يحتاج إلى بينة، ولأن مجلس القضاء يُصَانُ عن ذلك، والحق في ذلك لله تعالى، فلا يجوز للقاضي تركه.

٥- الجرح والتعديل، فيجوز للقاضي أن يستند لعلمه في تزكية الشهود، فإن كان علي علمٍ بحالهم قَبِلَهُم أو رَدَّهُم.

٦ – لو أقر القاضي بشيءٍ في مجلس قضائه، فله أن يقضي به، ويعتبر قضاءً بالإقرار لا قضاءً بالعلم.

٧ – لو علم الإمام اسْتِحْقَاقُ مَنْ طَلَبَ الزكاة، جاز الدفع له.

٨ – لو عاين القاضي اللوث كان له اعتماده، ولا يخرج على الخلاف في القضاء بالعلم.

٩ – أن يقر عنده بالطلاق الثلاث ثم يدعى زوجيتها.

=

وَأَمّا مِنْ طَرِيقِ الْمَعْنَى فَإِنّهُ إذَا كَانَ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِقَوْلِ الشّاهِدِ الّذِي هُوَ مَظْنُونٌ فِي حَقِّهِ فَأَحْرَى أَنْ يَحْكُمَ بِمَا هُوَ عِنْدَهُ يَقِينٌ .وَخَصّصَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ مَا يَحْكُمُ فِيهِ الْحَاكِمُ بِعِلْمِهِ فَقَالُوا :لَا يَقْضِي بِعِلْمِهِ فِي الْحُدُودِ وَيَقْضِي فِي غَيْرِ ذَلِكَ .وَخَصّصَ أَيْضًا أَبُو حَنِيفَةَ الْعِلْمَ الّذِي يَقْضِي بِهِ فَقَالَ :يَقْضِي بِعِلْمِهِ الّذِي عَلِمَهُ فِي الْقَضَاءِ، وَلَا يَقْضِي بِمَا عَلِمَهُ قَبْلَ الْقَضَاءِ.

وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنّهُ قَضَى بِعِلْمِهِ عَلَى أَبِي سُفْيَانَ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ .وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ :يَقْضِي بِعِلْمِهِ فِي الْمَجْلِسِ، أَعْنِي :بِمَا يَسْمَعُ، وَإِنْ لَمْ يُشْهَدْ عِنْدَهُ بِذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ كَمَا قُلْنَا. وَقَوْلُ الْمُغِيرَةِ هُوَ أَجْرَى عَلَى الْأُصُولِ؛ لِأَنّ الْأَصْلَ فِي هَذِهِ الشّرِيعَةِ لَا يَقْضِي إلّا بِدَلِيلٍ وَإِنْ كَانَتْ غَلَبَةُ الظّنّ الْوَاقِعَةُ بِهِ أَقْوَى مِنَ الظّنّ الْوَاقِعِ بِصِدْقِ الشّاهِدِينَ.

---

١٠ – أن يَدَّعِي أن فلانًا قتل أباه وهو يعلم أنه قتله غيره [٤٤].

الهوامش

(١) لسان العرب، مادة نكل.

(٢) الاختيار، ٢١٤/١٠.

(٣) المرجع السابق.

(٤) نيل الأوطار، ٩ / ١٩٤، ١٩٥.

(٥) الحديث سبق تخريجه.

(٦) حاشية ابن عابدين، ٥٣٤/٥، الخرشي على خليل، ٢١٤/٧، حاشية قليوبي، ٣٠٨/٤، كشاف القناع، ١٩٨/٤.

(٧) شرح فتح القدير ٧ / ٢٦٩، ٢٧١، تبيين الحقائق ٤ / ١٨٢، المغني ١٤ / ٧٧، ٧٨.

(٨) سورة النمل: من الآية رقم ٢٩.

(٩) الحديث أخرجه الترمذي، كتاب الديات، باب ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها، برقم (١٤١٥) ١٩/٤، وقال الترمذي: حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وأبو داود، كتاب الفرائض، باب في المرأة ترث من دية زوجها، برقم (٢٩٣٧) ٥٨/٣، وابن ماجة، كتاب الديات، باب الميراث من الدية، برقم (٢٦٤٢) ٨٨٣/٢.

(١٠) مسند الإمام أحمد، ٣١٠/٤، ٣١١.

(١١) مسند الإمام أحمد، ٣١٠/٤، ٣١١.

(١٢) هي الآية رقم ٦٤ من سورة آل عمران.

(١٣) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب دعاء النبي إلى الإسلام، برقم (٢٧٨٢) ١٠٧٤/٣.

(١٤) أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان برقم (٦٤) ٣٦/١.

(١٥) بدائع الصنائع، ٧/٧.

(١٦) تبصرة الحكام، ١٩/٢.

(١٧) شرح منتهى الإرادات، ٥٠٤/٣.

(١٨) أدب القضاء، لابن أبي الدم، ص ٤٧٦.

(١٩) يراجع في تفصيل هذه المسألة: بدائع الصنائع، ٧/٧، شرح فتح القدير، ٢٧٢/٧، روضة الطالبين ٨ / ١٦٠، وما بعدها، أدب القاضي، لابن أبي الدم، ص ٤٦٧، الحاوي، للماوردي، ٢٣٠/١٦، تبصرة الحكام، لابن فرحون، ٩/٢ – ٢١، المغني ٧٩/١٤، ٨٠.

(٢٠) الحاوي الكبير، ٢٢٦/١٦، ٢٢٧، تكملة المجموع، للمطيعي، ٢٢/ ٤٠٨ وما بعدها.

(٢١) الحاوي الكبير، ٢٣٤/١٦.

(٢٢) بلغة السالك، ٣١٢/٢.

(٢٣) بلغة السالك، ٣١٢/٢، مغني المحتاج، ٢٩٦/٦، المغني، ٣١/١٤، شرح كتاب النيل وشفاء العليل، ٨٠/١٣.

(٢٤) المبسوط، ١٠٥/١٦، البحر الزخار، ١٣٠/٦، ١٣١، معني المحتاج، ٢٩٦/٦، المغني، ٣١/١٤، ٣٢.

(٢٥) المحلى، ٤٢٦/٩، المغني، ٣١/١٤، المبسوط، ١٠٥/١٦، نهاية المحتاج، ٢٥٩/٨ وما بعدها، حاشية الشرقاوي على التحرير، ٤٩٥/٢.

(٢٦) سورة النور: من الآية ٤.

(٢٧) الحاوي الكبير، ٣٢٢/١٦.

(٢٨) أخرجه البخاري، كتاب الشهادات، باب من أقام البينة بعد اليمين، برقم (٢٦٨٠) ٣٤٠/٥، ومسلم، كتاب الأقضية، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة، برقم (١٧١٣) ١٢٨/٥.

(٢٩) نيل الأوطار، ٩ / ١٩٨.

(٣٠) نيل الأوطار، ٩ / ١٩٨.

(٣١) أخرجه الترمذي، كتاب أبواب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود، برقم (١٤٢٤) ٣٣/٤.

(٣٢) الاختيار، ٢ / ١٢١، ١٢٢.

(٣٣) سورة النساء: الآية ١٣٥.

(٣٤) المحلى، ٤٩/٩.

(٣٥) الحديث سبق تخريجه.

(٣٦) المغني، ٣١/١٤.

(٣٧) كنز العمال، ٦٦٦/١٢.

(٣٨) المغني، ٣٣/١٤، د/ إبراهيم بدوي: تعيين القاضي وأعوانه، ٤٧/٢.

(٣٩) حاشية الجمل على شرح المنهج، ٣٤٩/٥، بداية المجتهد، ٥٨٧/٢.

(٤٠) المغني، ٣٣/٣٢/١٤.

(٤١) نيل الأوطار، ١٩٩/٩.

(٤٢) د/ محمد رأفت عثمان: النظام القضائي في الفقه الإسلامي، ص ٥١٤، ٥١٥.

(٤٣) إعلام الموقعين، لابن القيم، ١٠/١.

(٤٤) مواهب الجليل، ٦ / ١٢٣، مغني المحتاج، ٦ / ٢٩٧، المبسوط، ١٦ / ١٠٨.

الْفَصْلُ الرّابعُ
فِي الْإِقْرَارِ [١]

---

(١) **تعريف الإقرار:**

لغة: مأخوذ من مادة قر، وهو ضد الجحود، أو هو وضع الشيء في قراءة، فكأن المقر جعل الحق في موضعه ،أو هو الإذعان للحق والاعتراف به [١].

وفي اصطلاح الفقهاء:

اختلف الفقهاء في تعريفه:

عرفه الحنفية بأنه: إخبار عن ثبوت حقٍ للغير على نفسه [٢].

وقال المالكية: الإقرار هو الاعتراف بما يوجب حقاً على قائله بشرطه [٣].

وقال الشافعية: الإقرار هو إخبار عن حقٍ سابق [٤].

وعرفه الحنابلة بأنه: إظهار مكلفٍ مختارٍ ما عليه لفظا أو كتابةً أو إشارةً من أخرسٍ أو على موكله أو موليه أو موروثه بما يمكن صدقه [٥].

وعموما فإن الاعتراف هو: قول صادر عن المتهم يقر فيه على نفسه، وبإرادةٍ حرةٍ وواعيةٍ بصحة ارتكابه الجريمة المنسوبة إليه كلها أو بعضها، بصفته فاعلا أصليا، أو شريكا فيها.

والإقرار في اصطلاح الشرع مرادف للاعتراف، ويقصد به: أن يقر شخص لآخر أو لله تعالى بحقٍ في مالٍ أو دم، أو هو إظهار مطلقٍ مختارٍ ما عليه أو ما يثبت ارتكابه لفعل يستوجب عقوبةً شرعا، أو هو: الاعتراف بواقعةٍ جنائيةٍ شرعية، فيشمل الاعتراف بأي اعتداء [٦].

مشروعية الإقرار:

قامت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على مشروعية الإقرار، وبالتالي اعتباره وسيلةً من وسائل الإثبات المعتبرة في الشريعة الإسلامية:

=

أولا: من الكتاب:

قوله تعالى: ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ﴾ (٧).

وجه الدلالة:

في هذه الآية أمر من الله تعالى للمؤمنين بإقامة العدل وقول الحق ولو على النفس، لأن معنى قوله "قوامين بالقسط" أي مواظبين على العدل مجدين في إقامته، ومعنى "شهداء لله ولو على أنفسكم" أي: تقيمون شهادتكم لوجه الله ولو على أنفسكم بأن تقروا عليها .

ثانيا: من السنة :

استدلوا بما رواه مسلم أن رجلًا من الأعراب أتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، أنشدك الله ألا قضيت لي بكتاب الله، فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي، فقال رسول الله ﷺ: قل، قال: إن ابنى كان عسيفا عند هذا، فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابنى الرجم، فافتديت منه بمائة شاةٍ ووليدة، فسألت أهل العلم، فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله ﷺ: والذى نفسى بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فغدا إليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله ﷺ فرجمت (٨).

فهذا الحديث دليل مؤكد لا يقبل الجدل على أن الإقرار إذا تم صحيحا، فإنه يستوجب العقوبة الشرعية المقررة، بدليل أن النبي ﷺ رجم المرأة عند اعترافها.

ثالثا: الإجماع:

فقد أجمعت الأمة من لدن رسول الله ﷺ إلى يومنا هذا على أن الإقرار جائز، ويعمل به كدليلٍ، دون إنكارٍ من أي منهم، فكان ذلك إجماعا، وهو ما فعله أبو

=

وَأَمّا الْإِقْرَارُ إِذَا كَانَ بَيّنًا فَلَا خِلَافَ فِي وُجُوبِ الْحُكْمِ بِهِ، وَإِنّمَا النّظَرُ فِيمَنْ يَجُوزُ إِقْرَارُهُ مِمّنْ لَا يَجُوزُ، وَإِذَا كَانَ الْإِقْرَارُ مُحْتَمَلًا رُفِعَ الْخِلَافُ.

أَمّا مَنْ يَجُوزُ إِقْرَارُهُ مِمّنْ لَا يَجُوزُ فَقَدْ تَقَدّمَ.

وَأَمّا عَدَدُ الْإِقْرَارَاتِ الْمُوجِبَةِ فَقَدْ تَقَدّمَ فِي بَابِ الْحُدُودِ، وَلَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ أَنّ الْإِقْرَارَ مَرّةً وَاحِدَةً عَامِلٌ فِي الْمَالِ.

وَأَمّا الْمَسَائِلُ الّتِي اخْتَلَفُوا فِيهَا مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ مِنْ قِبَلِ احْتِمَالِ اللّفْظِ، وَأَنْتَ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَقِفَ عَلَيْهِ فَمِنْ كِتَابِ الْفُرُوعِ.

بكر ﷺ بالنسبة لغير المحصن الذي وقع على بكر، فإنه قد اعترف بجريمته، وأمر أبو بكر بجلده وتغريبه وكذلك رجم عمر بن الخطاب المرأة التي اعترفت أمامه بالزنا.

الهوامش

(١) لسان العرب، لابن منظور، ٣٩٨/٦.

(٢) البحر الرائق،٢٤٩/٧.

(٣) حاشية الصاوي على الشرح الصغير، ٥٢٥/٣.

(٤) أسنى المطالب، ٢٨٧/٢.

(٥) كشاف القناع، ٤٥٢/٦، ٤٥٣.

(٦) د/ حسنى الجندي: أصول الإجراءات الجزائية في الإسلام، ص ٢٦٨.

(٧) سورة النساء: من الآية ١٣٥.

(٨) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحدود، باب هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه٢٥١٥/٦ رقم٦٤٦٧، ومسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى١٢١/٥رقم٢٥.

الْبَابُ الرّابِعُ

فِي مَعْرِفَةِ مَنْ يُقْضَى عَلَيْهِ أَوْ لَهُ

وَأَمّا عَلَى مَنْ يَقْضِي؟ وَلِمَنْ يَقْضِي؟ فَإِنّ الْفُقَهَاءَ اتّفَقُوا عَلَى أَنّهُ يَقْضِي لِمَنْ لَيْسَ يُتّهَمُ عَلَيْهِ. وَاخْتَلَفُوا فِي قَضَائِهِ لِمَنْ يُتّهَمُ عَلَيْهِ، فَقَالَ مَالِكٌ :لَا يَجُوزُ قَضَاؤُهُ عَلَى مَنْ لَا تَجُوزُ عَلَيْهِ شَهَادَتُهُ، وَقَالَ قَوْمٌ :يَجُوزُ؛ لِأَنّ الْقَضَاءَ يَكُونُ بِأَسْبَابٍ مَعْلُومَةٍ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ الشّهَادَةُ.

وَأَمّا عَلَى مَنْ يَقْضِي؟ فَإِنّهُمُ اتّفَقُوا عَلَى أَنّهُ يَقْضِي عَلَى الْمُسْلِمِ الْحَاضِرِ. وَاخْتَلَفُوا فِي الْغَائِبِ وَفِي الْقَضَاءِ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ.

فَأَمّا الْقَضَاءُ عَلَى الْغَائِبِ فَإِنّ مَالِكًا، وَالشّافِعِيّ قَالَا :يَقْضِي عَلَى الْغَائِبِ الْبَعِيدِ الْغَيْبَةِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ :لَا يَقْضِي عَلَى الْغَائِبِ أَصْلًا، وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ، وَقَدْ قِيلَ عَنْ مَالِكٍ :لَا يَقْضِي فِي الرّبَاعِ الْمُسْتَحَقّةِ.

فَعُمْدَةُ مَنْ رَأَى الْقَضَاءَ حَدِيثُ هِنْدٍ الْمُتَقَدّمُ وَلَا حُجّةَ فِيهِ؛ لِأَنّهُ لَمْ يَكُنْ غَائِبًا عَنِ الْمِصْرِ. وَعُمْدَةُ مَنْ لَمْ يَرَ الْقَضَاءَ قَوْلُهُ – عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسّلَامُ :- فَإِنّمَا أَقْضِي لَهُ بِحَسَبِ مَا أَسْمَع ، وَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ عَنْ عَلِيّ أَنّ النّبِيّ – صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قَالَ لَهُ حِينَ أَرْسَلَهُ إلَى الْيَمَنِ» :لَا تَقْضِ لِأَحَدِ الْخَصْمَيْنِ حَتّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخَرِ [1].

---

(١) القضاء على الغائب من المسائل التي اختلفت فيها كلمة الفقهاء، وجاء خلافهم على قولين:

القول الأول:

ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة في قول والظاهرية =

والزيدية إلى جواز القضاء على الغائب [١].

القول الثاني:

ذهب الحنفية والشافعية في القديم وأحمد في رواية وابن الماجشون من المالكية إلى عدم جواز القضاء على الغائب [٢].

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بجواز القضاء على الغائب بالكتاب، والسنة، والأثر، والمعقول:

أولاً: من الكتاب:

استدلوا من الكتاب بقوله تعالى: ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ [٣] وقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ﴾ [٤].

وجه الدلالة:

أمر الله عز وجل بإقامة الشهادة، من غير تفريقٍ بين حاضرٍ وغائب، مما يدل على عموم الآيات وشمولها للقضاء على الغائب.

المناقشة:

يناقش الاستدلال بالآيتين بأنهما خارجان عن محل النزاع؛ فهو استدلال بعموم الآية، وليس فيهما نص على جواز القضاء على الغائب، ومما يؤيد خروجهما عن محل النزاع: السياق الذي وردتا فيه، فقد وردتا في حَثِّ الشاهد على آداء الشهادة حتى ولو كانت على نفسه أو والديه أو أقربائه، ولم يذكر أحدٌ من المفسرين أن هذه الآية تدل على جواز القضاء على الغائب [٥].

ثانيًا: من السنة:

استدلوا من السنة بدليلين:

الدليل الأول:

ما روي عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ

=

أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، فَلَا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ [٦].

وجه الدلالة:

دل الحديث على جواز القضاء على الغائب؛ حيث قضى ﷺ على أبي سفيان بالنفقة وهو غائب، كما أن ما حَكَمَ به النبي ﷺ بينة عادلة مسموعة، وبالتالي يجب القضاء بها كما لو كان الخصم حاضرًا [٧]

ونوقش الاستدلال بهذا الحديث بمناقشات ثلاث:

المناقشة الأولى:

إن هند زوج أبى سفيان لم تطلب من النبي ﷺ قضاءً، وإنما طلبت منه فتوى، فما صدر عن النبي ﷺ لها ليس حكما، ودليل ذلك أن النبي ﷺ لم يحلفها يمين القضاء على الغائب، كما أنه ﷺ لم يقدر لها المحكوم به، ولم تَجْرِ الدعوى وِفْقَ شروطها [٨].

الجواب:

يجاب عن ذلك: بوجود الفرق بين الفتوى والحكم من حيث الجزم: فالفتوى لا يكون بها جزم، بخلاف الحكم، فإنه يكون على سبيل الجزم كما في الحديث، ولو قال النبي ﷺ لها: لك أن تأخذي، أو لا بأس عليك أو نحو ذلك، ولم يقل: خذي لكان فتوى، فلما قطع بالأخذ كان حكمًا لا فتوى [٩].

المناقشة الثانية:

على فرض التسليم بأن ما قاله النبي ﷺ لهند حكم وليس بفتوى، فهو حكم على حاضر وليس على غائب؛ لأن هذه القضية كانت في مكة، وكان أبو سفيان حاضرًا آنذاك في هذا المكان، ومن شرط القضاء على الغائب أن يكون غائبًا عن البلد، ولا يقدر على الإتيان به [١٠].

وآبة ذلك: أن هندًا لما بايعت وجاء قوله "ولا يسرقن" قالت: قد كنت

=

أصبت من مال أبي سفيان، فقال أبو سفيان: فما أصبت من مالي فهو حلال لك [١١].

ويجاب عن ذلك:

بأن أبا سفيان وإن لم يكن غائبًا إلا أن ذلك يحتمل تعدد القصة، وما أورده ابن حجر في الفتح وقع لما بايعت ثم جاءت مرةً أخرى فسألت عن الحكم، وتكون فهمت من الأول إحلال أبي سفيان لها ما مضى، فسألت عما يستقبل [١٢].

المناقشة الثالثة:

إن النبي ﷺ حَكَمَ على أبى سفيان لعلمه بصحة ما ذكرت له هند، أي أنه كان مستندًا لعلمه في الحكم، والذي يدل على ذلك أن هندًا لم تقم بينة على ما ذكرت [١٣].

الجواب:

يجاب عن ذلك: بأن علم الحاكم ليس بأقل من البينة مع الاختلاف بين العلماء في حكم القضاء بعلم القاضي، واتفاقهم على القضاء بالبينة، فإذا جاز القضاء على الغائب بعلم القاضي، فمن باب أولى يجوز الحكم عليه بالبينة [١٤].

الدليل الثاني:

استدلوا من السنة بما روي عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ هُوَ وَرِجَالٌ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ، فَأُتِيَ مُحَيِّصَةُ فَأُخْبِرَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ وَطُرِحَ فِي فَقِيرٍ أَوْ عَيْنٍ، فَأَتَى يَهُودَ فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللهِ قَتَلْتُمُوهُ. قَالُوا: وَاللهِ مَا قَتَلْنَاهُ. فَأَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُمْ ذَلِكَ، ثُمَّ أَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ، فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ لِيَتَكَلَّمَ وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كَبِّرْ كَبِّرْ يُرِيدُ السِّنَّ، فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِذَلِكَ، فَكَتَبُوا إِنَّا وَاللهِ مَا قَتَلْنَاهُ، فَقَالَ

=

رَسُولُ اللهِ ﷺ: لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ قَالُوا: لَا. قَالَ: فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ قَالُوا: لَيْسُوا مُسْلِمِينَ، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمِائَةِ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارَ قَالَ سَهْلٌ: لَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ [١٥].

وجه الدلالة:

في الحديث دليل على جواز الحكم عل الغائب، حيث حكم النبي باليمين عليهم من غير حضور منهم.

وناقش ابن حزم هذا الدليل بقوله: "إننا على يقين - ولله الحمد - من أن رسول الله ﷺ لا يلزم أحدا دية إلا قاتلًا عمدًا، أو عاقلة قاتل خطأ أو من بيت مال المسلمين عمن لا عاقلة له، فإلزامه عليه السلام اليهود الدية لا يخلو بيقين لا إشكال فيه مع أحد وجهين لا ثالث لهما: إما أن يكونوا قاتلي عمد، أو إما أن يكونوا عاقلة قاتلي خطأ - هذا ما لا يمكن أن يكون سواه، فوجب أن ينظر أي الوجهين هو المراد في هذا المكان؟"[١٦].

ثالثًا: من الأثر:

استدلوا بما ثبت عن صحابة رسول الله ﷺ أنهم أجازوا القضاء على الغائب، سواء كانت هذه الإجازة بالقول أم بالفعل، ومن ذلك:

- ما ورد أن عمر كتب إلى أبي موسى: إنه بلغني أن ناساً من قبلك دعوا بدعوى الجاهلية... فإذا أتاك كتابي هذا فأنهكهم عقوبة في أموالهم وأجسامهم حتى يفرقوا إذا لم يفقهوا [١٧].

- حكم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان في المفقود أن امرأته تتربص أربع سنين وأربعة أشهر وعشرًا ثم تتزوج.

فكل الوقائع السابقة تتضمن قضاء على الغائب، وهي إنما صدرت من صحابة عاصروا الرسول وعايشوه، فكان ذلك دليلًا على جواز القضاء على

=

الغائب.

قال ابن حزم: "وهذا كله قضاء على الغائب" [١٨].

رابعًا: من المعقول:

استدلوا بوجهين:

الأول:

إن منع القاضي من القضاء على الغائب يؤدي إلى فسادٍ أكبر بكثيرٍ من المنفعة التي تُرْجَى من هذا المنع، فمن مضار المنع أنه يؤدى إلى ضياع حقوق الناس التي أمر الشرع بالحفاظ عليها وذلك أن باستطاعة أي إنسان التغيب والتواري عن مجلس الحكم، فإذا منعنا القضاء على الغائب، فنكون بذلك قد أجزنا تمرد المتمردين، وكافأناهم، وبذلك تبطل الأحكام الشرعية [١٩].

الثاني:

إن كثيرًا من فقهاء الحنفية لمسوا مدى الحرج والضرر الذي وقع فيه الناس من جراء منع القضاء على الغائب.

كذلك فقد أفتى متأخروا الحنفية بصحة حكم الحنبلي بطلاق امرأة غاب عنها زوجها، وتضررت من هذه الغيبة لعدم الإنفاق عليها أو غير ذلك من الأضرار [٢٠].

أدلة القول الثاني:

استدل المانعون للقضاء على الغائب بالكتاب، والسنة، والآثار، والمعقول:

أولًا: من الكتاب:

استدلوا بقوله تعالى: ﴿وَإِذا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ﴾ [٢١].

وجه الدلالة:

دل هذا الذم على وجوب الحضور للحكم، ولو نفذ الحكم مع الغيبة لم

=

يجب الحضور، ولم يستحق الذم، فدل ذلك على عدم جواز الحكم على الغائب.

المناقشة:

يناقش بأنه لا منافاة بين ذمهم على عدم الحضور وبين نفوذ الحكم عليهم، لأنه واجب عليهم عند الغيبة، فيمكن أن يجتمع الأمران: الذم على عدم الحضور، ونفوذ الحكم عليهم مع الغيبة [٢٢].

ثانيًا: من السنة:

استدلوا بما روي عَنْ عَلِيٍّ ﷺ، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ، قَالَ: قُلْتُ: تَبْعَثُنِي إِلَى قَوْمٍ يَكُونُ بَيْنَهُمْ أَحْدَاثٌ، وَلا عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ؟ قَالَ: إِنَّ اللهَ سَيَهْدِي لِسَانَكَ، وَيُثَبِّتُ قَلْبَكَ، قَالَ: فَمَا شَكَكْتُ فِي قَضَاءٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ بَعْدُ [٢٣].

وجه الدلالة:

إن قوله ﷺ: "فلا تقضين حتى تسمع كلام الآخر" لأنه يدل على أن الخصمين حاضرين مجلس الحكم، وليس للقاضي أن يحكم أحدهما دون سماع من الآخر، وإذا منع القاضي من الحكم لأحد الخصمين الحاضرين حتى يسمع من الآخر، فمن باب أولى ألا يحكم على الغائب [٢٤].

ونوقش الاستدلال بهذا الحديث بمناقشتين:

الأولى:

إن هذا الحديث في سنده مقال يمنع الاستدلال به، قال ابن حزم: "أما الخبر عن رسول الله فساقط، لأن شريكًا مدلس، وسماك بن حرب يقبل التلقين، وحنش بن المعتمر ساقط مطرح" [٢٥].

الثانية:

على فرض صحة هذا الحديث فهو لا يدل على منع القضاء على الغائب،

=

وغاية ما يدل عليه أنه يتناول الحالة التي يحضر الخصمان فيها إلى مجلس الحكم، والحاضر حكمه خلاف الغائب.

قال ابن حزم: "لو صحت الأخبار لما كان لهم بها متعلق أصلًا؛ لأنه ليس فيها ألا يُقْضَى على حاضر بدعوى خصمه دون سماع حجته، وهذا شيء لا نخالفهم فيه، ولا يجوز أن يُقْضَى على حاضرٍ ولا غائبٍ بقول خصمه، لكن بالذي أمر الله تعالى به من البينة العادلة فقط" (٢٦).

ثالثًا: من الأثر:

استدلوا بما روي عن عمرو بن عثمان بن عفان قال: أتى عمر بن الخطاب رجل قد فقئت عينه، فقال له عمر: تحضر خصمك، فقال له: يا أمير المؤمنين، أما بك من الغضب إلا ما أرى، فقال له عمر: فلعلك قد فقأت عيني خصمك معًا، فقال عمر: إذا سمعت حجة الآخر بان لك القضاء (٢٧).

المناقشة:

نوقش الاستدلال بهذا الأثر بما يلي:

أولًا:

إن في سند هذا الأثر راويان مجهولان هما: محمد الغفاري عن ابن أبي ذئب الجهني، قال عنهما ابن حزم: "ولا يدري من هما في خلق الله تعالى" أضف إلى ذلك: أن هذا الأثر مروي عن عمرو بن عثمان بن عفان وعمرو لم يدرك عمر بن الخطاب، إذ إنه ولد في الليلة التي توفي فيها عمر، فالأثر على هذا منقطع لا يصلح للاحتجاج به.

ثانيًا:

إن النقل الصحيح عن عمر وعثمان أنهما قضيا على الغائب إذا صح الحق، ولم يصح عن أحدٍ من الصحابة خلاف ذلك.

=

ثالثًا:

على فرض التسليم بصحة هذا الأثر، فليس فيه ما يدل على منع القضاء على الغائب، لأن الرجل المدعى عليه كان حاضرًا في المدينة وأتى بعدها، واتضح أن عينيه الاثنتين قد فقئتا، وبالتالي يسقط الاستدلال بالأثر [٢٨].

رابعًا:

من المعقول: استدلوا بقولهم: إن العملية القضائية تتم إما بالإقرار وإما بالبينة، والبينة يحتاج إليها لقطع المنازعة، ولا توجد المنازعة إلا في حالة الإنكار، وعندها تطلب البينة، فإذا أجزنا القضاء على الغائب نكون قد وقعنا في مخالفتين:

الأولى: أن الإنكار لم يوجد حتى يجوز سماع البينة.

الثانية: أننا إذا اعتبرناه منكرًا، وسمعنا البينة، ثم حضر الغائب فإن المسألة تحتمل وجهين: أحدهما: أن يقر بالدعوى، وبالتالي يكون اعتبارنا له منكرًا غير صحيح، الثاني: أن يطعن بالبينة التي استمعت ويبطل الحكم، وصون الحكم عن البطلان من أجل الفوائد وأولاها بالاعتبار.

المناقشة:

يناقش الاستدلال السابق بأن الغائب لا يحكم عليه إلا بشروط وضمانات تحمي حقه، وله الطعن في الحكم إن كان هناك وجه للطعن، وإذا كان الغائب بحاجة لحفظ حقه، فالحاضر أيضًا بحاجة لحفظ حقه، وربما يكون الشهود حاضرين الآن ويخشى من سفرهم، ولئلا يتخذ الغياب ذريعة لتعطيل الأحكام وضياع الحقوق تسمع الدعوى على الغائب [٢٩].

القول الراجح:

بعد عرض الأقوال وأدلتها ومناقشة ما أمكن منها أرى أن الأولى بالقبول هو القول بجواز القضاء على الغائب، إلا أن هذا الجواز ليس على إطلاقه؛ بل هو

=

مقيد بالشروط الآتية:

الشرط الأول:

تعسر إحضار المدعي.

الشرط الثاني:

أن يكون المدعى به حقًّا لآدمي، فإن كان حقًّا خالصًا لله تعالى فلا يصح القضاء به على الغائب، كحد شرب الخمر والزنا، لأن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة، بخلاف حقوق الآدميين، فإن فامت بينة على غائب بسرقة مال حكم القاضي بالمال دون عقوبة السرقة، لأن العقوبة هنا حق من حقوق الله، وأما المال فهو حق الإنسان [٣٠].

الشرط الثالث:

أن يصرح المدعي بالدعوى ويعين المُدَّعَى به من ناحية القدر والجنس.

الشرط الرابع:

أن يقيم المدعي البينة [٣١].

الشرط الخامس:

أن يكون للمُدَّعَى عليه مال أو وكيل أو كفيل في بلد الحكم، لأن ولاية القاضي واختصاصه محدد في منطقته وليس على جميع الناس، وهذا عند المالكية فقط، إذ لم يشترطه بقية الفقهاء لاستطاعة القاضي أن يكتب كتابًا بما ثبت عنده من بينة لقاضي البلد التي يقيم بها المحكوم عليه أو التي له بها مال [٣٢].

الشرط السادس:

أن يحلف المحكوم له يمين الاستظهار، وتسمى عند المالكية بيمين القضاء، ويمين الاستبراء، ويحلف المدعي هذه اليمين على سبيل الوجوب في حالة كون المدعى عليه غائبًا، أو يتيمًا، أو وقفًا، أو صبيًّا، أو مجنونًا أو على

=

الهوامش

(١) تبصرة الحكام، لابن فرحون، ١٠٧/١، بداية المجتهد، ٤٧٢/٢، حلية العلماء، ١٤٦/٨، أدب القضاء لابن أبي الدم، ص ٢٨٠، المغني لابن قدامة، ٤٨٥/١١، شرح منتهى الإرادات، ٤٩٧/٣، المحلى، ٣٦٦/٩، السيل الجرار، ٢٩٢/٤.

(٢) تبيين الحقائق، ١٩١/٤، مجمع الأنهر، ١٦٤/٢، نهاية المحتاج، ٤٣/١، المحرر في الفقه، ٢١٠/٢.

(٣) سورة النساء: من الآية رقم ١٣٥.

(٤) سورة الطلاق: من الآية رقم ٢.

(٥) أحكام القرآن، لابن العربي، ٥٠٧/١.

(٦) أخرجه البخاري، كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل، فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها من معروف، برقم (٥٠٤٩) ٢٠٥٢/٥، ومسلم، كتاب الأقضية، باب قضية هند، برقم (١٧١٤) ١٢٩/٥.

(٧) المبسوط، للسرخسي، ٣٩/١٧.

(٨) شرح النووي لصحيح مسلم، ١٨/١٢، المبدع، ٦٢/١٠.

(٩) مغني المحتاج، ٤٠٦/٤.

(١٠) شرح النووي لصحيح مسلم، ٨/١٢.

(١١) فتح الباري لشرح صحيح البخاري، ٦٧/٤.

(١٢) فتح الباري، ٥١٠/٩.

(١٣) شرح العناية على الهداية، ٤٠١/٦.

ميت.

(١٤) المحلى، ٣٧٠/٩.

(١٥) أخرجه مسلم، كتاب القسامة والمحاربين، باب القسامة، برقم (١٦٦٩) ١٠٠/٥.

(١٦) المحلى، ٦/١١.

(١٧) المحلى، ٣٧٠/٩.

(١٨) شرح العناية على الهداية، ٤٠١/٦.

(١٩) د/ عبد الناصر أبو البصل: نظرية الحكم القضائي بين الشريعة والقانون، ص ٢٠٨.

(٢٠) جامع الفصوليين، ٤٤/١.

(٢١) سورة النور: من الآية رقم ٤٨.

(٢٢) د/ محمد رأفت عثمان: النظام القضائي في الفقه الإسلامي، ص ٢٢٦.

(٢٣) الحديث سبق تخريجه.

(٢٤) السنن الكبرى، للبيهقي، ١٤٠/١٠.

(٢٥) المحلى، ٣٦٨/٩.

(٢٦) المحلى، لابن حزم، ٣٦٨/٩.

(٢٧) المحلى، ٣٦٨/٩.

(٢٨) المحلى، ٣٦٨/٩، ٣٦٩.

(٢٩) د/ عبد الناصر أبو البصل: نظرية الحكم القضائي، ص ٢١٣.

(٣٠) المغني، لابن قدامة، ٤٨٦/١١.

(٣١) د/ محمد رأفت عثمان: النظام القضائي في الفقه الإسلامي، ص ٢٣٤.

(٣٢) تبصرة الحكام، لابن فرحون، ١٠٦/١، مغنى المحتاج، ٤٠٩/٤.

الْبَابُ الْخَامِسُ

فِي كَيْفِيّةِ الْقَضَاءِ

وَأَمّا كَيْفَ يَقْضِي الْقَاضِي فَإِنّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ أَنْ يُسَوّيَ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ فِي الْمَجْلِسِ [1]، وَأَلّا يَسْمَعَ مِنْ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ، وَأَنْ يَبْدَأَ بِالْمُدّعِي

---

(١) ينبغي للقاضي أن يكون مع الخصوم بكيفية لا يشعر فيها أحدهم بميله، أو احتمال ميله، وعماد ذلك أن يسوي القاضي بين الخصوم، وهذه التسوية لها جوانب متعددة على النحو التالي:

أولًا:

يجب على القاضي أن يسوى بين الخصوم في الدخول عليه، فلا يأذن لأحدهما ويمنع الآخر، وإذا أقبل على أحدهما وجب عليه أن يقبل على الطرف الآخر، وإذا سمع من أحدهما فعليه أن يسمع من الآخر.

ولا يجوز له أن يُجْلِسَ أحدهما ويوقف الطرف الآخر، حتى لا ينسى الخصم عذر خصمه ويتذكر جلوسه أمام القاضي، وحتى لا يعتقد أن هذا من باب الميل والمحاباة.

ثانيًا:

يجب على القاضي أن يسوى بين الخصمين في قيامه لهما عند دخولهما مجلس القضاء، فلا يخص أحدهما بقيامٍ ويترك الآخر، فإما أن يقوم لهما معًا، أو لا يقوم.

وقد كره البعض القيام لهما جميعًا، حرصًا على هيبة القاضي ولأن أحدهما قد يكون شريفًا، والآخر وضيعًا، فيظن الشريف أن القيام له، فيزداد حجة في الخصومة، بينما ينكسر قلب الآخر، فترك القيام أقرب إلى العدل وأنفى للتهمة.

وهذا هو ما مضت عليه سيرة القضاة في الماضي، فقد روي أن الخليفة

=

فَيَسْأَلَهُ الْبَيِّنَةَ إِنْ أَنْكَرَ الْمُدّعَى عَلَيْهِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَإِنْ كَانَ فِي مَالِهِ وَجَبَتِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدّعَى عَلَيْهِ بِاتِّفَاقٍ، وَإِنْ كَانَتْ فِي طَلَاقٍ أَوْ نِكَاحٍ أَوْ قَتْلٍ وَجَبَتْ عِنْدَ الشّافِعِيّ بِمُجَرّدِ الدّعْوَى، وَقَالَ مَالِكٌ :لَا تَجِبُ إِلَّا مَعَ شَاهِدٍ.

وَإِذَا كَانَ فِي الْمَالِ فَهَلْ يُحَلِّفُهُ الْمُدّعَى عَلَيْهِ بِنَفْسِ الدّعْوَى؟ أَمْ لَا يُحَلِّفُهُ حَتّى يُثْبِتَ الْمُدّعِي الْخُلْطَةَ؟ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ، فَقَالَ جُمْهُورُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ :الْيَمِينُ تَلْزَمُ الْمُدّعَى عَلَيْهِ بِنَفْسِ الدّعْوَى؛ لِعُمُومِ قَوْلِهِ – عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسّلَامُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبّاسٍ : الْبَيّنَةُ عَلَى الْمُدّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدّعَى عَلَيْهِ، وَقَالَ مَالِكٌ :لَا تَجِبُ الْيَمِينُ إِلَّا بِالْمُخَالَطَةِ، وَقَالَ بِهَا السّبْعَةُ مِنْ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ.

وَعُمْدَةُ مَنْ قَالَ بِهَا النّظَرُ إِلَى الْمَصْلَحَةِ؛ لِكَيْلَا يَتَطَرّقَ النّاسُ بِالدّعَاوَى إِلَى تَعْنِيتِ

المهدي تقدم مع خصوم له وهو خليفة إلى قاضي البصرة عبد الله بن الحسن العنبري، فلما رآه مقبلًا أطرق إلى الأرض حتى جلس المهدي مع خصومه مجلس المتقاضين، فلما انقضى القضاء بين الخصمين قام القاضي فوقف بين يديه، فقال له الخليفة المهدي: والله لو قمت حين دخلت عليك لعزلتك، ولو لم تقم حين انقضى الحكم لعزلتك [١].

وإذا دخل الخصمان عند القاضي وألقيا عليه السلام، رَدَّ عليهما جملة واحدة، وإن سلم أحدهما انتظر حتى يسلم الآخر حتى يرد عليهما معًا، أما إن طال الفصل بين دخول أحد الخصمين والآخر فإنه يرد على واحدٍ منهما منفردا [٢].

كذلك أيضًا يجب على القاضي أن يسوي بين الخصمين في المجلس فقد رَوَى عبد الله بن الزبير أن الرسول ﷺ قضى أن يقعد الخصمان بين يدي القاضي [٣].

بَعْضِهِمْ بَعْضًا، وَإِذَايَةِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا. وَمِنْ هُنَا لَمْ يَرَ مَالِكٌ إِحْلَافَ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا إِذَا ادّعَتْ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهَا شَاهِدٌ، وَكَذَلِكَ إِحْلَافُ الْعَبْدِ سَيّدَهُ فِي دَعْوَى الْعِتْقِ عَلَيْهِ.

الهوامش

(١) أدب القضاء، لابن أبي الدم، ص ٨٣ وما بعدها.

(٢) مغني المحتاج،٦/٢١٤.

(٣) سبل السلام، ٤/٢٣٥.

كتاب الصيد والذبائح

إعداد
قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون
بالقاهرة

كِتَابُ الذَّبَائِحِ[١]

وَالْقَوْلُ الْمُحِيطُ بِقَوَاعِدِ هَذَا الْكِتَابِ يَنْحَصِرُ فِي خَمْسَةِ أَبْوَابٍ:

البابُ الأَوّلُ: فِي مَعْرِفَةِ مَحَلِّ الذَّبْحِ[٢] وَالنَّحْرِ[٣]، وَهُوَ الْمَذْبُوحُ أَوِ الْمَنْحُورُ.

الْبَابُ الثَّانِي: فِي مَعْرِفَةِ الذَّبْحِ وَالنَّحْرِ.

الْبَابُ الثَّالِثُ: فِي مَعْرِفَةِ الْآلَةِ الَّتِي بِهَا يَكُونُ الذَّبْحُ وَالنَّحْرُ.

الْبَابُ الرَّابِعُ: فِي مَعْرِفَةِ شُرُوطِ الذَّكَاةِ.

الْبَابُ الْخَامِسُ: فِي مَعْرِفَةِ الذَّابِحِ وَالنَّاحِرِ.

وَالْأُصُولُ هِيَ الْأَرْبَعَةُ، وَالشُّرُوطُ يُمْكِنُ أَنْ تَدْخُلَ فِي الأَرْبَعَة أَبْوَابٍ، وَالْأَسْهَلُ فِي التَّعْلِيمِ أَنْ يُجْعَلَ بَابًا عَلَى حِدَتِهِ.

---

(١) الذبائح: جمع لكلمة الذبيحة، والذبيحة: اسم لما يذبح من الحيوان. يراجع لسان العرب ٤٣٦/٢.

(٢) الذبح: قطع الحلقوم من باطن عند النصيل، وهو موضع الذبح من الحلق، ويكون في سائر الطيور والحيوانات. يراجع لسان العرب ٤٣٦/٢.

(٣) النحر: يقال: نحر البعير ينحره نحرًا؛ إذا طعنه في منحره حيث يبدو الحلقوم من أعلى الصدر، والأصل أن يكون في الإبل دون غيرها. يراجع لسان العرب ١٩٥/٥.

الْبَابُ الْأَوَّلُ

فِي مَعْرِفَةِ مَحَلِّ الذَّبْحِ وَالنَّحْرِ

وَالْحَيَوَانُ فِي اشْتِرَاطِ الذَّكَاةِ فِي أَكْلِهِ عَلَى قِسْمَيْنِ: حَيَوَانٌ لَا يَحِلُّ إِلَّا بِذَكَاةٍ[١]، وَحَيَوَانٌ يَحِلُّ بِغَيْرِ ذَكَاةٍ[٢]. وَمِنْ هَذِهِ مَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ وَمِنْهَا مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ.

وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْحَيَوَانَ الَّذِي يَعْمَلُ فِيهِ الذَّبْحُ، هُوَ: الْحَيَوَانُ الْبَرِّيُّ ذُو الدَّمِ الَّذِي لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ، وَلَا مَنْفُودِ الْمَقَاتِلِ[٣]، وَلَا مَيْئُوسٍ مِنْهُ بِوَقْذٍ أَوْ نَطْحٍ أَوْ تَرَدٍّ أَوِ افْتِرَاسِ سَبُعٍ أَوْ مَرَضٍ، وَأَنَّ الْحَيَوَانَ الْبَحْرِيَّ لَيْسَ يَحْتَاجُ إِلَى ذَكَاةٍ.

وَاخْتَلَفُوا فِي الْحَيَوَانِ الَّذِي لَيْسَ يَدْمَى مِمَّا يَجُوزُ أَكْلُهُ، مِثْلَ: الْجَرَادِ وَغَيْرِهِ، هَلْ لَهُ ذَكَاةٌ أَمْ لَا؟, وَفِي الْحَيَوَانِ الْمُدْمَي الَّذِي يَكُونُ تَارَةً فِي الْبَحْرِ، وَتَارَةً فِي

---

(١) مثاله: بهيمة الأنعام، وسائر الطيور؛ فلا يحل أكلها إلا بعد ذبحها أو نحر ما ينحر منها.

(٢) مثل: الحيوانات البحرية، ويدل عليه ما أخرجه البيهقي عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، بسند صحيح موقوفا عليه، قال: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: الْجَرَادُ والحِيتان، وَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ». يراجع السنن الكبرى للبيهقي (١٢١١).

(٣) أي: الذي أصيب في مقتل من المقاتل، وقد نص المالكية عليه بقولهم: "(إِلَّا الْمَوْقُوذَةَ) أَيْ الْمَضْرُوبَةَ بِحَجَرٍ أَوْ عَصًا (وَمَا) ذُكِرَ (مَعَهَا) فِي الْآيَةِ قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا كَالْمُنْخَنِقَةِ بِحَبْلٍ وَنَحْوِهِ وَالْمُتَرَدِّيَةِ مِنْ شَاهِقٍ أَوْ فِي بِئْرٍ أَوْ حُفْرَةٍ وَالنَّطِيحَةِ مِنْ أُخْرَى، وَمَا أَكَلَ بَعْضَهَا السَّبُعُ (الْمَنْفُوذَةَ) بَعْضَ (الْمَقَاتِلِ) فَلَا تَعْمَلُ فِيهَا الذَّكَاةُ". يراجع: الشرح الكبير للدردير ١١٣/٢.

الْبَرِّ، مِثْلَ: السُّلَحْفَاةِ وَغَيْرِهَا.

وَاخْتَلَفُوا فِي تَأْثِيرِ الذَّكَاةِ فِي الْأَصْنَافِ الَّتِي نُصَّ عَلَيْهَا فِي آيَةِ التَّحْرِيمِ[1]، وَفِي تَأْثِيرِ الذَّكَاةِ فِيمَا لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ، أَعْنِي: فِي تَحْلِيلِ الِانْتِفَاعِ بِجُلُودِهَا، وَسَلْبِ النَّجَاسَةِ عَنْهَا.

فَفِي هَذَا الْبَابِ إِذًا سِتُّ مَسَائِلَ أُصُولٌ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: فِي تَأْثِيرِ الذَّكَاةِ فِي الْأَصْنَافِ الْخَمْسَةِ الَّتِي نُصَّ عَلَيْهَا فِي الْآيَةِ؛ إِذَا أُدْرِكَتْ حَيَّةً.

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: فِي تَأْثِيرِ الذَّكَاةِ فِي الْحَيَوَانِ الْمُحَرَّمِ الْأَكْلِ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: فِي تَأْثِيرِ الذَّكَاةِ فِي الْمَرِيضَةِ.

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: فِي هَلْ ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ أَمْ لَا؟

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: هَلْ لِلْجَرَادِ ذَكَاةٌ أَمْ لَا؟

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: هَلْ لِلْحَيَوَانِ الَّذِي يَأْوِي فِي الْبَرِّ تَارَةً، وَفِي الْبَحْرِ تَارَةً؛ ذَكَاةٌ، أَمْ لَا؟

---

(1) يشير إلى الأصناف المذكورة في قول الله سبحانه وتعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ (سورة المائدة: ٣).

الْمَسْأَلَةُ الأُولَى: أَمَّا الْمُنْخَنِقَةُ[١]، وَالْمَوْقُوذَةُ[٢]، وَالْمُتَرَدِّيَةُ[٣]، وَالنَّطِيحَةُ[٤]، وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ[٥]؛ فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا ــ فِيمَا أَعْلَمُ ــ على أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَبْلُغِ الْخَنْقُ، أَوِ الْوَقْذُ مِنْهَا إِلَى حَالَةٍ، لَا يُرْجَى فِيهِ أَنَّ الذَّكَاةَ عَامِلَةٌ فِيهَا، أَعْنِي: أَنَّهُ إِذَا غَلَبَ الظَّنُّ أَنَّهَا تَعِيشُ، وَذَلِكَ: بِأَنْ لَا يُصَابَ لَهَا مَقْتَلٌ.

وَاخْتَلَفُوا إِذَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهَا تَهْلِكُ مِنْ ذَلِكَ بِإِصَابَةِ مَقْتَلٍ أَوْ غَيْرِهِ[٦]: فَقَالَ قَوْمٌ: تَعْمَلُ الذَّكَاةُ فِيهَا، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالْمَشْهُورُ مِنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ والزُّهْرِيِّ.

---

(١) المنخنقة: اسم فاعل من انخنقت الشاة ونحوها، فهي منخنقة؛ إذا خنقها شيءٌ فماتت بسبب ذلك. يراجع تفسير القرطبي ٤٨/٦.

(٢) الموقوذة: هي التي قُتلَت بالخشب أو بغيره، فَمَاتت من غير ذكاة. يراجع تفسير القرطبي ٤٨/٦.

(٣) المتردية: هي التي سقطت من مكان مرتفع كالجبل ونحوه، حتى ماتت من غير ذكاة. يراجع تفسير القرطبي ٤٩/٦.

(٤) النطيحة: فعيلة بمعنى مفعولة، أي: منطوحة، وهي التي نطحت حتى ماتت بسبب ذلك. يراجع تفسير القرطبي ٤٩/٦.

(٥) أي: مأكولة السبع، وهي: كل ما افترسه ذو ناب وأظفار من الحيوان كالأسد وغيره. يراجع تفسير القرطبي ٤٩/٦.

(٦) يبدأ ابن رشد رحمه الله ﷻ في الحديث عن الأصناف المذكورة في الآية؛ إذا أدركت حية، ثم ذكيت، هل تكون ذكاتها سببا في جواز أكل لحمها أم لا؟

وَقَالَ قَوْمٌ: لَا تَعْمَلُ الذَّكَاةُ فِيهَا[١]. وَعَنْ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ الْوَجْهَانِ، وَلَكِنَّ الْأَشْهَرَ أَنَّهَا لَا تَعْمَلُ فِي الْمَيْئُوسِ مِنْهَا.

وَبَعْضُهُمْ تَأَوَّلَ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّ الْمَيْئُوسَ مِنْهَا عَلَى ضَرْبَيْنِ: مَيْئُوسَةٌ مَشْكُوكٌ فِيهَا، وَمَيْئُوسَةٌ مَقْطُوعٌ بِمَوْتِهَا، وَهِيَ: الْمَنْفُوذَةُ الْمَقَاتِلِ عَلَى اخْتِلَافٍ بَيْنَهُمْ أَيْضًا فِي الْمَقَاتِلِ، قَالَ: فَأَمَّا الْمَيْئُوسَةُ الْمَشْكُوكُ فِيهَا؛ فَفِي الْمَذْهَبِ فِيهَا رِوَايَتَانِ مَشْهُورَتَانِ. وَأَمَّا الْمَنْفُوذَةُ الْمَقَاتِلِ فَلَا خِلَافَ فِي الْمَذْهَبِ الْمَنْقُولِ أَنَّ الذَّكَاةَ لَا تَعْمَلُ فِيهَا، وَإِنْ كَانَ يَتَخَرَّجُ فِيهَا الْجَوَازُ عَلَى وَجْهٍ ضَعِيفٍ.

وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: اخْتِلَافُهُمْ فِي مَفْهُومِ قَوْلِه تَعَالَى: ﴿إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾[٢]. هَلْ هُوَ اسْتِثْنَاءٌ مُتَّصِلٌ[٣]؟ فَيَخْرُجُ مِنَ الْجِنْسِ بَعْضُ مَا يَتَنَاوَلُهُ اللَّفْظُ، وَهُوَ: الْمُنْخَنِقَةُ، وَالْمَوْقُوذَةُ، وَالْمُتَرَدِّيَةُ، وَالنَّطِيحَةُ، وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ، عَلَى عَادَةِ الِاسْتِثْنَاءِ الْمُتَّصِلِ، أَمْ هُوَ اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ[٤] لَا تَأْثِيرَ لَهُ فِي الْجُمْلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ؛ إِذْ

---

(١) وهذا قول مروي عن الشافعي ﷺ؛ قال ابن عبد البر: "قَالَ الْمُزَنِيُّ وَأَحْفَظُ لِلشَّافِعِيِّ قَوْلًا آخَرَ أَنَّهَا لَا تُؤْكَلُ إِذَا بَلَغَ مِنْهَا السَّبُعُ أَوِ التَّرَدِّي إِلَى مَا لَا حَيَاةَ مَعَهُ. قَالَ الْمُزَنِيُّ وَهُوَ قَوْلُ الْمَدَنِيِّينَ". يراجع الاستذكار لابن عبد البر ٢٥٣/٥، البيان في مذهب الإمام الشافعي ٥٣٤/٤.

(٢) (سورة المائدة: ٣).

(٣) الاستثناء المتصل: هو الذي له علاقة بالمتصل منه، فيخرج عن الجملة بعض ما يتناوله اللفظ. يراجع البيان والتحصيل لابن رشد ٤٢٤/١.

(٤) الاستثناء المنقطع: هو الذي انقطع عن الكلام السابق، ولا يخرج شيئا مما يتناوله اللفظ. يراجع البيان والتحصيل لابن رشد ٤٢٤/١.

كَانَ هَذَا أَيْضًا شَأْنَ الِاسْتِثْنَاءِ الْمُنْقَطِعِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ.

فَمَنْ قَالَ: إِنَّهُ مُتَّصِلٌ[١]؛ قَالَ: الذَّكَاةُ تَعْمَلُ فِي هَذِهِ الْأَصْنَافِ الْخَمْسَةِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: الِاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ[٢]؛ فَإِنَّهُ قَالَ: لَا تَعْمَلُ الذَّكَاةُ فِيهَا.

وَقَدِ احْتَجَّ مَنْ قَالَ: إِنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مُتَّصِلٌ؛ بِإِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّ الذَّكَاةَ تَعْمَلُ فِي الْمَرْجُوِّ مِنْهَا؛ قَالَ: فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ لَهُ تَأْثِيرٌ فِيهَا، فَهُوَ مُتَّصِلٌ.

وَقَدِ احْتَجَّ أَيْضًا مَنْ رَأَى أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ؛ بِأَنَّ التَّحْرِيمَ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِأَعْيَانِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الْخَمْسَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ، وَإِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ؛ فَالِاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ، وَذَلِكَ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِه تَعَالَى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [٣]؛ إِنَّمَا هُوَ لَحْمُ الْمَيْتَةِ، وَكَذَلِكَ لَحْمُ الْمَوْقُوذَةِ، وَالْمُتَرَدِّيَةِ، وَالنَّطِيحَةِ، وَسَائِرِهَا، أَيْ: لَحْمُ الْمَيْتَةِ بِهَذِهِ الْأَسْبَابِ، سِوَى الَّتِي تَمُوتُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهَا، وَهِيَ: الَّتِي تُسَمَّى مَيْتَةً أَكْثَرُ ذَلِكَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ، أَوْ بِالْحَقِيقَةِ.

قَالُوا: فَلَمَّا عُلِمَ أَنَّ الْمَقْصُودَ لَمْ يَكُنْ تَعْلِيقَ التَّحْرِيمِ بِأَعْيَانِ هَذِهِ وَهِيَ حَيَّةٌ، وَإِنَّمَا عُلِّقَ بِهَا بَعْدَ الْمَوْتِ؛ لِأَنَّ لَحْمَ الْحَيَوَانِ مُحَرَّمٌ فِي حَالِ الْحَيَاةِ، بِدَلِيلِ: اشْتِرَاطِ الذَّكَاةِ فِيهَا، وَبِدَلِيلِ قَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام: «مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ

---

(١) وهذا ما ذهب إليه الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو ما قاله ابن القاسم من المالكية. يراجع: تفسير القرطبي ٦/٥٠.

(٢) وهذا قول الإمام مالك ﷺ في رواية أشهب. يراجع البيان والتحصيل لابن رشد ١/٤٢٤.

(٣) (سورة المائدة: ٣).

حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ»[١]؛ وَجبَ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: ﴿إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ اسْتِثْنَاءً مُنْقَطِعًا؛ لَكِنَّ الْحَقَّ فِي ذَلِكَ أَنَّه كَيْفَمَا كَانَ الْأَمْرُ فِي الِاسْتِثْنَاءِ, فَوَاجِبٌ أَنْ تَكُونَ الذَّكَاةُ عاملة فِيهَا، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِنْ عَلَّقْنَا التَّحْرِيمَ بِهَذِهِ الْأَصْنَافِ فِي الْآيَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ؛ وَجَبَ أَنْ تَدْخُلَ فِي التَّذْكِيَةِ مِنْ جِهَةِ مَا هِيَ حَيَّةٌ, الْأَصْنَافُ الْخَمْسَةُ وَغَيْرُهَا؛ لِأَنَّهَا مَا دَامَتْ حَيَّةً مُسَاوِيَةً لِغَيْرِهَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْحَيَوَانِ، أَعْنِي: أَنَّهَا تَقْبَلُ الْحِلِّيَّةَ مِنْ قِبَلِ التَّذْكِيَةِ، الَّتِي يعد الْمَوْتُ مِنْهَا هُوَ سَبَبُ الْحِلِّيَّةِ. وَإِنْ قُلْنَا: إِنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مُتَّصِلٌ فَلَا خَفَاءَ بِوُجُوبِ ذَلِكَ.

وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ عُمُومَ التَّحْرِيمِ يُمْكِنُ أَنْ يُفْهَمَ مِنْهُ تَنَاوُلُ أَعْيَانِ هَذِهِ الْخَمْسَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَبْلَهُ، كَالْحَالِ فِي الْخِنْزِيرِ الَّذِي لَا تَعْمَلُ فِيهِ الذَّكَاةُ؛ فَيَكُونُ الِاسْتِثْنَاءُ عَلَى هَذَا رَافِعًا لِتَحْرِيمِ أَعْيَانِهَا، بِالتَّنْصِيصِ عَلَى عَمَلِ الذَّكَاةِ فِيهَا، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ؛ لَمْ يَلْزَمْ مَا اعْتَرَضَ بِهِ ذَلِكَ الْمُعْتَرِضُ، مِنَ الِاسْتِدْلَالِ عَلَى كَوْنِ الِاسْتِثْنَاءِ مُنْقَطِعًا.

وَأَمَّا مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْمَنْفُوذَةِ الْمَقَاتِلِ وَالْمَشْكُوكِ فِيهَا؛ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ مَذْهَبَهُ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مُنْقَطِعٌ، وَأَنَّهُ إِنَّمَا جَازَ تَأْثِيرُ الذَّكَاةِ فِي الْمَرْجُوَّةِ بِالْإِجْمَاعِ، وَقَاسَ الْمَشْكُوكَةَ عَلَى الْمَرْجُوَّةِ.

وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مُتَّصِلٌ، وَلَكِنَّ اسْتِثْنَاءَ هَذَا الصِّنْفِ مِنَ الْمَوْقُوذَةِ بِالْقِيَاسِ، وَذَلِكَ: أَنَّ الذَّكَاةَ إِنَّمَا يَجِبُ أَنْ تَعْمَلَ، فِي حِينِ يُقْطَعُ أَنَّهَا سَبَبُ

---

(١) أخرجه أبو داود والترمذي بسند فيه مقال، لكن البعض صححه. يراجع نيل الأوطار للشوكاني ١٦٦/٨.

الْمَوْتِ.

فَأَمَّا إِذَا شُكَّ هَلْ كَانَ مُوجِبُ الْمَوْتِ الذَّكَاةَ، أَوِ الْوَقْذَ، أَوِ النَّطْحَ، أَوْ سَائِرَهَا؟ فَلَا يَجِبُ أَنْ تَعْمَلَ فِي ذَلِكَ، وَهَذِهِ هِيَ حَالُ الْمَنْفُوذَةِ الْمَقَاتِلِ، وَلَهُ: أَنْ يَقُولَ إِنَّ الْمَنْفُوذَةَ الْمَقَاتِلِ فِي حُكْمِ الْمَيْتَةِ، وَالذَّكَاةُ مِنْ شَرْطِهَا: أَنْ تَرْفَعَ الْحَيَاةَ الثَّابِتَةَ، لَا الْحَيَاةَ الذَّاهِبَةَ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: وَأَمَّا هَلْ تَعْمَلُ الذَّكَاةُ فِي الْحَيَوَانَاتِ الْمُحَرَّمَاتِ الْأَكْلِ؛ حَتَّى تُطَهِّرَ بِذَلِكَ جُلُودَهُمْ؟ فَإِنَّهُمْ أَيْضًا اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ؛ فَقَالَ مَالِكٌ: الذَّكَاةُ تَعْمَلُ فِي السِّبَاعِ وَغَيْرِهَا مَا عَدَا الْخِنْزِيرَ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، إِلَّا أَنَّهُ اخْتَلَفَ الْمَذْهَبُ فِي كَوْنِ السِّبَاعِ فِيهِ مُحَرَّمَةً أَوْ مَكْرُوهَةً عَلَى مَا سَيَأْتِي فِي كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ وَالْأَشْرِبَةِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الذَّكَاةُ تَعْمَلُ فِي كُلِّ حَيَوَانٍ مُحَرَّمِ الْأَكْلِ[1]؛ فَيَجُوزُ بَيْعُ جَمِيعِ أَجْزَائِهِ وَالِانْتِفَاعُ بِهَا مَا عَدَا اللَّحْمَ.

وَسَبَبُ الْخِلَافِ: هَلْ جَمِيعُ أَجْزَاءِ الْحَيَوَانِ تَابِعَةٌ لِلَّحْمِ فِي الْحِلِّيَّةِ وَالْحُرْمَةِ، أَمْ لَيْسَتْ بِتَابِعَةٍ لِلَّحْمِ؟ فَمَنْ قَالَ: إِنَّهَا تَابِعَةٌ لِلَّحْمِ؛ قَالَ: إِذَا لَمْ تَعْمَلِ الذَّكَاةُ فِي اللَّحْمِ؛ لَمْ تَعْمَلْ فِيمَا سِوَاهُ.

---

(١) الصحيح أن مذهب الإمام الشافعي ﷺ أن الدباغ لا يطهر الكلب والخنزير؛ قال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله ﷻ:"(يطهر) أي الاندباغ (جلد غير كلب، وخنزير، وفرعهما) أي: فرع كل منهما مع غيره". يراجع: أسنى المطالب ١/١٧.

وَمَنْ رَأَى أَنَّهَا لَيْسَتْ بِتَابِعَةٍ؛ قَالَ: وَإِنْ لَمْ تَعْمَلْ فِي اللَّحْمِ، فَإِنَّهَا تَعْمَلُ فِي سَائِرِ أَجْزَاءِ الْحَيَوَانِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّهَا تَعْمَلُ فِي جَمِيعِ الْأَجْزَاءِ، فَإِذَا ارْتَفَعَ بِالدَّلِيلِ الْمُحَرِّمِ لِلَّحْمِ عَمَلُهَا فِي اللَّحْمِ؛ بَقِيَ عَمَلُهَا فِي سَائِرِ الْأَجْزَاءِ، إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى ارْتِفَاعِهِ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: وَاخْتَلَفُوا فِي تَأْثِيرِ الذَّكَاةِ فِي الْبَهِيمَةِ، الَّتِي أَشْرَفَتْ عَلَى الْمَوْتِ مِنْ شِدَّةِ الْمَرَضِ، بَعْدَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى عَمَلِ الذَّكَاةِ فِي الَّتِي لَا تُشْرِفُ عَلَى الْمَوْتِ؛ فَالْجُمْهُورُ: عَلَى أَنَّ الذَّكَاةَ تَعْمَلُ فِيهَا، وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ مَالِكٍ، وَرُوِيَ عَنْهُ: أَنَّ الذَّكَاةَ لَا تَعْمَلُ فِيهَا.

وَسَبَبُ الْخِلَافِ: مُعَارَضَةُ الْقِيَاسِ لِلْأَثَرِ، فَأَمَّا الْأَثَرُ: فَهُوَ مَا رُوِيَ «أَنَّ أَمَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا بِسَلْعٍ، فَأُصِيبَتْ شَاةٌ مِنْهَا، فَأَدْرَكَتْهَا فَذَكَّتْهَا بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: كُلُوهَا» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ[1] وَأَمَّا الْقِيَاسُ: فَلِأَنَّ الْمَعْلُومَ مِنَ الذَّكَاةِ؛ أَنَّهَا إِنَّمَا تُفْعَلُ فِي الْحَيِّ، وَهَذِهِ فِي حُكْمِ الْمَيِّتِ، وَكُلُّ مَنْ أَجَازَ ذَبْحَهَا؛ فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا تَعْمَلُ الذَّكَاةُ فِيهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ فِيهَا دَلِيلٌ عَلَى الْحَيَاةِ.

وَاخْتَلَفُوا فِيمَا هُوَ الدَّلِيلُ الْمُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ[2]، فَبَعْضُهُمُ اعْتَبَرَ الْحَرَكَةَ، وَبَعْضُهُمْ لَمْ يَعْتَبِرْهَا، وَالْأَوَّلُ: مَذْهَبُ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَالثَّانِي: مَذْهَبُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ. وَبَعْضُهُمُ اعْتَبَرَ فِيهَا ثَلَاثَ حَرَكَاتٍ: طَرْفُ الْعَيْنِ، وَتَحْرِيكُ الذَّنَبِ وَالرَّكْضُ

---

(1) أخرجه البخاري برقم: (٥٥٠١)، ولم أقف عليه في صحيح مسلم.

(2) أي: الدليل المعتبر في كون الحيوان حيا أو ميتا.

بِالرِّجْلِ، وَهُوَ مَذْهَبُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمَوَّازِ، وَبَعْضُهُمْ شَرَطَ مَعَ هَذِهِ التَّنَفُّسَ، وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ حَبِيبٍ.

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: وَاخْتَلَفُوا هَلْ تَعْمَلُ ذَكَاةُ الْأُمِّ فِي جَنِينِهَا أَمْ لَيْسَ تَعْمَلُ فِيهِ، وَإِنَّمَا هُوَ مَيْتَةٌ، أَعْنِي: إِذَا خَرَجَ مِنْهَا بَعْدَ ذَبْحِ الْأُمِّ؛ فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ ذَكَاةَ الْأُمِّ ذَكَاةٌ لِجَنِينِهَا، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ[1] وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ خَرَجَ حَيًّا ذُبِحَ وَأُكِلَ، وَإِنْ خَرَجَ مَيِّتًا فَهُوَ مَيْتَةٌ، وَالَّذِينَ قَالُوا: إِنَّ ذَكَاةَ الْأُمِّ ذَكَاةٌ لَهُ، بَعْضُهُمُ اشْتَرَطَ فِي ذَلِكَ تَمَامَ خِلْقَتِهِ وَنَبَاتَ شَعْرِهِ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ. وَبَعْضُهُمْ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: اخْتِلَافُهُمْ فِي صِحَّةِ الْأَثَرِ الْمَرْوِيِّ فِي ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ مَعَ مُخَالَفَتِهِ لِلْأُصُولِ، وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ هُوَ: قَالَ: «سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْبَقَرَةِ أَوِ النَّاقَةِ أَوِ الشَّاةِ يَنْحَرُهَا أَحَدُنَا فَنَجِدُ فِي بَطْنِهَا جَنِينًا أَنَأْكُلُهُ أَوْ نُلْقِيهِ؟ فَقَالَ: كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ». وَخَرَّجَ مِثْلَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ جَابِرٍ[2].

وَاخْتَلَفُوا فِي تَصْحِيحِ هَذَا الْأَثَرِ؛ فَلَمْ يُصَحِّحْهُ بَعْضُهُمْ، وَصَحَّحَهُ بَعْضُهُمْ، وَأَحَدُ مَنْ صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.

---

(١) وافقهم في ذلك أبو يوسف ومحمد من الحنفية والإمام أحمد ﷺ.
يراجع: تبيين الحقائق للزيلعي ٢٩٣/٥، كشاف القناع للبهوتي ٢٠٩/٦.

(٢) مسند الإمام أحمد (١١٣٤٣)، سنن ابن ماجه (٣١٩٩)، سنن أبي داود (٢٨٢٧)، سنن الترمذي (١٤٧٦).

وَأَمَّا مُخَالَفَةُ الْأَصْلِ فِي هَذَا الْبَابِ لِلْأَثَرِ؛ فَهُوَ أَنَّ الْجَنِينَ إِذَا كَانَ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ بِمَوْتِ أُمِّهِ؛ فَإِنَّمَا يَمُوتُ خَنْقًا، فَهُوَ مِنَ الْمُنْخَنِقَةِ الَّتِي وَرَدَ النَّصُّ بِتَحْرِيمِهَا، وَإِلَى تَحْرِيمِهِ ذَهَبَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَزْمٍ[١]، وَلَمْ يَرْضَ سَنَدَ الْحَدِيثِ.

وَأَمَّا اخْتِلَافُ الْقَائِلِينَ بِحِلِّيَّتِهِ فِي اشْتِرَاطِهِمْ نَبَاتَ الشَّعْرِ فِيهِ أَوْ لَا اشْتِرَاطِهِ؛ فَالسَّبَبُ فِيهِ مُعَارَضَةُ الْعُمُومِ لِلْقِيَاسِ، وَذَلِكَ: أَنَّ عُمُومَ قَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام: «ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ»؛ يَقْتَضِي أَنْ لَا يَقَعَ هُنَالِكَ تَفْصِيلٌ، وَكَوْنُهُ مَحَلًّا لِلذَّكَاةِ؛ يَقْتَضِي أَنْ يُشْتَرَطَ فِيهِ الْحَيَاةُ قِيَاسًا عَلَى الْأَشْيَاءِ الَّتِي تَعْمَلُ فِيهَا التَّذْكِيَةُ، وَالْحَيَاةُ لَا تُوجَدُ فِيهِ إِلَّا إِذَا نَبَتَ شَعْرُهُ وَتَمَّ خَلْقُهُ، وَيُعَضِّدُ هَذَا الْقِيَاسَ أَنَّ هَذَا الشَّرْطَ مَرْوِيٌّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ[٢].

وَرَوَى مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُونَ: إِذَا أَشْعَرَ الْجَنِينُ فَذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ»[٣].

وَرَوَى ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ، أَشْعَرَ أَوْ لَمْ يُشْعِرْ»[٤]. إِلَّا أَنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى سَيِّئُ

---

(١) المحلى لابن حزم ٩٦/٦.

(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن نافع، عن ابن عمر، قال: في الجنين "إذا خرج ميتا، وقد أشعر، أو وبر فذكاته ذكاة أمه". يراجع المصنف لعبد الرزاق رقم (٨٦٤٢).

(٣) المصنف لعبد الرزاق رقم (٨٦٤١).

(٤) سنن الدارقطني رقم (٤٧٣١).

الْحِفْظِ عِنْدَهُمْ.

وَالْقِيَاسُ يَقْتَضِي أَنْ تَكُونَ ذَكَاتُهُ فِي ذَكَاةِ أُمِّهِ مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ جُزْءٌ مِنْهَا، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فَلَا مَعْنَى لِاشْتِرَاطِ الْحَيَاةِ فِيهِ، فَيَضْعُفُ أَنْ يُخَصَّصَ الْعُمُومُ الْوَارِدُ فِي ذَلِكَ بِالْقِيَاسِ، الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ عَنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ[١].

الْمَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ: وَاخْتَلَفُوا فِي الْجَرَادِ؛ فَقَالَ مَالِكٌ: لَا يُؤْكَلُ مِنْ غَيْرِ ذَكَاةٍ، وَذَكَاتُهُ عِنْدَهُ هُوَ: أَنْ يُقْتَلَ إِمَّا بِقَطْعِ رَأْسِهِ، أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ.

وَقَالَ عَامَّةُ الْفُقَهَاءِ: يَجُوزُ أَكْلُ مَيْتَتِهِ، وَبِهِ قَالَ مُطَرِّفٌ. وَذَكَاةُ مَا لَيْسَ بِذِي دَمٍ عِنْدَ مَالِكٍ كَذَكَاةِ الْجَرَادِ.

وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي مَيْتَةِ الْجَرَادِ، هُوَ: هَلْ يَتَنَاوَلُهُ اسْمُ الْمَيْتَةِ أَمْ لَا فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [٢]؟ وَلِلْخِلَافِ سَبَبٌ آخَرُ، وَهُوَ: هَلْ هُوَ نَثْرَةُ حُوتٍ[٣] أَوْ حَيَوَانٌ بَرِّيٌّ؟[٤]

---

(١) رجح ابن رشد رحمه الله ﷻ مذهب جمهور الفقهاء في هذه المسألة.

(٢) (سورة المائدة: ٣).

(٣) نثرة حوت: أي: عطسته، وقيل: طرف الأنف؛ قال البدر العيني: "واختلف في قوله: (نثرة حوت)، فقيل: عطسته، وقيل: هو من تحريك النثرة، وهو طرف الأنف". يراجع: عمدة القاري للبدر العيني ١٠/١٦٤.

(٤) ومما يؤيد مذهب عامة الفقهاء في عدم احتياج الجراد إلى الذبح ما أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد حسن عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله =

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: وَاخْتَلَفُوا فِي الَّذِي يَتَصَرَّفُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ[١]، هَلْ يَحْتَاجُ إِلَى ذَكَاةٍ أَمْ لَا؟ فَغَلَّبَ قَوْمٌ فِيهِ حُكْمَ الْبَرِّ[٢]، وَغَلَّبَ آخَرُونَ حُكْمَ الْبَحْرِ[٣]، وَاعْتَبَرَ آخَرُونَ حَيْثُ يَكُونُ عَيْشُهُ وَمُتَصَرَّفُهُ مِنْهُمَا غَالِبًا[٤].

عليه وسلم: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ». يراجع مسند الإمام أحمد (٥٧٢٣)، سنن ابن ماجه (٣٢١٨).

(١) أي: يعيش في البر والبحر.

(٢) وبه قال الحنابلة. يراجع: كشاف القناع للبهوتي ٦/٢٠٤.

(٣) وبه قال المالكية في رواية. يراجع: التاج والإكليل ١/١٢٤.

(٤) وبه قال بعض المالكية. يراجع: المنتقى للباجي ٣/١٢٩.

الباب الثاني

في الذكاة [١]

وفي قواعد هذا الباب مسألتان:

المسألة الأولى: فِي أَنْوَاعِ الذَّكَاةِ الْمُخْتَصَّةِ بِصِنْفٍ صِنْفٍ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ.

الثَّانِيَةُ: فِي صِفَةِ الذَّكَاةِ.

المسألة الأولى: وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الذَّكَاةَ فِي بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ نَحْرٌ وَذَبْحٌ[٢]، وَأَنَّ مِنْ

---

١) الذكاة: اسم من ذكَّى الذبيحة تذكية إذا ذبحها، والتذكية الذبح والنحر، وهي في اللغة: مصدر ذكى، يقال: ذكيت الحيوان أي ذبحته أو نحرته، والذكاة: اسم المصدر. ومعناها إتمام الشيء. (لسان العرب ط دار المعارف (٣/ ١٥١٠).

وفي الاصطلاح: هي السبب الموصل لحل أكل الحيوان البري اختيارا، وقيل: التذكية: ذبح الحيوان في حلقه، أو في لَبَّته، إن كان مقدوراً عليه، أو بأيّ عقر مُزهِق للروح، إن لم يكن مقدورًا عليه، كصيد. والمذَكَّي: هو الحيوان الذي تمت تذكيته على وجه شرعي، بشروط مخصوصة، وكان مما يجوز أكله. ويعرف عند الحنفية: بأنه السبيل الشرعية لبقاء طهارة الحيوان، وحل أكله إن كان مأكولا، وحل الانتفاع بجلده وشعره إن كان غير مأكول. (الاختيار لتعليل المختار ٩/٥)، (الشرح الصغير بهامش بلغة السالك ٣١٢/١)، (المغني لابن قدامة ٨ / ٥٧٣)، و(القليوبي ٤ / ٣٤٢).

٢) المقصود في ذكاة بهيمة الأنعام سواء أكان بالذبح أو النحر: القَصد إلى استخراج الدم الحرام المستخبث من اللحم الحلال الطيب؛ قال تعالى: ﴿وَيُحِل لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ (سورة الأعراف: ١٥٧)، ولا =

سُنَّةِ الْغَنَمِ وَالطَّيْرِ الذَّبْحَ، وَأَنَّ مِنْ سُنَّةِ الْإِبِلِ النَّحْرَ(١)، وَأَنَّ الْبَقَرَ يَجُوزُ فِيهَا الذَّبْحُ وَالنَّحْرُ(٢).

وَاخْتَلَفُوا هَلْ يَجُوزُ النَّحْرُ فِي الْغَنَمِ وَالطَّيْرِ(٣)، وَالذَّبْحُ فِي الْإِبِلِ؟ فَذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ النَّحْرُ فِي الْغَنَمِ وَالطَّيْرِ، وَلَا الذَّبْحُ فِي الْإِبِلِ(٤)، وَذَلِكَ فِي غَيْرِ

تطيب إلا بخروج الدم المسفوح؛ على أن يكون هذا بأسهل الطرق على الحيوان. الفروق للقرافي (٣/ ١٢٣).

وذلك عملًا بما أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١٥٤٨)، عن شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ﷺ، قال: ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ».

(١) لأن الأصل في الذكاة إنما هو الأسهل على الحيوان، وما فيه نوع راحة له فهو أفضل، والأسهل في الإبل النحر؛ لخلو لبتها عن اللحم، واجتماع اللحم فيما سواها، والبقر والغنم ونحوها جميع عنقها لا يختلف. (بدائع الصنائع ٥ / ٤٠، ٤١)، (المقنع ٣ / ٥٣٨).

(٢) يعني أنه يجوز ذبح البقر بأن يكون في أعلى الرقبة مما يلي الرأس، كما يجوز نحرها، بأن يكون في أسفل الرقبة مما يلي الصدر؛ وذلك لأن عنق البقرة لما كان فوق الشاة ودون عنق البعير؛ جاز فيها الأمران الذبح والنحر؛ لقرب خروج الدم من جوفها بالذبح، والنحر فيه أخف.

(٣) ألحق الشافعية بالإبل؛ سائر ما طال عنقه كالإوز والبط وما قدر عليه من النَّعام. (الإقناع بحاشية البجيرمي ٤ / ٢٤٩).

(٤) أوجب المالكية النحر في الإبل؛ لقوله تعالى: ﴿فصل لربك وانحر﴾. (سورة الكوثر: ٢).

مَوْضِعِ الضَّرُورَةِ.

وَقَالَ قَوْمٌ: يَجُوزُ جَمِيعُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيُّ، وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ(١) وَقَالَ أَشْهَبُ(٢): إِنْ نُحِرَ مَا يُذْبَحُ أَوْ ذُبِحَ مَا يُنْحَرُ؛ أُكِلَ، وَلَكِنَّهُ يُكْرَهُ، وَفَرَّقَ ابْنُ بُكَيْرٍ بَيْنَ الْغَنَمِ وَالْإِبِلِ، فَقَالَ: يُؤْكَلُ الْبَعِيرُ بِالذَّبْحِ وَلَا تُؤْكَلُ الشَّاةُ بِالنَّحْرِ، وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي جَوَازِ ذَلِكَ فِي مَوْضِعِ الضَّرُورَةِ.

وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ مُعَارَضَةُ الْفِعْلِ لِلْعُمُومِ: فَأَمَّا الْعُمُومُ: فَقَوْلُهُ – صلى الله عليه

---

(١) وهو قول عطاء، قال البخاري: "باب النحر والذبح وقال ابن جريج، عن عطاء: «لا ذبح ولا منحر إلا في المذبح والمنحر» قلت: أيجزي ما يذبح أن أنحره؟ قال: «نعم، ذكر الله ذبح البقرة، فإن ذبحت شيئا ينحر جاز، والنحر أحب إلي، والذبح قطع الأوداج» قلت: فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاع؟ قال: «لا إخال»". صحيح البخاري (٧/ ٩٣).

(٢) هو أبو عمرو أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي العامري، اسمه مسكين، وأشهب لقبه: فقيه الديار المصرية في عصره، وُلِد بمصر سنة ١٤٠هـ، وقيل: ١٥٠هـ، وهو من كبار أصحاب مالك، حيث أخذ عنه العلم، وعن الليث، والفضيل بن عياض، وغيرهم، وروى عنه الحارث ابن مسكين، وابن عبد الحكم، وسحنون بن سعيد، وعبد الملك بن حبيب، وتوفي بها عام ٢٠٤هـ في رجب، وقيل في شعبان. يراجع: ترتيب المدارك للقاضي عياض(٣/٢٦٢)، وفيات الأعيان لابن خلكان(١/٢٣٨)، سير أعلام النبلاء للذهبي(٩/٥٠٠).

وسلم –: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ[١] وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ؛ فَكُلُوا»[٢] وَأَمَّا الْفِعْلُ: فَإِنَّهُ ثَبَتَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – نَحَرَ الْإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَذَبَحَ الْغَنَمَ»[٣] .

وَإِنَّمَا اتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِ ذَبْحِ الْبَقَرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ [البقرة: ٦٧]، وَعَلَى ذَبْحِ الْغَنَمِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾

---

(١) مَا أنهر الدَّم: أي أظهر الدم وأساله وصبّه بِكَثْرَة وأنهر أفعل من النَّهر شبه خُرُوج الدَّم من مَوَاضِع الذّبْح بجري المَاء فِي النَّهر. (تفسير غريب ما في الصحيحين (ص: ١١٧)

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه، ١٣٨/٣، برقم (٢٤٨٨)، ومسلم في صحيحه ١٥٥٨/٣، برقم (١٩٦٨)، ولفظ البخاري: عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، عن جده، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، فأصاب الناس جوع، فأصابوا إبلا وغنما، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، فعجلوا، وذبحوا، ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور، فأكفئت، ثم قسم، فعدل عشرة من الغنم ببعير فند منها بعير، فطلبوه، فأعياهم وكان في القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم، فحبسه الله ثم قال: «إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا»، فقال جدي: إنا نرجو – أو نخاف – العدو غدا، وليست معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ قال: "ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة".

(٣) فقد أخرج البخاري في صحيحه ١٣٩/٢) عن أنس ﷺ قال: " وَنَحَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قِيَامًا، وَذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ".

[الصافات: ١٠٧].

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: وَأَمَّا صِفَةُ الذَّكَاةِ: فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الذَّبْحَ الَّذِي يُقْطَعُ فِيهِ الْوَدَجَانِ(١) وَالْمَرِّيءُ(٢) وَالْحُلْقُومُ(٣)؛ مُبِيحٌ لِلْأَكْلِ.

وَاخْتَلَفُوا مِنْ ذَلِكَ فِي مَوَاضِعَ:

أَحَدُهَا: هَلِ الْوَاجِبُ قَطْعُ الْأَرْبَعَةِ كُلِّهَا أَوْ بَعْضِهَا؟ وَهَلِ الْوَاجِبُ فِي الْمَقْطُوعِ مِنْهَا قَطْعُ الْكُلِّ أَوِ الْأَكْثَرِ؟ وَهَلْ مِنْ شَرْطِ الْقَطْعِ أَنْ لَا تَقَعَ الْجَوْزَةُ إِلَى جِهَةِ الْبَدَنِ بَلْ إِلَى جِهَةِ الرَّأْسِ؟ وَهَلْ إِنْ قَطَعَهَا مِنْ جِهَةِ الْعُنُقِ جَازَ أَكْلُهَا أَمْ لَا؟ وَهَلْ إِنْ تَمَادَى فِي قَطْعِ هَذِهِ حَتَّى قَطَعَ النُّخَاعَ جَازَ ذَلِكَ أَمْ لَا؟ وَهَلْ مِنْ شَرْطِ الذَّكَاةِ أَنْ لَا يَرْفَعَ يَدَهُ حَتَّى يُتِمَّ الذَّكَاةَ أَمْ لَا؟

فَهَذِهِ سِتُّ مَسَائِلَ: فِي عَدَدِ الْمَقْطُوعِ، وَفِي مِقْدَارِهِ، وَفِي مَوْضِعِهِ، وَفِي نِهَايَةِ الْقَطْعِ، وَفِي جِهَتِهِ أَعْنِي: مِنْ قُدَّامٍ أَوْ خَلْفٍ، وَفِي صِفَتِهِ.

---

(١) الْوَدَجَانِ: عِرقان غليظان معروفان، موضعهما في العنق عن يمين ثغرة النحر ويسارها، تجري فيهما الدماء، وهما العرقان اللذان يقطعهما الذابح فلا يبقى معه حياة، والواحد وَدَج، والجمع أوداج. (تهذيب اللغة (١١/ ١١١)، (لسان العرب (٢/ ٣٩٧).

(٢) المريء: على وزن فعيل، هو مجرى الطعام والشراب. (طلبة الطلبة ص: ١٠١).

(٣) الحلقوم: هو مجرى النَّفَس- بفتح الفاء - لا يجري فيه الطعام والشراب. (المرجع السابق).

أما المسألة الأولى والثانية: فَإِنَّ الْمَشْهُورَ عَنْ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ هُوَ قَطْعُ الْوَدَجَيْنِ وَالْحُلْقُومِ، وَأَنَّهُ لَا يُجْزِئُ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ: وَقِيلَ عَنْهُ: بَلِ الْأَرْبَعَةُ. وَقِيلَ: بَلِ الْوَدَجَانِ فَقَطْ، وَلَمْ يَخْتَلِفِ الْمَذْهَبُ فِي أَنَّ الشَّرْطَ فِي قَطْعِ الْوَدَجَيْنِ هُوَ اسْتِيفَاؤُهُمَا.

وَاخْتُلِفَ فِي قَطْعِ الْحُلْقُومِ عَلَى الْقَوْلِ بِوُجُوبِهِ، فَقِيلَ: كُلُّهُ، وَقِيلَ: أَكْثَرُهُ. وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ، فَقَالَ: الْوَاجِبُ فِي التَّذْكِيَةِ هُوَ قَطْعُ ثَلَاثَةٍ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ مِنَ الْأَرْبَعَةِ: إِمَّا الْحُلْقُومُ وَالْوَدَجَانِ، وَإِمَّا الْمَرِيءُ وَالْحُلْقُومُ وَأَحَدُ الْوَدَجَيْنِ، أَوِ الْمَرِيءُ وَالْوَدَجَانِ[١]. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الْوَاجِبُ قَطْعُ الْمَرِيءِ وَالْحُلْقُومِ فَقَطْ[٢]. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: الْوَاجِبُ قَطْعُ أَكْثَرِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَرْبَعَةِ[٣].

وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ فِي ذَلِكَ شَرْطٌ مَنْقُولٌ، وَإِنَّمَا جَاءَ فِي ذَلِكَ أَثَرَانِ: أَحَدُهُمَا: يَقْتَضِي إِنْهَارَ الدَّمِ فَقَطْ، وَالْآخَرُ: يَقْتَضِي قَطْعَ الْأَوْدَاجِ مَعَ إِنْهَارِ الدَّمِ، فَفِي حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّهُ قَالَ – صلى الله عليه وسلم –: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ»[٤] وَهُوَ حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ.

---

(١) لأن للأكثر حكم الجميع. (بدائع الصنائع ٥ / ٤١).

(٢) لأن الذبح إزالة الحياة، والحياة لا تبقى بعد قطعهما عادة وقد تبقى بعد قطع الودجين. (نهاية المحتاج ٨ / ١٠٥).

(٣) لأنه إذا قطع الأكثر من كل واحد من الأربعة، فقد حصل المقصود بالذبح، وهو خروج الدم؛ لأنه يخرج به ما يخرج بقطع الجميع. (بدائع الصنائع ٥ / ٤١).

(٤) سبق تخريجه.

وَرُوِيَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – أَنَّهُ قَالَ: «مَا فَرَى[١] الْأَوْدَاجَ فَكُلُوا، مَا لَمْ يَكُنْ قَرْضَ[٢] نَابٍ أَوْ حَزَّ ظُفْرٍ»[٣].

فَظَاهِرُ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ يَقْتَضِي قَطْعَ بَعْضِ الْأَوْدَاجِ، فَقَطْ؛ لِأَنَّ إِنْهَارَ الدَّمِ يَكُونُ بِذَلِكَ، وَفِي الثَّانِي قَطْعُ جَمِيعِ الْأَوْدَاجِ، فَالْحَدِيثَانِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مُتَّفِقَانِ عَلَى قَطْعِ الْوَدَجَيْنِ: إِمَّا أَحَدُهُمَا، أَوِ الْبَعْضُ مِنْ كِلَيْهِمَا، أَوْ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَلِذَلِكَ وَجْهُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ أَنْ يُفْهَمَ مِنْ لَامِ التَّعْرِيفِ فِي قَوْلِهِ – صلى الله عليه وسلم –: «مَا فَرَى الْأَوْدَاجَ» الْبَعْضُ لَا الْكُلُّ؛ إِذْ كَانَتْ لَامُ التَّعْرِيفِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ قَدْ تَدُلُّ عَلَى الْبَعْضِ.

---

(١) الْفَرْي: هُوَ الْقَطْع. (عون المعبود ٦ / ٢٨٥).

(٢) القَرْض: القطع، وكذلك الحَزّ.

(٣) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ط إحياء التراث (٨/ ٢٥٠) ولفظه: عن أبي أمامة رضي الله عنه، قال: كانت جارية لأبي مسعود عقبة بن عمرو ترعى غنما، فعطبت شاة منها، فكسرت حجرا من المروة فذبحتها، فأتت بها إلى عقبة بن عمرو فأخبرته، فقال لها: اذهبي بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنت، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هَلْ أَفْرَيْتِ الأَوْدَاجَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: كُلُّ مَا فَرَى الأَوْدَاجَ مَا لَمْ يَكُنْ قَرْضَ سِنٍّ، أَوْ حَزَّ ظُفُرٍ".

تجدر الإشارة إلى أن قوله: (كل) ليس من الأكل؛ إذ لو كان كذلك، لوقع المعنى على الشفرة؛ لأن الشفرة هي التي تفري، وإنما معنى الحديث أن كل شيء أفرى الأوداج من عود أو حجر بعد أن يفريها فهو ذكي.

وَأَمَّا مَنِ اشْتَرَطَ قَطْعَ الْحُلْقُومِ وَالْمَرِّيءِ: فَلَيْسَ لَهُ حُجَّةٌ مِنَ السَّمَاعِ، وَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ مِنَ اشْتَرَطَ الْمَرِّيءَ وَالْحُلْقُومَ دُونَ الْوَدَجَيْنِ؛ وَلِهَذَا ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْوَاجِبَ هُوَ قَطْعُ مَا وَقَعَ الْإِجْمَاعُ عَلَى جَوَازِهِ؛ لِأَنَّ الذَّكَاةَ لَمَّا كَانَتْ شَرْطًا فِي التَّحْلِيلِ، وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ نَصٌّ فِيمَا يُجْزِي وَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْوَاجِبُ فِي ذَلِكَ مَا وَقَعَ الْإِجْمَاعُ عَلَى جَوَازِهِ، إِلَّا أَنْ يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى جَوَازِ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ ذَلِكَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّ مَا وَقَعَ الْإِجْمَاعُ عَلَى إِجْزَائِهِ لَيْسَ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ شَرْطًا فِي الصِّحَّةِ.

وأما المسألة الثالثة: فِي مَوْضِعِ الْقَطْعِ: وَهِيَ إِنْ لَمْ يَقْطَعِ الْجَوْزَةَ[1] فِي نِصْفِهَا، وَخَرَجَتْ إِلَى جِهَةِ الْبَدَنِ[2]، فَاخْتُلِفَ فِيهِ فِي الْمَذْهَبِ، فَقَالَ مَالِكٌ وَابْنُ الْقَاسِمِ: لَا تُؤْكَلُ، وَقَالَ أَشْهَبُ وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ وَابْنُ وَهْبٍ: تُؤْكَلُ.

وَسَبَبُ الْخِلَافِ: هَلْ قَطْعُ الْحُلْقُومِ شَرْطٌ فِي الذَّكَاةِ أَوْ لَيْسَ بِشَرْطٍ؟ فَمَنْ قَالَ إِنَّهُ شَرْطٌ قَالَ: لَا بُدَّ أَنْ تُقْطَعَ الْجَوْزَةُ، لِأَنَّهُ إِذَا قَطَعَ فَوْقَ الْجَوْزَةِ فَقَدْ خَرَجَ الْحُلْقُومُ سَلِيمًا، وَمَنْ قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ قَالَ: إِنْ قَطَعَ فَوْقَ الْجَوْزَةِ جَازَ.

وأما المسألة الرابعة: وَهِيَ إِنْ قَطَعَ أَعْضَاءَ الذَّكَاةِ مِنْ نَاحِيَةِ الْعُنُقِ، فَإِنَّ

---

(١) جوزة العنق: هي رأس الحلقوم، وتسمى المُغَلْصَمَةُ، وهي صفيحة غضروفية عند أصل اللسان، سرجية الشكل، مغطاة بغشاء مخاطي، وتنحدر إلى الخلف لتغطية فتحة الحنجرة لإقفالها في أثناء البلع. (مجمع اللغة العربية في المعجم الوسيط، مادة: (غلصم)

(٢) وذلك بأن يميل الذابح يده إلى جهة الذقن، فلا يقطع الجوزة، بل يجعلها كلها منحازة لجهة البدن مفصولة عن الرأس. (الشرح الصغير ١ / ٣١٣).

الْمَذْهَبَ لَا يَخْتَلِفُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ[١]، وَهُوَ مَذْهَبُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَابْنِ شِهَابٍ وَغَيْرِهِمْ. وَأَجَازَ ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَعِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ.

وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: هَلْ تَعْمَلُ الذَّكَاةُ فِي الْمَنْفُوذَةِ الْمَقَاتِلِ أَمْ لَا تَعْمَلُ؟ وَذَلِكَ أَنَّ الْقَاطِعَ لِأَعْضَاءِ الذَّكَاةِ مِنَ الْقَفَا لَا يَصِلُ إِلَيْهَا بِالْقَطْعِ إِلَّا بَعْدَ قَطْعِ النُّخَاعِ، وَهُوَ مَقْتَلٌ مِنَ الْمَقَاتِلِ، فَتَرِدُ الذَّكَاةُ عَلَى حَيَوَانٍ قَدْ أُصِيبَ مَقْتَلُهُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ سَبَبُ الْخِلَافِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ

وأما المسألة الخامسة: وَهِيَ أَنْ يَتَمَادَى الذَّابِحُ بِالذَّبْحِ حَتَّى يَقْطَعَ النُّخَاعَ): فَإِنَّ مَالِكًا كَرِهَ ذَلِكَ إِذَا تَمَادَى فِي الْقَطْعِ وَلَمْ يَنْوِ قَطْعَ النُّخَاعِ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ، لِأَنَّهُ إِنْ نَوَى ذَلِكَ فَكَأَنَّهُ نَوَى التَّذْكِيَةَ عَلَى غَيْرِ الصِّفَةِ الْجَائِزَةِ.

وَقَالَ مُطَرِّفٌ، وَابْنُ الْمَاجِشُونِ[٢]: لَا تُؤْكَلُ إِنْ قَطَعَهَا مُتَعَمِّدًا دُونَ جَهْلٍ،

---

(١) يعني أنه عند المالكية خلافا للجمهور: يشترط أن يقطع الذابح من مقدم العنق؛ فلا تحل الذبيحة إن ضربها من القفا؛ لأنها بقطع النخاع تصير ميتة.

(٢) هو أبو مروان عبد الملك ابن الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة بن المَاجَشُوْنِ التيمي مولاهم، المدني، المالكيّ، تلميذُ الإمام مالك. حدَّثَ عن: أبيه، وخاله؛ يوسف ابن يعقوب الماجشون، ومالك. كان فقيهاً فصيحاً، يُفْتِي أهل المدينة فِي زمانه، وكان ضريراً. قيل: إنه عَمِيَ في آخر عمره. توفي سنة ٢١٣هـ. ترتيب المدارك للقاضي عياض (١٣٦/٣)، الديباج المذهب لابن فرحون (١٥٣/١)، وفيات الأعيان لابن خلكان (١٦٦/٣).

وَتُؤْكَلُ إِنْ قَطَعَهَا سَاهِيًا أَوْ جَاهِلًا.

وأما المسألة السادسة: وَهِيَ هَلْ مِنْ شَرْطِ الذَّكَاةِ أَنْ تَكُونَ فِي فَوْرٍ وَاحِدٍ؟

فَإِنَّ الْمَذْهَبَ لَا يَخْتَلِفُ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ شَرْطِ الذَّكَاةِ، وَأَنَّهُ إِذَا رَفَعَ يَدَهُ قَبْلَ تَمَامِ الذَّبْحِ ثُمَّ أَعَادَهَا، وَقَدْ تَبَاعَدَ ذَلِكَ؛ أَنَّ تِلْكَ الذَّكَاةَ لَا تَجُوزُ. وَاخْتَلَفُوا إِذَا أَعَادَ يَدَهُ بِفَوْرِ ذَلِكَ وَبِالْقُرْبِ، فَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: إِنْ أَعَادَ يَدَهُ بِالْفَوْرِ أُكِلَتْ. وَقَالَ سَحْنُونٌ: لَا تُؤْكَلُ، وَقِيلَ: إِنْ رَفَعَهَا لِمَكَانِ الِاخْتِبَارِ؛ هَلْ تَمَّتِ الذَّكَاةُ أَمْ لَا، فَأَعَادَهَا عَلَى الْفَوْرِ: إِنْ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهَا لَمْ تَتِمَّ؛ أُكِلَتْ، وَهُوَ أَحَدُ مَا تُؤُوِّلَ عَلَى سَحْنُونٍ، وَقَدْ تُؤُوِّلَ قَوْلُهُ عَلَى الْكَرَاهَةِ.

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ اللَّخْمِيُّ: وَلَوْ قِيلَ عَكْسُ هَذَا لَكَانَ أَجْوَدَ؛ أَعْنِي أَنَّهُ إِذَا رَفَعَ يَدَهُ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ الذَّكَاةَ، فَتَبَيَّنَ لَهُ غَيْرُ ذَلِكَ، فَأَعَادَهَا؛ أَنَّهَا تُؤْكَلُ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ وَقَعَ عَنْ شَكٍّ، وَهَذَا عَنِ اعْتِقَادٍ ظَنَّهُ يَقِينًا، وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ مِنْ شَرْطِ الذَّكَاةِ قَطْعَ كُلِّ أَعْضَاءِ الذَّكَاةِ، فَإِذَا رَفَعَ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ تُسْتَتَمَّ كَانَتْ مَنْفُوذَةَ الْمَقَاتِلِ غَيْرَ مُذَكَّاةٍ؛ فَلَا تُؤَثِّرُ فِيهَا الْعَوْدَةُ؛ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ ذَكَاةٍ طَرَأَتْ عَلَى الْمَنْفُوذَةِ الْمَقَاتِلِ.

الْبَابُ الثَّالِثُ

فِيمَا تَكُونُ بِهِ الذَّكَاةُ

أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَفَرَى الْأَوْدَاجَ[١] مِنْ حَدِيدٍ أَوْ صَخْرٍ أَوْ عُودٍ أَوْ قَضِيبٍ[٢]، أَنَّ التَّذْكِيَةَ بِهِ جَائِزَةٌ.

وَاخْتَلَفُوا فِي ثَلَاثَةٍ: فِي السِّنِّ، وَالظُّفْرِ، وَالْعَظْمِ، فَمِنَ النَّاسِ مَنْ أَجَازَ التَّذْكِيَةَ بِالْعَظْمِ، وَمَنَعَهَا بِالسِّنِّ وَالظُّفْرِ، وَالَّذِينَ مَنَعُوهَا بِالسِّنِّ وَالظُّفْرِ مِنْهُمْ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَا مَنْزُوعَيْنِ أَوْ لَا يَكُونَا مَنْزُوعَيْنِ، فَأَجَازَ التَّذْكِيَةَ بِهِمَا إِذَا كَانَا مَنْزُوعَيْنِ، وَلَمْ يُجِزْهَا إِذَا كَانَا مُتَّصِلَيْنِ؛ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّ الذَّكَاةَ بِالسِّنِّ وَالْعَظْمِ مَكْرُوهَةٌ غَيْرُ مَمْنُوعَةٍ.

وَلَا خِلَافَ فِي الْمَذْهَبِ: أَنَّ الذَّكَاةَ بِالْعَظْمِ جَائِزَةٌ إِذَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَاخْتُلِفَ فِي

---

(١) أنهرَ الدمَ: أظهره وأساله وصبه بكثرة. قال أبو حفص النسفي: الإنهار: التسييل، ومنه النهْر الذي يسيل فيه الماء، والإفراء: القطع على وجه الإفساد، والفَرْيُ من حد ضرب هو القطع على وجه الإصلاح والأوداج جمع وَدَج - بفتح الدال- ولكل حيوان ودجان، وعروق الذبح أربعة: ودجان، والحلقوم، والمريء، فالحلقوم: مجرى النفس، والمريء: مجرى الطعام والشراب على وزن فعيل وهو مهموز). الغريبين في القرآن والحديث، لأبي عبيد الهروي، مادة: نهر (١٨٩٩/٦) نشر: مكتبة نزار مصطفى الباز- السعودية، ط: ١، ١٤١٩هـ-١٩٩٩م؛ وطلبة الطلبة، لأبي حفص النسفي (ص١٠١) نشر: المطبعة العامرة، مكتبة المثنى ببغداد، د. ط، تاريخ النشر: ١٣١١هـ.

(٢) القضيب: الغصن، وَالْجَمْعُ قُضُبٌ وقُضْبٌ، وقُضْبانٌ. لسان العرب، مادة: قضب (٦٧٨/١).

السِّنِّ وَالظُّفْرِ فِيهِ عَلَى الْأَقَاوِيلِ الثَّلَاثَةِ أَعْنِي: بِالْمَنْعِ مُطْلَقًا، وَالْفَرْقِ فِيهِمَا بَيْنَ الِانْفِصَالِ وَالِاتِّصَالِ، وَبِالْكَرَاهِيَةِ لَا بِالْمَنْعِ.

وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: اخْتِلَافُهُمْ فِي مَفْهُومِ النَّهْيِ الْوَارِدِ فِي قَوْلِهِ -عليه الصلاة والسلام- فِي حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ -رضي الله عنه-، وَفِيهِ: قَالَ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى، فَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ؟ فَقَالَ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ-: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفْرَ، وَأُحَدِّثُكُمْ عَنْهُ: أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ[1]»[2].

فَمِنَ النَّاسِ مَنْ فَهِمَ مِنْهُ أَنَّ ذَلِكَ لِمَكَانِ أَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ لَيْسَ فِي طَبْعِهَا أَنْ تُنْهِرَ الدَّمَ غَالِبًا؛ وَمِنْهُمْ مَنْ فَهِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ شَرْعٌ غَيْرُ مُعَلَّلٍ[3].

وَالَّذِينَ فَهِمُوا مِنْهُ أَنَّهُ شَرْعٌ غَيْرُ مُعَلَّلٍ: مِنْهُمْ مَن اعْتَقَدَ أَنَّ النَّهْيَ فِي ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، وَمِنْهُمْ مَن اعْتَقَدَ أَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، وَمِنْهُمْ مَن اعْتَقَدَ أَنَّ النَّهْيَ فِي ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْكَرَاهَةِ لَا عَلَى وَجْهِ الْحَظْرِ.

فَمَنْ فَهِمَ أَنَّ الْمَعْنَى فِي ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يُنْهِرُ الدَّمَ غَالِبًا قَالَ: إِذَا وُجِدَ مِنْهُمَا مَا

---

(١) المُدى: جمع مُدية وهي السكين، وقوله: "وأما الظفر فمدى الحبشة" معناه: أن الحبشة يدقون مذابح الشاة ويخرجونها بأظفارهم فيقيمون ذلك مقام الذبح بالمُدَى، وذلك في معنى الخنق. ينظر: شرح مسند الشافعي، للرافعي (١٧٢/٤) نشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إدارة الشؤون الإسلامية، قطر، الطبعة: الأولى، ١٤٢٨هـ-٢٠٠٧م.

(٢) سبق تخريجه.

(٣) أي أنه أمرٌ تعبُّدي، له علة، لكننا لم نقف على تلك العلة.

يُنْهِرُ الدَّمَ جَازَ، وَلِذَلِكَ رَأَى بَعْضُهُمْ أَنْ يَكُونَا مُنْفَصِلَيْنِ إِذْ كَانَ إِنْهَارُ الدَّمِ مِنْهُمَا إِذَا كَانَا بِهَذِهِ الصِّفَةِ أَمْكَنَ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ[١].

أثر الذبح بالسنِّ والظُّفُر على حلِّ الذبيحة وحرمتها:

وَمَنْ رَأَى أَنَّ النَّهْيَ عَنْهُمَا هُوَ مَشْرُوعٌ غَيْرُ مُعَلَّلٍ وَأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ قَالَ: إِنْ ذُبِحَ بِهِمَا لَمْ تَقَعِ التَّذْكِيَةُ ؛ وَإِنْ أَنْهرَ الدَّمُ [٢] وَمَنْ رَأَى أَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ قَالَ: إِنْ فَعَلَ وَأَنْهَرَ الدَّمَ أَثِمَ وَحَلَّتِ الذَّبِيحَةُ، وَمَنْ رَأَى أَنَّ النَّهْيَ عَلَى وَجْهِ الْكَرَاهِيَةِ كَرِهَ ذَلِكَ وَلَمْ يُحَرِّمْهُ، وَلَا مَعْنَى لِقَوْلِ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْعَظْمِ وَالسِّنِّ، فَإِنَّهُ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – قَدْ عَلَّلَ الْمَنْعَ فِي السِّنِّ بِأَنَّهُ عَظْمٌ.

---

(١) قال الفقيه الحنفي الإمام السرخسي في تعليل ذلك: "فإن الحبشة يستعملون في ذلك سنهم وظفرهم قبل النزع، وذكر في بعض الروايات ما خلا العض بالسن والقرض بالظفر والعض، والقرض إنما يتحقق في غير المنزوع عادة، ثم المنزوع آلة محددة يحصل بها تسييل الدم النجس فكانت كالسكين إلا أنه يكره الذبح بها لزيادة إيلام ومشقة على الحيوان. ولا يعد هذا الفصل من الإحسان في الذبح قال - عليه الصلاة والسلام -: «إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح...» الحديث". المبسوط، للسرخسي (٢/١٢) نشر: دار المعرفة- بيروت، د. ط، تاريخ النشر: ١٤١٤هـ - ١٩٩٣م.

(٢) وممن استثنى السن والظفر على كل حال: الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والحسن بن حي. الاستذكار، لابن عبد البر (٢٦٠/٥) دار الكتب العلمية- بيروت، ط: ١، ١٤٢١هـ- ٢٠٠٠م.

وَلَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ أَنَّهُ يُكْرَهُ غَيْرُ الْحَدِيدِ مِنَ الْمَحْدُودَاتِ مَعَ وُجُودِ الْحَدِيدِ لِقَوْلِهِ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ –: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ» خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ[1].

خلاصة المسألة:

أنَّ كلَّ ما تُمكِنُ التَّذكية به مما يسيل الدَّمَ وليس فيه معنًى يمنع من حصول التَّذكية، فالتّذكية به صحيحة جائزة، وأما مَا استثناه رسول الله (ﷺ) من السنِّ والظُّفُر، فقد اختلف الفقهاء في حكم التذكية به، فمن الفقهاء من يرى عدم جواز الذبح بالسنِّ والظُّفُر مطلقًا، مستدلًا بأنهما ليس من طبعهما الذبح، ومن الفقهاء من حمل النهي على الكراهة، لا على التحريم، ومن الفقهاء من يرى جواز الذبح بهما إذا كانا مفصولَين عن البدن؛ لأن هذا أمكن في إنهار الدم، أما إذا كانا متصلَين بالبدن فلا تصح التذكية بهما.

وسبب اختلافهم في هذه المسألة على هذا النحو: هو اختلافهم في فهم النهي الوارد في قوله (ﷺ): «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفْرَ، وَأُحَدِّثُكُمْ عَنْهُ: أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ».

ويترتب على ذلك الخلاف خلافٌ آخر في حكم الأكل من الذبيحة التي تم ذبحها بالسن أو الظفر؛ فمن الفقهاء من يرى أن الذبح بهما لا يُحِلُّ الذبيحةَ،

---

(1) صحيح مسلم، برقم: (١٩٥٥).

وأكلها محرم، ومنهم من يرى الكراهة لا التحريم، ومنهم من يرى أن الذابح بهما يأثم، لكن الذبيحة يحل أكلها، وأما مَن فرَّق بين العظم والسن؛ لأن النبي (ﷺ) علل المنع في السن بأنه عظم، مما يدلُّ على عدم الفرق بينهما في الحكم.

وعلى كلٍّ، فإنه يُكره استعمالُ آلةِ ذبحٍ من غير الحديد عند التمكن من استعمال الحديد؛ لأن في الحديد إحسان إلى الذبيحة، من جهة عدم تعذيبها، وقد قال (ﷺ): «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ»[1].

([1]) سبق تخريجه.

تدريبات على الباب:

ضع علامة (✓) عقب العبارة الصحيحة، وعلامة (X) عقب العبارة الخطأ، مع التعليل:

١- لا يجوز أن تكون آلة الذبح من غير الحديد. ( )

٢- الذبح بالظفر مما اتفق الفقهاء على حرمته مطلقًا. ( )

٣- التفريق بين العظم والسن في حكم الذبح بهما قولٌ مرجوح. ( )

٤- أجمع الفقهاء على عدم حلِّ الذبيحة إن تمت تذكيتها بالسن أو الظفر. ( )

٥- الإحسان إلى الذبيحة وعدم تعذيبها مقصد من المقاصد التي تجب مراعاتها عند الذبح. ( )

الْبَابُ الرَّابِعُ

فِي شُرُوطِ الذَّكَاةِ

وَفِي هَذَا الْبَابِ ثَلَاثُ مَسَائِلَ:

الْمَسْأَلَةُ الأُولَى: فِي اشْتِرَاطِ التَّسْمِيَةِ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: فِي اشْتِرَاطِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: فِي اشْتِرَاطِ النِّيَّةِ.

الْمَسْأَلَةُ الأُولَى: فِي اشْتِرَاطِ التَّسْمِيَةِ

قال المصنف: «وَاخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ التَّسْمِيَةِ عَلَى الذَّبِيحَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ: فَقِيلَ: هِيَ فَرْضٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ، وَقِيلَ: بَلْ هِيَ فَرْضٌ مَعَ الذِّكْرِ سَاقِطَةٌ مَعَ النِّسْيَانِ، وَقِيلَ: بَلْ هِيَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ. وَبِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ قَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ[١]، وَابْنُ عُمَرَ وَالشَّعْبِيُّ، وَابْنُ سِيرِينَ[٢]، وَبِالْقَوْلِ الثَّانِي قَالَ مَالِكٌ[٣]، وَأَبُو حَنِيفَةَ[٤]، وَالثَّوْرِيُّ[٥]، وَبِالْقَوْلِ

---

[١] ينظر المحلى لابن حزم (٦/٨١).

[٢] ذكر ابن حزم ذلك في المحلى عن ابن عمر والشعبي وابن سيرين. ينظر: المحلى لابن حزم (٦/٩٠).

[٣] ينظر الشرح الكبير للدردير (٢/١٠٦)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ومذهب الحنابلة في التسمية: المشهور من مذهب أحمد أن التسمية على الذبيحة شرط في إباحة أكلها مع الذكر وتسقط بالسهو. ينظر: الشرح الكبير على متن المقنع (١١/٥٨).

[٤] الاختيار لتعليل المختار (٥/٩)، والجوهرة النيرة (٢/١٨١).

[٥] ينظر المغني لابن قدامة (٩/٣٨٨).

الثَّالِثِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ[١]، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ ابْنِ عَبَّاس[٢]، وَأَبِي هُرَيْرَةَ[٣].

وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: مُعَارَضَةُ ظَاهِرِ الْكِتَابِ فِي ذَلِكَ لِلْأَثَرِ. فَأَمَّا الْكِتَابُ: فَقَوْلُهُ تَعَالَى: {وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [الأنعام: ١٢١].

وَأَمَّا السُّنَّةُ الْمُعَارِضَةُ لِهَذِهِ الْآيَةِ فَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ نَاسًا مِنَ الْبَادِيَةِ يَأْتُونَنَا بِلُحْمَانٍ وَلَا نَدْرِي أَسَمَّوُا اللَّهَ عَلَيْهَا أَمْ لَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهَا ثُمَّ كُلُوهَا»[٤].

---

[١] ينظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب (١/٥٤٠)، وتحفة المحتاج (٩/٣٢٥).

[٢] ينظر المغني لابن قدامة (٩/٣٨٨)، الاستذكار لابن عبد البر (٥/٢٥٠)، وشرح صحيح البخاري لابن بطال (٥/٤٠٥).

[٣] ينظر: الاستذكار لابن عبد البر (٥/٢٥٠).

[٤] الحديث أخرجه مالك بهذا السند في الموطأ، واللُحْمَانِ: جمع لَحم. ينظر: الموطأ(٣/٦٩٦)، وقال ابن عبد البر في التمهيد: لم يختلف عن مالك فيما علمت في إرسال هذا الحديث، وقد أسنده جماعة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة حدثنا عبد الله بن محمد بن أسد قال: حدثنا سعيد بن السكن قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا البخاري قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا أسامة بن حفص المدني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا فقال سموا الله ثم كلوا قال وكانوا حديثي العهد بالكفر، قال: البخاري تابعه علي عن الدراوردي، وتابعه أبو خالد، =

فَذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى أَنَّ الْآيَةَ نَاسِخَةٌ لِهَذَا الْحَدِيثِ، وَتَأَوَّلَ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، وَلَمْ يَرَ ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ، لِأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ كَانَ بِالْمَدِينَةِ، وَآيَةُ التَّسْمِيَةِ مَكِّيَّةٌ، فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ لِمَكَانِ هَذَا مَذْهَبَ الْجَمْعِ بِأَنْ حَمَلَ الْأَمْرَ بِالتَّسْمِيَةِ عَلَى النَّدْبِ، وَأَمَّا مَنِ اشْتَرَطَ الذِّكْرَ فِي الْوُجُوبِ فَمَصِيرًا إِلَى قَوْلِهِ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ –: «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»[(١)].

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: فِي اشْتِرَاطِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ.

قال المصنف: «وَأَمَّا اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ بِالذَّبِيحَةِ، فَإِنَّ قَوْمًا اسْتَحَبُّوا ذَلِكَ[(٢)]،

والطفاوي روى هذا الحديث مرسلا، كما رواه عن مالك جماعة منهم ابن عيينة ويحيى بن سعيد القطان ورواه مسندا جماعة منهم هؤلاء الذين ذكر البخاري وغيرهم. ينظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد.

(١) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تجاوز الله عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه». وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يُخرجاه". ينظر: المستدرك على الصحيحين (٢/٢١٦)، وهذا هو الراجح من الأقوال؛ لقوة ما استدلوا به من الآيات والأحاديث، وجمعًا بن الأدلة. وخلاصة المسألة: أن التسمية عند الذبح فيها ثلاثة أقول: الأول: الوجوب مطلقا ولا تسقط بحال، الثاني: الوجوب عند الذكر والسقوط عند السهو، والثالث: أنها سنة على أي حال، وسبب الخلاف معاضة ظاهر القرآن والآثار، والراجح أنها واجبة عند الذكر تسقط عند السهو لقوة الأدلة وجمعا بينها. والله أعلم.

(٢) التوجه سنة عند الشافعية: جاء في تحفة المحتاج: وأن يوجه للقبلة ذبيحته؛ =

وَقَوْمًا أَجَازُوا ذَلِكَ، وَقَوْمًا أَوْجَبُوهُ، وَقَوْمًا كَرِهُوا أَنْ لَا يُسْتَقْبَلَ بِهَا الْقِبْلَةُ[١]. وَالْكَرَاهِيَةُ وَالْمَنْعُ مَوْجُودَانِ فِي الْمَذْهَبِ[٢]، وَهِيَ مَسْأَلَةٌ مَسْكُوتٌ عَنْهَا، وَالْأَصْلُ فِيهَا الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى اشْتِرَاطِ ذَلِكَ، وَلَيْسَ فِي الشَّرْعِ شَيْءٌ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ أَصْلًا تُقَاسُ عَلَيْهِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ، إِلَّا أَنْ يُسْتَعْمَلَ فِيهَا قِيَاسٌ مُرْسَلٌ، وَهُوَ الْقِيَاسُ الَّذِي لَا يَسْتَنِدُ إِلَى أَصْلٍ مَخْصُوصٍ عِنْدَ مَنْ أَجَازَهُ، أَوْ قِيَاسُ شَبَهٍ بَعِيدٍ، وَذَلِكَ أَنَّ الْقِبْلَةَ هِيَ جِهَةٌ مُعَظَّمَةٌ، وَهَذِهِ عِبَادَةٌ، فَوَجَبَ أَنْ يُشْتَرَطَ فِيهَا الْجِهَةُ، لَكِنَّ هَذَا ضَعِيفٌ، لِأَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ عِبَادَةٍ تُشْتَرَطُ فِيهَا الْجِهَةُ مَا عَدَا الصَّلَاةَ، وَقِيَاسُ الذَّبْحِ عَلَى الصَّلَاةِ بَعِيدٌ، وَكَذَلِكَ قِيَاسُهُ عَلَى اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِالْمَيِّتِ»[٣].

للاتباع، وهو في الهدي، والأضحية آكد أي: مذبحها لا وجهها ليمكنه هو الاستقبال المندوب له أيضا، ولكون هذا عبادة. ينظر: تحفة المحتاج للرملي (٣٢٥/٩).

[١] يرى الحنفية كراهة ترك التوجه إلى القبلة؛ لمخالفته السنة. ينظر: حاشية ابن عابدين (٢٩٠/٦).

[٢] يقصد المؤلفُ – رحمه الله – مذهبه، وهو المذهب المالكي. قال ابن القاسم: "من السنة توجيه الذبيحة إلى القبلة، فإن لم يفعل أكلت وبئس ما صنع". التاج والإكليل للحطاب (٣٣٢/٣٣١/٤)

[٣] والراجح هو الاستحباب؛ لأسن الذبح فيه نوع عبادة فيستحب إذا أمكن التوجه إلى القبلة، فإن ترك الاستقبال فلا شيء هناك، لكن فاته الأولى؛ لما ذكرنا أن فيها نوع عبادة. وخلاصة المسألة: أن استقبال القبلة عند التذكية فيها عدة أقوال: القول الأول: استحباب الاستقبال، القول الثاني: الجواز، القول الثالث: وجوب استقبال القبلة، القول الرابع: كراهة أَنْ لَا يُسْتَقْبَلَ بِهَا =

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: فِي اشْتِرَاطِ النِّيَّةِ.

قال المصنف: «وَأَمَّا اشْتِرَاطُ النِّيَّةِ فِيهَا: فَقِيلَ فِي الْمَذْهَبِ بِوُجُوبِ ذَلِكَ[١]، وَلَا أَذْكُرُ فِيهَا خَارِجَ الْمَذْهَبِ فِي هَذَا الْوَقْتِ خِلَافًا فِي ذَلِكَ[٢]، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ قَوْلَانِ: قَوْلٌ بِالْوُجُوبِ، وَقَوْلٌ بِتَرْكِ الْوُجُوبِ، فَمَنْ أَوْجَبَ قَالَ[٣]: عِبَادَةٌ، لِاشْتِرَاطِ الصِّفَةِ فِيهَا وَالْعَدَدِ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ مِنْ شَرْطِهَا النِّيَّةُ. وَمَنْ لَمْ يُوجِبْهَا قَالَ: فِعْلٌ مَعْقُولٌ، يَحْصُلُ عَنْهُ فَوَاتُ النَّفْسِ الَّذِي هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ، فَوَجَبَ أَنْ لَا تُشْتَرَطَ فِيهَا النِّيَّةُ كَمَا يَحْصُلُ مِنْ غَسْلِ النَّجَاسَةِ إِزَالَةِ عَيْنِهَا»[٤].

الْقِبْلَةُ. وهي مسألة ليس فيها نص، ومدار الأدلة على القياس المرسل، والأقرب للرجحان ما سبق ذكره. والله أعلم.

[١] قال في الشرح الكبير: (ووجب في الذكاة بأنواعها نيتُها أي قصدُها، وإن لم يُلاحظ حلية الأكل، احترازا عما لو ضرب حيوانا بآلة فأصابت منحره أو أصابت صيدا أو قصدا مجرد إزهاق روحه من غير قصد تذكية لم يؤكل. ينظر الشرح الكبير للدردير (١٠٦/٢) مرجع سابق. وهو مذهب الحنابلة ينظر المغني لابن قدامة (٣٩٦/٩)

[٢] أي: لا يذكر المؤلف في نية الذبح خارج مذهبه – المالكي - خلافًا في وجوب التسمية.

[٣] أوجب نية الذبح.

[٤] وخلاصة المسألة أن في للعلماء قولان في نية ذبح حيوان بعينه: الوجوب وهذه مذهب المصنف والحنابلة، وعدم الوجوب ولم ينسبه المصنف لمذهب آخر، واعتذر لأنه لا يذكر حين تحريره المسألة، ولعله مذهب الحنفية، فمن أوجب قال عِبَادَةٌ، لِاشْتِرَاطِ الصِّفَةِ فِيهَا وَالْعَدَدِ، فَوَجَبَ أَنْ

=

يَكُونَ مِنْ شَرْطِهَا النِّيَّةُ. وَمَنْ لَمْ يُوجِبْهَا قَالَ: فِعْلٌ مَعْقُولٌ، يَحْصُلُ عَنْهُ فَوَاتُ النَّفْسِ الَّذِي هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ، فَوَجَبَ أَنْ لَا تُشْتَرَطَ فِيهَا النِّيَّةُ كَمَا يَحْصُلُ مِنْ غَسْلِ النَّجَاسَةِ إِزَالَةِ عَيْنِهَا. والراجح عدم الوجوب؛ لعدم ورود دليل بالوجوب، ولما ذكره المصنف: أنه فعل يحصل به فوات النفس فلا تجب فيه النية. والله أعلم.

أسئلة الباب:

س١: اذكر شروط الذكاة إجمالا.

س٢: اذكر سبب الخلاف بين الفقهاء في اشتراط التسمية عند التذكية.

س٣: اذكر اقوال الفقهاء في حكم التسمية عند الذكية.

س٤: اذكر أقوال الفقهاء فِي اشْتِرَاطِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ عند الذكية.

س٥: ما المقصود بالقياس المرسل الذي ذكره المصنف؟

س٦: ما هو مذهب المصنف الفقهي؟ وما حكم اشتراط النية عند التذكية في مذهب المصنف؟

س٧: هل ذكر المصنف أقوالا في حكم اشتراط النية عند الذبح؟

س٨: اذكر سبب وجوب اشتراط النية عند التذكية.

الْبَابُ الْخَامِسُ

فِيمَنْ تَجُوزُ تَذْكِيَتُهُ وَمَنْ لَا تَجُوزُ[١]

وَالْمَذْكُورُ فِي الشَّرْعِ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ: صِنْفٌ اتُّفِقَ عَلَى جَوَازِ تَذْكِيَتِهِ، وَصِنْفٌ اتُّفِقَ عَلَى مَنْعِ ذَكَاتِهِ، وَصِنْفٌ اخْتُلِفَ فِيهِ.

فَأَمَّا الصِّنْفُ الَّذِي اتُّفِقَ عَلَى ذَكَاتِهِ: فَمَنْ جَمَعَ خَمْسَةَ شُرُوطٍ: الْإِسْلَامَ وَالذُّكُورِيَّةَ وَالْبُلُوغَ وَالْعَقْلَ وَتَرْكَ تَضْيِيعِ الصَّلَاةِ.

وَأَمَّا الَّذِي اتُّفِقَ عَلَى مَنْعِ تَذْكِيَتِهِ: فَالْمُشْرِكُونَ عَبْدَةُ الْأَصْنَامِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ} [المائدة: ٣]، وَلِقَوْلِهِ: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [المائدة: ٣].

---

(١) المقصود بهذا العنوان: بيان من يجوز له أن يتولى الذبح، ومن ثمَ تحل ذبيحته، وبيان من لا يجوز له أن يتولى الذبح، ومن ثمَ لا تحل ذبيحته.

وقد ذكر ابن رشد أن هذه المسألة بها محل اتفاق، ومحل خلاف.

أولًا: محل الاتفاق في المسألة: اتفق الفقهاء على جواز الذبح وحل ذبيحته ممن توافرت فيه خمسة شروط، وهو: المسلم، الذكر، البالغ، العاقل، المحافظ على صلاته.

كما اتفقوا على عدم جواز الذبح وعدم حل ذبيحته من عَبْدَة الْأَصْنَامِ، وغيرهم ممن لا يدينون بدين سماوي؛ وذلك لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ} [المائدة: ٣]، وَلِقَوْلِهِ: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [المائدة: ٣].

محل الخلاف في المسألة: اخْتُلِفَوا بعد هذا الاتفاق فِي أَصْنَافٍ كَثِيرَةٍ، لَكِنَّ الْمَشْهُورَ مِنْهَا عَشَرَةٌ، وهم: أَهْلُ الْكِتَابِ، وَالْمَجُوسُ، وَالصَّابِئُونَ، وَالْمَرْأَةُ، وَالصَّبِيُّ، وَالْمَجْنُونُ، وَالسَّكْرَانُ، وَالَّذِي يُضَيِّعُ الصَّلَاةَ، وَالسَّارِقُ، وَالْغَاصِبُ.

وَأَمَّا الَّذِينَ اخْتُلِفَ فِيهِمْ: فَأَصْنَافٌ كَثِيرَةٌ، لَكِنَّ الْمَشْهُورَ مِنْهَا عَشَرَةٌ: أَهْلُ الْكِتَابِ، وَالْمَجُوسُ، وَالصَّابِئُونَ، وَالْمَرْأَةُ، وَالصَّبِيُّ، وَالْمَجْنُونُ، وَالسَّكْرَانُ، وَالَّذِي يُضَيِّعُ الصَّلَاةَ، وَالسَّارِقُ، وَالْغَاصِبُ.

فَأَمَّا أَهْلُ الْكِتَابِ: فَالْعُلَمَاءُ مُجْمِعُونَ عَلَى جَوَازِ ذَبَائِحِهِمْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} [المائدة: ٥] وَمُخْتَلِفُونَ فِي التَّفْصِيلِ، فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُمْ إِذَا لَمْ يَكُونُوا مِنْ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ[١] وَلَا مُرْتَدِّينَ[٢]، وَذَبَحُوا لِأَنْفُسِهِمْ، وَعُلِمَ أَنَّهُمْ سَمَّوُا اللَّهَ تَعَالَى عَلَى ذَبِيحَتِهِمْ، وَكَانَتِ الذَّبِيحَةُ مِمَّا لَمْ تُحَرَّمْ عَلَيْهِمْ فِي التَّوْرَاةِ وَلَا حَرَّمُوهَا هُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُ يَجُوزُ مِنْهَا مَا عَدَا الشَّحْمَ[٣].

---

(١) وذلك لأن الفقهاء مختلفون في حكم ذبائح نصارى تغلب من العرب هل تأخذ حكم ذبائح أهل الكتاب، فيصح ذبحهم، ويحل الأكل من ذبيحتهم، أم لا تأخذ حكم ذبائح أهل الكتاب، ومن ثَمَّ لا يصح ذبحهم، ولا يحل الأكل من ذبيحتهم؟

(٢) أي ارتدوا بعد دخولهم الإسلام إلى اليهودية، أو النصرانية؛ وذلك لأن المرتد حال ردته لا يقر على دين عند بعض الفقهاء.

(٣) هذه شروط وضعها الفقهاء لصحة ذبائح أهل الكتاب، وحلَ الأكل منها، وهي كما ورد بالنص:

١- ألا يَكُون الذابح مِنْ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ.

٢- ألا يَكُون الذابح مسلم قد ارتد عن الإسلام.

٣- ألا يَكُون الذابح من أهل الكتاب قد ذَبَح الذبيحة لِنْفُسِهِ.

٤- أن يعلم المسلم أَنَّهُمْ سَمَّوُا اللَّهَ تَعَالَى عَلَى ذَبِيحَتِهِمْ عند الذبح.

=

وَاخْتَلَفُوا فِي مُقَابِلَاتِ هَذِهِ الشُّرُوطِ [١]أَعْنِي: إِذَا ذَبَحُوا لِمُسْلِمٍ بِاسْتِنَابَتِهِ[٢]، أَوْ كَانُوا مِنْ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ أَوْ مُرْتَدِّينَ، وَإِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُمْ سَمَّوُا اللَّـهَ، أَوْ جُهِلَ

٥- ألا تكون الذَّبِيحَةُ مِمَّا لَمْ تُحَرَّمْ عَلَيْهِمْ فِي التَّوْرَاةِ وَلَا حَرَّمُوهَا هُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ، وهي المشار إليها في قول الله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ} [الأنعام: ١٤٦] هذا ما حرمه الله عليهم. فإن اختل شرط من هذه الشروط، فقد اختلف الفقهاء في صحة الذبح، وحل الأكل من الذبيحة.

أما ما حرموه على أنفسه، فهي الإبل، وألبانها، وقد أشار إلى هذا الإمام البغوي عند بيانه لسبب نزول قوله تعالى: { كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ} سورة آل عمران الآية ٩٤.

سبب نزول هذه الآية:

أن اليهود قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: تزعم أنك على ملة إبراهيم؟ وكان إبراهيم لا يأكل لحوم الإبل وألبانها وأنت تأكلها، فلست على ملته! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كان ذلك حلالا لإبراهيم عليه السلام" فقالوا: كلُّ ما نحرمه اليوم كان ذلك حرامًا على نوح وإبراهيم حتى انتهى إلينا فأنزل الله تعالى هذه الآية (٤) {كُلّ الطَّعَامِ كَانَ حِلا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ} يريد: سِوَى الميتة والدم، فإنه لم يكن حلالا قط. ينظر في هذا: تفسير البغوي (٦٧/٢).

(١) أي: إذا لم تتوافر هذه الشروط هل تصح ذبائحهم أم لا؟

(٢) أي: وكلهم المسلم؛ ليذبحوا له ذبيحته.

مَقْصُودُ ذَبْحِهِمْ[١]، أَوْ عُلِمَ أَنَّهُمْ سَمَّوْا غَيْرَ اللَّهِ مِمَّا يَذْبَحُونَهُ لِكَنَائِسِهِمْ وَأَعْيَادِهِمْ، أَوْ كَانَتِ الذَّبِيحَةُ مِمَّا حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ بِالتَّوْرَاةِ[٢] كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {كُلَّ ذِي ظُفُرٍ} [الأنعام: ١٤٦] أَوْ كَانَتْ مِمَّا حَرَّمُوهَا عَلَى أَنْفُسِهِمْ مِثْلَ الذَّبَائِحِ الَّتِي تَكُونُ عِنْدَ الْيَهُودِ فَاسِدَةً مِنْ قِبَلِ خِلْقَةٍ إلَهِيَّةٍ) . وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي الشُّحُومِ.

فَأَمَّا إذَا ذَبَحُوا بِاسْتِنَابَةِ مُسْلِمٍ: فَقِيلَ فِي الْمَذْهَبِ عَنْ مَالِكٍ: يَجُوزُ وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ. وَسَبَبُ الِاخْتِلَافِ: هَلْ مِنْ شَرْطِ ذَبْحِ الْمُسْلِمِ اعْتِقَادُ تَحْلِيلِ الذَّبِيحَةِ عَلَى الشُّرُوطِ الْإِسْلَامِيَّةِ فِي ذَلِكَ أَمْ لَا؟ فَمَنْ رَأَى أَنَّ النِّيَّةَ شَرْطٌ فِي الذَّبِيحَةِ قَالَ: لَا تَحِلُّ ذَبِيحَةُ الْكِتَابِيِّ لِمُسْلِمٍ، لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْهُ وُجُودُ هَذِهِ النِّيَّةِ.

وَمَنْ رَأَى أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَغَلَّبَ عُمُومَ الْكِتَابِ أَعْنِي: قَوْله تَعَالَى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: ٥] قَالَ: يَجُوزُ، وَكَذَلِكَ مَن اعْتَقَدَ أَنَّ نِيَّةَ الْمُسْتَنِيبِ تُجْزِي وَهُوَ أَصْلُ قَوْلِ ابْنِ وَهْبٍ[٣].

---

(١) أي: لم يعلم المسلم نيتهم من ذبحهم لهذه الذبيحة.

(٢) أي: لم يعلم المسلم قصدهم من ذبح هذه الذبيحة.

(٣) هذا الخلاف مترتب على فقدان شرط من الشروط المجمع عليها عند الفقهاء؛ لصحة ذبح أهل الكتاب، وحل الأكل من ذبائحهم، ألا وهو: عدم ذبح الكتابي للمسلم بطريقة الاستنابة، بأن يوكل المسلم الكتابي؛ ليذبح له.

وقد اختلف الفقهاء على رأيين:

الرأي الأول: يرى أصحابه الجواز.

الرأي الثاني: عدم الجواز.

سبب الخلاف: هل النية من شروط صحة الذبح للذابح أم لا؟

الأثر المترتب على هذا الخلاف: أن من رأى أن النية شرط لجواز الذبح، =

وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: وَهِيَ ذَبَائِحُ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ وَالْمُرْتَدِّينَ: فَإِنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى أَنَّ ذَبَائِحَ النَّصَارَى مِنَ الْعَرَبِ حُكْمُهَا حُكْمُ ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُجْزِ ذَبَائِحَهُمْ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ[1].

وَسَبَبُ الْخِلَافِ: هَلْ يَتَنَاوَلُ الْعَرَبَ الْمُتَنَصِّرِينَ اسْمُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، كَمَا يَتَنَاوَلُ ذَلِكَ الْأُمَمَ الْمُخْتَصَّةَ بِالْكِتَابِ، وَهُمْ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَالرُّومُ.

وحل الأكل من الذبيحة، قال بعدم الجواز؛ لأن النية لا تصح من الكتابي؛ لكونه غير أهل لها.

ومن قال بأن النية لا تشترط: قال بالجواز، وحل الأكل من الذبيحة.

(1) هذا الخلاف مترتب على فقدان شرط من الشروط المجمع عليها عند الفقهاء؛ لصحة ذبح أهل الكتاب، وحلّ الأكل من ذبائحهم، ألا وهو: ألا يكون الذابح من نصارى تغلب، وقد اختلف الفقهاء في هذا على رأيين:

الرأي الأول: يرح أصحابه صحة الذبح، وجواز الأكل من الذبيحة، وهو رأي الْجُمْهُور؛ وذلك بناء عَلَى أَنَّ ذَبَائِحَ النَّصَارَى مِنَ الْعَرَبِ حُكْمُهَا حُكْمُ ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ.

الرأي الثاني: يرح أصحابه عدم الجواز.

سبب الخلاف: هَلْ يَتَنَاوَلُ الْعَرَبَ الْمُتَنَصِّرِينَ اسْمُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، كَمَا يَتَنَاوَلُ ذَلِكَ الْأُمَمَ الْمُخْتَصَّةَ بِالْكِتَابِ، وَهُمْ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَالرُّومُ؟

الأثر المترتب على هذا الخلاف: أن من رأى أن ذبائح نصارى أهل تغلب من العرب، كذبائح أهل الكتاب، قال بالجواز، وحل الأكل من الذبيحة.

ومن رأى أن ذبائح نصارى أهل تغلب من العرب، ليست كذبائح أهل الكتاب: قال بعدم الجواز، وعدم حلّ الأكل من الذبيحة.

وَأَمَّا الْمُرْتَدُّ: فَإِنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى أَنَّ ذَبِيحَتَهُ لَا تُؤْكَلُ. وَقَالَ إِسْحَاقُ: ذَبِيحَتُهُ جَائِزَةٌ. وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: مَكْرُوهَةٌ.

وَسَبَبُ الْخِلَافِ: هَلِ الْمُرْتَدُّ لَا يَتَنَاوَلُهُ اسْمُ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذْ كَانَ لَيْسَ لَهُ حُرْمَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ أَوْ يَتَنَاوَلُهُ؟[١].

وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: وَهِيَ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ سَمَّوُا اللَّهَ عَلَى الذَّبِيحَةِ فَقَالَ الْجُمْهُورُ: تُؤْكَلُ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عَلِيٍّ، وَلَسْتُ أَذْكُرُ فِيهِ فِي هَذَا الْوَقْتِ خِلَافًا، وَيَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ الِاحْتِمَالُ بِأَنْ يُقَالَ: إِنَّ الْأَصْلَ هُوَ أَنْ لَا يُؤْكَلَ مِنْ تَذْكِيَتِهِمْ إِلَّا مَا كَانَ عَلَى شُرُوطِ الْإِسْلَامِ، فَإِذَا قِيلَ عَلَى هَذَا: إِنَّ التَّسْمِيَةَ مِنْ شَرْطِ التَّذْكِيَةِ وَجَبَ أَنْ لَا تُؤْكَلَ ذَبَائِحُهُمْ بِالشَّكِّ فِي ذَلِكَ[٢].

---

(١) هذا الخلاف مترتب على فقدان شرط من الشروط المجمع عليها عند الفقهاء؛ لصحة ذبح أهل الكتاب، وحلّ الأكل من ذبائحهم، ألا وهو ألا يكون الذابح قد ارتد بعد الإسلام، وقد اختلف الفقهاء على ثلاثة أراء:

الرأي الأول: قول الْجُمْهُور عَلَى أَنَّ ذَبِيحَتَهُ لَا تُؤْكَلُ.

الرأي الثاني: قول إِسْحَاق: ذَبِيحَتُهُ جَائِزَةٌ.

الرأي الثالث: قول الثَّوْرِيّ: مَكْرُوهَةٌ.

وَسَبَبُ الْخِلَافِ: هَلِ الْمُرْتَدُّ لَا يَتَنَاوَلُهُ اسْمُ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذْ كَانَ لَيْسَ لَهُ حُرْمَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ أَوْ يَتَنَاوَلُهُ؟

الأثر المترتب على هذا الخلاف: أن من قال إن اسم أَهْل الْكِتَابِ لَا يَتَنَاوَلُهُ، قال أَنَّ ذَبِيحَتَهُ لَا تُؤْكَلُ.

ومن قال إن اسم أَهْل الْكِتَابِ يَتَنَاوَلُهُ قال بجواز الأكل من ذبائحهم.

(٢) هذا هو الشرط الرابع من شروط صحة ذبيحة أهل الكتاب، وحلّ الأكل منها، =

وَأَمَّا إِذَا عُلِمَ أَنَّهُمْ ذَبَحُوا ذَلِكَ لِأَعْيَادِهِمْ وَكَنَائِسِهِمْ فَإِنَّ مِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ كَرِهَهُ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ. وَمِنْهُمْ مَنْ أَبَاحَهُ، وَهُوَ قَوْلُ أَشْهَبَ. وَمِنْهُمْ مَنْ حَرَّمَهُ، وَهُوَ الشَّافِعِيُّ[1].

وهو: أن يعلم المسلم أَنَّهُمْ سَمَّوُا اللَّهَ تَعَالَى عَلَى ذَبِيحَتِهِمْ عند الذبح. فإن لم يعلم بأنهم قد سَمَّوُا اللَّهَ تَعَالَى عَلَى ذَبِيحَتِهِمْ عند الذبح، فهل يجوز للمسلم أن يأكل منها أم لا؟

يقول ابن رشد بصحة الذبح، وحل الأكل منها، ولا يعلم في هذا خلاف، ثم يبين احتمالية وجود الخلاف في هذا بِأَنْ يُقَالَ: إِنَّ الْأَصْلَ هُوَ أَنْ لَا يُؤْكَلَ مِنْ تَذْكِيَتِهِمْ إِلَّا مَا كَانَ عَلَى شُرُوطِ الْإِسْلَامِ، مما يترتب عليه عدم جوز الأكل منها في هذه الحالة؛ إذ التسمية شرط من شروط الذبح في الإسلام، فإذا شك في التسمية، فلا تصح الذبيحة، ووَجَبَ أَنْ لَا تُؤْكَلَ ذَبَائِحُهُمْ بِالشَّكِّ فِي ذَلِكَ.

(١) هذا الخلاف مترتب على فقدان شرط من الشروط المجمع عليها عند الفقهاء لصحة ذبح أهل الكتاب، وحلّ الأكل من ذبائحهم، ألا وهو: أن يعلم المسلم أَنَّهُمْ سَمَّوُا اللَّهَ تَعَالَى عَلَى ذَبِيحَتِهِمْ عند الذبح، فإن عُلِمَ أَنَّهُمْ سَمَّوْا غَيْرَ اللَّهِ مِمَّا يَذْبَحُونَهُ لِكَنَائِسِهِمْ وَأَعْيَادِهِمْ، فهل تصح ذبيحتهم، ويحل للمسلم أن يأكل منها؟

اختلف الفقهاء في هذا على ثلاثة أراء:

الرأي الأول: كراهة الأكل منها، وهو قول الإمام مالك.

الرأي الثاني: إباحة الأكل منها، وهو قول أشهب.

الرأي الثالث: حرمة الأكل منها، وهو قول الإمام الشافعي.

وَسَبَبُ الْخِلَافِ: هَلِ الْمُرْتَدُّ لَا يَتَنَاوَلُهُ اسْمُ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذْ كَانَ لَيْسَ لَهُ حُرْمَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ أَوْ يَتَنَاوَلُهُ؟

=

وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ تَعَارُضُ عُمُومَيِ الْكِتَابِ فِي هَذَا الْبَابِ، وَذَلِكَ أَنَّ قَوْلَه تَعَالَى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: ٥] يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُخَصِّصًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [المائدة: ٣] . وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَوْله تَعَالَى: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [المائدة: ٣] مُخَصِّصًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: ٥] إِذْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَصِحُّ أَنْ يُسْتَثْنَى مِنَ الْآخَرِ.

فَمَنْ جَعَلَ قَوْله تَعَالَى: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [المائدة: ٣] مُخَصِّصًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: ٥] قَالَ: لَا يَجُوزُ مَا أُهِلَّ بِهِ لِلْكَنَائِسِ وَالْأَعْيَادِ. وَمَنْ عَكَسَ الْأَمْرَ قَالَ: يَجُوزُ(١).

وَأَمَّا إِذَا كَانَتِ الذَّبِيحَةُ مِمَّا حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ(٢)، فَقِيلَ: يَجُوزُ، وَقِيلَ: لَا

الأثر المترتب على هذا الخلاف: أن من قال إن اسْمُ أَهْلِ الْكِتَابِ لَا يَتَنَاوَلُهُ، قال إِنَّ ذَبِيحَتَهُ لَا تُؤْكَلُ، وحل الأكل من الذبيحة.

ومن أن من قال إن اسْم أَهْلِ الْكِتَابِ يَتَنَاوَلُهُ قال بجواز الأكل من ذبائحهم. عُلِمَ أَنَّهُمْ سَمَّوْا غَيْرَ اللَّهِ مِمَّا يَذْبَحُونَهُ لِكَنَائِسِهِمْ وَأَعْيَادِهِمْ

(١) يرجعَ سَبَبُ الخلاف في هذه المسألة إلى أن كلًا من الآيتين الكريمتين الوارد ذكرهما في نص ابن رشد عام؛ مما أوجد تعارض بينهما من ناحية الظاهر أيهما عامة والأخرى مخصصة له، فَمَنْ جَعَلَ قَوْله تَعَالَى: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [المائدة: ٣] مُخَصِّصًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: ٥] قَالَ: لَا يَجُوزُ مَا أُهِلَّ بِهِ لِلْكَنَائِسِ وَالْأَعْيَادِ. وَمَنْ عَكَسَ بأن قال أن قَوْله تَعَالَى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}،[المائدة: ٥] مُخَصِّصًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [المائدة: ٣] قَالَ: يَجُوزُ.

(٢) ما حُرم عليهم على نوعين:

=

يَجُوزُ، وَقِيلَ: بِالْفَرْقِ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ بِالتَّوْرَاةِ، أَوْ مِنْ قِبَلِ أَنْفُسِهِمْ أَعْنِي بِإِبَاحَةِ مَا ذَبَحُوا مِمَّا حَرَّمُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَمَنْعِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وَقِيلَ: يُكْرَهُ وَلَا يُمْنَعُ، وَالْأَقَاوِيلُ الْأَرْبَعَةُ مَوْجُودَةٌ فِي الْمَذْهَبِ[١]: الْمَنْعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَالْإِبَاحَةُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ وَابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، وَالتَّفْرِقَةُ عَنْ أَشْهَبَ[٢].

وَأَصْلُ الِاخْتِلَافِ: مُعَارَضَةُ عُمُومِ الْآيَةِ لِاشْتِرَاطِ نِيَّةِ الذَّكَاةِ أَعْنِي اعْتِقَادَ تَحْلِيلِ الذَّبِيحَةِ بِالتَّذْكِيَةِ[٣].

الأول: ما حرمه الله عليهم في التوراة، والذي بينته الآية الكريمة في سورة المائدة بالآية السابق ذكرها.

النوع الثاني: ما حرموه على أنفسهم بأنفسهم؛ لاعتقادهم تحريمه عليهم.

وقد اختلف العلماء في هذا على أربعة أراء: فَقِيلَ: يَجُوزُ، وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ، وَقِيلَ: بِالْفَرْقِ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ بِالتَّوْرَاةِ، أَوْ مِنْ قِبَلِ أَنْفُسِهِمْ أَعْنِي بِإِبَاحَةِ مَا ذَبَحُوا مِمَّا حَرَّمُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَمَنْعِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وَقِيلَ: يُكْرَهُ وَلَا يُمْنَعُ، وَالْأَقَاوِيلُ الْأَرْبَعَةُ مَوْجُودَةٌ فِي الْمَذْهَبِ: الْمَنْعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَالْإِبَاحَةُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ وَابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، وَالتَّفْرِقَةُ عَنْ أَشْهَبَ.

(١) أي هذه الأقوال الأربعة التي هي نتاج اختلاف فقهاء المذاهب في المسألة موجودة أيضًا عند المالكية.

(٢) هؤلاء العلماء من أتباع الإمام مالك (رحمه الله).

(٣) يرجع سبب الخلاف في هذه الآية إلى وجود تعارض بين الآية الكريمة التي يقول الله فيها {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: ٥]، والتي تفيد بعمومها حلَ ذبيحة أهل الكتاب دون نظر لاعتقاده حالة الذبحة هل تحل بالتذكية أم لا؟، وجعل هذا الاعتقاد شرطًا في حلِّ ذبيحة أهل الكتاب، فَمَنْ جعل اعتقاد حلِّ الذبيحة بالتذكية شرطًا فِي التَّذْكِيَةِ قَالَ:

=

فَمَنْ قَالَ: ذَلِكَ شَرْطٌ فِي التَّذْكِيَةِ قَالَ: لَا تَجُوزُ هَذِهِ الذَّبَائِحُ، لِأَنَّهُمْ لَا يَعْتَقِدُونَ تَحْلِيلَهَا بِالتَّذْكِيَةِ. وَمَنْ قَالَ: لَيْسَ بِشَرْطٍ فِيهَا ؛ وَتَمَسَّكَ بِعُمُومِ الْآيَةِ الْمُحَلِّلَةِ قَالَ: تَجُوزُ هَذِهِ الذَّبَائِحُ.

وَهَذَا بِعَيْنِهِ هُوَ سَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي أَكْلِ الشُّحُومِ[1] مِنْ ذَبَائِحِهِمْ، وَلَمْ يُخَالِفْ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّ الشُّحُومَ مُحَرَّمَةٌ وَهُوَ قَوْلُ أَشْهَبَ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: مَكْرُوهَةٌ، وَالْقَوْلَانِ عَنْ مَالِكٍ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: مُبَاحَةٌ.

وَيَدْخُلُ فِي الشُّحُومِ سَبَبٌ آخَرُ مِنْ أَسْبَابِ الْخِلَافِ سِوَى مُعَارَضَةِ الْعُمُومِ لِاشْتِرَاطِ اعْتِقَادِ تَحْلِيلِ الذَّبِيحَةِ بِالذَّكَاةِ، وَهُوَ هَلْ تَتَبَعَّضُ التَّذْكِيَةُ أَوْ لَا تَتَبَعَّضُ؟[2] فَمَنْ قَالَ: تَتَبَعَّضُ قَالَ: لَا تُؤْكَلُ الشُّحُومُ، وَمَنْ قَالَ لَا تَتَبَعَّضُ قَالَ: يُؤْكَلُ الشَّحْمُ[3].

لَا تَجُوزُ هَذِهِ الذَّبَائِحُ، لِأَنَّهُمْ لَا يَعْتَقِدُونَ تَحْلِيلَهَا بِالتَّذْكِيَةِ. وَمَنْ قَالَ: لَيْسَ بِشَرْطٍ فِيهَا، وَتَمَسَّكَ بِعُمُومِ الْآيَةِ الْمُحَلِّلَةِ قَالَ: تَجُوزُ هَذِهِ الذَّبَائِحُ.

(١) أي ما سبق من جعل اعتقاد حلَ الذبيحة بالتذكية شرط لحل أكل ذبيحة أهل الكتاب. والشحم: الدهن. ينظر في هذا: المعجم الوسيط (١/ ٤٧٤).

(٢) أي من أسباب الخلاف في مسألة الشحوم ما سبق من شرط اعتقاد الذابح حلَ الذبيحة بالتذكية حالة الذبح، ويُضاف إليه سبب آخر ألا وهو: اختلافهم في التذكية هل يترتب عليها حلَ الذبيحة كلها ما نص عليه، وما لم ينص أم يفيد حل بعض الذبيحة الذي ورد النص بحله، وحرمة البعض الذي ورد النص بتحريمه؟

(٣) أي من يرى أن التذكية تُفيدُ حل الذبيحة جميعها دون تفرقة بين ما ورد النص =

وَيَدُلُّ عَلَى تَحْلِيلِ شُحُومِ ذَبَائِحِهِمْ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ «إِذْ أَصَابَ جِرَابَ الشَّحْمِ يَوْمَ خَيْبَرَ»(١)، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ.

وَمَنْ فَرَّقَ بَيْنَ مَا حُرِّمَ عَلَيْهِمْ مِنْ ذَلِكَ فِي أَصْلِ شَرْعِهِمْ وَبَيْنَ مَا حَرَّمُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ قَالَ: مَا حُرِّمَ عَلَيْهِمْ هُوَ أَمْرٌ حَقٌّ، فَلَا تَعْمَلُ فِيهِ الذَّكَاةُ، وَمَا حَرَّمُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ هُوَ أَمْرٌ بَاطِلٌ، فَتَعْمَلُ فِيهِ التَّذْكِيَةُ(٢).

قَالَ الْقَاضِي: وَالْحَقُّ أَنَّ مَا حُرِّمَ عَلَيْهِمْ أَوْ حَرَّمُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ هُوَ فِي وَقْتِ شَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ أَمْرٌ بَاطِلٌ، إِذْ كَانَتْ نَاسِخَةً لِجَمِيعِ الشَّرَائِعِ، فَيَجِبُ أَنْ لَا يُرَاعَى اعْتِقَادُهُمْ فِي ذَلِكَ(٣).

وَلَا يُشْتَرَطُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ اعْتِقَادُهُمْ فِي تَحْلِيلِ الذَّبَائِحِ اعْتِقَادَ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا

بحله، وما ورد بتحريمه لم يستثن من الحل شيئا. ومن قال إنها تفيد حل البعض استثنى من الحل ما ورد الشرع بتحريمه.

(١) الهداية في تخريج أحاديث البداية (٦/ ٢٤٢).

(٢) هذا هو الرأي الثالث: يرى أصحابه التفرقة في حل الذبيحة بالتذكية، وعدم الحلِّ بين ما ورد النص بتحريمه عليهم، وبين ما حرموه على أنفسهم باعتقادهم حرمته، فقال أصحابه: أن ما حرمه الله عليهم لا يقبل الحل بالتذكية؛ لأن تحريمه حق. الثاني: ما حرموه على أنفسهم باعتقادهم حرمته، فهو حلال بالتذكية، ولا يُأثر في حله اعتقادهم؛ لأن اعتقادهم تحريمه اعتقاد باطل.

(٣) يرى القاضي عبد الوهاب: أن ما حُرم عليهم، أو اعتقدوا تحريمه على أنفسهم لا يؤثر في الذبيحة للمسلمين؛ لأن شريعة الإسلام ناسخة لشرائعهم.

اعْتِقَادَ شَرِيعَتِهِمْ، لِأَنَّهُ لَو اشْتُرِطَ ذَلِكَ لِمَا جَازَ أَكْلُ ذَبَائِحِهِمْ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ، لِكَوْنِ اعْتِقَادِ شَرِيعَتِهِمْ فِي ذَلِكَ مَنْسُوخًا، وَاعْتِقَادِ شَرِيعَتِنَا لَا يَصِحُّ مِنْهُمْ، وَإِنَّمَا هَذَا حُكْمٌ خَصَّهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ، فَذَبَائِحُهُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ جَائِزَةٌ لَنَا عَلَى الْإِطْلَاقِ، وَإِلَّا ارْتَفَعَ حُكْمُ آيَةِ التَّحْلِيلِ جُمْلَةً. فَتَأَمَّلْ هَذَا فَإِنَّهُ بَيِّنٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا الْمَجُوسُ [١]: فَإِنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى أَنَّهُ لَا تَجُوزُ ذَبَائِحُهُمْ لِأَنَّهُمْ مُشْرِكُونَ، وَتَمَسَّكَ قَوْمٌ فِي إِجَازَتِهَا بِعُمُومِ قَوْلِهِ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ –: «سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ»[٢].

وَأَمَّا الصَّابِئُونَ[٣]: فَالِاخْتِلَافُ فِيهِمْ مِنْ قِبَلِ اخْتِلَافِهِمْ فِي: هَلْ هُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَمْ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ؟

وَأَمَّا الْمَرْأَةُ وَالصَّبِيُّ: فَإِنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى أَنَّ ذَبَائِحَهُمْ جَائِزَةٌ غَيْرُ مَكْرُوهَةٍ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَكَرِهَ ذَلِكَ أَبُو الْمُصْعَبِ، وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ: نُقْصَانُ الْمَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ[٤]، وَإِنَّمَا لَمْ يَخْتَلِفِ الْجُمْهُورُ فِي الْمَرْأَةِ لِحَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ سَعِيدٍ: «أَنَّ

---

(١) المجوس: قوم كانوا يعبدون الشمس والقمر والنار، وأطلق عليهم هذا اللقب منذ القرن الثالث للميلاد. ينظر في هذا: المعجم الوسيط (٢/ ٨٥٥).

(٢) أخرجه الإمام مالك في موطأ (٢/ ٣٩٥)، والبيهقي في السنن الكبرى، (٩/ ١٨٩).

(٣) الصابئون: من يتركون دينهم ويدينون بآخر، وقوم يعبدون الكواكب، ويزعمون أنهم على ملة نوح، وقبلتهم مهب الشمال عند منتصف النهار. ينظر في هذا: المعجم الوسيط (١/ ٥٠٥).

(٤) الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى اشترط العقل في الذابح؛ لصحة الذبح، وهو من الشروط المتفق على توافرها؛ لصحة الذبح، وحل الأكل من =

جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى بِسَلْعٍ فَأُصِيبَتْ شَاةٌ، فَأَدْرَكَتْهَا فَذَبَحَتْهَا بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا فَكُلُوهَا»[١]. وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

وَأَمَّا الْمَجْنُونُ وَالسَّكْرَانُ: فَإِنَّ مَالِكًا لَمْ يُجِزْ ذَبِيحَتَهُمَا، وَأَجَازَ ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ

وَسَبَبُ الْخِلَافِ: اشْتِرَاطُ النِّيَّةِ فِي الذَّكَاةِ، فَمَنِ اشْتَرَطَ النِّيَّةَ مَنَعَ ذَلِكَ، إِذْ لَا يَصِحُّ مِنَ الْمَجْنُونِ وَلَا مِنَ السَّكْرَانِ وَبِخَاصَّةٍ الْمُلْتَخُّ[٢].

وَأَمَّا جَوَازُ تَذْكِيَةِ السَّارِقِ وَالْغَاصِبِ: فَإِنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ. وَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَ ذَلِكَ وَرَأَى أَنَّهَا مَيْتَةٌ، وَبِهِ قَالَ دَاوُدُ وَإِسْحَاقُ ابْنُ رَاهَوَيْهِ.

وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: هَلِ النَّهْيُ يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ أَوْ لَا يَدُلُّ؟ فَمَنْ قَالَ: يَدُلُّ، قَالَ: السَّارِقُ وَالْغَاصِبُ مَنْهِيٌّ عَنْ ذَكَاتِهَا وَتَنَاوُلِهَا وَتَمَلُّكِهَا، فَإِذَا كَانَ ذَكَّاهَا فَسَدَتِ التَّذْكِيَةُ. وَمَنْ قَالَ: لَا يَدُلُّ إِلَّا إِذَا كَانَ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ شَرْطًا مِنْ شُرُوطِ ذَلِكَ الْفِعْلِ قَالَ: تَذْكِيَتُهُمْ جَائِزَةٌ، لِأَنَّهُ لَيْسَ صِحَّةُ الْمِلْكِ شَرْطًا مِنْ شُرُوطِ التَّذْكِيَةِ[٣].

الذبيحة،

وهنا يبين ابن رشد حكم ذبح السكران، والمجنون، فيذكر أن الفقهاء قد اختلفوا في هذه المسألة على رأيين، فَالإمام مَالِك لَمْ يُجِزْ ذَبِيحَتَهُمَا، وَأَجَازَ ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ.

(١) سبق تخريجه.

(٢) سكرانُ مُلْتَخٌّ: أي مختلط عقله. ينظر في هذا: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: للجوهري، (١/ ٤٣٠)

(٣) هذه المسألة يبين فيه ابن رشد حكم ذبيحة السارق، والغاصب هل تصح =

وَفِي مُوَطَّأِ ابْنِ وَهْبٍ: «أَنَّهُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ – عَنْهَـا فَلَمْ يَرَ بِهَا بَأْسًا»، وَقَدْ جَاءَ إِبَاحَةُ ذَلِكَ مَعَ الْكَرَاهِيَةِ فِيمَا رُوِيَ «عَنِ النَّبِـيِّ عَلَيْـهِ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – فِي الشَّاةِ الَّتِي ذُبِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ رَبِّهَا، فَقَـالَ رَسُـولُ اللَّـهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: " أَطْعِمُوهَا الْأُسَارَى»[1].

وَهَذَا الْقَدْرُ كَافٍ فِي أُصُولِ هَذَا الْكِتَابِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ذبيحته، ومن ثم يحلَّ الأكل منها، أم لا تصح، فلا يحل الأكل منها؟ وقد اختلفوا فيها على رأيين، فمنهم من قال بصحة ذكاته، وحل الأكل من ذبيحته. ومنهم من قال بعدم الصحة، وعدم حل الأكل من ذبيحته. وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: هَلِ النَّهْيُ يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ أَوْ لَا يَدُلُّ؟ الأثر المترتب على هذا الخلاف: فَمَنْ قَالَ: يَدُلُّ، قَالَ: السَّارِقُ وَالْغَاصِبُ مَنْهِيٌّ عَنْ ذَكَاتِهَا وَتَنَاوُلِهَا وَتَمَلُّكِهَا، فَإِذَا كَانَ ذَكَّاهَا فَسَدَتِ التَّذْكِيَةُ. وَمَنْ قَالَ: لَا يَدُلُّ إِلَّا إِذَا كَانَ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ شَرْطًا مِنْ شُرُوطِ ذَلِكَ الْفِعْلِ قَالَ: تَذْكِيَتُهُمْ جَائِزَةٌ، لِأَنَّهُ لَيْسَ صِحَّةُ الْمِلْكِ شَرْطًا مِنْ شُرُوطِ التَّذْكِيَةِ.

(١) رواه أحمد بن حنبل في مسنده، (٥/ ٢٩٣).

تدريبات:

ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة، وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة:

أ- لا خلاف بين الفقهاء على صحة ذبيحة نصارى تغلب. ( ).

ب- من الشروط المتفق عليها عند الفقهاء لصحة الذبيحة أن يكون الذابح مسلمًا بالغًا. ( ).

ت- لا خلاف بين الفقهاء في عدم حل الأكل من ذبائح أهل الكتاب التي اعتقدوا تحريمها على أنفسهم. ( ).

ث- اتفق الفقهاء على حرمة الأكل من ذبائح المجوس. ( ).

كِتَابُ الصَّيْدِ [١].

وَهَذَا الْكِتَابُ فِي أُصُولِهِ-أَيْضًا-أَرْبَعَةُ أَبْوَابٍ:

الْأَوَّلُ: فِي حُكْمِ الصَّيْدِ، وَفِي مَحَلِّ الصَّيْدِ.

الثَّانِي: فِيمَا بِهِ يَكُونُ الصَّيْدُ.

الثَّالِثُ: فِي صِفَةِ ذَكَاةِ الصَّيْدِ، وَالشَّرَائِطِ الْمُشْتَرَطَةِ فِي عَمَلِ الذَّكَاةِ فِي الصَّيْدِ.

الرَّابِعُ: فِيمَنْ يَجُوزُ صَيْدُهُ.

---

(١) تَعْرِيفُ الصَّيْدِ: الصَّيْدُ لُغَةً: مَصْدَرٌ بِمَعْنَى، الاِصْطِيَادِ، وَالْقَنْصِ، وَبِمَعْنَى الْمَصِيدِ. ينظر: لسان العرب (٣/٢٦٠). أما تَعْرِيفُ الصَّيْدِ في الاصطلاح: الصَّيْدُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ هُوَ: الْحَيَوَانُ الْبَرِّيُّ الْمُمْتَنِعُ عَنْ أَخْذِهِ بِقَوَائِمِهِ، أَوْ جَنَاحَيْهِ، الْمُتَوَحِّشُ فِي أَصْل الْخِلْقَةِ. ينظر: بدائع الصنائع (٢/١٩٦). وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ هُوَ: الْحَيَوَانُ الْبَرِّيُّ الْمُتَوَحِّشُ فِي أَصْل الْخِلْقَةِ. ينظر: الشرح الكبير للدردير (٢/٧٢). وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ هُوَ: الْحَيَوَانُ الْبَرِّيُّ الْمُتَوَحِّشُ الْمَأْكُول اللَّحْمِ. ينظر في الفقه الشافعي: حاشية الجمل على حاشية الجمل (٢/٥٢٢). وينظر في الفقه الحنبلي: حاشية الروض المربع (٤/١٩).

الْبَابُ الْأَوَّل

فِي حُكْمِ الصَّيْدِ وَمَحَلِّهِ

فَأَمَّا حُكْمُ الصَّيْدِ فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ مُبَاحٌ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: ٩٦]، ثُمَّ قَالَ: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: ٢].

وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالصَّيْدِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ بَعْدَ النَّهْيِ يَدُلُّ عَلَى الْإِبَاحَةِ، كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى ذَلِكَ فِي قَوْله تَعَالَى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [الجمعة: ١٠]. أَعْنِي: أَنَّ الْمَقْصُودَ بِهِ الْإِبَاحَةُ؛ لِوُقُوعِ الْأَمْرِ بَعْدَ النَّهْيِ، وَإِنْ كَانَ اخْتَلَفُوا هَلِ الْأَمْرُ بَعْدَ النَّهْيِ يَقْتَضِي الْإِبَاحَةَ؟ أَوْ لَا يَقْتَضِيهِ، وَإِنَّمَا يَقْتَضِي عَلَى أَصْلِهِ الْوُجُوبَ؟

وَكَرِهَ مَالِكٌ الصَّيْدَ الَّذِي يُقْصَدُ بِهِ السَّرَفُ، وَلِلْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِ تَفْصِيلٌ؛ مَحْصُولُ قَوْلِهِمْ فِيهِ: أَنَّ مِنْهُ مَا هُوَ فِي حَقِّ بَعْضِ النَّاسِ وَاجِبٌ، وَفِي حَقِّ بَعْضِهِمْ مَنْدُوبٌ، وَفِي حَقِّ بَعْضِهِمْ مَكْرُوهٌ.

وَهَذَا النَّظَرُ فِي الشَّرْعِ تَغَلْغُلٌ فِي الْقِيَاسِ وَبُعْدٌ عَنِ الْأُصُولِ الْمَنْطُوقِ بِهَا فِي الشَّرْعِ، فَلَيْسَ يَلِيقُ بِكِتَابِنَا هَذَا؛ إِذْ كَانَ قَصْدُنَا فِيهِ إِنَّمَا هُوَ ذِكْرُ الْمَنْطُوقِ بِهِ مِنَ الشَّرْعِ، أَوْ مَا كَانَ قَرِيبًا مِنَ الْمَنْطُوقِ بِهِ.

وَأَمَّا مَحَلُّ الصَّيْدِ فَإِنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَحَلَّهُ مِنَ الْحَيَوَانِ الْبَحْرِيِّ، وَهُوَ السَّمَكُ وَأَصْنَافُهُ، وَمِنَ الْحَيَوَانِ الْبَرِّيِّ الْحَلَالُ الْأَكْلِ الْغَيْرُ مُسْتَأْنَسٍ.

وَاخْتَلَفُوا فِيمَا اسْتَوْحَشَ مِنَ الْحَيَوَانِ الْمُسْتَأْنَسِ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَى أَخْذِهِ وَلَا ذَبْحِهِ

أَوْ نَحْرِهِ، فَقَالَ مَالِكٌ: لَا يُؤْكَلُ إِلَّا أَنْ يُنْحَرَ مِنْ ذَلِكَ مَا ذَكَاتُهُ النَّحْرُ، وَيُذْبَحَ مَا ذَكَاتُهُ الذَّبْحُ، أَوْ يُفْعَلَ بِهِ أَحَدُهُمَا إِنْ كَانَ مِمَّا يَجُوزُ فِيهِ الْأَمْرَانِ جَمِيعًا. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ: إِذَا لَمْ يُقْدَرْ عَلَى ذَكَاةِ الْبَعِيرِ الشَّارِدِ فَإِنَّهُ يَقْتُلُ كَالصَّيْدِ.

وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ مُعَارَضَةُ الْأَصْلِ فِي ذَلِكَ لِلْخَبَرِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْأَصْلَ فِي هَذَا الْبَابِ هُوَ أَنَّ الْحَيَوَانَ الْإِنْسِيَّ لَا يُؤْكَلُ إِلَّا بِالذَّبْحِ أَوِ النَّحْرِ، وَأَنَّ الْوَحْشِيَّ يُؤْكَلُ بِالْعَقْرِ(١).

وَأَمَّا الْخَبَرُ الْمُعَارِضُ لِهَذِهِ الْأُصُولِ فَحَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، وَفِيهِ قَالَ: «فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ، وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ، فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَجُلٌ بِسَهْمٍ، فَحَبَسَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ –: "إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ(٢) كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا نَدَّ(٣) عَلَيْكُمْ فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا»(٤). وَالْقَوْلُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَوْلَى لِصِحَّتِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ ذَلِكَ الْأَصْلِ، مَعَ أَنَّ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: إِنَّهُ جَارٍ مَجْرَى الْأَصْلِ فِي هَذَا الْبَابِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْعِلَّةَ فِي كَوْنِ الْعَقْرِ ذَكَاةً فِي بَعْضِ الْحَيَوَانِ لَيْسَ شَيْئًا أَكْثَرَ مِنْ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ؛ لَا لِأَنَّهُ

---

(١) العقر: عَقَرَه أَي جَرَحَه، والعَقْرُ: شَبِيهٌ بالحَزِّ؛ وعَقَر الفرسَ والبعيرَ بِالسَّيْفِ عَقْراً: قَطَعَ قَوَائِمَهُ. ينظر: لسان العرب (٥٩٢/٤).

(٢) الأَوابد: جَمْعُ آبِدَةٍ؛ وَهِيَ الَّتِي قَدْ تَوَحَّشَتْ ونفرَت مِنَ الإِنس. ينظر: لسان العرب (٦٩/٣).

(٣) ندّ: هرب.

(٤) صحيح البخاري (١٣٨/٣)؛ كتاب: الشركة، باب: قسمة الغنم، ح/٢٤٨٨.

وَحْشِيٌّ فَقَطْ، فَإِذَا وُجِدَ هَذَا الْمَعْنَى مِنَ الْإِنْسِيِّ جَازَ أَنْ تَكُونَ ذَكَاتُهُ ذَكَاةَ الْوَحْشِيِّ، فَيَتَّفِقُ الْقِيَاسُ وَالسَّمَاعُ.

الخلاصة:

تناول هذا الباب ما يلي:

أولًا: أنَّ الصيد مباح عند جمهور الفقهاء.

ثانيًا: أنَّ الإمام مالكًا-رحمه الله-كَرِهَ الصَّيْدَ الَّذِي يُقْصَدُ بِهِ السَّرَفُ، وأنَّ لِلْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِ تَفْصِيلًا.

ثالثًا: أنَّ العلماء اتفقوا على أنَّ مَحَلَّ الصَّيْدِ مِنَ الْحَيَوَانِ الْبَحْرِيِّ، وَهُوَ السَّمَكُ وَأَصْنَافُهُ، وَمِنَ الْحَيَوَانِ الْبَرِّيِّ الْحَلَالُ الْأَكْلِ الْغَيْرُ مُسْتَأْنَسٍ.

رابعًا: أنَّ الفقهاء اخْتَلَفُوا فِي أكل الحيوانِ الْمُسْتَأْنَسِ إذا اسْتَوْحَشَ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَى أَخْذِهِ وَلَا ذَبْحِهِ أَوْ نَحْرِهِ.

سبب الخلاف: وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ مُعَارَضَةُ الْأَصْلِ لِلْخَبَرِ.

تدريبات على الباب:

س١: بين حكم الصيد، مع ذكر الدليل، وتوضيحه.

س ٢: ضع علامة صح أو خطأ مع تصحيح الخطأ:

حرم الإمام مالك الصيد الذي يقصد به السرف. ( )

اتفق الفقهاء على حِلِّ صيد ما اسْتَوْحَشَ مِنَ الْحَيَوَانِ الْمُسْتَأْنَسِ. ( )

الْبَابُ الثَّانِي

فِيمَا به يَكُونُ الصَّيْدُ[١]

وَالْأَصْلُ فِي هَذَا الْبَابِ آيَتَانِ وَحَدِيثَانِ: الْآيَةُ الْأُولَى: قَوْله تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ﴾ [المائدة: ٩٤] وَالثَّانِيَةُ قَوْله تَعَالَى: ﴿قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ [المائدة: ٤] الْآيَةَ.

وَأَمَّا الْحَدِيثَانِ: فَأَحَدُهُمَا: حَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ[٢] وَفِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: «إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَةَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ، وَإِنْ أَكَلَ الْكَلْبُ فَلَا تَأْكُلْ؛ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ غَيْرُهَا فَلَا تَأْكُلْ؛ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ» وَسَأَلَهُ عَنِ الْمِعْرَاضِ[٣] فَقَالَ: «إِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ[٤]»[١]

---

(١) المقصود بهذا العنوان: الأشياء التي يجوز الاصطياد بها، والأشياء التي لا يجوز الاصطياد بها.

(٢) هو عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي، صحابي جليل، أسلم سنة: ٩هـ، وهو ابن حاتم الطائي الّذي يضرب بجوده المثل، وتوفي سنة: ٦٨هـ. انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب ١٠٥٧/٣

(٣) المعراض: هو سهم محدد الطرفين، غليظ الوسط، يصيب تارة بحده، وتارة بعرضه. انظر: منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري١٦٤/٥.

(٤) وقيذ وموقوذ وشاة موقوذة قتلت بالخشب أو بغيره، فماتت من غير ذكاة. =

وَهَذَا الْحَدِيثُ هُوَ أَصْلٌ فِي أَكْثَرِ مَا فِي هَذَا الْكِتَابِ.

وَالْحَدِيثُ الثَّانِي: حَدِيثُ أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ وَفِيهِ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «مَا أَصَبْتَ بِقَوْسِكَ فَسَمِّ اللَّهَ ثُمَّ كُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ وَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ»[٢] وَهَذَانَ الْحَدِيثَانِ اتَّفَقَ أَهْلُ الصَّحِيحِ عَلَى إِخْرَاجِهِمَا.

الآلات التي يجوز الصيد بها:

وَالْآلَاتُ الَّتِي يُصَادُ بِهَا مِنْهَا مَا اتَّفَقُوا عَلَيْهَا بِالْجُمْلَةِ، وَمِنْهَا مَا اخْتَلَفُوا فِيهَا وَفِي صِفَاتِهَا، وَهِيَ ثَلَاثٌ: حَيَوَانٌ جَارِحٌ، وَمُحَدَّدٌ، وَمُثَقَّلٌ.

فَأَمَّا الْمُحَدَّدُ: فَاتَّفَقُوا عَلَيْهِ، كَالرِّمَاحِ، وَالسُّيُوفِ، وَالسِّهَامِ؛ لِلنَّصِّ عَلَيْهَا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَكَذَلِكَ بِمَا جَرَى مَجْرَاهَا مِمَّا يَعْقِرُ، مَا عَدَا الْأَشْيَاءَ الَّتِي اخْتَلَفُوا فِي عَمَلِهَا فِي ذَكَاةِ الْحَيَوَانِ الْإِنْسِيِّ، وَهِيَ: السِّنُّ، وَالظُّفْرُ، وَالْعَظْمُ. وَقَدْ تَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي ذَلِكَ، فَلَا مَعْنَى لِإِعَادَتِهِ.

وَأَمَّا الْمُثَقَّلُ فَاخْتَلَفُوا فِي الصَّيْدِ بِهِ: مِثْلَ الصَّيْدِ بِالْمِعْرَاضِ وَالْحَجَرِ؛ فَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ لَمْ يُجِزْ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مَا أُدْرِكَتْ ذَكَاتُهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَجَازَهُ عَلَى الْإِطْلَاقِ، وَمِنْهُمْ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ مَا قَتَلَهُ الْمِعْرَاضُ أَوِ الْحَجَرُ بِثِقَلِهِ، أَوْ بِحَدِّهِ إِذَا خَرَقَ جَسَدَ

انظر: المصباح المنير٢/٦٦٨.

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه برقم: [٥٤٨٣] ومسلم في صحيحه برقم: [١٩٢٩]

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: [١٩٣٠].

الصَّيْدِ، فَأَجَازَهُ إِذَا خَرَقَ، وَلَمْ يُجِزْهُ إِذَا لَمْ يَخْرِقْ، وَبِهَذَا الْقَوْلِ قَالَ مَشَاهِيرُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ: الشَّافِعِيُّ، وَمَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَحْمَدُ، وَالثَّوْرِيُّ[١]، وَغَيْرُهُمْ، وَهُوَ رَاجِعٌ إِلَى أَنَّهُ لَا ذَكَاةَ إِلَّا بِمُحَدَّدٍ.

وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ مُعَارَضَةُ الْأُصُولِ فِي هَذَا الْبَابِ بَعْضَهَا بَعْضًا، وَمُعَارَضَةُ الْأَثَرِ لَهَا، وَذَلِكَ أَنَّ مِنَ الْأُصُولِ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّ الْوَقِيذَ مُحَرَّمٌ بِالْكِتَابِ وَالْإِجْمَاعِ، وَمِنْ أُصُولِهِ أَنَّ الْعَقْرَ[٢] ذَكَاةُ الصَّيْدِ، فَمَنْ رَأَى أَنَّ مَا قَتَلَ الْمِعْرَاضُ وَقِيذٌ مَنَعَهُ عَلَى الْإِطْلَاقِ، وَمَنْ رَآهُ عَقْرًا مُخْتَصًّا بِالصَّيْدِ، وَأَنَّ الْوَقِيذَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِيهِ أَجَازَهُ عَلَى الْإِطْلَاقِ، وَمَنْ فَرَّقَ بَيْنَ مَا خَرَقَ مِنْ ذَلِكَ، أَوْ لَمْ يَخْرِقْ، فَمَصِيرًا إِلَى حَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ الْمُتَقَدِّمِ، وَهُوَ الصَّوَابُ، وَأَمَّا الْحَيَوَانُ الْجَارِحُ فَالِاتِّفَاقُ وَالِاخْتِلَافُ فِيهِ: مِنْهُ مُتَعَلِّقٌ بِالنَّوْعِ وَالشَّرْطِ، وَمِنْهُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالشَّرْطِ، فَأَمَّا النَّوْعُ الَّذِي اتَّفَقُوا عَلَيْهِ فَهُوَ الْكِلَابُ، مَا عَدَا الْكَلْبَ الْأَسْوَدَ؛ فَإِنَّهُ كَرِهَهُ قَوْمٌ مِنْهُمْ: الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ[٣] وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ[٤] .....

---

١) انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي٤/٤٠٨، المدونة١/٥٣٩، البيان في مذهب الإمام الشافعي٤/٥٤٨، المغني لابن قدامة٩/٣٨٣.

(٢) أي الجَرْح.

(٣) الحسن البصري: الحسن بن يسار البصري، أبو سعيد، كان من سادات التابعين وكبرائهم، أبوه مولى زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، وأمه خيرة مولاة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ولد سنة: ٢١هـ، وتوفي سنة: ١١٠هـ. انظر: وفيات الأعيان٢/٦٩.

(٤) إبراهيم النخعي: إبراهيم بن يزيد بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن =

وَقَتَادَةُ[١] وَقَالَ أَحْمَدُ: مَا أَعْرِفُ أَحَدًا يُرَخِّصُ فِيهِ إِذَا كَانَ بَهِيمًا[٢] وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ[٣] وَأَمَّا الْجُمْهُورُ فَعَلَى إِجَازَةِ صَيْدِهِ إِذَا كَانَ مُعَلَّمًا.

وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ مُعَارَضَةُ الْقِيَاسِ لِلْعُمُومِ، وَذَلِكَ أَنَّ عُمُومَ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ [المائدة: ٤] يَقْتَضِي تَسْوِيَةَ جَمِيعِ الْكِلَابِ فِي ذَلِكَ، وَأَمْرُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ يَقْتَضِي فِي ذَلِكَ الْقِيَاسُ أَنْ لَا يَجُوزَ اصْطِيَادُهُ عَلَى رَأْيِ مَنْ رَأَى أَنَّ النَّهْيَ يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ الْمَنْهِيِّ عَنْه

سعد بن مالك بن النخع، الفقيه، الكوفي، النخعي؛ أحد الأئمة المشاهير، تابعي رأي عائشة رضي الله عنها ودخل عليها، ولم يثبت له منها سماع، توفي سنة ٩٦هـ. انظر: وفيات الأعيان١/٢٥.

(١) قتادة: هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسي، وقيل: قتادة بن دعامة بن عكابة، حافظ العصر، قدوة المفسرين والمحدثين، أبو الخطاب السدوسي، البصري، الضرير، الأكمه، ولد سنة ٦٠هـ، وكان من أوعية العلم، وممن يضرب به المثل في قوة الحفظ، وكان أيضا رأسا في العربية والغريب وأيام العرب وأنسابها، وتوفي سنة ١١٨هـ. انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي١/٨٩، سير أعلام النبلاء للذهبي٥/٢٦٩.

البهيم: اللون الذي لا يخالطه غيره، سوادا كان أو غيره. انظر: معجم مقاييس (٢) اللغة ١/٣١١.

(٣) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه٨/٣٩٨٥، وإسحاق: هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد، أبو يعقوب، ابن راهويه، إمام من أئمة المسلمين، ولد سنة: ١٦١هـ، وتوفي سنة: ٢٣٨هـ. انظر: التعديل والتجريح، لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح١/٣٧٢.

وَأَمَّا الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْ أَنْوَاعِ الْجَوَارِحِ فِيمَا عَدَا الْكَلْبَ، وَمِنْ جَوَارِحِ الطُّيُورِ، وَحَيَوَانَاتِهَا السَّاعِيَةِ، فَمِنْهُمْ مَنْ أَجَازَ جَمِيعَهَا إِذَا عُلِّمَتْ حَتَّى السِّنَّوْرَ[١] كَمَا قَالَ ابْنُ شَعْبَانَ[٢] وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ، وَبِهِ قَالَ فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَعْنِي أَنَّ مَا قَبِلَ التَّعْلِيمَ مِنْ جَمِيعِ الْجَوَارِحِ فَهُوَ آلَةٌ لِذَكَاةِ الصَّيْدِ، وَقَالَ قَوْمٌ: لَا اصْطِيَادَ بِجَارِحٍ مَا عَدَا الْكَلْبَ، لَا بَازٌ، وَلَا صَقْرٌ، وَلَا غَيْرُ ذَلِكَ، إِلَّا مَا أُدْرِكَتْ ذَكَاتُهُ، وَهُوَ قَوْلُ مُجَاهِدٍ، وَاسْتَثْنَى بَعْضُهُمْ مِنَ الطُّيُورِ الْجَارِحَةِ الْبَازِيَّ فَقَطْ فَقَالَ: يَجُوزُ صَيْدُهُ وَحْدَهُ.

وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْئَانِ:

أَحَدُهُمَا: قِيَاسُ سَائِرِ الْجَوَارِحِ عَلَى الْكِلَابِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ يُظَنُّ أَنَّ النَّصَّ إِنَّمَا وَرَدَ فِي الْكِلَابِ، أَعْنِي قَوْلَه تَعَالَى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ [المائدة: ٤] إِلَّا أَنْ يُتَأَوَّلَ أَنَّ لَفْظَةَ "مُكَلِّبِينَ" مُشْتَقَّةٌ مِنْ كَلَّبَ الْجَارِحَ لَا مِنْ لَفْظِ الْكَلْبِ، وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا عُمُومُ اسْمِ الْجَوَارِحِ الَّذِي فِي الْآيَةِ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ سَبَبُ الِاخْتِلَافِ الِاشْتِرَاكَ الَّذِي فِي لَفْظَةِ "مُكَلِّبِينَ".

وَالسَّبَبُ الثَّانِي: هَلْ مِنْ شَرْطِ الْإِمْسَاكِ الْإِمْسَاكُ عَلَى صَاحِبِهِ؟ أَمْ لَا؟ وَإِنْ كَانَ

---

(١) السنور: الهر. انظر: جمهرة اللغة ١/١٢٧.

(٢) ابن شعبان: هو أبو إسحاق، محمد بن القاسم بن شعبان بن محمد بن ربيعة العماري المصري، شيخ المالكية بمصر في زمانه، له تصانيف كثيرة، منها: كتاب "الزاهي" في الفقه، وكتاب "أحكام القرآن" و"مناقب مالك، وتوفي سنة: ٣٥٥هـ. انظر: سير أعلام النبلاء ١٢/١٧٤.

مِنْ شَرْطِهِ فَهَلْ يُوجَدُ فِي غَيْرِ الْكَلْبِ أَوْ لَا يُوجَدُ؟

فَمَنْ قَالَ: لَا يُقَاسُ سَائِرُ الْجَوَارِحِ عَلَى الْكِلَابِ، وَأَنَّ لَفْظَةَ مُكَلِّبِينَ هِيَ مُشْتَقَّةٌ مِن اسْمِ الْكَلْبِ لَا مِن اسْمِ غَيْرِ الْكَلْبِ، أَوْ أَنَّهُ لَا يُوجَدُ الْإِمْسَاكُ إِلَّا فِي الْكَلْبِ، أَعْنِي عَلَى صَاحِبِهِ، وَأَنَّ ذَلِكَ شَرْطٌ، قَالَ: لَا يُصَادُ بِجَارِحٍ سِوَى الْكَلْبِ، وَمَنْ قَاسَ عَلَى الْكَلْبِ سَائِرَ الْجَوَارِحِ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ فِي الْإِمْسَاكِ الْإِمْسَاكَ عَلَى صَاحِبِهِ قَالَ: يَجُوزُ صَيْدُ سَائِرِ الْجَوَارِحِ إِذَا قَبِلَتِ التَّعْلِيمَ، وَأَمَّا مَن اسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الْبَازِيَّ فَقَطْ فَمَصِيرًا إِلَى مَا رُوِيَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْبَازِيِّ فَقَالَ: «مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ» خَرَّجَهُ التِّرْمِذِيُّ[1] فَهَذِهِ هِيَ أَسْبَابُ اتِّفَاقِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ فِي أَنْوَاعِ الْجَوَارِحِ.

الشروط المعتبرة لحل صيد الجوارح:

وَأَمَّا الشُّرُوطُ الْمُشْتَرَطَةُ فِي الْجَوَارِحِ فَإِنَّ مِنْهَا مَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ، وَهُوَ التَّعْلِيمُ بِالْجُمْلَةِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ [المائدة: ٤] وَقَوْلِهِ

أخرجه الترمذي في سننه برقم: [١٤٦٧] وقال: " هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، لَا يَرَوْنَ بِصَيْدِ البُزَاةِ وَالصُّقُورِ بَأْسًا، وقَالَ مُجَاهِدٌ: " البُزَاةُ: هُوَ الطَّيْرُ الَّذِي يُصَادُ بِهِ مِنَ الجَوَارِحِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الجَوَارِحِ} [المائدة: ٤]، فَسَّرَ الكِلَابَ وَالطَّيْرَ الَّذِي يُصَادُ بِهِ، وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِي صَيْدِ البَازِي، وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ، وَقَالُوا: إِنَّمَا تَعْلِيمُهُ إِجَابَتُهُ، وَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ، وَالفُقَهَاءُ (١) أَكْثَرُهُمْ قَالُوا: نَأْكُلُ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ"

عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ»(١).

وَاخْتَلَفُوا فِي صِفَةِ التَّعْلِيمِ وَشُرُوطِهِ، فَقَالَ قَوْمٌ: التَّعْلِيمُ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ:

أَحَدُهَا: أَنْ تَدْعُوَ الْجَارِحَ، فَيُجِيبَ.

وَالثَّانِي: أَنْ تُشْلِيَهُ، فَيَنْشَلِيَ(٢).

وَالثَّالِثُ: أَنْ تَزْجُرَهُ فَيُزْدَجَرَ.

وَلَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي اشْتِرَاطِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ فِي الْكَلْبِ.

وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي اشْتِرَاطِ الِانْزِجَارِ فِي سَائِرِ الْجَوَارِحِ، فَاخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي هَلْ مِنْ شَرْطِهِ أَنْ لَا يَأْكُلَ الْجَارِحُ؟ فَمِنْهُمْ مَنِ اشْتَرَطَهُ عَلَى الْإِطْلَاقِ، وَمِنْهُمْ مَنِ اشْتَرَطَهُ فِي الْكَلْبِ فَقَطْ، وَقَوْلُ مَالِكٍ: إِنَّ هَذِهِ الشُّرُوطَ الثَّلَاثَةَ شَرْطٌ فِي الْكِلَابِ وَغَيْرِهَا، وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ مِنْ أَصْحَابِهِ: لَيْسَ يُشْتَرَطُ الِانْزِجَارُ فِيمَا لَيْسَ يَقْبَلُ ذَلِكَ مِنَ الْجَوَارِحِ مِثْلِ الْبُزَاةِ، وَالصُّقُورِ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ، أَعْنِي أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْجَارِحِ لَا كَلْبٌ وَلَا غَيْرُهُ أَنْ لَا يَأْكُلَ(٣) وَاشْتَرَطَهُ بَعْضُهُمْ فِي الْكَلْبِ، وَلَمْ يَشْتَرِطْهُ فِيمَا عَدَاهُ

متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه برقم: [١٧٥] ومسلم في صحيحه برقم: [١٩٢٩].

(١)

في معنى الإشلاء قولان: قال قوم: معناها دُعِي، يقال: أشليت الكلب إذا دعوته،

(٢) وقال آخرون: أشليته إذا أغريته بالصيد. انظر: حلية الفقهاء ص٢٠٢.

(٣) قال ابن عبد البر: " ولا يضر أكل المعلم من الصيد عند مالك وأكثر أهل المدينة، وجائز عندهم أكل ما أكل منه الكلب المعلم من الصيد ولو لم تبق

=

مِنْ جَوَارِحِ الطُّيُورِ، وَمِنْهُمْ مَنِ اشْتَرَطَهُ كَمَا قُلْنَا فِي الْكُلِّ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى جَوَازِ أَكْلِ صَيْدِ الْبَازِيِّ وَالصَّقْرِ وَإِنْ أَكَلَ؛ لِأَنَّ تَضْرِيَتَهُ[1] إِنَّمَا تَكُونُ بِالْأَكْلِ، فَالْخِلَافُ فِي هَذَا الْبَابِ رَاجِعٌ إِلَى مَوْضِعَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: هَلْ مِنْ شَرْطِ التَّعْلِيمِ أَنْ يَنْزَجِرَ إِذَا زُجِرَ؟

وَالثَّانِي: هَلْ مِنْ شَرطِهِ أَلَّا يَأْكُلَ؟

وَسَبَبُ الْخِلَافِ فِي اشْتِرَاطِ الْأَكْلِ أَوْ عَدَمِهِ شَيْئَانِ:

أَحَدُهُمَا: اخْتِلَافُ حَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ الْمُتَقَدِّمُ، وَفِيهِ «فَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ؛ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ»

وَالْحَدِيثُ الْمُعَارِضُ لِهَذَا حَدِيثُ أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ، قُلْتُ: وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَإِنْ أَكَلَ» فَمَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ بِأَنْ حَمَلَ حَدِيثَ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَلَى النَّدْبِ، وَهَذَا عَلَى الْجَوَازِ قَالَ: لَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ أَلَّا يَأْكُلَ، وَمَنْ رَجَّحَ حَدِيثَ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ؛ إِذْ هُوَ حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَحَدِيثُ أَبِي ثَعْلَبَةَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ – وَلِذَلِكَ لَمْ يُخْرِجْهُ الشَّيْخَانِ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ – وَقَالَ: مِنْ شَرْطِ

إلا بضعة واحدة". انظر: الكافي في فقه أهل المدينة١/٤٣١.

(١) ضَرِي الكلب بالصيد يَضْرَى ضَراوَةً، أي تعوَّد، وكلبٌ ضارٍ وكلبةٌ ضارِيةٌ، وأضراهُ صاحبُه، أي درَّبه وعوَّده، وأَضْراهُ به أيضاً، أي أغراه. انظر: الصحاح للجوهري، مادة: (ضرا) ٦/٢٤٠٨.

الْإِمْسَاكِ أَنْ لَا يَأْكُلَ بِدَلِيلِ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ، قَالَ: إِنْ أَكَلَ الصَّيْدَ لَمْ يُؤْكَلْ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ(١).

وَرَخَّصَ فِي أَكْلِ مَا أَكَلَ الْكَلْبُ كَمَا قُلْنَا: مَالِكٌ، وَسَعِيدُ بْنُ مَالِكٍ وَابْنُ عُمَرَ وَسُلَيْمَانُ وَقَالَتِ الْمَالِكِيَّةُ الْمُتَأَخِّرَةُ: إِنَّهُ لَيْسَ الْأَكْلُ بِدَلِيلٍ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُمْسِكْ لِسَيِّدِهِ، وَلَا الْإِمْسَاكُ لِسَيِّدِهِ بِشَرْطٍ فِي الذَّكَاةِ؛ لِأَنَّ نِيَّةَ الْكَلْبِ غَيْرُ مَعْلُومَةٍ، وَقَدْ يُمْسِكُ لِسَيِّدِهِ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَيُمْسِكُ لِنَفْسِهِ، وَهَذَا الَّذِي قَالُوهُ خِلَافُ النَّصِّ فِي الْحَدِيثِ، وَخِلَافُ ظَاهِرِ الْكِتَابِ، وَهُوَ قَوْله تَعَالَى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: ٤] وَلِلْإِمْسَاكِ عَلَى سَيِّدِ الْكَلْبِ طَرِيقٌ تُعْرَفُ بِهِ، وَهُوَ الْعَادَةُ، وَلِذَلِكَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «فَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ» وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي الِازْدِجَارِ فَلَيْسَ لَهُ سَبَبٌ إِلَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي قِيَاسِ سَائِرِ الْجَوَارِحِ فِي ذَلِكَ عَلَى الْكَلْبِ؛ لِأَنَّ الْكَلْبَ الَّذِي لَا يَزْدَجِرُ لَا يُسَمَّى مُعَلَّمًا بِاتِّفَاقٍ، فَأَمَّا سَائِرُ الْجَوَارِحِ إِذَا لَمْ تَنْزَجِرْ هَلْ تُسَمَّى مُعَلَّمَةً؟ أَمْ لَا؟ فَفِيهِ التَّرَدُّدُ، وَهُوَ سَبَبُ الْخِلَافِ.

---

(١) انظر في تفصيل مذاهب الأئمة: الهداية في شرح بداية المبتدي٤/٤٠٢، روضة الطالبين وعمدة المفتين٣/٢٤٦، المغني لابن قدامة١٣/٢٥٧.

تدريبات

ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة، وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة

١-اتفق الفقهاء على حكم الصيد بالمثقل، مثل الصيد بالمعراض والحجر. ( )

٢- اتفق الفقهاء على جواز الاصطياد بكل الجوارح. ( )

٣- اختلف الفقهاء في صفة تعليم الجارح وشروطه. ( )

٤- ذهب جُمْهُورُ الفقهاء إِلَى جَوَازِ أَكْلِ صَيْدِ الْبَازِيِّ وَالصَّقْرِ وَإِنْ أَكَلَ منه. ( )

الْبَابُ الثَّالِثُ

فِي مَعْرِفَةِ الذَّكَاةِ الْمُخْتَصَّةِ بِالصَّيْدِ وَشُرُوطِهَا

وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الذَّكَاةَ الْمُخْتَصَّةَ بِالصَّيْدِ هِيَ الْعَقْرُ، وَاخْتَلَفُوا فِي شُرُوطِهَا اخْتِلَافًا كَثِيرًا. وَإِذَا اعْتَبَرْتَ أُصُولَهَا الَّتِي هِيَ أَسْبَابُ الِاخْتِلَافِ سِوَى الشُّرُوطِ الْمُشْتَرَطَةِ فِي الْآلَةِ وَفِي الصَّائِدِ وَجَدْتَهَا ثَمَانِيَةَ شُرُوطٍ: اثْنَانِ يَشْتَرِكَانِ فِي الذَّكَاتَيْنِ، أَعْنِي: ذَكَاةَ الْمَصِيدِ وَغَيْرِ الْمُصِيدِ، وَهِيَ: النِّيَّةُ وَالتَّسْمِيَةُ.

وَسِتَّةٌ تَخْتَصُّ بِهَذِهِ الذَّكَاةِ:

أَحَدُهَا: أَنَّهَا إِنْ لَمْ تَكُنِ الْآلَةُ أَوِ الْجَارِحُ الَّذِي أَصَابَ الصَّيْدَ قَدْ أَنْفَذَ مَقَاتِلَهُ فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُذَكَّى بِذَكَاةِ الْحَيَوَانِ الْإِنْسِيِّ إِذَا قَدَرَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ مِمَّا أَصَابَهُ مِنَ الْجَارِحِ أَوْ مِنَ الضَّرْبِ. وَأَمَّا إِنْ كَانَ قَدْ أَنْفَذَ مَقَاتِلَهُ فَلَيْسَ يَجِبُ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ قَدْ يُسْتَحَبُّ[1].

---

(1) ومن الأمثلة على ذلك الصيد بالمعراض؛ لما أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيد، بَابُ الصَّيْدِ بِالْكِلَابِ الْمُعَلَّمَةِ (رقم ١٩٢٩) من حديث عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمِعْرَاضِ، فَقَالَ: «إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ، فَإِنَّهُ وَقِيذٌ، فَلَا تَأْكُلْ». وفي رواية: قُلْتُ لَهُ: فَإِنِّي أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ الصَّيْدَ، فَأُصِيبُ، فَقَالَ: «إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَزَقَ فَكُلْهُ، وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ، فَلَا تَأْكُلْهُ». قال النووي في شرح مسلم (٧٥/١٣): المعراض: بكسر الميم وبالعين المهملة وهي خشبة ثقيلة أو عصا في طرفها حديدة وقد تكون بغير حديدة هذا هو الصحيح في تفسيره. وقال =

وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ الَّذِي أُصِيبَ بِهِ الصَّيْدُ مَبْدَؤُهُ مِنَ الصَّائِدِ لَا مِنْ غَيْرِهِ[١]، أَعْنِي: لَا مِنَ الْآلَةِ كَالْحَالِ فِي الْحِبَالَةِ[٢]، وَلَا مِنَ الْجَارِحِ كَالْحَالِ فِيمَا

الهروي: هو سهم لا ريش فيه ولا نصل. وقال ابن دريد: هو سهم طويل له أربع قُذَذ رقاق، فإذا رمى به اعترض. وقال الخليل كقول الهروي، ونحوه عن الأصمعي. وقيل: هو عود رقيق الطرفين غليظ الوسط إذا رمي به ذهب مستويا. وأما خزق فهو بالخاء المعجمة والزاي ومعناه: نفذ. والوقذ والموقوذ: هو الذي يقتل بغير محدد من عصا أو حجر وغيرهما، ومذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد والجماهير: أنه إذا اصطاد بالمعراض فقتل الصيد بحده حل، وإن قتله بعرضه لم يحل لهذا الحديث. وقال مكحول والأوزاعي وغيرهما من فقهاء الشام: يَحِلُّ مطلقًا. وكذا قال هؤلاء وابن أبى ليلى: أنه يَحِلُّ ما قتله بالبندقية، وحُكي أيضاً عن سعيد بن المسيب. وقال الجماهير: لا يَحِلُّ صيد البندقية مطلقاً؛ لحديث المِعْراض؛ لأنه كلُّه رض ووقْذٌ، وهو معنى الرواية الأخرى "فإنه وقيذ"، أي: مقتول بغير محدد، والمَوقوذةُ المقتولةُ بالعصا ونحوها، وأصلهُ من الكسر والرض.

(١) انظر: حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (٥٨٩/١)، حيث قال: "يُشْتَرَطُ فِي الْمُصَادِ بِهِ إِذَا كَانَ حَيَوَانًا ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ: أَنْ يَكُونَ مُعَلَّمًا، وَأَنْ يَكُونَ يَفْقَهُ التَّعْلِيمَ، وَأَنْ يَكُونَ مُرْسَلًا مِنْ يَدِ الصَّائِدِ". قلت: وذلك لاشتراط النية والقصد في الصيد لحديث: "إنما الأعمال بالنيات"، والقاعدة الفقهية الكبرى: الأمور بمقاصدها، واشتراط النية هو مذهب المالكية والحنابلة. يراجع: الشرح الكبير للدردير (١٠٦/٢)، المغني لابن قدامة (٣٩٥/٩، ٣٩٦).

(٢) وهي الحبالة التي يضعها الناس للصيد، وهناك مناجل وآلات يخصصونها للصيد، فإذا وقع الصيد فيها فقتله في الحال فجمهور الفقهاء يرون أن ذلك =

يُصِيبُ الْكَلْبُ الَّذِي يَنْشَلِي مِنْ ذَاتِهِ[١].

وَالثَّالِثُ: أَنْ لَا يُشَارِكَهُ فِي الْعَقْرِ مَنْ لَيْسَ عَقْرُهُ ذَكَاةً[٢].

وَالرَّابِعُ: أَنْ لَا يَشُكَّ فِي عَيْنِ الصَّيْدِ الَّذِي أَصَابَهُ، وَذَلِكَ عِنْدَ غَيْبَتِهِ عَنْ عَيْنِهِ.

وَالْخَامِسُ: أَنْ لَا يَكُونَ الصَّيْدُ مَقْدُورًا عَلَيْهِ فِي وَقْتِ الْإِرْسَالِ عَلَيْهِ.

وَالسَّادِسُ: أَنْ لَا يَكُونَ مَوْتُهُ مِنْ رُعْبٍ مِنَ الْجَارِحِ أَوْ بِصَدْمَةٍ مِنْهُ.

فَهَذِهِ هِيَ أُصُولُ الشُّرُوطِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ اشْتِرَاطِهَا أَوْ لَا اشْتِرَاطِهَا عَرَضَ الْخِلَافُ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، وَرُبَّمَا اتَّفَقُوا عَلَى وُجُوبِ بَعْضِ هَذِهِ الشُّرُوطِ، وَيَخْتَلِفُونَ فِي وُجُودِهَا فِي نَازِلَةٍ نَازِلَةٍ، كَاتِّفَاقِ الْمَالِكِيَّةِ عَلَى أَنَّ مِنْ شَرْطِ الْفِعْلِ أَنْ يَكُونَ مَبْدَؤُهُ مِنَ الصَّائِدِ[٣] وَاخْتِلَافِهِمْ إِذَا أَفْلَتَ الْجَارِحُ مِنْ يَدِهِ أَوْ خَرَجَ بِنَفْسِهِ، ثُمَّ أَغْرَاهُ، هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ الصَّيْدُ أَمْ لَا؟ لِتَرَدُّدِ هَذِهِ الْحَالِ بَيْنَ أَنْ يُوجَدَ لَهَا هَذَا الشَّرْطُ أَوْ لَا يُوجَدَ.

غير جائز ولا يحل أكله، وذهب الحنابلة إلى جوازه وأنه يؤكل. يراجع: حاشية ابن عابدين (٤٦٩/٦)، المدونة الكبرى (٥٣٦/١، ٥٣٧)، مغني المحتاج للشربيني (١٠٨/٦، ١٠٩)، كشاف القناع للبهوتي (٢١٩/٦، ٢٢٠).

(١) أي: ينطلق من تلقاء نفسه.

(٢) قال ابن جزي في القوانين الفقهية (ص١١٩): أَن لَا يُشَارِكهُ فِي الْعقر مَا لَيْسَ عقره ذَكَاة كَغَيْر الْمُعَلم، فَإِن تَيَقّن أَن الْمُعَلم هُوَ الْمُنْفَرد بالعقر أَكَلَ، وَإِن تَيَقّن خلاف ذَلِك أَو شكّ لم يُؤْكَل، وَإِن غلب على ظَنّه أَنه الْقَاتِل فَفِيهِ خلاف، وَإِن أدْركهُ غير منفوذ الْمقَاتل فذكاه أَكَلَ مُطلقًا.

(٣) انظر: حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (٥٨٩/١)، الشرح الكبير للدردير (١٠٦/٢)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١٦٣/٢).

كَاتِّفَاقِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ عَلَى أَنَّ مِنْ شَرْطِهِ إِذَا أُدْرِكَ غَيْرُ مَنْفُوذِ الْمَقَاتِلِ أَنْ يُذَكَّى إِذَا قُدِرَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ. وَاخْتِلَافِهِمْ بَيْنَ أَنْ يُخَلِّصَهُ حَيًّا فَيَمُوتَ فِي يَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَمَكَّنَ مِنْ ذَكَاتِهِ، فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ مَنَعَ هَذَا، وَأَجَازَهُ مَالِكٌ، وَرَآهُ مِثْلَ الْأَوَّلِ، أَعْنِي: إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى تَخْلِيصِهِ مِنَ الْجَارِحِ حَتَّى مَاتَ؛ لِتَرَدُّدِ هَذِهِ الْحَالِ بَيْنَ أَنْ يُقَالَ: أَدْرَكَهُ غَيْرَ مَنْفُوذِ الْمَقَاتِلِ، وَفِي غَيْرِ يَدِ الْجَارِحِ، فَأَشْبَهَ الْمُفَرِّطَ أَوْ لَمْ يُشْبِهْهُ فَلَمْ يَقَعْ مِنْهُ تَفْرِيطٌ[1].

---

(1) قال الجصاص في شرح مختصر الطحاوي (٧/٢٥٤) قال: (وإذا أصاب الصيد في يده حيا، فذكاته لا تكون إلا بالذبح، سواء أمكنه أن يذكيه، أو لم يمكنه حتى مات). وذلك لأنه لما حصل في يده حيا، فقد خرج من أن يكون صيدا، فلا تكون ذكاته إلا بالذبح، كالشاة لا تكون ذكاتها إلا بالذبح وإن صارت بحال لا يمكنه التذكية حتى تموت. ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ثعلبة الخشني: "وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم، فأدركت ذكاته، فكله". فإنما أباحه بالذكاة إذا حصل في يده حيًا. وقال الله تعالى: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ [المائدة: ٣]، وكل ما حصل حيًا في يده، فلا ذكاة له إلا بالذبح.

والحديث أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الذبائح والصيد، باب آنية المجوس والميتة برقم (٥٤٩٦). وقال القاضي عبد الوهاب في المعونة للقاضي (ص٦٨٤): "إذا أدرك الصيد والجوارح تنهشه وتجرحه ولم تنفذ مقاتله وقدر على تخليصه منها فلا يأكله إلا بأن يذكيه، لأنه صار مقدورًا عليه قبل أن تكون ذكاته العقر، وإن لم يقدر أن يذكيه حتى مات بجرحها جاز أكله، لأن فوات نفسه حصل قبل القدرة عليه، وكذلك إن خلصه جريحًا، فمات في الفور قبل أن يتمكن من تذكيته، فإن أكله جائز خلافًا لأبي حنيفة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل وإن قتل"، ولأن الجارح عقره

=

وَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ هِيَ أُصُولَ الشُّرُوطِ الْمُشْتَرَطَةِ فِي الصَّيْدِ مَعَ سَائِرِ الشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْآلَةِ وَالصَّائِدِ نَفْسِهِ عَلَى مَا سَيَأْتِي يَجِبُ أَنْ يُذْكَرَ مِنْهَا مَا اتَّفَقُوا مِنْهُ عَلَيْهِ وَمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، وَأَسْبَابُ الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ وَمَا يَتَفَرَّعُ عَنْهَا مِنْ مَشْهُورِ مَسَائِلِهِمْ. فَنَقُولُ: أَمَّا التَّسْمِيَةُ وَالنِّيَّةُ فَقَدْ تَقَدَّمَ الْخِلَافُ فِيهِمَا وَسَبَبُهُ فِي كِتَابِ الذَّبَائِحِ[1]، وَمِنْ قِبَلِ اشْتِرَاطِ النِّيَّةِ فِي الذَّكَاةِ لَمْ يَجُزْ عِنْدَ مَنِ اشْتَرَطَهَا إِذَا

قبل القدرة على تذكيته، فكان كما لو مات في يديه قبل القدرة على تخليصه، وإن خلصه من الجارح قبل فوات نفسه أو نفاذ مقاتله، فتركه حتى مات فلا يؤكل لتفريطه في تذكيته، وكذلك لو تشاغل بإخراج سكين يذبحه بها.

قلت: والحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيد والذبائح، بَابُ الصَّيْدِ بِالْكِلَابِ الْمُعَلَّمَةِ برقم(١٩٢٩)، وابن أبي شيبة في مصنفه برقم (١٩٥٧٧).

(1) قال ابن رشد في بداية المجتهد (٢/٢١١): وَاخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ التَّسْمِيَةِ عَلَى الذَّبِيحَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ: فَقِيلَ: هِيَ فَرْضٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ، وَقِيلَ: بَلْ هِيَ فَرْضٌ مَعَ الذِّكْرِ سَاقِطَةٌ مَعَ النِّسْيَانِ، وَقِيلَ: بَلْ هِيَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ. وَبِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ قَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ، وَابْنُ عُمَرَ وَالشَّعْبِيُّ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَبِالْقَوْلِ الثَّانِي قَالَ مَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيُّ، وَبِالْقَوْلِ الثَّالِثِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ. وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ مُعَارَضَةُ ظَاهِرِ الْكِتَابِ فِي ذَلِكَ لِلْأَثَرِ.

فَأَمَّا الْكِتَابُ: فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ [الأنعام: ١٢١]، وَأَمَّا السُّنَّةُ الْمُعَارِضَةُ لِهَذِهِ الْآيَةِ فَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ نَاسًا مِنَ الْبَادِيَةِ يَأْتُونَنَا بِلُحْمَانٍ وَلَا نَدْرِي أَسَمَّوُا اللَّهَ عَلَيْهَا أَمْ لَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

=

أَرْسَلَ الْجَارِحَ عَلَى صَيْدٍ وَأَخَذَ آخَرَ – ذَكَاةُ ذَلِكَ الصَّيْدِ الَّذِي لَمْ يُرْسَلْ عَلَيْهِ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ[١].

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَحْمَدُ، وَأَبُو ثَوْرٍ: ذَلِكَ جَائِزٌ وَيُؤْكَلُ[٢].

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهَا ثُمَّ كُلُوهَا»، سبق تخريجه.

فَذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى أَنَّ الْآيَةَ نَاسِخَةٌ لِهَذَا الْحَدِيثِ، وَتَأَوَّلَ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، وَلَمْ يَرَ ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ، لِأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ كَانَ بِالْمَدِينَةِ، وَآيَةُ التَّسْمِيَةِ مَكِّيَّةٌ، فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ لِمَكَانِ هَذَا مَذْهَبَ الْجَمْعِ بِأَنْ حَمَلَ الْأَمْرَ بِالتَّسْمِيَةِ عَلَى النَّدْبِ.

وَأَمَّا مَنِ اشْتَرَطَ الذِّكْرَ فِي الْوُجُوبِ فَمَصِيرًا إِلَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ».

وَأَمَّا اشْتِرَاطُ النِّيَّةِ فِيهَا: فَقِيلَ فِي الْمَذْهَبِ بِوُجُوبِ ذَلِكَ، وَلَا أَذْكُرُ فِيهَا خَارِجَ الْمَذْهَبِ فِي هَذَا الْوَقْتِ خِلَافًا فِي ذَلِكَ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ قَوْلَانِ: قَوْلٌ بِالْوُجُوبِ، وَقَوْلٌ بِتَرْكِ الْوُجُوبِ.

فَمَنْ أَوْجَبَ قَالَ: عِبَادَةٌ، لِاشْتِرَاطِ الصِّفَةِ فِيهَا وَالْعَدَدِ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ مِنْ شَرْطِهَا النِّيَّةُ. وَمَنْ لَمْ يُوجِبْهَا قَالَ: فِعْلٌ مَعْقُولٌ، يَحْصُلُ عَنْهُ فَوَاتُ النَّفْسِ الَّذِي هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ، فَوَجَبَ أَنْ لَا تُشْتَرَطَ فِيهَا النِّيَّةُ كَمَا يَحْصُلُ مِنْ غَسْلِ النَّجَاسَةِ إِزَالَةِ عَيْنِهَا.

(١) انظر: التهذيب في اختصار المدونة للبراذعي (١٣/٢) حيث قال: "قال مالك: وإن أرسل كلبه على صيد فأخذ غيره لم يؤكل".

(٢) انظر: البيان للعمراني (٥٥٤/٤)، بدائع الصنائع للكاساني (٥٠/٥)، شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٤٣٢/٣)، الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (٤٥٥/٣) حيث قال: "واختلف في الكلب يرسل على صيد بعينه =

وَمِنْ قِبَلِ هَذَا أَيْضًا اخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ[١] فِي الْإِرْسَالِ عَلَى صَيْدٍ غَيْرِ مَرْئِيٍّ، كَالَّذِي يُرْسِلُ عَلَى مَا فِي غَيْضَةٍ[٢]،أَوْ مِنْ وَرَاءِ أَكَمَةٍ[٣]، وَلَا يَدْرِي هَلْ هُنَالِكَ شَيْءٌ أَمْ لَا؟ لِأَنَّ الْقَصْدَ فِي هَذَا يَشُوبُهُ شَيْءٌ مِنَ الْجَهْلِ.

وَأَمَّا الشَّرْطُ الْأَوَّلُ الْخَاصُّ بِذَكَاةِ الصَّيْدِ مِنَ الشُّرُوطِ السِّتَّةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا، وَهُوَ أَنَّ عَقْرَ الْجَارِحِ لَهُ إِذَا لَمْ يُنْفِذْ مَقَاتِلَهُ، إِنَّمَا يَكُونُ لَمْ يُدْرِكْهُ الْمُرْسِلُ حَيًّا – فَبِاشْتِرَاطِهِ. قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ[٤]: لِمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ فِي بَعْضِ

فيأخذ غيره، فقال الحسن البصري، والنخعي، وقتادة، والحسن البصري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: يؤكل".

(١) انظر التبصرة للخمي (١٤٧٩/٤) حيث قال: "واختُلف في الإرسال على صيد غير مرئي، كالذي يرسل على ما في غَيْضَةٍ أو غارٍ أو ما وراء أَكَمَةٍ، ولا يدري: هل هناك شيء أم لا؟ أو على جماعة وينويها وما وراءها. فأجاز ذلك مالك، ورآه ذكيًا. ومنعه أشهب، وقال: لا يؤكل إلا ما رآه وقت الإرسال. وإليه ذهب سحنون في العتبية".

(٢) الغيضة: الأجمة وهي الشجر الملتف بحيث يخفى على الإنسان كثير مما فيها، وجمعها غياض. انظر: الصحاح للجوهري (١٠٩٧/٣)، المصباح المنير للفيومي (٤٥٩/٢). مادة (غ ي ض).

(٣) الأكمة: هي ما ارتفع من الأرض، أو تل، وقيل: شرفة كالرابية وهو ما اجتمع من الحجارة في مكان واحد وربما غلظ وربما لم يغلظ، والجمع أَكَمٌ وَأَكَمَاتٌ. انظر: الزاهر للأزهري (ص٨٧)، المصباح المنير للفيومي (١٨/١). مادة (ء ك م).

(٤) انظر: تبيين الحقائق للزيلعي (٥٣/٦)، البيان للعمراني (٥٥٠/٤، ٥٥١)، =

رِوَايَاتِهِ أَنَّهُ قَالَ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ –: «وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ»(١).

وَكَانَ النَّخَعِيُّ يَقُولُ: إِذَا أَدْرَكْتَهُ حَيًّا، وَلَمْ يَكُنْ مَعَكَ حَدِيدَةٌ – فَأَرْسِلْ عَلَيْهِ الْكِلَابَ حَتَّى تَقْتُلَهُ، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ مَصِيرًا؛ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: ٤](٢).

وَمِنْ قِبَلِ هَذَا الشَّرْطِ قَالَ مَالِكٌ: لَا يَتَوَانَى الْمُرْسِلُ فِي طَلَبِ الصَّيْدِ، فَإِنْ تَوَانَى فَأَدْرَكَهُ مَيِّتًا؛ فَإِنْ كَانَ مَنْفُوذَ الْمَقَاتِلِ بِسَهْمٍ حَلَّ أَكْلُهُ، وَإِلَّا لَمْ يَحِلَّ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَتَوَانَ لَكَانَ يُمْكِنُ أَنْ يُدْرِكَهُ حَيًّا غَيْرَ مَنْفُوذِ الْمَقَاتِلِ(٣).

وَأَمَّا الشَّرْطُ الثَّانِي، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ مَبْدَؤُهُ مِنَ الْقَانِصِ، وَيَكُونَ مُتَّصِلًا حَتَّى يُصِيبَ الصَّيْدَ – فَمِنْ قِبَلِ اخْتِلَافِهِمْ فِيهِ اخْتَلَفُوا فِيمَا تُصِيبُهُ الْحِبَالَةُ وَالشَّبَكَةُ إِذَا أُنْفِذَتِ الْمَقَاتِلُ بِمُحَدَّدٍ فِيهَا، فَمَنَعَ ذَلِكَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَالْجُمْهُورُ(٤)، وَرَخَّصَ

المغني لابن قدامة (٩/٣٧٤).

(١) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب الصيد بالكلاب المُعَلَّمة (١/١٥٣١ ح ١٩٢٩). عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ، فَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ، وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ، وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ، وَقَدْ قَتَلَ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّهُمَا قَتَلَهُ، وَإِنْ رَمَيْتَ سَهْمَكَ، فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا، فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلَّا أَثَرَ سَهْمِكَ، فَكُلْ إِنْ شِئْتَ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ، فَلَا تَأْكُلْ».

(٢) انظر الإشراف لابن المنذر (٣/٤٥٥)، المحلى لابن حزم (٦/١٥٥).

(٣) انظر: التاج والإكليل للمواق (٤/٣٢٧).

(٤) انظر: حاشية ابن عابدين (٦/٤٦٩)، المدونة الكبرى (١/٥٣٦، ٥٣٧)، مغني =

فِيهِ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ[١] وَمِنْ هَذَا الْأَصْلِ لَمْ يُجِزْ مَالِكٌ الصَّيْدَ الَّذِي أُرْسِلَ عَلَيْهِ الْجَارِحُ فَتَشَاغَلَ بِشَيْءٍ آخَرَ، ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ[٢].

وَأَمَّا الشَّرْطُ الثَّالِثُ، وَهُوَ أَنْ لَا يُشَارِكَهُ فِي الْعَقْرِ مَنْ لَيْسَ عَقْرُهُ ذَكَاةً لَهُ – فَهُوَ شَرْطٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ فِيمَا أَذْكُرُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي مَنْ قَتَلَهُ[٣].

المحتاج للشربيني (١٠٨/٦، ١٠٩)، كشاف القناع للبهوتي (٢١٩/٦، ٢٢٠).

(١) قال ابن المنذر في الإشراف (٤٦٥/٣): واختلفوا في الشبكة والأحبولة يقع فيها الصيد فيدركه صاحبه وقد مات. فقالت طائفة: لا تؤكل إلا أن يدرك ذكاته، هذا قول عطاء، والنخعي، وعمرو بن دينار، وقتادة، وبه قال ربيعة والشافعي، وكذلك قال الزهري ومالك، فيما قتلت الحبالة.

وقال الثوري: لا يعجبني إلا أن يدركه فيذكيه، وقد روينا عن الحسن أنه رخص في ذلك، ذكر يونس عنه أنه كان لا يرى بصيد المناجل بأساً، وقال: سَمٍّ إذا أنصبتها، وذكر قتادة عن الحسن: أنه كان لا يرى بأسا بها قتل المنجل، والحبل إذا سَمَى فدخل فيه وجرحه.

(٢) أي: انشغل الكلب بشيء آخر عن الصيد ثم عاد مرة أخرى فلحق به فصاده، فهل يكفي القصد الأول والتسمية، مع كون الكلب انشغل عنه، أم لابد من وجود اتصال بين صيده وبين الإرسال، فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يؤكل إلا بإرسال مستأنف. انظر: حاشية ابن عابدين (٤٦٦/٦، ٤٦٧)، التاج والإكليل للمواق (٣٢٣/٤)، الأم للشافعي (٢٥١/٢)، المبدع في شرح المقنع لابن مفلح (٥١/٨).

(٣) كأن يشاركه كلب مجوسي، أو غير معلم، أو شاركته كلاب لا يدري أذكر اسم الله عليها أم لا، فلا يؤكل باتفاق الأئمة الأربعة. انظر: حاشية ابن عابدين =

وَأَمَّا الشَّرْطُ الرَّابِعُ، وَهُوَ أَنْ لَا يَشُكَّ فِي عَيْنِ الصَّيْدِ، وَلَا فِي قَتْلِ جَارِحِهِ لَهُ – فَمِنْ قِبَلِ ذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي أَكْلِ الصَّيْدِ إِذَا غَابَ مَصْرَعُهُ، فَقَالَ مَالِكٌ[١] مَرَّةً: لَا بَأْسَ بِأَكْلِ الصَّيْدِ إِذَا غَابَ عَنْكَ مَصْرَعُهُ إِذَا وَجَدْتَ بِهِ أَثَرًا مِنْ كَلْبِكَ، أَوْ كَانَ بِهِ سَهْمُكَ مَا لَمْ يَبِتْ، فَإِذَا بَاتَ فَإِنِّي أَكْرَهُهُ. وَبِالْكَرَاهِيَةِ قَالَ الثَّوْرِيُّ[٢]، وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ: إِذَا بَاتَ الصَّيْدُ مِنَ الْجَارِحِ لَمْ يُؤْكَلْ، وَفِي السَّهْمِ خِلَافٌ.

وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ: يُؤْكَلُ فِيهِمَا جَمِيعًا إِذَا وُجِدَ مَنْفُوذَ الْمَقَاتِلِ[٣]، وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُدَوَّنَةِ: لَا يُؤْكَلُ فِيهِمَا جَمِيعًا إِذَا بَاتَ وَإِنْ وُجِدَ مَنْفُوذَ الْمَقَاتِلِ[٤]. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الْقِيَاسُ أَنْ لَا تَأْكُلَهُ إِذَا غَابَ عَنْكَ مَصْرَعُهُ[٥]. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا تَوَارَى الصَّيْدُ وَالْكَلْبُ فِي طَلَبِهِ، فَوَجَدَهُ الْمُرْسِلُ مَقْتُولًا – جَازَ أَكْلُهُ مَا لَمْ يَتْرُكِ الْكَلْبُ الطَّلَبَ، فَإِنْ تَرَكَهُ كَرِهْنَا أَكْلَهُ[٦].

وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ شَيْئَانِ اثْنَانِ: الشَّكُّ الْعَارِضُ فِي عَيْنِ الصَّيْدِ أَوْ فِي زَكَاتِهِ،

(٤٦٦/٦)، حاشية الدسوقي (١٠٥/٢)، نهاية المحتاج للرملي (١١٢/٨)، كشاف القناع للبهوتي (٢١٧/٦).

(١) انظر: المدونة الكبرى (٥٣٣/١).

(٢) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (٤٦٠/٣).

(٣) انظر: البيان والتحصيل لابن رشد الجد (٣١١/٣).

(٤) انظر: المدونة الكبرى (٥٣٣/١).

(٥) انظر: الأم للشافعي (٢٥٠/٢).

(٦) انظر: بدائع الصنائع للكاساني (٥٩/٥).

وَالسَّبَبُ الثَّانِي: اخْتِلَافُ الْآثَارِ فِي هَذَا الْبَابِ، فَرَوَى مُسْلِمٌ[١]، وَالنَّسَائِيُّ[٢]، وَالتِّرْمِذِيُّ[٣]، وَأَبُو دَاوُدَ[٤] عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ عَنِ النَّبِيِّ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – فِي الَّذِي يُدْرِكُ صَيْدَهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَقَالَ: «كُلْ مَا لَمْ يُنْتِنْ». وَرَوَى مُسْلِمٌ[٥] عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ أَيْضًا عَنِ النَّبِيِّ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – قَالَ: «إِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ، فَغَابَ عَنْكَ مَصْرَعُهُ – فَكُلْ مَا لَمْ يَبِتْ». وَفِي حَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ أَنَّهُ قَالَ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ –: «إِذَا وَجَدْتَ سَهْمَكَ فِيهِ، وَلَمْ تَجِدْ فِيهِ أَثَرَ سَبُعٍ، وَعَلِمْتَ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ – فَكُلْ»[٦].

وَمِنْ هَذَا الْبَابِ اخْتِلَافُهُمْ فِي الصَّيْدِ يُصَادُ بِالسَّهْمِ أَوْ يُصِيبُهُ الْجَارِحُ، فَيَسْقُطُ

---

(١) في صحيحه: كتاب الصيد، بَابُ إِذَا غَابَ عَنْهُ الصَّيْدُ ثُمَّ وَجَدَهُ (٣/١٥٣٢ح١٩٣١).

(٢) في السنن: كتاب الصيد، بابُ الصَّيْدِ إِذَا أَنْتَنَ (٧/١٩٣ح٤٣٠٣).

(٣) لم أقف عليه عند الترمذي.

(٤) في السنن: كتاب الصيد، باب اتباع الصيد (٤/٤٨٣ح٢٨٦١).

(٥) لم أجده في صحيح مسلم بهذا اللفظ.

(٦) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الصيد، باب ما جاء في الرجل يرمي الصيد فيغيب عنه (٤/٦٧ح١٤٦٨) وقال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، والنسائي: كتاب الصيد، بابُ الصَّيْدِ إِذَا أَنْتَنَ (٧/١٩٣ح٤٣٠٠).

فِي مَاءٍ أَوْ يَتَرَدَّى مِنْ مَكَانٍ عَالٍ – فَقَالَ مَالِكٌ[١]: لَا يُؤْكَلُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي مِنْ أَيِّ الْأَمْرَيْنِ مَاتَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ السَّهْمُ قَدْ أَنْفَذَ مَقَاتِلَهُ وَلَا يَشُكَّ أَنَّ مِنْهُ مَاتَ، وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ[٢]. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُؤْكَلُ إِنْ وَقَعَ فِي مَاءٍ مَنْفُوذُ الْمَقَاتِلِ، وَيُؤْكَلُ إِنْ تَرَدَّى[٣] وَقَالَ عَطَاءٌ: لَا يُؤْكَلُ أَصْلًا إِذَا أُصِيبَتِ الْمَقَاتِلُ، وَقَعَ فِي مَاءٍ أَوْ تَرَدَّى مِنْ مَوْضِعٍ عَالٍ؛ لِإِمْكَانِ أَنْ يَكُونَ زَهُوقُ نَفْسِهِ مِنْ قِبَلِ التَّرَدِّي أَوْ مِنَ الْمَاءِ قَبْلَ زُهُوقِهَا مِنْ قِبَلِ إِنْفَاذِ الْمَقَاتِلِ[٤].

وَأَمَّا مَوْتُهُ مِنْ صَدْمِ الْجَارِحِ لَهُ فَإِنَّ ابْنَ الْقَاسِمِ[٥] مَنَعَهُ قِيَاسًا عَلَى الْمُثْقَّلِ، وَأَجَازَهُ

---

(١) في المدونة الكبرى (٥٣٨/١).

(٢) انظر: تبيين الحقائق للزيلعي (٥٨/٦)، مغني المحتاج للشربيني (١٠٩/٦)، المغني لابن قدامة (٣٧٩/٩).

(٣) انظر: حاشية ابن عابدين (٤٧٢/٦).

(٤) انظر: الإشراف لابن المنذر (٤٦١/٣).

(٥) هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي بالولاء، الفقيه المالكي؛ جمع بين الزهد والعلم وتفقه بالإمام مالك ولازمه عشرين سنة، روى عن مالك، والليث، وعبد العزيز بن الماجشون، ومسلم بن خالد الزنجي، وغيرهم، روى عنه أصبغ، وسحنون، ومحمد بن عبد الحكم، وخرج عنه البخاري في صحيحه. وهو صاحب المدونة، وهي أجل كتب المالكية، وعنه أخذها سحنون. وكانت ولادته في سنة اثنتين وثلاثين ومائة، وتوفي في شهر صفر سنة ١٩١ه بمصر. وفيات الأعيان لابن خلكان (١٢٩/٣)، الديباج المذهب لابن فرحون (٤٦٥/١).

أَشْهَبُ؛ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: ٤] [١].

وَلَمْ يَخْتَلِفِ الْمَذْهَبُ أَنَّ مَا مَاتَ مِنْ خَوْفِ الْجَارِحِ أَنَّهُ غَيْرُ مُذَكًّى.

وَأَمَّا كَوْنُهُ فِي حِينِ الْإِرْسَالِ غَيْرَ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ شَرْطٌ فِيمَا عَلِمْتُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ يُوجَدُ إِذَا كَانَ الصَّيْدُ مَقْدُورًا عَلَى أَخْذِهِ بِالْيَدِ دُونَ خَوْفٍ أَوْ غَرَرٍ؛ إِمَّا مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ قَدْ نَشَبَ فِي شَيْءٍ، أَوْ تَعَلَّقَ بِشَيْءٍ، أَوْ رَمَاهُ أَحَدٌ فَكَسَرَ جَنَاحَهُ أَوْ سَاقَهُ.

وَفِي هَذَا الْبَابِ فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ مِنْ قِبَلِ تَرَدُّدِ بَعْضِ الْأَحْوَالِ بَيْنَ أَنْ يُوصَفَ فِيهَا الصَّيْدُ بِأَنَّهُ مَقْدُورٌ عَلَيْهِ أَوْ غَيْرُ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ، مِثْلَ أَنْ تَضْطَرَّهُ الْكِلَابُ فَيَقَعَ فِي حُفْرَةٍ – فَقِيلَ فِي الْمَذْهَبِ: يُؤْكَلُ، وَقِيلَ: لَا يُؤْكَلُ[٢].

وَاخْتَلَفُوا فِي صِفَةِ الْعَقْرِ إِذَا ضُرِبَ الصَّيْدُ، فَأُبِينَ مِنْهُ عُضْوٌ – فَقَالَ قَوْمٌ: يُؤْكَلُ الصَّيْدُ إِلَّا مَا بَانَ مِنْهُ. وَقَالَ قَوْمٌ: يُؤْكَلَانِ جَمِيعًا. وَفَرَّقَ قَوْمٌ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْعُضْوُ مَقْتَلًا أَوْ غَيْرَ مَقْتَلٍ، فَقَالُوا: إِنْ كَانَ مَقْتَلًا أُكِلَا جَمِيعًا، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَقْتَلٍ أُكِلَ الصَّيْدُ وَلَمْ يُؤْكَلِ الْعُضْوُ. وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ مَالِكٍ، وَإِلَى هَذَا يَرْجِعُ خِلَافُهُمْ فِي أَنْ يَكُونَ الْقَطْعُ بِنِصْفَيْنِ، أَوْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا أَكْبَرَ مِنَ الثَّانِي.

وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: مُعَارَضَةُ قَوْلِهِ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ –: «مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ»[٣]؛ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ

---

(١) انظر: المعونة للقاضي عبد الوهاب (ص٦٨٤).

(٢) انظر: حاشية الدسوقي (١٠٣/٢).

(٣) أخرجه أحمد في المسند (٢٣٣/٣٦ح٢١٩٠٣)، وأبو داود في السنن: كتاب =

عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: ٤]، وَلِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: ﴿تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ﴾ [المائدة: ٩٤] .

فَمَنْ غَلَّبَ حُكْمَ الصَّيْدِ وَهُوَ الْعَقْرُ مُطْلَقًا قَالَ: يُؤْكَلُ الصَّيْدُ وَالْعُضْوُ الْمَقْطُوعُ مِنَ الصَّيْدِ، وَحَمَلَ الْحَدِيثَ عَلَى الْإِنْسِيِّ. وَمَنْ حَمَلَهُ عَلَى الْوَحْشِيِّ وَالْإِنْسِيِّ مَعًا، وَاسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الْعُمُومِ بِالْحَدِيثِ الْعُضْوَ الْمَقْطُوعَ – فَقَالَ: كُلُّ الصَّيْدُ دُونَ الْعُضْوِ الْبَائِنِ. وَمَن اعْتَبَرَ فِي ذَلِكَ الْحَيَاةَ الْمُسْتَقِرَّةَ، أَعْنِي: فِي قَوْلِهِ: وَهِيَ حَيَّةٌ – فَرَّقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْعُضْوُ مَقْتَلًا أَوْ غَيْرَ مَقْتَلٍ.

الصيد، باب في صيد قطع منه قطعة (٣/١١١ح٢٨٥٨)، والترمذي: كتاب الصيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما قطع من الحي فهو ميت (٤/٧٤ح١٤٨٠) وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم، والعمل على هذا عند أهل العلم.

الخلاصة:

وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الذَّكَاةَ الْمُخْتَصَّةَ بِالصَّيْدِ هِيَ الْعَقْرُ، وَاخْتَلَفُوا فِي شُرُوطِهَا اخْتِلَافًا كَثِيرًا.

الشروط المشتركة بين الأضاحي والذبائح والصيد: شرطان وهما: النِّيَّةُ وَالتَّسْمِيَةُ.

وَسِتَّةٌ تَخْتَصُّ بِهَذِهِ الذَّكَاةِ، أي ذكاة الصيد:

الأول: أَنَّهَا إِنْ لَمْ تَكُنِ الْآلَةُ أَوِ الْجَارِحُ الَّذِي أَصَابَ الصَّيْدَ قَدْ أَنْفَذَ مَقَاتِلَهُ فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُذَكَّى بِذَكَاةِ الْحَيَوَانِ الْإِنْسِيِّ إِذَا قَدَرَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ مِمَّا أَصَابَهُ مِنَ الْجَارِحِ أَوْ مِنَ الضَّرْبِ. وَأَمَّا إِنْ كَانَ قَدْ أَنْفَذَ مَقَاتِلَهُ فَلَيْسَ يَجِبُ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ قَدْ يُسْتَحَبُّ.

وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ الَّذِي أُصِيبَ بِهِ الصَّيْدُ مَبْدَؤُهُ مِنَ الصَّائِدِ لَا مِنْ غَيْرِهِ، أَعْنِي: لَا مِنَ الْآلَةِ كَالْحَالِ فِي الْحِبَالَةِ، وَلَا مِنَ الْجَارِحِ كَالْحَالِ فِيمَا يُصِيبُ الْكَلْبُ الَّذِي يَنْشَلِي مِنْ ذَاتِهِ.

وَالثَّالِثُ: أَنْ لَا يُشَارِكَهُ فِي الْعَقْرِ مَنْ لَيْسَ عَقْرُهُ ذَكَاةً.

وَالرَّابِعُ: أَنْ لَا يَشُكَّ فِي عَيْنِ الصَّيْدِ الَّذِي أَصَابَهُ، وَذَلِكَ عِنْدَ غَيْبَتِهِ عَنْ عَيْنِهِ.

وَالْخَامِسُ: أَنْ لَا يَكُونَ الصَّيْدُ مَقْدُورًا عَلَيْهِ فِي وَقْتِ الْإِرْسَالِ عَلَيْهِ.

وَالسَّادِسُ: أَنْ لَا يَكُونَ مَوْتُهُ مِنْ رُعْبٍ مِنَ الْجَارِحِ أَوْ بِصَدْمَةٍ مِنْهُ.

تدريبات:

س١: عرف العقر لغة واصطلاحاً؟

س٢: اذكر الشروط المختصة بالذكاة في الصيد إجمالاً؟

س٣: بين الحكم فيما يأتي مستدلاً لما تذكر:

أ- الصيد بالمعراض.

ب- الصيد بالبندقية.

ت- الصيد بالحبالة والشبكة والمناجل.

ث- إذا أدرك الصيد حياً.

ج- الصَّيْدِ يُصَادُ بِالسَّهْمِ أَوْ يُصِيبُهُ الْجَارِحُ، فَيَسْقُطُ فِي مَاءٍ أَوْ يَتَرَدَّى مِنْ مَكَانٍ عَالٍ.

الْبَابُ الرَّابِعُ

فِي شُرُوطِ الْقَانِصِ[١].

وَشُرُوطُ الْقَانِصِ هِيَ شُرُوطُ الذَّابِحِ نَفْسِهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الذَّبَائِحِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا وَالْمُخْتَلَفِ فِيهَا.

وَيَخُصُّ الِاصْطِيَادَ فِي الْبَرِّ شَرْطٌ زَائِدٌ، وَهُوَ: أَنْ لَا يَكُونَ مُحْرِمًا، وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: ٩٦]. فَإِنِ اصْطَادَ مُحْرِمٌ فَهَلْ يَحِلُّ ذَلِكَ الصَّيْدُ لِلْحَلَالِ؟ أَمْ هُوَ مَيْتَةٌ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَصْلًا؟

اخْتَلَفَ فِيهِ الْفُقَهَاءُ، فَذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى أَنَّهُ مَيْتَةٌ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو ثَوْرٍ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِغَيْرِ الْمُحْرِمِ أَكْلُهُ.

وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ هُوَ الْأَصْلُ الْمَشْهُورُ، وَهُوَ: هَلِ النَّهْيُ يَعُودُ بِفَسَادِ الْمَنْهِيِّ أَمْ لَا؟ وَذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ ذَبْحِ السَّارِقِ وَالْغَاصِبِ[٢].

وَاخْتَلَفُوا مِنْ هَذَا الْبَابِ فِي كَلْبِ الْمَجُوسِ الْمُعَلَّمِ؛ فَقَالَ مَالِكٌ: الِاصْطِيَادُ بِهِ جَائِزٌ، فَإِنَّ الْمُعْتَبَرَ الصَّائِدُ لَا الْآلَةُ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَغَيْرُهُمْ. وَكَرِهَهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنُ، وَعَطَاءٌ، وَمُجَاهِدٌ، وَالثَّوْرِيُّ؛ لِأَنَّ الْخِطَابَ فِي قَوْلِه

---

(١) المقصود بالقانص: هو مَنْ يقوم بعملية الصيد؛ وهو اسم فاعل من الفعل (قنص) والقانص، والقناص: الصَّائِد، تهذيب اللغة٨/٢٨٩، لسان العرب٢/٨٣.

(٢) المقصود هنا: الحيوان الذي يذبحه سارقه أو غاصبه.

تَعَالَى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} [المائدة: ٤] **مُتَوَجِّهٌ نَحْوَ الْمُؤْمِنِينَ، وَهَذَا كَافٍ بِحَسَبِ الْمَقْصُودِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ.**

الخلاصة: تتناول هذه المسألة ما يلي:

أولا: بيان مَن يجوز صيده؛ وذلك ببيان الشروط التي يجب توافرها في القانص؛ وهذه الشروط هي ذاتها شروط الذابح؛ فإذا كان الاصطياد في البر ففيه شرط زائد؛ وهو: ألا يكون القانص أو الذابح محرمًا، وذلك باتفاق.

ثانيًا: اختلف الفقهاء في صيد المحرم؛ هل يحل أكله لغير المحرم؟ وذلك على قولين؛ جواز الأكل وعدمه.

سبب الخلاف:

يرجع سبب الخلاف إلى قاعدة: هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه أم لا؟

ثالثًا: اختلف الفقهاء في حكم الصيد بكلب المجوس المعلم على قولين؛ الجواز والكراهة.

تدريبات على الباب:

س١: اختلف الفقهاء في صيد المحرم؛ هل يحل أكله لغير المحرم؟ وضح ذلك.

س٢: اختر مما بين القوسين مع التعليل:

اصطاد بكلب المجوس (حل الأكل باتفاق- لم يحل الأكل باتفاق- اختلف الفقهاء في حل الأكل).

فهرس الموضوعات

مقدمة مختصرة عن كتاب بداية المجتهد ٣

المبحث الأول: ترجمة الإمام أبي الوليد بن رشد ٦

أولا: اسمه، ونسبه، وكنيته، ومولده، ووفاته ٦

ثانيا: البيئة العلمية التي نشأ بها وشيوخه وتلاميذه ٦

ثالثا: تصانيفه ومؤلفاته ٨

رابعا: سبب تأليفه بداية المجتهد ٩

المبحث الثاني: منهجه في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد ١١

أولا: التعريف بالمصطلحات التي ذكرها في كتابه ١١

ثانيا: المصادر التي اعتمد عليها ابن رشد في كتابه ١٣

ثالثا: منهج ابن رشد في كيفية عرض المسائل الفقهية ومناقشتها ١٤

أحكام الأقضية والشهادات ١٩

كتاب الأقضية ٢١

- القضاء في اللغة ٢١
- القضاء في الاصطلاح ٢١
- حكم القضاء وأدلته ٢٢
- حكم طلب القضاء ٢٦
- أركان القضاء ٢٧

الباب الأول: في معرفة من يجوز قضاؤه ٣٢

الباب الثاني: في معرفة ما يقضي به ٦٠
الباب الثالث: فيما يكون به القضاء ٦٩
الفصل الأول: في الشهادة ٦٩
الفصل الثاني: في الأيمان ١٠٢
الفصل الثالث: في النكول ١٠٩
الفصل الرابع: في الإقرار ١٢٩
الباب الرابع: في معرفة من يقضى عليه أو له ١٣٣
الباب الخامس: في كيفية القضاء ١٤٥
كتاب الصيد والذبائح ١٥١
كتاب الذبائح ١٥٣
الباب الأول: في معرفة محل الذبح والنحر ١٥٤
الباب الثاني: في الذكاة ١٦٦
الباب الثالث: فيما تكون به الذكاة ١٧٦
الباب الرابع: في شروط الذكاة ١٨٢
الباب الخامس: فيمن تجوز تذكيته ومن لا تجوز ١٨٩
كتاب الصيد ٢٠٤
الباب الأول: في حكم الصيد ومحله ٢٠٥
الباب الثاني: فيما يكون به الصيد ٢١٠

الباب الثالث: في معرفة الذكاة المختصة بالصيد وشروطها ٢٢٠

الباب الرابع: في شروط القانص ٢٣٦

فهرس الموضوعات ٢٣٩